

<입문-제1장 개설.제1절 개요>

I. 사법(私法) : 민법, 상법 등) 적용

1. 사법 적용의 영역

- 사법은 사인(私人) 상호 간의 법률 관계를 규율하는 법으로서, 대등한 당사자 간의 자유로운 의사에 따른 법률 행위를 기본 전제로 한다. 민법은 재산 관계와 가족 관계 등 일반적인 사법 관계를 규율하며, 상법은 영리 목적의 상행위 및 회사 등 특별한 사법 관계를 규율한다. 행정 영역에서도 국가나 지방자치단체와 같은 행정주체가 사인의 지위에서 활동하는 경우, 그 법률 관계에는 사법이 적용된다. 이는 행정주체의 활동 중 공익 실현이라는 우월적 지위가 인정되지 않는 비권력적 활동에 해당한다.

2. 사법 적용의 구체적 사례

(1) 행정주체의 재산 행위

- 행정주체가 행정 목적을 달성하기 위해 필요한 물품을 구매하거나, 청사 부지를 확보하기 위해 사유 재산을 매매 또는 임대하는 행위는 사법상의 매매 또는 임대차 계약에 해당한다. 이 경우 행정주체는 매도인 또는 임대인으로서 민법의 규율을 받는다. 또한, 행정주체가 국유 재산 중 일반 재산(구 잡종 재산)을 대부(貸付)하거나 매각하는 행위 역시 사법 관계로 본다. 이 경우 행정주체는 공권력을 행사하는 것이 아니라 일반 사인과 같이 대등한 당사자로서 법률 행위를 한다.

(2) 공법인의 사법상 활동

- 공법인인 공기업이나 공단이 영리 목적으로 수행하는 수익 사업이나, 직원 채용 시 근로계약을 체결하는 행위는 사법 관계에 해당한다. 특히, 공법인이 일반 사업자와 같이 물품 공급 계약을 체결하거나 용역을 제공받는 경우에도 상법이나 민법이 적용된다.

3. 사법 적용 시 법적 쟁송 수단

- 행정주체가 사인으로서 사법상 계약을 체결하고 이행하는 과정에서 분쟁이 발생하면, 이는 민사 소송의 대상이 된다. 예를 들어 행정주체가 체결한 물품 구매 계약의 대금 지급을 거부하는 경우, 상대방 사인은 대금 청구의 민사 소송을 제기해야 한다. 이러한 사법 관계에서는 행정법의 일반 원칙(비례의 원칙, 평등의 원칙 등)이 직접적으로 적용되지 않으며, 민법상의 원칙(신의성실의 원칙, 계약 자유의 원칙 등)이 우선 적용된다.

II. 행정법 적용

1. 행정법 적용의 영역

- 행정법은 행정조직, 작용, 구제 등 공행정(公行政)에 관한 공법의 총체이다. 행정법은 공익 실현을 목적으로 하며, 행정주체가 우월적 지위에서 공권력을 행사하여 사인에게 법적 효과를 발생시키는 권력적 작용(행정 처분)에 주로 적용된다. 이는 행정주체가 국가 또는 지방자치단체의 공적 기능을 수행할 때 성립하는 공법 관계이다.

2. 공법 관계와 사법 관계의 구별 기준

(1) 당사자 기준설

- 법률 관계의 당사자 중 한쪽 당사자가 행정주체이면 공법 관계로, 양쪽 당사자가 사인이거나 행정주체가 사인의 지위에 있으면 사법 관계로 보는 견해이다. 그러나 행정주체가 당사자인 경우에도 사법 관계가 성립할 수 있어 불완전하다.

(2) 목적 기준설

- 법률 관계가 공익 실현을 목적으로 하면 공법 관계로, 사익 보호를 목적으로 하면 사법 관계로 보는 견해이다. 그러나 공익과 사익을 명확히 구분하기 어려워 적용에 한계가 있다.

(3) 성질 기준설(권력성 기준설)

- 법률 관계의 성질이 공권력 행사를 포함하는 상하 관계(우월적 지위)이면 공법 관계로, 대등한 관계이면 사법 관계로 보는 견해이다. 판례는 주로 이 권력성을 중요한 기준으로 삼아 행정주체가 일방적으로 법적 효과를 발생시키는지를 본다.

(4) 종속성 기준설

- 해당 법률 관계가 행정법규에 의해 규율되면 공법 관계로, 사법법규에 의해 규율되면 사법 관계로 보는 견해이다. 판례는 대체로 법률 관계를 규율하는 근거 법규의 성격을 가장 주요한 판단 기준으로 삼는다. 예를 들어 공무원 임용 행위는 국가공무원법에 근거하므로 공법 관계이다.

3. 행정법 적용 시 법적 쟁송 수단

- 행정법이 적용되는 공법 관계에서 행정주체의 위법한 공권력 행사로 인해 사인의 권익이 침해되면, 이는 행정쟁송의 대상이 된다. 행정쟁송에는 행정심판과 행정소송이 있으며, 사인은 이를 통해 행정작용의 위법성을 다투고 자신의 권익을 구제받는다.

III. 행정작용 개요

1. 행정작용의 개념

- 행정작용이란 행정주체가 공익 실현이라는 행정 목적을 달성하기 위해 구체적인 사실에 대해 행하는 일체의 활동을 의미한다. 행정작용은 행정조직이 수행하는 공권력적, 비권력적 활동을 모두 포괄하는 광범위한 개념이다.

2. 행정작용의 주요 유형

(1) 행정행위

① 개념

- 행정청이 구체적 사실에 대한 법 집행으로서 행하는 권력적 단독 행위이다. 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하며, 가장 대표적인 행정작용이다. 행정소송의 대상이 되는 처분의 핵심을 이룬다. (예 : 영업 허가, 과세 처분, 공무원 징계)

② 특징

- 공정력이 인정되어 설령 위법하더라도 권한 있는 기관(법원)에 의해 취소되기 전까지는 일단 유효한 것으로 통용된다.

(2) 행정입법

① 개념

- 행정기관이 법규 사항에 관해 일반적·추상적인 규율을 정립하는 작용이다. 법규명령과 행정규칙으로 나뉜다. 법규명령은 대외적 구속력을 가져 국민의 권리·의무에 영향을 미친다.

② 특징

- 국회가 제정한 법률의 세부 사항을 보충하거나 집행을 위해 제정된다. 행정소송의 직접적인 대상은 될 수 없으나, 집행 행위(처분)의 위법성 판단 시 간접적으로 다루어진다.

(3) 행정계획

① 개념

- 미래의 일정한 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 수단을 종합적·조직적으로 조정·결정하는 활동 또는 그 결과다. (예 : 도시 기본 계획, 환경보전 계획)

② 특징

- 구속적 행정 계획은 처분성이 인정되어 행정쟁송의 대상이 되기도 하며, 계획 재량의 문제가 발생한다.

(4) 행정주체의 계약

① 개념

- 행정주체가 사인과 대등한 지위에서 합의를 통해 법적 효과를 발생시키는 작용이다. 행정주체의 사법상 계약과 공법상 계약을 포함하며, 공법상 계약은 행정 목적을 위한 것이나 권력 행사를 수반하지 않는다. (예 : 공무원 채용 계약)

② 특징

- 비권력적이므로 공정력과 같은 특수한 효력은 인정되지 않으며, 분쟁 발생 시 민사소송 또는 당사자소송(공법상 계약의 경우)의 대상이 된다.

IV. 행정쟁송 개요

1. 행정쟁송의 개념

- 행정쟁송이란 행정작용의 위법 또는 부당으로 인해 권익을 침해당한 국민이 행정주체를 상대로 행정작용의 취소, 변경, 무효 확인 등을 구하는 법적 구제 절차를 통칭한다. 이는 행정의 자율적 통제와 사법적 통제를 통해 국민의 권익을 보호하고 행정의 적법성을 확보하는 데 목적이 있다.

2. 행정쟁송의 유형

(1) 행정심판

① 개념

- 행정심판위원회 등 행정기관(행정부)이 심리·재결하는 행정상의 쟁송 절차이다. 처분의 위법성뿐만 아니라 부당성까지 다룰 수 있으며, 간이·신속한 구제를 목적으로 한다.

② 특징

- 행정소송을 제기하기 위한 필수적 절차인 경우도 있으며(필요적 행정심판전치주의), 행정주체 스스로 위법·부당한 행정작용을 시정할 기회를 제공한다.

(2) 행정소송

① 개념

- 법원(사법부)이 심리·판결하는 사법적 쟁송 절차이다. 처분 등의 위법성만을 다룰 수 있으며, 공정하고 최종적인 사법 통제를 통해 국민의 권리를 구제한다.

② 유형

- 항고소송(취소소송, 무효등 확인소송, 부작위위법확인소송), 당사자소송(공법상 계약이나 법률 관계의 다툼), 민중소송, 기관소송 등으로 분류된다. 취소소송이 가장 대표적인 형태이다.

3. 행정쟁송의 기능

(1) 국민의 권익 구제

- 위법하거나 부당한 행정작용으로 인해 침해된 국민의 권리를 회복시키고 손해를 전보함으로써 개인적 권리 구제를 실현한다.

(2) 행정의 적법성 확보(법치행정의 실현)

- 법원이나 행정심판위원회의 심리를 통해 행정기관의 법규 준수를 강제하고, 위법한 행정 관행을 시정함으로써 법치 행정의 원리를 확립한다.

(3) 행정작용의 형성

- 쟁송 결과에 따라 행정기관은 유사 사건에 대한 처리 기준을 재정립하게 되므로, 미래의 행정작용을 합법적이고 합리적으로 형성하는 데 기여한다.

V. 결론

- 행정법은 공익 실현을 목적으로 하는 행정주체의 우월적 공권력 행사를 규율하지만, 행정주체가 사인의 지위에서 활동하는 재산 행위 등에는 사법(민법, 상법)이 적용된다. 행정작용은 행정행위(처분), 행정입법, 공법상 계약 등 다양한 형태로 나타나며, 이 중 처분의 위법 또는 부당으로 국민의 권익이 침해되면 행정심판과 행정소송으로 구성된 행정쟁송을 통해 사법적 통제와 권익 구제를 실현한다. 행정쟁송은 국민의 권리 보호와 행정의 적법성 확보라는 이중적 기능을 수행하며 법치 행정의 원리를 구현한다.

<입문-제1장 개설.제2절 필수용어 정리>

I. 작용에 있어서 일반·개별, 추상·구체의 의미

- 행정법상 행정작용을 분류하고 그 법적 성격을 규명하는 데 필수적인 용어인 일반·개별, 추상·구체는 행정작용의 적용 대상이 되는 사람과 사건을 기준으로 그 범위를 한정하는 개념이다. 이 네 가지 개념의 조합을 통해 행정입법, 행정행위, 일반처분 등 행정작용의 기본 유형이 구분된다.

1. 사람을 대상으로 한 구분

- 행정작용이 규율하는 대상인 사람을 기준으로 불특정 다수인지 특정인인지를 구별하는 개념이다. 이는 규율의 상대방이 특정되었는지 여부를 나타낸다.

(1) 일반

- 일반은 행정작용의 수범자(受範者), 즉 규율을 받는 대상이 불특정 다수인 경우를 의미한다. 이는 행정작용이 발해될 당시 누가 수범자가 될지 개별적으로 특정되어 있지 않음을 뜻한다. 일반의 대상은 일정한 자격이나 요건을 갖춘 불특정 다수의 사람들일 수도 있고, 일정한 장소에 있는 모든 사람들일 수도 있다. (예 : 도로교통법상의 운전자 전체, 특정 지역의 주민 전체)

(2) 개별

- 개별은 행정작용의 수범자가 특정된 한 사람 또는 한 무리의 사람들인 경우를 의미한다. 행정작용이 발해될 때 그 법적 효과를 받는 대상이 이미 확정적으로 정해져 있는 경우이다. 행정행위(처분)의 가장 전형적인 형태는 개별을 대상으로 한다. (예 : 특정인에 대한 운전면허 정지 처분, 특정 회사에 대한 과징금 부과)

2. 사건을 대상으로 한 구분

- 행정작용이 규율하는 사건을 기준으로 반복 적용될 수 있는 일반적 기준인지 일회적으로 종료되는 구체적 사안인지를 구별하는 개념이다. 이는 규율 내용의 반복 적용 가능성을 나타낸다.

(1) 추상

- 추상은 행정작용의 규율 내용이 다수의 장래 사건에 대해 반복적으로 적용될 수 있는 일반적인 기준이나 원칙인 경우를 의미한다. 이는 미래의 불특정 상황에 대비하여 법규를 일반화하는 작용의 성격을 가진다. 법규명령이나 행정규칙과 같은 행정입법이 전형적인 추상적 규율에 해당한다. (예 : '음주 운전 시 면허를 취소한다'라는 법규정)

(2) 구체

- 구체는 행정작용의 규율 내용이 이미 발생했거나 또는 특정 시점에 발생할 일회적인 사건에 대해 적용되어 그 사건으로 법적 관계가 종료되는 경우를 의미한다. 이는 특정한 사실 관계를 전제로 하여 법적 효과를 발생시키는 작용의 성격을 가진다. 행정행위(처분)가 전형적인 구체적 규율에 해당한다. (예 : 2024년 11월 19일 20시에 발생한 A의 음주 운전 사실에 근거하여 면허를 취소한다)

3. 구체적 사안

- 위에서 정의된 사람에 대한 구분(일반·개별)과 사건에 대한 구분(추상·구체)을 조합하면 행정작용의 네 가지 기본 유형이 도출된다.

(1) 일반·구체(일반처분)

① 개념

- 불특정 다수의 사람에게 적용되나, 일회적으로 종료되는 특정 사건을 규율하는 작용이다. 이 작용이 행정청이 행하는 권력적 단독 행위인 경우 이를 일반처분(一般處分)이라고 한다. 이는 항고소송의 대상(처분)이 인정된다.

② 특징

- 대상인 사람은 불특정 다수이나, 그 규율 내용은 장소나 시간 등으로 한정되어 구체화된다는 특징이 있다. (예 : 특정 도로의 통행 금지, 문화재 보호 구역 지정)

(2) 개별·구체(행정행위)

① 개념

- 특정 개인에게 일회적으로 종료되는 구체적인 사실 관계를 규율하는 작용이다. 특정인을 대상으로 공권력을 행사하여 권리·의무를 직접 변동시키는 행정행위(처분)가 여기에 해당한다.

② 특징

- 국민의 권익에 가장 직접적이고 구체적인 영향을 미치므로, 행정쟁송의 대상이 되는 처분의 전형적인 모습이다. 공정력, 구속력 등의 특수한 효력이 인정된다.

(3) 일반·추상(행정입법)

① 개념

- 불특정 다수의 사람에게 반복적으로 적용될 일반적인 기준을 규율하는 작용이다. 행정주체가 제정하는 법규명령과 행정규칙 등의 행정입법이 여기에 해당한다. 이는 국회의 입법 작용과 유사한 성격을 가지나 주체가 행정기관이라는 차이가 있다.

② 특징

- 원칙적으로 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하지 않아 항고소송의 대상(처분)이 될 수 없다. 다만, 예외적으로 법규명령의 경우 집행행위 없이도 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 때에는 처분성이 인정될 수도 있다.

(4) 개별·추상

① 개념

- 특정 개인에게 반복 적용될 수 있는 일반적 기준을 정하는 작용이다.

② 특징

- 특정인에게만 법규를 적용하는 형태로서, 법적 안정성 및 평등의 원칙에 반할 소지가 크기 때문에 현실적인 행정작용에서는 거의 존재하지 않는 유형이다. 행정법적으로 의미 있는 유형으로 취급되지 않는다.

II. 일반처분(일반·구체)의 종류

1. 의의

- 일반처분은 일반(불특정 다수)을 대상으로 하고 구체(일회적 사안)를 규율하는 행정작용으로서, 행정행위의 한 유형으로 인정된다. 즉, 일반처분은 일반의 대상을 규율함에도 불구하고, 그 규율의 효과가 특정 장소, 특정 물건 등의 특정 사건에 한정되어 일회적으로 종료되므로 처분성이 인정된다. 행

정소송법상 처분에 해당하므로, 이로 인해 권익을 침해당한 사인은 취소소송을 제기할 수 있다. 일반처분은 특정인에 대한 개별처분과 마찬가지로 공정력이 인정된다.

2. 종류

- 일반처분은 규율의 대상에 따라 크게 물적 일반처분과 장소적 일반처분 등으로 분류된다.

(1) 물적 일반처분

- 특정 물건(공물)에 대해 사용 방식이나 규제 사항을 설정하여 불특정 다수의 사람에게 법적 효과를 미치는 경우이다.

① 공물의 설정 및 폐지

- 도로, 하천, 공원 등 공중의 사용을 목적으로 하는 공물을 설정하거나 폐지하는 행위이다. 이러한 공물 설정 행위는 일반 주민들의 공물 사용 권리에 직접적인 영향을 미치므로 처분성이 인정된다. 예를 들어 특정 사인의 토지를 도로 부지로 지정하여 공용 개시하는 행위는 토지 소유자에게 권리 제한을 가져오는 처분이다.

② 물건에 대한 사용 제한

- 특정 공공 물건에 대해 일반의 사용을 제한하는 행위이다. 예를 들어 수도, 전기, 가스 등 공공 시설의 사용을 중지시키거나 특정 기간 동안 사용 방법을 제한하는 행위는 해당 물건을 이용하는 불특정 다수에게 영향을 미치는 일반처분이다.

(2) 장소적 일반처분

- 특정 장소나 구역을 대상으로 일반인의 행위를 규제하거나 특정 행위를 금지함으로써 불특정 다수의 사람에게 영향을 미치는 경우이다.

① 교통 규제

- 특정 도로 구역에 대해 차량 통행을 금지하거나 일방 통행으로 지정하는 행위이다. 이는 특정 장소라는 구체적인 사건에 대해 모든 운전자라는 일반인에게 규율을 가하는 작용으로서 일반처분에 해당한다. 판례는 특정 구역의 차량 통행 금지 조치를 처분으로 인정한다.

② 개발 제한 구역 지정

- 국토 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 특정 지역을 개발 제한 구역(그린벨트)으로 지정하는 행위는 해당 구역의 주민 전체라는 일반인에게 재산권 행사를 구체적으로 제한하는 효과를 발생시키므로 처분성이 인정된다.

③ 문화재 보호 구역 지정

- 특정 구역을 문화재 보호 구역으로 지정하여 해당 구역 내의 건축 행위 등을 일률적으로 제한하는 행위 또한 일반처분에 해당한다. 이는 지정 구역이라는 구체적 사안을 대상으로 불특정 다수인 토지 소유자에게 재산권상의 의무를 부과한다.

III. 결론

- 행정작용은 일반·개별(인적 요소)과 추상·구체(사건적 요소)의 조합을 통해 행정입법(일반·추상), 행정행위(개별·구체), 일반처분(일반·구체)으로 구분된다. 특히 일반처분은 불특정 다수를 대상으로 하면서도 구체적인 사건을 규율하여 처분성이 인정되는 특성을 가지며, 공물 설정이나 교통 규제와 같이 국민의 권익에 직접적으로 영향을 미치는 중요한 행정작용 유형이다. 행정법의 이해를 위해 이 네 가지 필수 용어와 그 조합을 통한 행정작용의 법적 성격 규명이 필수적이다.

<입문-제1장 개설.제3절 행정법의 기본구조>

I. 행정법 기본구조의 의의

- 행정법의 기본구조는 법치 행정의 원리를 근간으로 하여 공권력을 행사하는 행정주체와 그 규율을 받는 국민(사인) 간의 법률 관계를 형성하고, 이 과정에서 발생하는 국민의 권리 침해를 사법적으로 통제하는 시스템을 의미한다. 이러한 구조는 행정의 목적(공익 실현)과 국민의 권리 보호(사익 보호)라는 이중적 가치를 조화시키기 위한 헌법적 요청을 반영한다. 행정법의 기본구조를 이해하는 것은 행정작용의 적법성을 판단하고 행정쟁송의 원고적격 및 대상을 설정하는 데 필수적이다.

II. 행정법 관계의 주체와 객체

1. 행정주체와 행정객체

(1) 행정주체

- 행정주체는 자신의 의사와 책임 하에 행정작용을 수행하고 그 법적 효과가 자신에게 귀속되는 권리와 의무의 주체를 의미한다. 이는 국가(정부), 지방자치단체, 법률에 의해 공적 기능을 위임받거나 위탁받아 수행하는 공법인(공사, 공단 등) 및 사인(私人)까지 포함한다.

(2) 행정객체

- 행정객체는 행정주체의 작용에 의해 직접적인 규율을 받는 대상을 의미하며, 주로 국민(사인)이 이에 해당한다. 행정객체는 행정주체의 일방적인 공권력 행사(처분)에 의해 권리가 제한되거나 의무가 부과되는 종속적인 지위에 놓일 수 있으나, 주관적 공권을 통해 행정주체에게 특정한 행위를 요구하거나 위법한 작용에 대해 구제를 요청할 수 있는 권리 또한 가진다.

2. 공권과 사권

(1) 공권(公權)

- 공권은 공법 관계에서 행정주체나 국민이 가지는 법률상의 권리를 의미한다. 특히 국민의 공권(주관적 공권)은 행정주체에 대해 자기의 이익을 위하여 일정한 행위를 요구하거나 침해되는 권리에 대한 구제를 구할 수 있는 법률상의 힘이다. 행정소송을 제기할 수 있는 원고적격은 이러한 주관적 공권이 법률상 보호되는 이익으로 인정될 때 성립한다.

(2) 사권(私權)

- 사권은 민법 등 사법에 의해 규율되는 사인 상호 간의 대등한 관계에서 발생하는 권리를 의미한다. 행정주체가 사인의 지위에서 활동하는 사법 관계에서는 사권이 적용된다. 공권과 달리 대등한 당사자 간의 자유로운 의사를 기반으로 하며, 분쟁 발생 시 민사 소송의 대상이 된다.

III. 법률우위 및 법률유보의 원칙

- 행정법의 기본구조는 법치주의에 입각하며, 그 핵심 원리로서 법률우위의 원칙과 법률유보의 원칙이 존재한다.

1. 법률우위의 원칙(법의 우위)

- 법률우위의 원칙은 행정작용이 헌법 및 법률 등 상위의 법규범에 위반되어서는 안 된다는 원칙이다. 이는 소극적 요건으로서, 행정은 적법하게 존재하는 법률에 의해 구속받으며, 법률에 위반되는 행정작용은 위법하여 무효 또는 취소의 대상이 된다. 행정은 법률을 위반하는 범위 내에서 자유로울 수 없다는 의미를 내포한다.

2. 법률유보의 원칙(법의 유보)

- 법률유보의 원칙은 행정작용이 발해지기 위해서는 반드시 헌법 또는 법률에 그 근거를 두어야 한다는 원칙이다. 이는 적극적 요건으로서, 특히 국민의 자유와 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 침익적 행정작용의 경우 법률의 명확한 근거가 필수적이다. 법률에 근거가 없는 행정작용은 위법하며, 권력 작용의 경우 법률유보의 위반은 중대한 위법 사유로 간주된다. 중요 사항 유보설(본질성설)에 따라 국민의 기본권에 본질적인 영향을 미치는 사항은 행정입법이 아닌 국회 제정 법률로 규정되어야 한다.

IV. 행정작용의 단계적 구조

- 행정법 관계는 법률적 근거에서 시작하여 구체적 행정작용을 거쳐 최종적으로 사법적 통제에 이르는 단계적 순환 구조를 가진다.

1. 법규범의 존재

- 국회가 제정한 법률과 행정기관이 제정한 법규명령 및 행정규칙 등의 법규범이 행정작용의 정당성과 근거를 제공하는 가장 상위의 단계이다. 이 법규범은 행정청에게 권한을 부여하거나 국민에게 권리를 인정하고 의무를 부과하는 일반적·추상적인 규율의 역할을 한다.

2. 행정작용의 발생

- 행정청은 구체적인 사실 관계에 대해 위의 법규범을 집행하여 행정작용을 발생시킨다. 이 중 국민의 권리·의무에 직접적인 법적 변동을 초래하는 권력적 작용인 행정행위(처분)가 핵심적인 단계이다. 처분은 일방적인 공권력 행사로서 공정력 등 특수한 효력이 인정된다.

3. 권리 구제 및 통제

- 발생한 행정작용(처분)이 위법하거나 부당하여 국민의 권익을 침해한 경우, 국민은 행정쟁송(행정심판 및 행정소송)을 통해 구제를 요청한다. 행정쟁송은 행정작용의 적법성을 사법적으로 심사하여 위법한 처분을 취소하거나 무효임을 확인함으로써 행정주체를 통제하고 국민의 권익을 회복하는 최종 단계를 구성한다. 행정쟁송의 결과는 다시 법규범의 해석과 행정 관행에 영향을 미쳐 새로운 행정작용의 정당성을 형성하는 순환적 역할을 한다.

V. 공권과 사권의 관계

1. 공권의 존재

- 행정작용의 기본 구조에서 국민이 구제를 요청할 수 있는 근거는 주관적 공권의 존재에 있다. 헌법이 기본권을 보장하고 행정법이 개별적인 이익을 법률상 보호할 때, 국민은 행정주체에게 특정한 행위를 요구하거나 위법한 행위의 제거를 요구할 법적 힘을 얻는다.

2. 법률상 이익의 범위

- 행정소송법은 취소소송의 원고적격을 법률상 보호되는 이익이 있는 자에게 인정한다. 이는 단순히 사실상·경제상 또는 반사적 이익만으로는 원고적격을 인정받을 수 없음을 의미한다. 행정법은 법률이 국민의 개별적인 이익까지 보호하려는 목적을 가질 때만 공권을 인정하고, 그 결과로서 쟁송을 통한 권리 구제를 허용한다.

3. 권한의 한계

- 법치 행정의 구조 하에서 행정주체의 모든 공권력 행사는 법률에 의해 부여된 권한의 범위 내에서만 정당화된다. 법률이 재량을 부여한 경우에도 행정청은 재량권의 한계를 준수해야 하며, 재량권을 일탈하거나 남용하는 경우, 이는 위법한 행정작용으로 간주되어 사법 심사의 대상이 된다.

VI. 결론

- 행정법의 기본구조는 법률우위 및 법률유보라는 법치 행정의 원리에 기반을 두고, 법규범의 존재에서부터 행정작용의 발생(처분), 그리고 행정쟁송을 통한 사법적 통제에 이르는 단계적 순환 구조로 이루어진다. 이 구조 내에서 행정주체는 공권력을 행사하고 국민은 주관적 공권을 통해 권익을 보호받으며, 법원은 최종적인 권한으로 위법한 행정작용을 심사하여 행정의 적법성을 확보하고 국민의 권리 구제를 실현한다.

<입문-제1장 개설.제4절 행정법의 법원>

I. 개설

1. 의의

- 행정법의 법원(法源)이란 행정주체의 행정작용에 대한 구속력을 가지는 법규범의 존재 형식을 의미한다. 이는 행정조직, 행정작용, 행정 구제 등 행정법 관계를 규율하는 법의 연원(淵源)으로서, 재판 기관(법원)이 행정소송을 통해 행정작용의 위법성을 판단할 때 판단 근거가 되는 규범들을 포괄한다. 법치 행정의 원리상 행정은 법원에 의해 구속되며, 행정주체가 법원을 위반한 행정작용을 한 경우 위법성이 인정된다.

2. 학설

(1) 실질적 의미의 법원

- 실질적 의미의 법원은 내용 면에서 행정법 관계를 규율하는 모든 규범을 의미한다. 이는 성문 법규범(헌법, 법률 등)뿐만 아니라 불문 법규범(관습법, 조리)까지 포함하는 가장 광의의 개념이다. 재판 기관이 행정의 위법성을 판단할 때 실제로 적용하는 모든 규범을 포괄한다.

(2) 형식적 의미의 법원

- 형식적 의미의 법원은 법의 존재 형식을 기준으로 성문(成文)의 형태로 존재하는 규범만을 의미한다. 이는 법전 또는 공식적인 문서로 작성되어 명시적인 효력을 가지는 규범으로서, 주로 국내법인 헌법, 법률, 명령 등을 지칭한다.

(3) 법적 확신설

- 법적 확신설은 행정법의 법원이 되기 위해서는 국가 또는 구성원의 일반적인 법적 확신을 얻고 있어야 한다는 견해이다. 이는 관습법과 같은 불문 법원의 법적 효력 근거를 설명하는 데 유용하다.

3. 특징

(1) 다양성과 복잡성

- 행정법은 공익 실현이라는 다양한 목적을 추구하므로, 그 법원 역시 헌법, 법률 등 상위 법규범뿐만 아니라 국제법, 지방자치단체 조례·규칙 등 다양한 영역에서 발생하며 그 체계가 복잡하다. 특히, 행정관습법과 조리와 같은 불문 법원이 중요한 역할을 수행한다.

(2) 성문법원 중심주의

- 법치 행정의 원리와 국민의 권리 보호의 명확성 때문에, 행정법은 법률이라는 성문 법원을 중심으로 구성되며, 불문 법원은 성문법의 결함을 보충하거나 해석의 기준을 제시하는 보충적 역할에 그친다.

(3) 불문법원의 중요성

- 행정 영역의 복잡성과 전문성으로 인해 성문법만으로 모든 사안을 규율하기 어렵고, 법률유보의 원칙에도 불구하고 행정 재량의 영역에서 행정법의 일반 원칙(조리)이 위법성 판단의 중요한 기준이 되는 등 불문 법원의 역할이 매우 크다.

4. 법원의 체계

- 행정법의 법원 체계는 헌법을 최상위 규범으로 하며, 법규범 간의 상하 관계에 따라 효력의 우열이 결정되는 피라미드 구조를 이룬다.

(1) 헌법(최상위)

- 행정조직 및 작용의 기본 원리와 국민의 기본권을 규정하는 최고 규범이다. 모든 행정작용은 헌법에 합치되어야 한다.

(2) 법률 및 국제법

- 국회가 제정한 법률과 헌법에 따라 체결·공포된 조약 및 일반적으로 승인된 국제법규가 법률과 동일한 효력을 가진다.

(3) 명령

- 대통령령(시행령), 총리령, 부령(시행규칙) 등 행정기관이 제정한 법규명령으로서, 법률의 세부 사항을 규정하거나 위임받은 사항을 집행한다.

(4) 자치 법규(조례·규칙)

- 지방자치단체가 법령의 범위 내에서 제정하는 조례(의회 제정)와 규칙(단체장 제정)이 당해 자치단체의 영역 내에서 효력을 가진다.

(5) 불문 법원

- 행정관습법, 판례법, 조리 등은 성문 법원을 보충하거나 해석하는 기준으로 작용하며, 성문법이 없을 때 보충적으로 행정작용의 법원이 된다.

II. 행정법의 성문법원

1. 정의

- 법률이라는 성문(成文)의 형태로 존재하는 규범을 의미한다.

2. 헌법

- 행정법의 최고 법원으로서, 법률유보의 원칙, 법치주의, 민주주의 원리 등 행정의 기본 원리를 제공하며 국민의 기본권을 보장한다. 행정법의 모든 규범과 행정작용은 헌법에 합치되어야 한다.

3. 법률

- 국회의 의결을 거쳐 제정된 성문 법규범으로서, 행정조직, 행정작용에 대한 가장 중요한 직접적인 근거를 제공한다. 법률은 국민의 권리·의무에 관한 본질적인 사항을 규정하여 법률유보의 원칙을 실현한다.

4. 명령

- 행정기관이 법률의 위임을 받아 제정하거나 법률을 집행하기 위해 제정하는 법규명령을 의미한다. 대통령령(시행령), 총리령, 부령(시행규칙) 등이 있으며, 이들은 법률에 위반되어서는 안 된다.

5. 자치법규

- 지방자치단체가 제정하는 조례(지방의회 의결)와 규칙(지방자치단체장 제정)이 있다. 조례는 법령의 범위 내에서 제정되어 법규의 효력을 가지며, 규칙은 지방자치단체장의 권한에 속하는 사무에 관하여 제정된다.

6. 행정규칙

- 행정조직 내부에서 행정 사무의 처리 기준이나 운영 방침을 정하기 위해 제정하는 규범이다. 원칙적으로 대외적인 구속력을 가지지 않아 행정법의 법원은 아니지만, 재량 준칙이 반복되어 평등의 원칙이나 신뢰 보호의 원칙에 따라 대외적 구속력을 갖는 경우(자기 구속의 법리)에는 실질적 법원으로 기능하기도 한다.

7. 국제법(조약 및 일반적으로 승인된 국제법규)

(1) 헌법 제6조 제1항

- 대한민국 헌법은 헌법에 의하여 체결 · 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다고 규정한다. 따라서 이들은 국내 행정법에 대해 직접적인 구속력을 가지는 성문법원이 된다.

(2) 조약

- 국가 간에 체결된 문서에 의한 합의로서, 인권, 노동, 무역, 환경 등 다양한 분야에서 행정작용의 기준을 제시한다. 행정주체는 조약의 내용에 위반되는 행정작용을 할 수 없다.

(3) 일반적으로 승인된 국제법규

- 국제 관습법 등 국제 사회에서 국가들이 공통적으로 인정하는 법규범을 의미하며, 이 역시 국내 행정법의 법원으로 기능한다.

III. 행정법의 불문법원

1. 정의

- 불문 법원은 성문(成文)의 형태로 존재하지 않지만 법적 확신을 얻어 행정주체의 행정작용을 구속하는 규범을 의미한다. 이는 성문법의 보완적성을 보충한다. 특히, 행정 재량권 행사의 통제 기준으로서 법치 행정의 실현에 중요한 역할을 한다.

2. 행정관습법

(1) 개념

- 행정 분야에서 오랜 기간에 걸쳐 반복적으로 형성된 관행에 대해 국민과 행정기관이 법적 구속력을 인정하고 있는 규범이다. 성립 요건으로는 관행의 존재와 법적 확신이 필요하다.

(2) 효력

- 행정관습법은 법률의 보충적 법원으로 기능한다. 행정관습법이 성문법에 위반되거나 모순될 경우 효력을 가질 수 없다(성문법우위 원칙). 다만, 성문법이 특정 사항을 관습에 위임한 경우에는 관습이 직접적 법원이 될 수 있다.

(3) 폐지된 관습법(폐지 관습)

- 기존의 관습이 새로운 법률이 제정됨에 따라 효력을 잃고 폐지된 관습으로 남는 경우가 있다. 판례는 특정 관습이 법적 효력을 가지는지 여부를 엄격하게 판단한다.

3. 판례법

(1) 개념 및 효력

- 판례법은 법원의 판결에 의해 법규범이 형성되는 것을 의미한다. 대륙법계에 속하는 한국은 판례가 원칙적으로 법원을 구성하지는 않으나, 상급법원(대법원)의 판례가 하급심에 사실상의 구속력을 가지며 법 해석의 통일을 통해 실질적인 법원으로서 역할을 한다.

(2) 행정소송의 기속력

- 행정소송법상 확정된 판결은 당해 사건에 관하여 당사자인 행정청과 관계 행정청을 기속하는 효력(기속력)을 가진다. 이는 특정 사건에 한정되지만, 실질적으로 유사 사건에 대한 행정청의 반복된 위법 행위를 막아 간접적으로 법원으로서 기능한다.

4. 조리(행정법의 일반원칙)

(1) 개념

- 조리(條理)란 사물의 본성 또는 합리적인 이치를 의미하며, 법률에 규정이 없을 때 보충적 법원으로서 기능하는 일반적인 행위 기준이다. 행정법에서는 조리가 행정법의 일반 원칙이라는 이름으로 구체화되어 가장 중요한 불문 법원으로 인정된다.

(2) 행정법의 일반원칙

- 조리는 다음과 같은 행정법의 일반 원칙을 통해 행정작용을 구속한다. 이 원칙들은 특히 행정청이 법률로부터 재량권을 부여받은 경우 재량권의 한계를 설정하는 통제 기준으로 활용된다.

① 비례의 원칙(과잉금지의 원칙)

- 행정목적 달성을 위해 사용되는 수단은 목적과 합리적인 비례 관계를 이루어야 하며, 목적 달성에 필요한 최소한에 그쳐야 한다는 원칙이다.

② 신뢰 보호의 원칙

- 행정청의 선행 행위(공적인 견해 표명)에 대한 국민의 정당한 신뢰는 보호되어야 하며, 행정청은 사정 변경이 없는 한 선행 행위에 반하는 행위를 해서는 안 된다는 원칙이다.

③ 평등의 원칙

- 합리적인 이유 없이 특정 개인을 차별해서는 안 된다는 원칙이다. 행정청이 재량 준칙을 반복하여 시행함으로써 스스로를 구속하게 되는 자기 구속의 법리는 평등의 원칙과 신뢰 보호의 원칙에서 그 근거를 찾는다.

④ 부당결부 금지의 원칙

- 행정주체가 공권력 행사와 상대방의 의무 이행 사이에 실질적인 관련성이 없는 부당한 결부를 통해서 상대방에게 반대급부를 강요하거나 부당한 제한을 가해서는 안 된다는 원칙이다.

⑤ 권한 남용 금지의 원칙

- 행정청이 법률에 의해 부여받은 권한을 정당한 목적이 아닌 부당한 동기로 사용하는 것을 금지하는 원칙이다.

IV. 결론

- 행정법의 법원은 성문법원(헌법, 법률, 명령, 자치법규, 행정규칙, 국제법)과 불문법원(행정관습법, 판례법, 조리)으로 구성되며, 법치 행정의 원리를 구현하는 규범적 근거이다. 헌법이 최고 법원이며 법률이 중심을 이루는 성문법원 중심주의 하에서도, 조리를 통해 구체화된 비례의 원칙, 평등의 원칙, 신뢰 보호의 원칙 등 행정법의 일반 원칙은 행정 재량권 통제의 핵심 기준으로서 불문 법원 중 가장 중요한 역할을 수행한다. 행정주체는 모든 행정작용에서 이러한 성문 및 불문 법원에 의해 구속된다.

<입문-제2장 행정입법(법규명령·행정규칙).제1절 법규명령>

I. 구조

1. 법규명령의 의의

- 법규명령은 행정기관이 법률에 근거하거나 법률을 집행하기 위해 국민의 권리·의무에 관한 사항을 일반적·추상적으로 규율하는 행정입법의 한 형태이다. 이는 법률과 마찬가지로 대외적인 구속력을 가지며, 국민과 법원 등 모든 기관을 구속하는 법원(法源)으로서의 성격을 가진다. 법규명령은 국회의 입법을 보충하거나 실현하는 기능을 수행하며, 법률우위의 원칙과 법률유보의 원칙이라는 법치 행정의 원리에 종속된다는 구조적 특징을 가진다.

2. 법규명령의 특징

(1) 행정기관의 제정

- 법규명령은 국가가 아닌 행정부의 수반인 대통령을 비롯하여 총리, 각 부처 장관 등 행정기관이 제정한다. 이는 행정의 전문성과 신속성을 활용하여 법률의 세부 사항을 효율적으로 규율하기 위함이다.

(2) 대외적 구속력

- 법규명령은 행정조직 내부만을 구속하는 행정규칙과 달리, 행정조직뿐만 아니라 일반 국민과 법원을 대외적으로 구속하는 법규로서의 성격을 가진다. 이 때문에 법규명령은 반드시 상위 법률에 위반되어서는 안 된다.

(3) 일반·추상적 규율

- 법규명령은 특정 개인이나 구체적 사건을 규율하는 행정행위(처분)와 달리, 불특정 다수의 사람에게 반복 적용될 수 있는 일반적·추상적인 기준을 규율한다. 이는 법률과 같은 입법 작용의 성격을 가진다.

3. 법규명령의 한계

- 법규명령은 국민의 대표 기관인 국가가 제정한 법률에 종속된다. 따라서 법규명령은 법률우위의 원칙상 상위 법률에 위반되어서는 안 되며, 법률유보의 원칙상 국민의 권리·의무에 관한 새로운 사항을 정하기 위해서는 반드시 법률의 구체적인 위임(수권)이 있어야 한다.

II. 수권범위·근거에 따른 법규명령의 종류

- 법규명령은 상위 법규범으로부터 어떤 내용을 수권(授權)받아 제정되었는지에 따라 그 법적 성격이 구분된다.

1. 헌법-명령

- 헌법대위명령 또는 비상명령이라 한다. 비상상황시 행정권 발령, 헌법적 효력을 가지며, 그 예로 유신헌법 하의 긴급조치와 같은 명령이 있다.

2. 법률-명령

- 법률대위명령 또는 독립명령이라 한다. 헌법이 규정하는 법적효력을 지닌 명령으로, 헌법 76조상의 긴급명령, 긴급재정, 경제명령 등이 있다.

3. 명령-명령

- 법률종속명령이라 하며, 위임명령과 집행명령으로 구분한다.

(1) 위임명령

- 상위 법령에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항에 관하여 새로운 입법 사항을 정하는 명령을 의미한다.

(2) 집행명령

- 상위 법령의 시행에 필요한 절차나 형식 등 세부적인 사항을 정하는 명령으로 새로운 입법 사항을 정할 수 없다.

III. 법형식에 따른 법규명령의 종류

- 법규명령은 법률상의 형식이 아닌, 헌법이 특정 기관에 권한을 부여했는지 여부에 따라 구분될 수도 있다.

1. 헌법이 명시하는 법규명령

(1) 대통령령(시행령)

- 헌법 제75조에 따라 대통령에게 법률의 위임이나 집행을 위한 명령을 발할 권한이 직접 명시되어 있다. 법규명령 중 가장 상위에 위치한다.

(2) 총리령 및 부령(시행규칙)

- 헌법은 국무총리와 행정 각 부의 장에게 법률 또는 대통령령의 위임에 따라 또는 직권으로 총리령 및 부령을 발할 수 있는 권한을 명시적으로 부여하고 있다. 이들은 대통령령의 하위 법규명령으로서 주로 세부적인 집행 사항을 규정한다.

2. 헌법이 명시하지 않는 법규명령

(1) 중앙선거관리위원회 규칙

- 헌법 제114조 제6항은 중앙선거관리위원회가 법률의 범위 안에서 선거 관리, 국민 투표 등에 관한 규칙을 제정할 수 있음을 규정하며, 이는 법규명령의 효력을 가진다. 행정기관의 명령은 아니지만 법규로서 인정된다.

(2) 대법원 규칙

- 헌법 제108조에 따라 대법원이 법률에 저촉되지 않는 범위 내에서 소송 절차, 법원 내부 규율 등에 관한 규칙을 제정할 수 있으며, 이 역시 법규로서의 효력을 가진다. 사법부의 입법 작용이지만 법규명령의 기능을 수행한다.

(3) 국회 규칙, 헌법재판소 규칙

- 헌법 제64조에 따른 국회 규칙 및 헌법 제112조에 따른 헌법재판소 규칙 또한 각 기관의 자율적인 운영을 위한 것이지만, 법규로서 대외적 구속력을 가질 수 있는 경우 법규명령에 준하는 효력을 가진다.

IV. 법령보충규칙

1. 법령보충규칙의 의의

- 법령보충규칙이란 법률이나 상위 법규명령이 특정 사항을 행정규칙(고시, 훈령 등)의 형식으로 제정하도록 위임한 경우, 그 위임을 받아 제정된 행정규칙을 의미한다. 형식은 행정규칙이지만, 내용은 법률의 위임을 받아 국민의 권리·의무에 영향을 미치므로 법규명령의 효력을 갖는다.

2. 법규명령성 인정 근거

(1) 관련 법령

- 행정규제기본법은 법치주의 원칙에 따라 국민의 권리를 제한하는 규제는 법률에 그 근거를 두어야 함을 명시한다. 이와 관련하여 고시는 일반적으로 행정규칙의 한 형태이지만, 행정규제기본법 제4조 제2항은 법령에서 특정 사항을 고시, 훈령 등 행정규칙의 형식으로 정하도록 위임한 경우에도 그 규제 내용이 국민의 권리·의무에 관한 것이라면 법규명령의 효력을 가질 수 있음을 간접적으로 시사한다. 다만, 법규명령으로서 효력을 갖기 위해서는 상위 법령의 구체적 위임이 있어야 하며, 고시 자체가 법률상의 권한 위임을 넘어서 새로운 규제를 창설할 수는 없다.

(2) 관련 판례

- 판례는 법령보충규칙이 상위 법령과 결합하여 대외적 구속력을 가진다고 보아 법규명령성을 인정한다. 이는 법규명령이 법규로서의 실질을 갖는다면 형식이 행정규칙이라 하더라도 법치 행정의 원칙상 국민의 권리를 침해할 수 없다는 논리에 기초한다. 따라서 이러한 법령보충규칙은 상위 법령의 위임 한계를 벗어나서는 안 된다.

V. 법률종속명령(위임명령 + 집행명령) 근거

- 법률종속명령은 법률에 효력상 종속되는 모든 법규명령을 총칭하며, 그 주된 유형은 위임명령과 집행명령이다. 이들의 정당성 근거는 현대 행정의 필요성과 헌법적 근거에 있다.

1. 헌법적 근거

- 헌법 제75조는 대통령에게 법률에서 구체적으로 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위해 명령을 발할 수 있는 권한을 부여함으로써 위임명령과 집행명령의 제정 근거를 직접적으로 명시한다. 헌법 제95조는 총리와 각 부처 장관에게도 명령 제정권을 부여한다.

2. 위임명령의 근거

- 위임명령의 정당성 근거는 법률유보의 원칙의 예외적 허용에 있다. 국가가 모든 사항을 규율하기 어렵다는 현실적 제약과 행정의 전문성·기술성을 활용하기 위해, 법률은 일정한 한계 내에서 국민의 권리·의무에 관한 사항을 행정기관에 위임할 수 있다. 다만, 위임은 포괄적으로 이루어질 수 없으며 구체적이고 개별적인 범위를 정해야 한다(포괄적 위임 금지 원칙).

3. 집행명령의 근거

- 집행명령의 정당성 근거는 법률우위의 원칙과 행정의 능률성에 있다. 법률이 일단 제정되면 행정기관은 그 법률을 실질적으로 실현해야 할 의무를 가진다. 법률의 절차나 형식 등 세부적인 사항을 행정기관이 자체적으로 규율하는 것은 법률의 집행을 효율적으로 수행하기 위해 필수적이다. 집행명령은 법률을 보충하거나 변경할 수 없고 법률의 취지를 따라야 한다.

VI. 결론

- 법규명령은 행정기관이 제정하는 국민 구속력을 가진 일반적·추상적인 법규범으로서, 법률의 종속성이라는 구조적 한계를 가진다. 헌법의 직접 수권을 받는 대통령령부터 법률의 위임을 받는 위임명령과 집행명령까지 수권 범위에 따라 다양하게 구분된다. 특히 고시 등 행정규칙의 형식을 취하더라도 상위 법령의 구체적인 위임을 받아 국민의 권리·의무를 규율하는 법령보충규칙은 법규명령의 실질적 효력이 인정되어 법치 행정의 원리에 따라 엄격한 통제를 받는다.

<입문-제2장 행정입법(법규명령·행정규칙).제2절 행정규칙(행정명령)>

I. 행정규칙의 의의

1. 개념

- 행정규칙은 행정기관이 자신의 직무 범위 내에서 행정 사무의 처리에 관하여 조직 내부의 일반적·추상적인 기준을 정립하는 행정입법의 한 형식이다. 행정규칙은 원칙적으로 행정조직 내부만을 규율하며, 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 대외적인 구속력을 가지는 법규로서의 효력은 없다. 이는 행정의 능률과 통일성을 확보하고, 행정청이 부여받은 재량권을 합리적으로 행사하도록 유도하는 데 그 주된 목적이 있다.

2. 법규명령과 행정규칙의 비교

- 법규명령과 행정규칙은 모두 행정기관이 제정하는 일반적·추상적 규율이라는 공통점을 가지나, 그 법적 성질과 효력 면에서 근본적인 차이를 가진다.

(1) 규율 대상 및 효력

① 법규명령

- 대외적인 구속력을 가지며, 행정조직뿐만 아니라 일반 국민과 법원(法院)을 구속한다. 법원(法源)으로서의 지위가 인정된다.

② 행정규칙

- 행정조직 내부만을 규율하며, 원칙적으로 대외적인 구속력을 가지지 않는다. 따라서 행정소송의 직접적인 심사 대상이 되는 법원(法源)은 아니다.

(2) 제정 근거

① 법규명령

- 법률의 위임을 받거나 법률을 집행하기 위한 헌법적 근거가 필수적이다. 법률유보의 원칙이 엄격하게 적용된다.

② 행정규칙

- 법률의 위임이 없더라도 행정기관의 직무 권한 내에서 자율적으로 제정할 수 있다. 다만, 법규의 내용을 정하기 위해서는 법률의 위임이 필요하다.

(3) 법 형식

① 법규명령

- 주로 대통령령(시행령), 총리령, 부령(시행규칙) 등의 법규명령 형식으로 제정된다.

② 행정규칙

- 훈령, 예규, 지시, 고시 등 행정조직 내부에서 사용되는 행정규칙 형식으로 제정된다.

(4) 사법적 통제

① 법규명령

- 행정소송에서 위헌·위법 심사의 대상이 되어 직접적인 사법 통제를 받는다.

② 행정규칙

- 원칙적으로 사법 통제 대상이 아니나, 행정규칙에 따른 구체적인 행정 처분이 위법한지 여부를 판단할 때 간접적으로 심사될 수 있다. 또한, 재량 준칙이 자기 구속의 법리에 의해 대외적 효력을 가지게 되는 경우에는 위법성 심사의 기준이 된다.

II. 행정규칙의 종류

1. 형식에 따른 분류

- 행정규칙은 발령 기관과 명칭에 따라 다양하게 분류되나, 공통적으로 행정조직 내부의 통일적 사무 처리를 목적으로 한다.

(1) 훈령

- 상급 행정기관이 하급 행정기관에 대하여 장기간에 걸쳐 그 권한 행사를 일반적으로 지시하기 위해 발하는 명령이다. 행정조직 내의 위계 질서를 확립하고 상명하복 관계를 규율한다.

(2) 지시

- 상급 행정기관이 하급 행정기관에 대하여 구체적인 개별적인 사무 처리를 명령하기 위해 발하는 명령이다. 훈령은 일반적인데 반해 지시는 구체적이고 개별적인 사안에 한정된다.

(3) 예규

- 행정 사무의 동일한 처리 기준을 설정하여 반복적으로 활용하도록 하는 행정규칙이다. 특정 행정작용에 대한 표준적인 절차나 형식을 제시한다.

(4) 고시

- 행정기관이 특정 사항을 일반 국민에게 알리는 행위로서, 일반적으로 행정규칙의 성격을 가진다. 다만, 고시가 법령의 위임을 받아 법규 사항을 정하는 경우 법령 보충적 행정규칙으로서 법규명령의 효력을 가지기도 한다.

(5) 공고

- 행정기관이 특정 사항을 일반 국민에게 일시적으로 알리는 행위로서, 고시와 유사하나 기간이 단기적이고 효력이 일회적인 경우가 많다.

2. 내용에 따른 분류

- 행정규칙은 그 규율 내용이 행정청의 재량권 행사에 대한 것인지, 법 해석에 대한 것인지에 따라 분류된다.

(1) 재량 준칙

- 법률이 행정청에게 재량권을 부여한 경우, 행정청이 그 재량권을 통일적으로 행사하기 위해 내부적으로 설정한 처리 기준이다(예: 영업 정지 처분 시 위반 횟수에 따른 처분 기간을 정한 기준). 원칙적으로 행정조직 내부만을 구속하나, 재량 준칙이 반복적으로 시행되어 평등의 원칙과 신뢰 보호의 원칙을 근거로 대외적 구속력(자기 구속의 법리)을 갖게 되는 경우, 위법성 판단의 기준으로 활용된다.

(2) 법규 해석 규칙

- 상위 법규의 내용을 하급 기관에 통일적으로 해석·적용하도록 하기 위해 발하는 규칙이다. 이는 상위 법규의 적용 기준을 명확히 하는 데 목적이 있으며, 상위 법규의 위임을 받아 새로운 법규 사항을 창설할 수는 없다.

(3) 법령 보충 규칙

- 법령의 위임에 따라 그 위임받은 내용을 정하는 행정규칙으로서, 이 범위 내에서는 상위법령과 결합하여 법규성을 지니게 된다. 형식은 행정규칙이지만, 내용은 법률의 위임을 받아 국민의 권리·의무에 영향을 미치므로 법규명령의 효력을 갖는다.

3. 기능에 따른 분류

- 행정규칙은 행정조직 내에서 수행하는 주요 기능에 따라 분류된다.

(1) 조직 규칙

- 행정조직의 내부 구조, 권한 배분, 직제, 업무 분장 등 조직 내부에 관한 사항을 규율하는 규칙이다. 행정의 능률과 효율성을 높이는 데 중점을 둔다.

(2) 근무 규칙

- 공무원의 복무, 근무 조건, 징계 기준 등 공무원 개인의 행위 및 관계를 규율하는 규칙이다. 이는 공무원 관계법의 세부 사항을 규정하는 경우가 많다.

(3) 사무 규칙

- 행정 사무의 구체적인 처리 절차, 양식, 기한 등 일반적인 사무 처리에 관한 사항을 규율하는 규칙이다. 이는 행정의 통일성과 일관성을 확보하는 데 기여한다.

(4) 재량 규칙

- 위에서 언급된 재량 준칙이 여기에 해당하며, 행정청이 부여받은 재량권을 합리적이고 평등하게 행사하도록 유도하는 기능을 수행한다.

Ⅲ. 결론

- 행정규칙은 행정기관 내부의 통일적 사무 처리를 위한 일반적·추상적 규율로서, 법규명령과 달리 원칙적으로 대외적 구속력은 없으나 행정조직 내부를 구속한다. 훈령, 고시 등 다양한 형식과 재량 준칙, 법규 해석 규칙 등 내용에 따라 분류되며, 특히 법령 보충 규칙과 재량 준칙의 자기 구속의 법리는 행정규칙의 법적 성질에 대한 핵심적인 쟁점을 이룬다. 행정규칙은 법치 행정의 원리 하에서 법률에 위반되지 않는 한 행정의 효율성을 높이는 데 기여한다.

<입문-제2장 행정입법(법규명령·행정규칙).제3절 행정규칙의 형식과 내용>

I. 법규명령 형식의 행정규칙

1. 문제의 소재

- 법규명령 형식의 행정규칙이란 형식은 대통령령, 부령 등 법규명령의 형태를 취하고 있지만, 그 내용은 국민의 권리·의무에 관한 사항이 아닌 행정조직 내부의 사무처리 기준이나 재량권 행사 준칙만을 규율하는 경우를 말한다. 원칙적으로 법규명령은 대외적 구속력을 가져야 하지만, 이러한 경우 내용상으로는 법규성이 없는 행정규칙의 성질을 가지므로 그 법적 효력을 어떻게 볼 것인지에 대한 견해의 대립이 발생한다. 특히, 해당 규정이 국민에게 간접적으로라도 영향을 미칠 때, 이를 법규명령으로 보아 위헌·위법 심사의 대상으로 삼아야 하는지 여부가 핵심 문제이다.

2. 학설

(1) 행정규칙설

- 규율 내용이 법규 사항(국민의 권리·의무)이 아닌 행정조직 내부의 사무처리 기준이나 재량 준칙에 불과하므로, 그 형식이 법규명령이라 하더라도 실질적으로는 행정규칙에 해당한다는 견해이다. 따라서 대외적 구속력을 부정하며, 법원의 직접적인 심사 대상이 되지 않는다고 본다. 이 견해는 법규명령의 실질적 의미를 중요시한다.

(2) 법규명령설

- 대통령령, 부령 등 법규명령의 형식으로 제정된 이상, 국민의 대표 기관인 국회의 위임을 받아 법규명령으로 제정된 것이므로 행정조직 내부만을 규율하는 내용이라 할지라도 법적 안정성과 권력 분립 원칙상 법규명령으로 보아야 한다는 견해이다. 다만, 그 내용이 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치지 않아 재량 준칙의 성격을 가진다면, 대외적 구속력은 인정하지 않거나 제한적으로 인정하는 입장이 병존한다.

(3) 절충설

- 법규명령의 형식을 취한 이상, 행정조직 내부에서는 법규명령으로서 효력을 가지고, 외부 관계에서는 재량 준칙으로서 행정규칙의 성질을 가진다고 보는 견해이다. 법적 안정성과 실질적인 규율 내용을 모두 고려하여 절충적으로 해결하고자 한다.

3. 판례

- 판례는 대통령령에 규정된 경우에는 법규명령으로, 부령에 규정된 경우에는 행정규칙으로 본다.

(1) 대통령령 형식인 경우

- 판례는 제재적 처분기준이 대통령령의 형식으로 정해진 경우 당해 처분 기준을 법규명령으로 본다.

(2) 부령 형식인 경우

- 원칙은 행정규칙으로 보나, 예외적으로 법규명령으로 본 판례(대법원 2006.6.27. 2003두4355-부령 형식으로 본 특허의 인가기준)와 법령(도로교통법 시행규칙 제97조-운전면허의 취소·정지 처분 기준 등)이 있다.

II. 행정규칙 형식의 법규명령(법령보충규칙, 법령보충적 행정규칙)

1. 문제의 소재

- 행정규칙 형식의 법규명령이란 훈령, 예규, 고시 등 행정규칙의 형식으로 제정되었으나, 법률이나 상위 법규명령의 구체적인 위임을 받아 국민의 권리·의무에 관한 사항을 보충적으로 규정하는 경우를 말한다. 원칙적으로 행정규칙은 대외적 구속력이 없어야 하지만, 법규 사항을 규정하고 있으므로 그 법적 성질과 효력을 행정규칙으로 보아야 할지 법규명령으로 보아야 할지가 핵심 문제이다. 특히, 이러한 규칙이 국민의 권리를 제한하는 경우, 법률유보의 원칙을 준수했는지 여부가 중요하게 다루어진다.

2. 학설

(1) 행정규칙설

- 법규명령은 대통령령, 부령 등 법규명령의 형식으로만 제정되어야 한다는 형식주의에 입각하여, 고시 등 행정규칙의 형식을 취한 이상 내용이 법규 사항이라 하더라도 행정규칙에 불과하다는 견해이다. 이 견해는 법규명령의 형식적 안정성을 중요시하며, 국민의 권리 제한은 법규명령의 형식으로 이루어져야 한다고 본다.

(2) 법규명령설(법령보충규칙설)

- 법률이나 상위 명령이 구체적으로 위임한 사항을 보충하는 내용이라면, 그 형식이 행정규칙(고시 등)이라 하더라도 상위 법령과 결합하여 대외적인 법규로서의 효력을 가진다는 견해이다. 이는 법규명칙주의(실질적 법치주의)에 입각하여 실질적인 규율 내용과 상위 법령과의 연결 관계를 중요시하며, 판례가 취하는 통설적 입장이다.

(3) 독자적 효력 부정설

- 행정규칙 형식으로 제정된 내용은 상위 법령의 위임 범위 내에서만 상위 법령과 합체하여 대외적 효력을 가진다고 본다. 즉, 행정규칙 자체가 독자적인 법규로서의 효력을 가지는 것이 아니라, 상위 법령의 효력에 의존하여 법규명령과 같은 기능을 수행한다고 본다.

3. 판례

- 판례는 법령보충적 행정규칙에 대해 법규명령설의 입장을 취하며, 그 대외적 구속력을 인정한다.

(1) 법규명령성 인정 기준

- 판례는 고시, 훈령 등 행정규칙의 형식을 취하고 있더라도, 상위 법령(법률, 명령)이 구체적으로 위임한 사항을 정하고 있다면, 그 고시 등은 상위 법령과 결합하여 대외적인 법규로서의 효력을 가진다고 본다. 이 경우, 고시 등은 상위 법령을 보충하는 기능을 수행하며, 국민의 권리·의무를 규율하는 법원(法源)이 된다.

(2) 법률유보의 원칙 적용

- 법령보충규칙이 법규명령의 효력을 가지기 위해서는 법률유보의 원칙이 적용되어야 한다. 즉, 상위 법령의 구체적이고 개별적인 위임이 있어야 하며, 고시 등의 규율 내용이 상위 법령의 위임 범위를 벗어나 새로운 규제를 창설하거나 위임의 근본 취지에 반해서는 안 된다. 위임 한계를 벗어난 부분은 무효로 판단된다.

(3) 처분성 인정 여부

- 법령보충규칙은 상위 법령과 결합하여 대외적 구속력을 가지지만, 일반적·추상적인 규율의 성격을 가지므로 원칙적으로는 행정 처분에 해당하지 않는다. 그러나 행정청이 이 규칙에 근거하여 구체적인 집행 행위(처분)를 한 경우, 행정 처분의 위법성은 상위 법령과 결합된 법령보충규칙의 위법 여부를 기준으로 심사된다.

III. 결론

- 법규명령 형식의 행정규칙과 행정규칙 형식의 법규명령(법령보충규칙)은 행정입법의 형식과 내용이 불일치하여 발생하는 법적 효력에 관한 중요한 쟁점이다. 판례는 법적 안정성과 법률유보의 원칙을 모두 고려하여, 전자의 경우는 형식을 존중하여 법규명령성을 인정(대통령령, 부령 일부)하고, 후자의 경우는 상위 법령과의 결합을 통해 실질적인 내용을 존중하여 법규명령의 효력을 인정한다. 특히 법령보충규칙은 상위 법령의 구체적 위임이 한계가 되며, 이 한계를 벗어난 경우 무효가 되어 법치 행정의 원리에 따른 사법 통제를 받는다.

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제1절 비례의 원칙>

I. 개설

1. 개념

- 비례의 원칙은 행정주체가 행정목적 달성을 위하여 행정작용을 할 때, 그 목적과 수단 사이에 합리적인 비례 관계가 있어야 하며, 특히 국민의 권리를 제한하거나 침해하는 경우 필요 최소한의 정도에 그쳐야 한다는 행정법의 일반 원칙 중 하나다. 이는 과잉금지의 원칙이라고도 불리며, 공익과 사익의 조화를 목적으로 한다. 법치국가 원리의 실질적 실현을 위한 중요한 통제 수단으로 기능한다.

2. 법적 근거

(1) 헌법적 근거

- 비례의 원칙은 명문화된 규정은 없지만, 헌법이 보장하는 국민의 기본권을 국가 권력으로부터 보호하려는 헌법 제37조 제2항의 기본권 제한의 한계 원칙에 일반적 근거를 두고 있다. 헌법 제37조 제2항은 국민의 자유와 권리는 국가 안전 보장, 질서 유지 또는 공공 복리를 위하여 법률로써 제한할 수 있으나, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다고 규정한다. 비례의 원칙은 이러한 기본권 제한에 대한 최소한의 기준을 제시한다.

(2) 개별 법률적 근거

- 행정기본법 제10조는 행정목적 달성을 데 유효하고 적절할 것, 행정목적 달성을 데 필요한 최소한도에 그칠 것, 행정작용으로 인한 국민의 이익 침해가 그 행정작용이 의도하는 공익보다 크지 아니할 것라고 하여, 행정작용에 대한 비례의 원칙을 명시적으로 규정한다. 이로써 비례의 원칙의 세 가지 요소(적합성, 필요성, 상당성)를 법정화하고 있다.

3. 적용 범위

(1) 행정작용 전반

- 비례의 원칙은 행정주체가 수행하는 모든 행정작용에 일반적으로 적용되는 불문 법원이다. 침익적 행정(제재 처분, 의무 부과 등)은 물론, 수익적 행정(특허, 허가 등), 행정입법을 포함하는 광범위한 영역에 걸쳐 적용된다.

(2) 침익적 행정작용의 통제

- 비례의 원칙은 특히 국민의 권리를 제한하는 행정 처분에 대한 사법적 통제의 핵심 기준으로 활용된다. 예를 들어, 위반 행위에 대한 제재 처분(영업 정지, 과징금 부과)의 종류나 정도가 위반 행위의 중대성에 비하여 지나치게 가혹한 경우, 비례의 원칙 위반으로 위법성이 인정될 수 있다.

(3) 재량 행위의 통제

- 법률이 행정청에 재량권을 부여한 경우에도, 비례의 원칙은 재량권 행사의 한계를 설정하는 기준이 된다. 행정청이 재량을 행사할 때 비례의 원칙을 위반하면 이는 재량권의 일탈 또는 남용에 해당하여 위법하게 된다.

II 비례원칙의 내용

1. 비례원칙의 구성

- 비례의 원칙은 세 가지 하위 원칙으로 구성되어 있으며, 이들은 단계적으로 행정작용의 적법성을 심사하는 기준이 된다.

(1) 적합성의 원칙

- 행정주체가 행정목적 달성을 위해 선택한 수단이 그 목적을 달성하는 데 실질적으로 기여할 수 있어야 한다는 원칙이다. 만약 선택된 수단이 목적 달성에 전혀 도움이 되지 않거나 비합리적이라면, 그 행정작용은 부적합하여 위법하게 된다. 이는 행정작용의 효율성을 요구하는 측면이 있다.

(2) 필요성의 원칙

- 행정목적 달성을 데 적합한 여러 수단 중에서 국민의 권리를 가장 적게 침해하는 최소한의 수단을 선택해야 한다는 원칙이다. 이를 최소 침해의 원칙이라고도 한다. 행정청은 동일한 목적을 달성할 수 있는 여러 가지 수단이 있을 경우, 국민에게 가장 덜 부담이 되는 수단을 우선적으로 사용해야 한다.

(3) 상당성의 원칙(협의의 비례의 원칙)

- 선택된 수단으로 인해 국민이 침해받는 사익(私益)과 그 행정작용을 통해 달성하고자 하는 공익(公益) 사이에 합리적인 균형이 이루어져야 한다는 원칙이다. 즉, 침해되는 사익이 달성되는 공익보다 현저하게 크지 않아야 한다. 만약 사익의 침해가 공익보다 지나치게 큰 경우, 이는 과잉 금지에 해당하여 위법하게 된다. 판례는 이 원칙을 엄격하게 적용하여 제재 처분의 가혹성 여부를 판단한다.

2. 단계적 구조

- 비례의 원칙에 따른 심사는 적합성, 필요성, 상당성의 순서로 단계적으로 이루어진다. 선행 단계의 원칙을 충족하지 못하면 후행 단계의 심사로 넘어갈 필요 없이 위법이 인정된다.

(1) 제1단계 : 적합성 심사

- 행정작용이 정당한 행정목적 달성을 데 효과적인지 여부를 심사한다. 예를 들어 무허가 건물에 대한 강제 철거 명령은 도시 계획이라는 행정 목적 달성에 적합한 수단이다.

(2) 제2단계 : 필요성 심사

- 적합성이 인정된 수단 중에서 국민에게 가장 덜 부담을 주는 대안적인 수단이 있는지 여부를 심사한다. 예를 들어 강제 철거 대신 사용 중지 명령이나 벌금 부과 등 덜 침익적인 수단이 있는지 검토한다. 행정청은 최소 침해 수단을 선택해야 한다.

(3) 제3단계 : 상당성 심사

- 최소 침해 수단이 선택되었다 하더라도, 그 수단으로 인해 침해되는 사익과 달성되는 공익을 비교 형량하여 침해의 정도가 균형을 이루는지 심사한다. 예를 들어 경미한 위반에 대해 영구적인 영업 허가 취소를 하는 것은 공익에 비해 사익 침해가 과도하여 위법하다.

III 위반의 효과

1. 행정작용의 위법성

- 행정주체가 비례의 원칙을 위반하여 행한 행정작용은 위법하게 된다. 위법성의 정도에 따라 무효 또는 취소의 원인이 된다.

(1) 취소 사유

- 비례의 원칙 위반이 중대·명백하지 않은 경우(중대 OR 명백)에는 취소할 수 있는 행위로 본다. 대부분의 경우 제재 처분의 양정 과다는 재량권의 일탈 또는 남용으로 간주되어 취소소송의 대상이 된다. 판례는 영업 정지 기간이 위반 행위의 경중에 비해 지나치게 가혹한 경우 위법하여 취소되어야 한다고 본다.

(2) 무효 사유

- 비례의 원칙 위반이 중대·명백한 경우(중대 AND 명백)에는 무효 사유가 될 수 있다. 예를 들어, 처분의 목적 자체가 행정목적과 무관하며 사익만을 침해할 목적인 경우 등이다.

2. 국가 배상 책임

- 행정주체가 비례의 원칙을 위반하여 위법한 행정작용을 함으로써 국민에게 손해를 입힌 경우, 이는 공무원의 직무상 불법 행위에 해당하여 국가배상법에 따른 손해 배상 책임이 발생할 수 있다.

3. 재량권의 한계 설정

- 비례의 원칙 위반은 재량 행위에 있어서 재량권의 한계를 일탈하거나 남용한 것으로 간주되어 사법 심사를 통해 위법성이 확인된다. 이는 행정청의 자의적인 권한 행사를 방지하고 국민의 권익을 실질적으로 보호하는 가장 중요한 역할을 한다.

IV. 결론

- 비례의 원칙은 법치국가 원리와 기본권 보장을 실질적으로 구현하는 핵심 원칙으로서, 행정주체의 모든 행정작용을 적합성, 필요성, 상당성의 단계적 구조를 통해 통제한다. 행정작용이 행정목적 달성에 적합해야 하고, 최소한의 침해 수단이어야 하며, 공익과 사익 간에 균형을 이루어야 한다는 이 원칙은, 특히 국민의 권리를 제한하는 침익적 행위와 행정청의 재량권 행사에 대한 사법 통제의 가장 강력한 기준이 된다. 비례의 원칙을 위반한 행정작용은 중대하거나 명백한 경우는 취소, 중대하고 명백한 경우는 무효의 대상이 된다.

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제2절 신뢰보호의 원칙>

I. 개설

1. 개념

- 신뢰보호의 원칙은 행정주체가 행한 적법한 선행조치(공적인 견해 표명)에 대하여 사인(私人)이 그 정당성을 신뢰하여 일정한 행위를 하였을 때, 행정주체는 그 선행조치에 반(反)하는 후행처분을 통해 사인의 신뢰를 배신하여 손해를 입혀서는 안 된다는 행정법의 일반 원칙이다. 이는 법치 행정의 원리 중 법적 안정성과 신의성실의 원칙을 행정 영역에서 구현하는 중요한 원칙이다. 이 원칙은 국민의 권익을 보호하고 행정에 대한 신뢰를 증진시켜 국가와 국민 간의 신뢰 관계를 유지하는 데 기여한다.

2. 법적 근거

(1) 헌법적 근거

- 신뢰보호의 원칙은 헌법에 명문으로 규정되어 있지는 않다. 하지만 헌법 제11조의 평등의 원칙과 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치 및 행복 추구권에서 파생되는 법치국가 원리 중 법적 안정성의 요소로서 간접적인 헌법적 근거를 찾을 수 있다. 법적 안정성은 국가 행위에 대한 국민의 예측 가능성을 보장하는 것이며, 이는 신뢰 보호를 통해 실현된다. 또한, 신의성실의 원칙을 공법적 영역으로 확장한 것으로 이해된다.

(2) 개별 법률적 근거

- 행정기본법 제12조는 행정청은 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다.고 하여, 신뢰보호의 원칙을 명시적으로 규정하고 있다. 이는 행정법의 일반 원칙 중 하나인 신뢰보호의 원칙을 법률로 법정화하여 그 적용에 대한 명확한 기준과 구속력을 부여한 것이다.

II. 성립요건

- 신뢰보호의 원칙이 적용되어 행정청의 후속 처분이 위법하게 되기 위해서는 엄격하게 요구되는 다음과 같은 요건들을 모두 충족해야 한다.

1. 행정청의 선행조치

(1) 개념

- 선행조치는 행정주체가 신뢰를 유발하는 행위를 하였음을 의미하며, 이는 공적 견해 표명의 형태를 취한다. 선행조치는 반드시 적극적인 행위(명시적인 허가, 확약 등)일 필요는 없으며, 소극적인 행위(장기간의 무응답)나 묵시적인 언동으로도 가능하다.

(2) 공적 견해 표명

- 가장 중요한 것은 선행조치가 행정청의 공적인 의사로서 표명되어야 한다는 점이다. 단순한 사실 행위, 내부적인 결정, 사적인 발언 등은 공적인 견해 표명으로 볼 수 없다. 또한, 공적인 견해 표명은 장래에 어떠한 행정 처분을 하거나 하지 않겠다는 확정적인 의사를 포함해야 하며, 단순한 정책적 방향이나 법령의 일반적 설명만으로는 부족하다.

(3) 권한 있는 행정청

- 선행조치를 한 행정청이 적어도 실질적으로 후행처분을 할 권한을 가진 행정청이거나, 또는 권한을 가지지 않았더라도 객관적으로 정당한 권한을 행사할 수 있는 것으로 오인될 만한 외관을 갖추고 있어야 한다. 판례는 권한이 없는 행정청의 공적인 견해 표명이라도, 실질적인 담당 공무원이 묵시적으로 승인한 경우 등 특별한 사정이 있으면 신뢰보호를 인정하기도 한다.

2. 보호가치 있는 정당한 신뢰

(1) 신뢰의 정당성

- 행정청의 선행조치에 대한 사인의 신뢰가 법적으로 보호받을 가치가 있어야 한다. 사인이 행정청의 선행조치가 위법하거나 법규에 위반된다는 것을 알았거나 또는 중대한 과실로 알지 못했을 경우, 그 신뢰는 정당성을 결여하여 보호받을 수 없다.

(2) 사인의 귀책사유 부존재

- 사인에게 사실 은폐, 사기, 기타 부정한 수단으로 선행조치를 유도한 귀책사유가 없어야 한다. 신청 서류에 허위 내용을 기재하거나 중요한 정보를 제출하지 않은 경우, 신뢰는 정당성을 잃게 된다.

3. 신뢰에 기한 상대방의 조치

- 상대방(사인)은 행정청의 선행조치를 믿고 그에 근거하여 자신의 사익을 위한 일정한 행위를 이행하거나 재산적 처분 등 경제적 부담을 감수하는 조치를 취해야 한다. 단순한 심정적인 기대나 행위로 나아가지 않은 단계에서는 신뢰보호의 원칙이 적용되지 않는다. (예 : 행정청의 확약을 믿고 건축 허가를 받기 위해 건축 설계를 하거나 토지를 매입하는 행위)

4. 인과관계

- 상대방의 조치(행위)와 행정청의 선행조치 사이에 인과관계가 존재해야 한다. 즉, 상대방은 행정청의 선행조치가 없었더라면 그러한 경제적 또는 법률적 조치를 취하지 않았을 것이라는 인과성이 입증되어야 한다.

5. 선행조치에 반하는 후행처분

(1) 개념

- 행정청이 선행조치에서 표명했던 공적인 견해와 모순되거나 반대되는 내용의 행정 처분을 후행적으로 하는 것을 의미한다. 신뢰보호의 원칙은 바로 이 후행처분의 위법성을 판단하는 기준이 된다.

(2) 모순성

- 선행조치가 장래에 특정 처분을 하지 않겠다는 내용이었는데, 실제로 그 처분을 하거나, 특정 처분을 해주겠다는 내용이었는데 거부 또는 철회하는 경우가 전형적이다. 판례는 세금 부과 처분이 과거의 세금 비과세 조치에 모순되는 경우 신뢰보호의 원칙 위반으로 판단한 바 있다.

6. 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우가 아닐 것

- 신뢰보호의 원칙은 법치국가 원리 중 법적 안정성을 실현하는 원칙이지만, 공익을 배제하고 무조건적으로 사익만을 보호할 수는 없다. 따라서 행정청이 선행조치에 반하는 처분을 해야 할 중대한 공익적 사유가 있거나, 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우에는 신뢰보호의 원칙의 적용이 제한되거나 배제된다. 공익과 사익 간의 비교 형량이 이루어져야 하며, 공익이 사인의 신뢰 이익보다 우월한 경우에만 신뢰보호 원칙이 배제될 수 있다.

III. 위반의 효과

1. 행정작용의 위법성 및 취소

- 신뢰보호의 원칙의 성립 요건이 모두 충족되었음에도 불구하고 행정청이 선행조치에 반하는 후행처분을 한 경우, 그 후행처분은 신뢰보호의 원칙을 위반하여 위법하게 된다. 이 위법성은 재량권을 부여받은 행위일 경우 재량권의 일탈 또는 남용에 해당한다. 따라서 사인은 취소소송을 통해 후행처분의

취소를 구할 수 있다.

2. 인허가 처분의 위법성

- 행정청이 과거의 공적인 견해 표명(선행조치)에 반하여 인허가를 거부하거나 철회하는 경우, 이는 신뢰보호의 원칙 위반으로 위법하다.

3. 위반자에 대한 제재의 감경

- 법규 위반 행위에 대한 제재 처분을 함에 있어 행정청이 선행조치로 위반 행위를 묵인하거나 방조한 사실이 있는 경우, 신뢰보호의 원칙에 따라 제재의 정도가 감경되어야 한다. 전적으로 신뢰가 침해된 경우 처분이 취소되지만, 공익이 우월하여 신뢰보호가 제한적으로 이루어져야 할 경우 제재의 감경 등의 조정적 효과가 발생한다.

4. 손해 배상 또는 손실 보상

- 신뢰보호의 원칙에 위반된 후행처분이 취소 사유에 그치고 무효가 아닌 경우, 행정청의 위법한 처분으로 인해 사인이 손해를 입었다면, 이는 국가배상법에 따른 국가 배상 책임의 성립 요건이 될 수 있다. 행정청이 위법하지는 않으나 적법하게 후행처분을 하였고 그로 인해 사인이 특별한 희생을 입었다면, 손실 보상의 문제가 발생할 수 있다.

IV. 결론

- 신뢰보호의 원칙은 행정청의 공적인 견해 표명(선행조치), 보호가치 있는 신뢰, 신뢰에 기한 조치 및 인과관계, 선행조치에 반하는 후행처분 등 엄격한 요건을 모두 충족할 때 비로소 적용되는 행정법의 일반 원칙이다. 이 원칙은 법적 안정성을 확보하고 국민의 정당한 권익을 보호하는 데 가장 중요한 역할을 한다. 다만, 중대한 공익적 요청이나 제3자의 정당한 이익과의 형량을 통해 적용이 배제되거나 제한될 수 있으며, 이를 위반한 후행처분은 위법하여 취소의 대상이 된다.

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제3절 평등의 원칙>

I. 개설

1. 개념

- 평등의 원칙은 행정법 영역에서 행정주체가 행정작용을 함에 있어 합리적인 이유 없이 국민을 차별해서는 안 된다는 행정법의 일반 원칙이다. 이는 본질적으로 같은 것을 같게 취급하고, 다른 것을 다르게 취급해야 한다는 상대적 평등을 의미한다. 행정의 공정성과 객관성을 확보함으로써 법적 안정성을 실현하는 데 중대한 기능을 수행한다.

2. 법적 근거

(1) 헌법적 근거

- 평등의 원칙의 직접적인 근거는 헌법 제11조 제1항에 있다. 헌법은 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다고 규정한다. 이는 국가 작용 전체를 구속하는 최상위의 법 원칙이며, 행정청의 행정작용 역시 이 헌법적 평등 원칙에 구속된다.

(2) 개별 법률적 근거

- 행정기본법 제9조는 행정청은 합리적 이유 없이 국민을 차별하여서는 아니 된다고 규정하여, 행정법상의 일반 원칙으로서 법정화되었다.

II. 헌법상 심사기준

- 헌법재판소 및 법원은 평등의 원칙 위반 여부를 심사할 때 차별의 합리성을 기준으로 삼는다. 이는 차별이 정당한 목적을 위해 합리적인 수단을 사용했는지 여부를 판단하는 것이다.

1. 자의금지 원칙

- 평등 원칙 심사의 가장 기본적인 기준은 자의금지의 원칙이다. 이는 차별에 합리적인 이유가 있는지 여부를 판단하는 것으로, 차별이 관련 법규 및 행정목적과의 관계에서 현저히 불합리하거나 자의적인 것이라면 평등 원칙에 위반된다고 본다. 차별의 합리성은 비교 대상 간의 사실 관계, 규율 목적 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 차별 심사의 정도

- 차별이 국민의 기본권에 미치는 영향이나 차별의 기준에 따라 심사의 강도가 달라진다.

(1) 엄격한 심사

- 헌법이 특별히 평등을 요구하는 영역(성별, 종교)이나 기본권에 대한 중대한 제한을 초래하는 차별에 대해서는 엄격한 심사 기준이 적용된다. 차별의 목적이 정당하고, 수단이 목적 달성에 필요 불가결하며, 침해되는 기본권과 달성되는 공익 간에 균형이 이루어졌는지(비례의 원칙의 엄격한 심사와 유사)를 심사한다.

(2) 완화된 심사

- 입법자나 행정청에게 광범위한 형성의 자유가 인정되는 정책적 영역(경제 정책, 조세)에서는 완화된 심사 기준이 적용된다. 이 경우, 차별이 입법 목적 달성에 현저히 자의적인 것이 아니라면 평등 원칙에 위반되지 않는다고 본다.

III. 행정법에서의 기능

1. 재량권 통제원칙으로서 기능

- 평등의 원칙은 행정청의 재량 행위에 대한 통제 원칙으로서 가장 중요하게 기능한다. 법률이 행정청에 재량권을 부여한 경우에도, 행정청은 같은 사안에 대해서는 과거의 선례나 다른 사안과의 비교를 통해 합리적이고 평등하게 재량권을 행사해야 한다. 행정청이 합리적 이유 없이 특정 개인을 과거의 유사한 사례와 다르게 취급하여 불리한 처분을 한 경우, 이는 재량권의 일탈 또는 남용에 해당하여 위법하게 된다.

2. 재량준칙을 법규로 전환시키는 전환규범으로서 기능

- 평등의 원칙은 행정규칙(재량 준칙)이 대외적 구속력(법규성)을 갖게 하는 자기 구속의 법리의 매개 규범이 된다. 행정청이 재량준칙에 따라 반복적으로 행정처분을 하여 관행이 성립하면, 행정청은 스스로 그 준칙에 구속된다. 이는 준칙에 따라 평등하게 처분할 것을 국민에게 신뢰하게 하였으므로, 행정청이 준칙을 위반하면 평등의 원칙에 위반된다는 논리가 성립한다. 이로 인해 재량준칙은 대외적인 구속력을 갖는 법규로 전환되는 효과를 가지며, 이를 전환규범이라고 부른다.

IV. 한계

- 평등의 원칙은 절대적인 평등이 아닌 상대적인 평등만을 요구한다. 따라서 본질적으로 다른 사항에 대해서는 차별적 취급이 허용된다. 평등 원칙의 가장 중요한 한계는 위법한 행정 선례에 대한 평등의 요구(평등 대 위법) 문제다. 행정청이 과거에 위법한 행정처분(선례)을 한 경우, 다른 국민이 행정청에 대하여 그 위법한 처분과 동일한 처분을 요구할 권리는 인정되지 않는다. 위법에는 평등이 없다는 원칙이 적용되어, 평등의 원칙은 법의 합법성을 희생시키면서까지 적용될 수 없다. 다만, 선례가 명백히 위법하지 않거나, 선례에 대한 신뢰보호의 원칙이 적용될 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 제한적으로 평등의 요구가 인정될 여지가 있을 뿐이다.

V. 위반의 효과

- 행정주체가 평등의 원칙을 위반하여 행정작용을 한 경우, 그 작용은 위법하게 된다.

1. 취소 사유

- 평등의 원칙 위반은 재량권을 부여받은 행정 행위의 경우, 재량권의 일탈 또는 남용의 한 유형으로 간주된다. 따라서 재량 행위가 평등의 원칙을 위반한 경우, 행정심판이나 행정소송을 통해 취소될 수 있다.

2. 국가 배상 책임

- 평등의 원칙을 위반한 위법한 행정작용으로 인해 국민이 손해를 입은 경우, 이는 공무원의 직무상 불법 행위에 해당하여 국가 배상 책임이 발생할 수 있다. 행정청이 자의적으로 특정 국민에게만 불리한 처분을 한 경우 공무원의 고의 또는 과실이 인정될 수 있다.

VI. 처분적 법률의 위반 여부

1. 개념

- 처분적 법률이란 법률의 형식을 갖추고 있지만, 일반적이고 추상적인 규율이 아니라 특정 개인이나 특정 사건에 대해서만 개별적이고 구체적으로 규율하는 법률을 말한다. 이는 입법부가 본래의 기능인 일반 법규의 제정을 넘어 행정부나 사법부의 처분 기능을 대신하는 형태로 나타난다.

2. 유형

- 처분적 법률은 특정 개인의 권리를 제한하거나 박탈하는 경우, 특정 지역이나 특정 집단에 대해서만 개별적으로 의무를 부과하는 경우, 또는 특정 사안의 처리 절차를 법률로 직접 규정하는 경우 등 다양한 형태로 나타난다.

3. 평등원칙 · 권력분립과 처분적 법률의 관계

(1) 평등의 원칙과의 관계

- 처분적 법률은 특정 개인이나 집단만을 규율하므로, 일반 국민과의 관계에서 차별의 문제를 필연적으로 야기한다. 따라서 처분적 법률이 평등의 원칙에 위반되는지 여부는 그 차별이 정당한 목적을 위해 합리적 이유를 가지는지 여부에 따라 판단되어야 한다. 국가의 중대한 공익적 요청이 있거나 사안의 특수성이 인정되는 경우에는 합리성이 인정될 수 있지만, 합리적인 이유가 없는 자의적인 차별은 평등의 원칙에 위반되어 위헌이다.

(2) 권력분립 원칙과의 관계

- 처분적 법률은 입법부가 행정이나 사법의 기능을 침해할 수 있다는 점에서 권력분립의 원칙에 위반될 소지가 있다. 헌법은 법률의 일반성과 추상성을 원칙으로 하므로, 처분적 법률은 극히 예외적인 경우에 한하여 허용된다. 입법부가 사법적 기능(형벌 부과)을 대신하거나, 행정적 기능(개별 처분)을 법률로 직접 하는 것은 권력분립의 원칙에 정면으로 위반된다.

4. 관련 판례

- 판례는 처분적 법률의 위헌성을 판단할 때 평등의 원칙을 중요한 기준으로 삼는다. 특정 개인이나 집단을 대상으로 한 법률이 다른 국민과 합리적인 이유 없이 차별적으로 부담을 지우는 경우, 평등의 원칙에 위반된다고 본다. 예를 들어 특정 토지의 소유자에게만 아무런 보상 없이 공익적 의무를 특별히 부과하는 법률은 평등의 원칙에 위반되어 위헌이 된다. 입법 목적의 정당성과 구체적 타당성이 인정되어야만 처분적 법률이 합헌적으로 인정될 수 있다.

VI. 결론

- 평등의 원칙은 헌법 제11조에 근거를 둔 행정법의 일반 원칙으로서, 행정청의 모든 행정작용에 대하여 합리적인 이유 없는 차별을 금지한다. 특히, 재량 행위의 통제 기준과 재량 준칙의 법규 전환 규범으로서 핵심적인 기능을 수행한다. 위법한 선례에 대한 평등 요구는 위법에는 평등이 없다는 원칙에 따라 원칙적으로 부정되나, 처분적 법률의 경우 권력분립과 더불어 평등의 원칙이 엄격한 심사 기준으로 작용하여 합리적 이유 없는 차별은 위헌으로 판단된다.

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제4절 자기구속의 원칙>

I. 개설

1. 개념

- 자기구속의 원칙은 행정주체가 재량권을 행사할 때 동일하거나 유사한 사안에 대해서는 이미 확립된 관행(선례)이나 스스로 정한 기준(재량 준칙)에 따라 일관성 있게 처분해야 하며, 자의적으로 그 기준을 벗어나서는 안 된다는 행정법의 일반 원칙이다. 이는 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙을 근거로 하여 행정의 공정성과 예측 가능성을 확보하는 데 그 목적이 있다. 행정의 통일성을 유지하고 재량권의 남용을 방지하는 기능을 수행한다.

2. 구별

(1) 평등의 원칙과의 구별

- 평등의 원칙은 행정주체의 모든 행위에 대해 합리적인 이유 없는 차별을 금지하는 광범위한 원칙이다. 반면, 자기구속의 원칙은 재량행위의 영역에서 행정청이 스스로 설정하거나 반복적으로 형성한 선례에 구속된다는 특수한 원칙이다. 자기구속의 원칙은 평등의 원칙을 실현하는 하위 원칙 또는 구체적 실현 방식으로 이해된다.

(2) 신뢰보호의 원칙과의 구별

- 신뢰보호의 원칙은 행정청의 선행조치(공적 견해 표명)에 대한 상대방(국민)의 정당한 신뢰를 보호하는 데 초점을 맞춘다. 반면, 자기구속의 원칙은 상대방의 신뢰뿐만 아니라 행정청 스스로가 설정한 기준에 일관성을 유지해야 할 의무에 중점을 둔다. 신뢰보호는 선행조치가 하나만 존재해도 적용될 수 있지만, 자기구속은 반복된 선례나 일반화된 재량 준칙을 전제로 한다.

II. 근거

1. 학설

(1) 평등설(통설)

- 자기구속의 원칙의 근거를 헌법 제11조의 평등의 원칙에서 찾는 견해이다. 행정청이 재량 준칙을 일반적으로 적용하거나 반복적으로 선례를 형성하면, 동종의 사안에 대해서는 평등하게 취급해야 할 의무가 발생한다는 것이다. 행정청이 스스로 정한 기준에 따르지 않고 특정 국민에게만 불리한 처분을 하는 것은 합리적 이유 없는 차별에 해당하여 평등의 원칙에 위반된다고 본다. 이는 판례가 취하는 주된 입장이기도 하다.

(2) 신뢰보호설

- 행정청이 재량 준칙을 제정하거나 반복된 선례를 형성하면, 국민은 장래에도 그 기준에 따라 처분을 받을 것이라는 정당한 신뢰를 형성하게 되므로, 행정청은 그 신뢰를 보호하기 위해 스스로 구속된다는 견해이다.

(3) 절충설

- 자기구속의 원칙이 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙이라는 두 가지 법적 근거에 의해 종합적으로 지지된다는 견해이다. 평등 원칙은 수평적으로 유사한 사안 간의 형평성을, 신뢰보호 원칙은 시간적으로 선례와 후행 처분 간의 일관성을 보장하는 근거가 된다고 본다.

2. 판례

- 판례는 자기구속의 원칙의 근거를 주로 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙에서 찾으며, 특히 평등의 원칙에 의해 재량 준칙의 대외적 구속력(법규성)을 인정한다.

(1) 평등의 원칙에 근거

- 판례는 행정청이 재량권을 행사하는 경우 재량 준칙을 정하여 공표한 때에는 특단의 사정이 없는 한 그 준칙에 따라야 하며, 이를 위반하여 합리적인 이유 없이 불이익을 주는 것은 평등의 원칙에 위반되어 위법하다는 입장을 확립하고 있다.

(2) 재량 준칙의 대외적 효력

- 재량 준칙은 원칙적으로 법규성이 없으나, 판례는 재량 준칙이 반복적으로 시행되어 행정 관행이 성립하면 자기구속의 법리에 의해 대외적 구속력을 갖게 되어 위법성 판단의 기준이 된다고 본다.

III. 역할과 기능

1. 전환규범으로서의 역할

- 자기구속의 원칙은 재량 준칙과 같은 행정규칙을 법규명령에 준하는 대외적 구속력을 가진 법규로 전환시키는 매개 규범으로서의 역할을 한다. 재량 준칙이 반복적으로 적용되어 자기 구속의 법리가 발생하면, 행정청은 평등의 원칙에 따라 그 준칙에 구속되고, 이는 재량 준칙이 위법성 판단의 기준이 되는 법규성을 간접적으로 획득하게 만든다.

2. 기능

(1) 행정의 통일성 확보

- 자기구속의 원칙은 동일하거나 유사한 사안에 대해 일관된 행정 처분을 하도록 하여 행정작용의 통일성과 균형성을 확보한다. 이는 행정청이 담당 공무원의 교체 또는 시간의 변화에 따라 기준을 자의적으로 변경하는 것을 방지한다.

(2) 국민의 예측 가능성 보장

- 행정청이 스스로 정한 기준을 준수함으로써 국민에게 장래의 행정작용에 대한 예측 가능성을 부여하고, 법적 안정성을 실현하는 데 기여한다.

(3) 재량권의 통제

- 재량행위의 영역에서 행정청의 자의적인 권한 행사를 방지하고, 재량권의 일탈 또는 남용 여부를 판단하는 사법 통제의 실질적인 기준을 제공한다.

IV. 성립요건

- 자기구속의 원칙이 성립하여 행정청을 구속하기 위해서는 다음과 같은 요건이 모두 충족되어야 한다.

1. 재량행위의 영역일 것

- 자기구속의 원칙은 법률이 행정청에게 판단의 여지를 부여한 재량행위의 영역에서만 성립한다. 법규에 따라 기속되는 기속행위의 영역에서는 법규 자체가 평등을 요구하므로 별도로 자기구속의 원칙을 원용할 필요성이 없다.

2. 동종의 사안일 것

- 선례가 된 사안과 후행 처분의 대상 사안이 본질적으로 동일하거나 유사해야 한다. 동일성이나 유사성은 처분의 근거 법규, 사실 관계 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 본질적으로 다른 사안에 대해서는 행정청이 다르게 처분할 수 있으며, 이는 평등의 원칙에 위반되지 않는다.

3. 동일한 행정청일 것

- 선례를 형성하거나 준칙을 제정한 행정청과 후행 처분을 하는 행정청이 동일하거나 동일한 행정주체에 속해야 한다. 판례는 하급 행정청이 상급 행정청의 재량 준칙을 따르지 않은 경우에도 위법하다고 판단하는 등 행정조직 전체의 통일성을 고려한다.

4. 선례의 존재 여부

- 자기구속의 원칙이 성립하기 위해서는 이미 확립된 관행(선례) 또는 재량 준칙의 존재가 필요하다.

(1) 재량 준칙의 공표

- 행정청이 재량 준칙을 제정하여 공표한 경우에는 반복된 선례가 없더라도 즉시 자기구속의 원칙이 발생한다는 것이 판례의 입장이다.

(2) 반복된 선례의 존재

- 재량 준칙이 없더라도 동일하거나 유사한 사안에 대해 반복적으로 동일한 처분을 하여 행정 관행이 성립한 경우, 이 선례가 자기구속의 원칙을 발생시킨다.

V. 한계

- 자기구속의 원칙은 법치 행정의 원리에 종속되므로, 행정의 합법성을 희생시키면서까지 무제한적으로 적용될 수는 없다.

1. 선례가 위법인 경우

- 행정청이 과거에 위법한 선례를 형성하였거나, 위법한 재량 준칙을 제정하였더라도, 행정청은 그 위법한 선례에 구속되지 않는다. 위법에는 평등이 없다는 원칙에 따라, 행정청은 법률에 적합한 처분을 해야 한다. 만약 위법한 선례에 구속된다면 법치 행정의 원리가 훼손되기 때문이다. 다만, 선례가 경미한 위법이거나 위법성이 명백하지 않은 경우에는 신뢰보호의 관점에서 제한적으로 구속력이 인정될 여지가 있다.

2. 중대한 사정변경이 있는 경우

- 선례가 형성된 이후에 법률이 개정되거나 사회·경제적 사정에 중대한 변경이 발생하여 종전의 기준을 유지하는 것이 공익에 현저히 반하는 경우에는 행정청은 자기구속에서 벗어나 새로운 처분 기준을 적용할 수 있다. 이 경우 행정청은 사정 변경의 정당성을 입증해야 한다.

VI. 위반의 효과

- 행정주체가 자기구속의 원칙을 위반하여 합리적인 이유 없이 선례나 재량 준칙과 다른 처분을 한 경우, 그 후행 처분은 위법하게 된다.

1. 재량권의 일탈·남용

- 자기구속의 원칙 위반은 재량권을 부여받은 행위에서 재량권의 한계를 벗어난 것(일탈 또는 남용)으로 간주된다. 이는 평등의 원칙 위반으로 직결된다.

2. 행정 처분의 취소

- 위법하게 된 후행 처분은 행정심판이나 행정소송(취소소송)을 통해 취소될 수 있다. 법원은 행정청이 자가 설정한 기준을 합리적인 이유 없이 위반했는지 여부를 심사하여 위법성을 확인한다.

3. 국가 배상 책임

- 자기구속의 원칙을 위반한 위법한 행정작용으로 국민이 손해를 입은 경우, 국가배상법에 따른 손해 배상 책임이 발생할 수 있다.

VI. 결론

- 자기구속의 원칙은 재량행위 영역에서 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙을 근거로 하여 행정청이 스스로 정한 기준(재량 준칙)이나 반복된 관행(선례)에 구속되도록 하는 핵심 원칙이다. 이는 재량 준칙의 법규 전환 규범으로서 중요한 역할을 하며, 행정의 공정성과 예측 가능성을 보장한다. 다만, 선례가 위법하거나 중대한 사정 변경이 있는 경우에는 법치 행정의 원리상 적용이 제한되며, 원칙을 위반한 처분은 재량권의 일탈·남용으로 위법하여 취소의 대상이 된다.

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제5절 부당결부금지의 원칙>

I. 개설

1. 개념

- 부당결부금지의 원칙은 행정주체가 행정작용을 함에 있어 실질적인 관련성이 없는 사항을 서로 결부시켜 상대방인 국민에게 법률상 의무가 없는 부당한 부담을 지우거나 강요해서는 안 된다는 행정법의 일반 원칙이다. 이는 행정청이 자신의 우월적 지위를 남용하여 공행정의 목적과 무관한 사익을 추구하거나, 국민에게 수익적 행위를 대가로 부당한 반대 급부를 요구하는 것을 금지한다. 즉, 특정한 공권력 행사의 조건이나 내용이 그 권력 행사의 목적 또는 법적 근거와 관련성이 있어야 한다는 제한 원칙이다. 이 원칙은 행정의 합목적성을 넘어 합법성과 공정성을 확보하는 데 중요한 기능을 수행한다.

2. 성질

- 부당결부금지의 원칙은 행정청의 권한 행사가 법률의 목적 범위 내에서 이루어져야 한다는 법률 적합성의 원칙을 구체화한 것이다. 특히, 이는 비례의 원칙(과잉 금지의 원칙)과 밀접한 관계를 갖는다. 부당하게 결부된 부담을 통해 사익을 침해하는 것은 목적과 수단 사이에 합리적인 비례 관계를 결여하는 경우가 많기 때문이다. 따라서 재량권을 행사하는 영역에서 행정청의 자의적인 권한 남용을 통제하는 헌법적 효력을 가진 일반 원칙으로 인정된다. 이는 공익의 추구 과정에서 국민의 사적 자유를 부당하게 침해하지 않도록 국가 권력을 구속하는 기능을 한다.

3. 법적 근거

(1) 헌법적 근거

- 부당결부금지의 원칙은 헌법에 명문으로 규정되어 있지 않다. 그러나 이는 법치국가 원리 중 권력 남용 금지의 원칙과 헌법 제37조 제2항의 기본권 제한의 한계를 규정한 비례의 원칙에서 파생된다. 국가의 공권력 행사는 법률이 부여한 권한과 목적의 범위 내에서만 정당성을 가지며, 그 목적과 무관한 사익을 강제하는 것은 헌법이 용인하지 않는다.

(2) 개별법적 근거

- 행정기본법 제13조는 행정청은 행정작용을 할 때 상대방에게 해당 행정작용과 실질적인 관련이 없는 의무를 부과해서는 아니 된다.고 규정하여, 부당결부금지의 원칙의 명시적인 법적 근거를 마련한다. 이로써 이 원칙은 행정청을 직접적으로 구속하는 법적 효력을 가진다.

II. 성립요건

- 부당결부금지의 원칙이 적용되어 행정작용의 위법성이 인정되기 위해서는 다음과 같은 요건이 모두 충족되어야 한다.

1. 두 개 이상의 행정작용 또는 요소의 존재

- 행정청의 하나의 행정작용 내에서 서로 다른 두 가지 사항이 결부되거나, 두 가지 이상의 행정작용이 연계되어야 한다. 일반적으로 수익적 행정 처분(예 : 영업 허가, 건축 허가)과 상대방에게 불리한 의무 부과(예 : 부담, 기부 채납 요구)가 결합되는 형태로 나타난다. 이 결부는 명시적이거나 묵시적일 수 있다.

2. 결부된 사항 사이에 합리적 관련성이 없을 것

- 결부된 두 가지 사항이 내용적 또는 기능적으로 합리적인 관련성이 없어야 한다. 합리적 관련성의 유무는 원칙 위반을 판단하는 가장 중요한 요건이다.

(1) 내용적 관련성

- 결부된 두 사항이 법률에 의하여 동일한 목적을 위해 규율되거나, 사실적으로 직접적인 원인·결과 관계에 있어야 내용적 관련성이 인정된다. 예를 들어 건축 행위로 발생이 예상되는 인근 지역의 환경 오염을 방지하기 위한 시설 설치 부담은 내용적 관련성이 인정된다.

(2) 기능적 관련성

- 두 사항이 직접적인 내용적 관련성은 없더라도, 주된 행정작용의 법적 목적을 달성하는 데 간접적으로 기여하는 기능적 관련성이 인정될 수 있다. 그러나 부당결부금지의 원칙은 이 기능적 관련성이 법률상 또는 사실상 현저히 미약하거나 전혀 없는 경우에 위반된다. 행정청이 자신의 다른 행정 목적을 달성하기 위해 특정 허가를 수단으로 활용하는 경우, 이는 기능적 관련성이 결여된 것으로 간주된다.

3. 결부된 사항의 하나를 다른 사항의 조건으로 강제할 것

- 행정청이 수익적 행정작용(예 : 인가, 허가)을 조건으로, 상대방에게 법률상 의무가 없는 다른 사항을 강요하거나 의무로 부과하여 상대방의 자유로운 의사를 억압해야 한다. 행정청이 자신의 권한을 이용하여 상대방에게 불이익을 주는 방식으로 부당하게 요구 사항을 관철시키려는 압력이 수반되어야 한다. 단순한 제의나 자발적 합의는 원칙 위반으로 보기 어렵다.

III. 적용 범위

- 부당결부금지의 원칙은 행정주체의 권한 행사가 수반되는 모든 영역에서 적용된다.

1. 공법상 계약

- 공법상 계약은 공법적 효과의 발생을 목적으로 하는 행정주체와 사인 간의 합의이다. 행정주체가 계약 체결을 조건으로, 계약 목적이나 관련 법규와 실질적 관련성이 없는 사항(예 : 공익 재단 기부, 특정 물품 구매)을 계약 내용에 포함시키도록 강요하는 것은 부당결부금지의 원칙에 위반되어 위법하다. 이는 행정청이 우월적 지위를 이용하여 자유로운 의사를 훼손하는 행위이기 때문이다.

2. 부관

- 부관, 특히 부담은 주된 행정 행위의 효력을 제한하거나 상대방에게 의무를 부과하는 요소이다. 부담의 적법성은 주된 행정 행위와 부담 사이에 실질적 관련성이 있는지 여부에 따라 판단되며, 이는 곧 부당결부금지의 원칙의 적용 문제이다. 건축 허가의 조건으로 허가 대상 토지와 전혀 무관한 다른 지역의 도로를 개설하도록 하는 부담을 부과한다면, 부당 결부에 위반되어 위법하게 된다. 법원은 부담이 주된 행위의 목적 달성에 필요하고 합리적인 범위 내에서만 적법성을 인정한다.

3. 공급거부·관허사업의 제한 등 행정의 실효성 확보 수단

- 행정상 의무 이행을 강제하기 위해 사용되는 공공 서비스의 공급 거부나 관허 사업에 대한 제한과 같은 간접적 강제 수단에서도 부당결부금지의 원칙이 적용된다. 국민이 법적 의무(벌금, 과태료)를 이행하지 않는다는 이유만으로, 그 의무와 전혀 관련 없는 공공 서비스(예 : 전기, 가스, 수도)의 공급을 거부하거나 기존의 관허 사업에 대한 허가를 철회하는 것은 부당한 결부에 해당하여 위법하다. 행정청은 법률이 정한 직접적인 강제 수단이나 관련된 제재를 사용해야 한다.

4. 관련 판례

- 판례는 주택 사업 계획 승인을 조건으로 주택 사업과 직접 관련이 없는 공공시설 부지를 행정청에 기부 채납하도록 요구하는 부담을 부과한 사안에서, 사업 계획의 승인으로 인해 발생하는 공익적 폐해에 대한 보충의 범위를 넘어서는 부담의 부과는 부당결부금지의 원칙에 위반되어 위법하다고 판단하였다. 또한, 무허가 건물의 철거 의무와 철거 대상이 아닌 다른 건물에 대한 사용 승인을 연계하여 자진 철거를 조건으로 사용 승인을 내어주는 행위는

부당한 결부로서 위법하다는 취지의 판단을 내린 바 있다. 이러한 판례는 부담의 목적과 수단 사이의 내재적 관련성을 엄격하게 요구함으로써 행정청의 결부를 통제한다.

IV. 위반의 효과

- 행정작용이 부당결부금지의 원칙을 위반한 경우, 그 행정작용은 위법하게 된다.

1. 행정 처분의 위법성

- 부당 결부는 비례의 원칙 위반의 일종으로서 재량권의 일탈 또는 남용에 해당하며, 후행 처분의 위법 사유가 된다. 따라서 부당 결부가 있는 행정 처분은 취소소송을 통해 취소될 수 있다.

2. 부관의 부분 취소 또는 무효

- 수익적 행정 처분(허가)에 부과된 부담(부관)이 부당결부금지의 원칙에 위반된 경우, 부담은 위법하게 된다. 이 경우 원칙적으로 위법한 부담만이 취소소송을 통해 취소되고 주된 처분은 유효하게 남는다. 다만, 위법한 부담이 없었더라면 주된 처분을 하지 않았을 것이라는 행정청의 의사가 명백하여 가분성이 인정되지 않는다면, 주된 처분 전체가 위법하여 취소될 수 있다. 공법상 계약에서 부당 결부된 조건은 무효로 판단된다.

3. 국가 배상 책임

- 행정청의 부당 결부로 인해 국민이 손해를 입은 경우, 부당 결부된 행정작용이 위법하므로 국가배상법에 따른 손해 배상 책임이 발생할 수 있다.

V. 결론

- 부당결부금지의 원칙은 행정주체가 행정 권한을 본래의 목적과 실질적인 관련성이 없는 사익 추구의 수단으로 활용하는 것을 방지하는 헌법적 효력을 가진 핵심 원칙이다. 수익적 행위와 침익적 의무를 결부시킬 때 두 사항 사이에 내용적·기능적인 합리적 관련성이 없다면, 이는 원칙에 위반되어 위법하게 된다. 이 원칙은 부관의 한계를 설정하고 재량권 남용을 통제함으로써 행정의 공정성과 합법성을 확보하는 데 결정적인 역할을 한다.

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제6절 기타 제 원칙>

I. 적법절차의 원칙

1. 의의

- 적법절차의 원칙은 국가의 모든 공권력 작용이 실체적 내용뿐만 아니라 형식적 절차에 있어서도 법률에 적합해야 한다는 헌법적 원칙이다. 헌법 제12조 제1항과 제3항에 명시적으로 근거하며, 원래는 형사 사법 절차에 적용되었으나, 현대에는 행정 영역을 포함한 모든 국가 작용에 확대 적용된다. 행정법상 적법절차의 원칙은 행정주체가 국민의 권리를 제한하거나, 의무를 부과하는 침익적 행정작용을 할 때 적절하고 합리적인 절차를 거쳐야 함을 의미한다. 이는 행정의 공정성, 투명성, 신뢰성을 확보하고 행정 처분의 정당성을 높이는 데 기여한다.

2. 내용

- 주요 내용은 다음과 같다.

(1) 사전 통지 의무

- 행정청은 상대방에게 권리를 제한하거나, 의무를 부과하는 처분을 할 때, 처분의 제목, 처분하려는 원인이 되는 사실, 처분의 내용 및 법적 근거 등을 당사자에게 미리 통지해야 한다.

(2) 의견 청취 기회 부여

- 당사자에게 처분에 대해 의견을 제시할 기회(청문, 공청회, 의견 제출 등)를 충분히 부여해야 한다. 이는 행정청의 일방적 판단을 방지하고 신중한 결정을 내리도록 유도한다.

(3) 이유 제시 의무

- 행정청은 처분을 할 때 당사자가 어떤 근거와 이유로 처분이 내려졌는지를 명확하게 알 수 있도록 그 이유를 제시해야 한다. 이는 처분의 불복을 용이하게 한다.

II. 신의성실의 원칙

1. 의의

- 신의성실의 원칙은 모든 법 관계의 당사자가 상대방의 정당한 신뢰를 배신하지 않고 사회 공동체의 일원으로서 신의에 따라 성실하게 행동해야 한다는 법의 일반 원칙이다. 이는 민법 제2조 제1항에서 가장 명확히 규정하고 있으며, 공법 영역에서도 행정청과 국민 간의 관계에 적용된다. 행정청은 국민과의 관계에서 성실하게 직무를 수행하고, 국민은 행정청에 협력해야 하는 의무를 포괄적으로 함축한다.

2. 근거

- 신의성실의 원칙의 근거는 법치국가 원리와 행정의 자기구속의 원칙, 신뢰 보호의 원칙과 밀접하게 연결된다. 특히 행정의 신뢰성과 투명성을 확보해야 한다는 요구에 기초한다. 국민이 공권력에 대해 기대하는 정당한 신뢰를 보호함으로써, 행정청의 예측 가능성이 떨어지는 행위나 자의적인 태도 변화를 금지한다. 행정절차법 제4조 제2항은 행정청은 법령등의 해석 또는 행정청의 관행이 일반적으로 국민들에게 받아들여진 때에는 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우를 제외하고는 새로운 해석 또는 관행에 의하여 소급하여 불리하게 처리하여서는 아니된다.고 규정하여 신의성실의 원칙을 구체화하고 법적 근거를 제시한다.

3. 주요 법리

- 판례는 행정 영역에서 신의성실의 원칙을 두 가지 주요 법리로 구체화하여 적용한다.

(1) 신뢰 보호의 법리

- 행정청이 적법하게 공적 견해를 표명한 경우, 그 표명에 대한 국민의 정당한 신뢰를 보호해야 하며, 이에 반하는 처분은 신의칙에 위반되어 위법하게 된다. 예를 들어 폐기물 처리업에 대한 적정 통보를 받은 자가 그 통보를 신뢰하여 대규모 시설을 설치하였음에도, 행정청이 공익상 이유 없이 사업 부지가 부적합하다는 이유로 허가를 거부하는 것은 위법하다.

(2) 실권의 법리(실효의 원칙)

- 행정청이 자신의 권한을 장기간 행사하지 않아 상대방이 더 이상 그 권한이 행사되지 않을 것이라고 정당하게 신뢰한 경우, 뒤늦게 권한을 행사하여 상대방에게 불이익을 주는 것은 신의성실의 원칙에 위반되어 허용되지 않는다. 예를 들어 위반 건축물에 대해 장기간 시정 명령이나 철거 명령을 내리지 않다가, 상대방이 건물을 매입한 이후에 갑자기 철거 명령을 내리는 것은 실권의 법리에 따라 제한될 수 있다. 그러나 판례는 실권의 법리를 엄격하게 적용하여, 단순한 불행사만으로는 성립하지 않고 상대방의 신뢰와 공익의 침해 정도를 종합적으로 고려한다.

III. 권리남용금지의 원칙

1. 의의

- 권리남용금지의 원칙은 권리자가 자신의 권리를 행사함에 있어 사회 질서를 위반하거나 사회적 한계를 일탈하여 행사하는 것을 금지하는 법 원칙이다. 이는 민법 제2조 제2항에 명시되어 있으며, 행정법 관계에도 유추 적용된다. 권리 남용은 권리 행사의 형식적 요건은 갖추었으나, 실질적인 목적이 부당하거나 정당한 이유 없이 오직 상대방에게 손해를 가할 목적으로 권리를 행사하는 경우에 성립한다.

2. 적용

- 행정법 영역에서는 크게 두 가지 측면에서 적용된다.

(1) 행정청의 권한 행사 통제

- 행정청이 자신에게 부여된 공권력을 행정 목적을 벗어나 자의적으로 행사하는 것을 통제하는 기준으로 적용된다. 이는 재량권의 남용을 판단하는 기준의 하나가 된다. 예를 들어 오직 특정 개인을 괴롭힐 목적으로 사소한 법규 위반에 대해 극도의 불이익 처분을 내리는 경우가 이에 해당한다.

(2) 사인의 공법상 권리 행사 제한

- 국민이 행정청에 대해 가지고 있는 공법상 권리(정보 공개 청구권, 민원 신청권)를 행사함에 있어, 오직 행정 기관의 업무를 방해할 목적으로 반복하거나 남용하는 것을 제한하는 근거가 된다. 판례는 권리 행사가 권리의 사회적 기능을 일탈하였는지 여부를 기준으로 판단한다.

IV. 결론

- 적법절차의 원칙, 신의성실의 원칙, 권리남용금지의 원칙은 행정법의 일반 원칙으로서 헌법의 법치국가 원리를 구체화한다. 적법절차는 행정작용의 형식적 절차의 정당성을, 신의성실은 행정청과 국민 간의 신뢰를 바탕으로 한 실질적 공정성을, 권리남용금지는 행정청과 사인의 권한 행사에 내재된 사회적 한계를 확보한다. 이들 원칙은 법치 행정의 기본 질서를 유지하고 국민의 권익을 보호하는 데 필수적인 기초 규범이다.

<입문-제4장 행정법 관계.제1절 행정법 관계의 서설>

I. 행정법 관계의 의의와 특성

1. 행정법 관계의 개념

- 행정법 관계란 행정법에 의해 규율되는 법률 관계를 총칭하는 개념이다. 이는 행정주체와 국민 간의 관계를 주된 내용으로 하며, 공익의 실현을 목표로 하는 행정작용을 매개로 형성된다. 국가와 지방자치단체 등의 행정주체가 국민에게 권력적인 지위에서 명령하거나, 혹은 비권력적인 지위에서 협력적인 행위를 하는 모든 관계가 포함된다. 행정법 관계는 사법 관계와 근본적으로 구별되는 공법적 특성을 지닌다.

2. 행정법 관계의 정의

- 행정법 관계는 공법의 규율을 받는 법률 관계로서, 행정주체의 공권력 행사 또는 사인의 공법상 의무 이행 등 행정목적 달성을 위한 법률적 효과를 발생시킨다. 이는 국가의 통치 작용 중 행정이라는 특수한 영역에서 발생하는 권리와 의무의 집합이다. 행정법 관계의 존재는 행정소송이나 행정심판 등 공법상 구제 절차의 적용을 결정하는 근거가 된다.

3. 행정법 관계의 공법적 특성

- 행정법 관계는 사법 관계와 달리 일방적인 우월성과 복종성이 내포된 공법적 특성을 가진다.

(1) 권한과 의무의 주체

- 행정주체는 공익을 실현하기 위해 우월적인 권한(공권력)을 행사하며, 국민은 원칙적으로 이에 복종할 의무를 진다.

(2) 특수한 공법적 효력

- 공권력과 집행력이라는 특수한 효력이 인정된다.

① 공권력

- 일단 행정 행위가 발생하면 비록 흠결이 있더라도 권한이 있는 기관에 의해 취소되기 전까지 유효하게 통용되는 힘을 의미한다.

② 집행력

- 행정주체가 법적 절차를 거쳐 스스로 강제할 수 있는 힘을 의미한다.

(3) 법적 효력

- 불가쟁력과 불가변력 등 행정의 특수성에서 비롯되는 법적 효력이 발생한다.

II. 행정법 관계의 당사자

1. 행정법 관계의 기본 당사자

- 행정법 관계는 일반적으로 행정주체와 사인이라는 두 축을 중심으로 형성되며, 각 당사자는 공법상 권리와 의무를 가지고 서로 대립하거나 협력한다.

2. 행정주체

- 행정주체는 행정작용의 주체로서 자신의 이름과 책임으로 공법상 권리를 가지고 의무를 부담하는 법인 또는 기관이다. 국가와 지방자치단체가 가장 대표적이며, 공공 단체(한국 토지 주택 공사, 공립 대학) 및 공무 수탁 사인(운전 면허 시험 관리 기관)도 법률이 정하는 바에 따라 행정주체가 될 수 있다. 이들은 공권력을 행사하는 주체로서 관계의 일방에서 우월적인 지위를 차지한다.

3. 사인(국민)

- 사인은 행정법 관계에서 행정주체의 상대방으로서 권리를 향유하고 의무를 부담하는 자이다. 국민은 행정주체의 권력 행사에 대해 방어적인 공권(자유권적 기본권)을 가지며, 때로는 급부를 요구할 수 있는 공권(사회권적 기본권)을 가진다. 국민에게 부과되는 공법상 의무(납세 의무, 병역 의무)의 이행도 행정법 관계의 중요한 내용을 이룬다.

III. 행정법 관계의 내용 : 공법상 권리와 의무

1. 행정법 관계의 내용 개요

- 행정법 관계의 내용은 행정주체와 사인이 서로 가지고 대립하는 공권(공법상 권리)과 공의무(공법상 의무)이다.

1. 공권(공법상 권리)

- 공권은 행정법 관계에서 행정주체나 다른 사인에 대해 특정한 행위나 급부를 요구하거나 특정한 법적 이익을 향유할 수 있는 힘이다. 공권은 주로 국민이 행정주체에 대해 가지는 권리를 의미하며, 자유권적 공권(침해 배제 청구권, 방어권)과 수익적 공권(급부 청구권, 행정 개입 청구권)으로 나뉜다. 공권이 성립하기 위해서는 법규가 국민에게 이익을 부여하는 규정이어야 하며, 동시에 개인적이고 구체적인 이익으로 보호될 수 있도록 되어 있어야 한다.

2. 공의무(공법상 의무)

- 공의무는 행정법 관계에서 행정주체나 다른 사인에 대해 특정한 행위를 하거나 하지 않아야 할 법적 구속이다. 사인이 행정주체에 대해 가지는 대표적인 공의무로는 납세 의무, 병역 의무, 법규 준수 의무 등이 있다. 행정주체도 국민에 대해 법규에 따른 행정처분 의무, 정보 공개 의무 등의 공의무를 부담한다.

IV. 행정법 관계의 분류

- 행정법 관계는 행정주체가 어떤 지위에서 활동하는지에 따라 크게 권력 관계와 비권력 관계로 분류된다.

1. 권력 관계와 비권력 관계

- 권력 관계는 행정주체가 국민에 대해 공권력을 행사하는 우월적 지위에 있으면서 형성되는 관계이다. 행정처분(허가, 하명, 면제 등)과 행정 강제 등이 대표적이며, 강제성과 단일성이 특징이다. 이 관계에서 발생하는 분쟁은 행정소송의 대상이 된다. 비권력 관계는 행정주체가 국민과 대등한 지위에서 활동하는 관계이다. 이는 다시 공법상 계약, 행정 지도, 공법상 사실 행위 등을 포함하는 관리 관계와 공물 이용 관계 등을 포함하는 국고 관계로 세분되기도 한다. 관리 관계는 공법의 규율을 받는 대등 관계이며, 국고 관계는 순수하게 사법의 규율을 받는 행정주체의 경제적 활동을 포함한다.

2. 사법 관계로의 전환 (행정법 관계의 사법화)

- 현대 행정의 영역이 확대되고 복잡해짐에 따라, 행정주체가 공익 목적을 달성하기위한 경우에도 사법의 형식을 빌려 활동하는 경우가 증가하고 있다. 예를 들어 국가가 특정 물품을 구매하거나 공유 재산을 대부하는 행위 등은 비록 행정목적과 관련되더라도 사법 관계로 취급되어 민사 소송의 대상이 된다. 행정법 관계가 사법적 규율을 받는 영역으로 전환되는 현상은 행정의 효율성을 높이는 동시에, 공법적 통제의 필요성을 여전히 남긴다. 사법 관계로 전환된 영역이라도 기본권 침해와 관련된 문제가 발생하면 헌법의 일반 원칙은 계속 적용된다.

V. 결론

- 행정법 관계는 행정주체의 우월적 지위와 공권력의 행사라는 특성을 바탕으로 공권과 공의무를 내용으로 한다. 특히, 권력 관계에서 나타나는 공정력, 집행력 등의 특수한 효력은 일반 사법 관계와 구별되는 행정법 고유의 영역을 형성한다. 현대 행정은 비권력적 관계의 비중이 커지면서 사법적 요소가 증가하고 있으나, 근본은 공익 실현을 목표로 한다는 점에서 공법적 통제가 필수적이다. 행정법 관계에 대한 명확한 이해는 향후 개별 행정작용과 이에 대한 구제 절차를 학습하는 데 있어 결정적인 준거점이 된다.

<입문-제4장 행정법 관계.제2절 행정법 관계의 당사자>

I. 행정기관

1. 의의

- 행정기관은 행정주체의 의사를 결정하고 대외적으로 표시하거나 결정된 의사를 집행하는 국가 또는 공공단체의 내부적 구성 요소를 말한다. 행정기관은 법인격이 없으므로 스스로 권리와 의무를 가지지 못하며, 오직 행정주체의 이름과 책임 하에 법률이 정한 행정 권한만을 행사할 수 있다. 따라서 행정기관이 행한 행위의 법적 효과는 모두 행정주체에게 귀속된다. 행정기관의 권한 행사는 법치 행정의 원칙에 따라 엄격히 통제되며, 권한의 위임, 위탁, 대리 등의 형태로 그 권한의 행사 주체가 달라질 수 있다. 행정기관은 기능적 도구로서 행정작용의 합법성 확보에 핵심적인 역할을 수행한다.

2. 행정기관의 종류

- 행정기관은 그 기능과 권한의 성격에 따라 다양하게 분류되며, 이러한 구분은 행정조직의 내부적 질서와 책임 분배를 이해하는 데 중요한 기초가 된다.

(1) 행정청

- 행정청은 행정기관 중에서도 특히 행정주체의 의사를 대외적으로 결정하고 표시할 수 있는 권한을 가진 기관을 지칭하며, 국민의 권리와 의무에 직접적인 영향을 미치는 행정 처분 등의 주체가 된다.

(2) 의사결정 기관

- 의사결정 기관은 행정주체의 최종적인 의사를 형성하고 결정하는 기관을 말한다. 이는 대통령, 국무총리, 각부 장관, 행정청인 지방자치단체장 등이 대표적이다. 이들 중 대외적으로 자신들의 의사를 표시할 수 있는 권한을 가진 기관만이 행정청으로 간주된다. 행정 처분과 같은 중요한 법적 효과를 수반하는 행위는 이러한 의사결정 기관에 의해 이루어진다. 의사결정 기관의 권한 행사에는 재량의 여지가 포함될 수 있으며, 이는 법률유보의 원칙에 따라 통제된다.

(3) 집행 기관

- 집행 기관은 의사결정 기관에 의해 결정된 행정주체의 의사를 현장에서 사실적으로 실현하는 기관을 말한다. 예를 들어 경찰관, 소방관, 세무 공무원 등 일선 공무원들이 수행하는 현장 활동이 이에 해당한다. 집행 기관의 활동은 주로 단순 집행 행위, 사실 행위, 강제 집행 등의 형태로 나타나며, 이들 행위는 원칙적으로 대외적 구속력이 없다. 다만, 집행 기관이 법률에 의해 특정 권한을 부여받아 독자적인 결정을 내릴 경우에는 예외적으로 행정청의 지위를 가질 수도 있다. 집행 기관의 행위는 국민의 일상생활과 가장 직결되며, 비례 원칙 등의 적용을 통해 권한의 남용이 방지된다.

(4) 보조 기관, 자문 기관, 심의 의결 기관

- 보조 기관은 의사결정 기관 및 집행 기관의 직무 수행을 기술적 또는 행정적으로 지원하는 기관이다. 차관, 실·국장, 과장 등의 직위가 이에 속하며, 이들은 상급자를 위해 사전 조사, 기획, 연구 등의 내부 업무를 담당한다. 자문 기관은 주요 정책 결정에 앞서 전문적 지식을 바탕으로 행정청에게 조언이나 의견을 제시하는 기관이다. 예를 들어 각종 위원회 등이 있다. 심의 의결 기관은 법률이 정한 바에 따라 독립적인 심의 및 의결 권한을 가지며, 행정청의 결정을 일정 부분 구속할 수 있는 기관이다. 예를 들어 행정심판위원회 등이 있으며, 이들의 결정은 준사법적 성격을 가진다.

II. 행정주체

1. 의의

- 행정주체는 행정법 관계에서 자신의 이름과 책임 하에 공법상 권리를 가지고 의무를 부담하는 법적 실체를 의미한다. 행정기관이 수행한 행정작용의 법적 효과와 책임이 궁극적으로 귀속되는 당사자이다. 국민의 입장에서 볼 때 행정소송의 피고 적격자가 되며, 위법한 공권력 행사에 대해 국가 배상이나 손실 보상 책임을 부담하는 주체이다. 행정주체는 법률에 의해 부여된 공법상 법인격을 가진다. 현대 행정에서 행정주체는 국가 이외에도 그 범위가 확대되고 있으며, 이는 행정의 다양성과 전문화에 대응하기 위함이다. 행정주체의 존재는 행정법 관계의 법적 안정성과 책임 원칙을 구현하는 핵심 요소이다.

2. 행정주체의 종류

- 행정주체는 법적 성격 및 활동 범위에 따라 크게 네 가지로 구분된다. 각 주체는 법률에 따라 제한되거나 특정된 범위의 권능만을 행사할 수 있다.

(1) 국가

- 국가는 가장 포괄적인 행정주체로서, 모든 공법상 권리 능력의 원천이다. 국가는 대통령, 국회, 법원 등의 모든 국가 기관을 포함하는 최고의 법적 실체이며, 전국적인 행정 사무를 총괄한다. 국가가 행한 위법한 행정작용에 대해서는 국가배상법에 따른 책임을 지며, 행정소송 등의 피고로서 당사자가 된다. 국가의 행정 활동은 헌법과 법률에 따라 가장 엄격한 통제를 받는다.

(2) 지방자치단체

- 지방자치단체는 지방자치법 등 개별 법률에 의해 법인격이 인정된 지역적인 행정주체이다. 특별시, 광역시, 도 등의 광역자치단체와 시, 군, 구 등의 기초자치단체로 구분된다. 이들은 법령의 범위 내에서 자신들의 고유 사무(자치 사무)를 처리할 권한을 가지며, 그 사무에 대한 책임을 진다. 지방자치단체장은 대외적인 행정청의 역할을 수행하며, 소속 기관을 통해 행정 업무를 처리한다. 자치 단체의 재산은 공유 재산으로서 공법상 보호를 받는다.

(3) 공공단체

- 공공단체는 국가나 지방자치단체 이외에 특정 공익 목적을 위해 설립된 공법상 법인을 총칭한다. 영조물 법인(국립대학, 공사 등), 공법상 사단 법인(농협, 수협 등), 공법상 재단 법인 등의 형태로 존재한다. 이들은 설립 목적 및 법률이 부여한 권한의 범위 내에서만 행정주체로서의 지위를 가지며, 그 범위를 넘어서는 행위는 사법상 행위로 간주될 수 있다. 공공단체가 공법상 권한을 행사하여 국민에게 손해를 입힌 경우에는 공무수탁을 전제로 국가배상법이 적용될 여지가 있다.

(4) 공무수탁사인

- 공무수탁사인은 원래 공법상 법인격이 없는 사인이지만, 법률 또는 행정주체의 처분(위탁)에 의해 특정 공무를 위임받아 자신의 이름으로 처리하는 자이다. 예를 들어 버스 운수 사업자에 대한 여객 운송 업무의 위탁, 사립 학교의 학적 관리 등이 있다. 이들은 수탁받은 공무의 범위 내에서 행정주체의 지위를 가지며, 공권력을 행사하는 행정청의 역할을 수행한다. 판례는 공무수탁사인이 행한 처분에 대해 행정소송의 피고 적격을 인정한다. 이들의 행위가 위법할 경우 국가 배상 책임은 원칙적으로 위탁 한 행정주체에게 귀속된다.

III. 행정객체

1. 의의

- 행정객체는 행정주체의 행정작용에 의해 직접적으로 법적 효과 또는 영향을 받는 상대방을 의미한다. 행정법 관계의 대부분에서는 사인(개인 또는 민간 법인)이 행정객체의 지위를 차지한다. 행정객체는 행정주체에 대해 공법상 의무를 부담하거나, 공법상 권리를 요구할 수 있는 상대적 지위를 갖는다. 행정작용의 대상인 물건이나 재산 자체는 법적 주체가 아니므로 엄밀한 의미의 행정객체가 될 수 없으나, 그 물건에 대한 소유권자 등 권리자가 최종

적인 법적 효과의 대상이 된다는 점에서 실질적인 객체의 지위를 갖는다. 행정객체는 행정주체의 일방적인 권력 행사 하에 놓이기도 하지만, 동시에 법치 행정의 원칙에 따라 권리 보호를 받는 가장 중요한 대상이다.

2. 행정기관의 경우

- 행정기관은 자체적으로는 법적 권리 능력이 없고 행정주체의 도구에 불과하므로, 대외적인 행정법 관계에서는 행정객체가 되지 않는다. 그러나 행정조직의 내부 관계에서는 행정기관이 상급 기관의 지휘 또는 통제의 대상이 된다는 측면에서 제한적인 의미의 객체 지위를 가진다.

(1) 지휘 · 감독의 대상

- 하급 행정기관은 상급 행정기관의 직무상 명령이나 지휘 · 감독의 대상이 된다. 상급 기관이 하급 기관에 대해 내리는 훈령, 지시, 예규 등의 내부적 행위는 하급 기관의 업무 수행을 제한하거나 특정 방향으로 유도한다. 이러한 관계에서 하급 기관은 상급 기관의 권한 행사에 대해 복종해야 할 의무를 부담하는 객체적 지위에 놓인다. 다만, 이러한 내부적 관계는 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 원칙적으로 행정소송의 대상이 되는 공법상 분쟁 관계로 발전하지 않는다.

(2) 권한 다툼의 대상

- 예외적으로 서로 다른 행정기관 간에 권한의 범위를 둘러싼 다툼이 발생하는 경우, 이들 기관은 헌법재판소의 권한 쟁의 심판이나 상급 기관의 권한 분쟁 조정의 대상이 된다. 이러한 맥락에서 행정기관은 분쟁 해결 절차의 객체적 지위를 가진다. 그러나 이 경우에도 행정기관 자체의 권리 의무가 다 투여되는 것이 아니라, 행정주체가 가지는 공권력을 어떤 기관이 적법하게 행사할 수 있는지가 핵심 쟁점이다. 따라서 행정기관의 객체 지위는 행정주체의 대외적 행정작용을 받는 사인과는 본질적으로 구별되는 제한적 지위로 이해해야 한다.

IV. 결론

- 행정법 관계의 당사자는 행정주체(권리 · 의무의 발생 · 변경 · 소멸의 귀속 주체), 행정기관(의사 결정 및 집행 도구), 행정객체(법적 효과의 수령자)라는 삼각 구도로 구성된다. 이들 간의 관계에 대한 명확한 이해는 행정 법규의 적용, 행정작용의 합법성 여부 판단, 그리고 궁극적으로 위법한 행정작용에 대한 권리 구제 절차를 확립하는 데 필수적이다. 특히 행정주체와 행정기관의 법적 구별은 행정소송 시 피고 적격을 결정하고 국가 배상 책임을 정하는 중요한 기준이 된다. 현대 행정의 특성상 공무원수탁사인과 같은 다양한 행정주체가 등장하고 있으며, 이는 국민의 법적 안정성을 위해 행정법 관계의 당사자 범위에 대한 지속적인 학문적 연구와 판례의 축적을 요구한다. 이러한 권능과 책임의 구조를 통해 행정법은 공익 실현과 국민 권리 보호의 균형을 도모한다.

<입문-제4장 행정법 관계.제3절 행정상 법률관계>

I. 개설

1. 정의 및 개념

- 행정상 법률관계란 행정을 둘러싼 공법적 또는 사법적 법률관계를 총칭하는 개념이다. 이는 행정주체와 사인이 행정법의 규율 아래에서 갖게 되는 권리·의무 관계를 의미하며, 그 실체적 내용에 따라 행정조직법 관계, 행정작용법 관계 등으로 구분된다.

2. 특수성

- 행정법 관계는 공익 실현이라는 특수한 목적을 가지므로, 사법(私法) 관계와는 달리 행정주체에게 우월적 지위를 인정하거나 공익에 기여하는 방향으로 법률관계를 형성하는 특수성을 갖는다.

3. 당사자

- 행정법 관계의 당사자는 행정주체와 행정객체이다. 행정주체는 국가 또는 공공단체 등 자기의 이름과 책임 아래 행정 활동을 수행하고 그 결과의 법적 효과를 귀속시키는 주체이며, 행정객체는 행정주체의 활동에 대해 권리·의무를 부담하는 사인 또는 다른 행정주체를 포함한다.

4. 법률적 특성

- 행정법 관계의 법률적 특성은 첫째, 당사자 일방(행정주체)의 우월적 지위이다. 행정주체는 공익 실현을 위해 공권력을 행사할 수 있는 우월적 지위에 있으며, 이는 행정작용법 관계, 특히 권력관계에서 두드러진다. 둘째, 공정력, 구속력, 자력집행력 등과 같은 특수한 효력이 인정된다. 셋째, 행정주체의 법률관계 발생·변경·소멸에 관한 재량권을 인정하는 경우가 많다.

5. 관계구별의 실익

- 행정법 관계의 종류를 구별하는 실익은 관계의 성질에 따라 적용되는 법규범(공법 또는 사법)과 분쟁 해결 수단(행정소송 또는 민사소송)이 달라진다는 점에 있다. 특히, 행정작용법 관계를 공법관계와 사법관계로 구분하는 것은 행정법의 핵심적인 문제 중 하나이다.

II. 행정조직법 관계

1. 개념

- 행정조직법 관계는 행정주체 내부에서 행정기관 상호 간 또는 행정주체와 그 소속 공무원 간에 발생하는 법률관계를 의미한다. 이는 주로 행정조직의 설치, 구성, 권한 배분, 지휘·감독 등에 관한 관계를 규율한다.

2. 행정기관 상호 간 관계

- 행정기관 상호 간의 관계는 기관의 권한과 책임 소재를 명확히 하고 행정의 효율성을 확보하기 위한 관계이다. 예를 들어 중앙행정기관과 지방자치단체 간의 감독 관계, 상급 행정기관과 하급 행정기관 간의 지휘 관계 등이 있다. 이러한 관계는 원칙적으로 공법 관계의 영역에 속하며, 조직법적 행위(예: 위임, 대리, 보조)를 통해 형성된다.

3. 행정주체와 공무원 관계

- 행정주체와 공무원 간의 관계는 공무원이 행정주체의 행정 활동을 수행하기 위해 맺는 특별한 공법 관계, 즉 특별 권력 관계로 이해되어 왔다. 과거에는 공무원의 근무 관계에 대해 행정주체가 광범위한 지배권을 갖고 사법심사가 배제되는 것으로 보았으나, 현대 행정법은 이 특별 권력 관계의 영역을 축소하고 공무원의 기본권을 보장하는 방향으로 변화하였다. 오늘날에는 공무원 관계를 특별 행정법 관계로 파악하며, 공무원의 직무 수행에 필수적인 목적 달성에 필요한 범위 내에서만 특별한 구속 관계를 인정한다. 공무원의 임용, 징계, 신분 변동 등은 공법적 행정 행위에 해당하며, 이에 대한 다툼은 공법상 당사자소송이나 항고소송의 대상이 된다. 예를 들어 공무원에 대한 징계 처분은 항고소송의 대상이다.

4. 변화의 의의

- 특별 권력 관계 이론의 변화는 공법과 사법의 구별 기준에 대한 논의와 맞물려 행정법 관계 전체의 법치주의적 통제를 강화하는 데 기여하였다.

III. 행정작용법 관계

1. 개념

- 행정작용법 관계는 행정주체가 대외적으로 행정 목적을 실현하기 위해 사인(私人)에게 직접 영향을 미치는 작용을 할 때 발생하는 법률관계를 말한다. 이는 행정주체와 사인 간의 관계를 핵심으로 하며, 그 내용과 법적 성질에 따라 공법관계와 사법관계로 구분된다. 공법관계는 다시 권력관계와 관리관계로 나뉘며, 사법관계는 행정사법관계와 국고관계로 나뉜다.

2. 공법관계-권력관계

(1) 개념

- 권력관계는 행정주체가 공권력 행사를 통하여 일방적으로 우월한 지위에서 행정객체의 법적 지위에 영향을 미치는 법률관계이다. 이는 행정주체의 명령·강제에 의해 공익을 실현하는 데 주로 사용된다.

(2) 성립 및 특징

① 권력관계의 성립

- 법률의 근거에 따라 행정주체가 행하는 행정 행위(명령적 행위, 형성적 행위 등)를 통해 성립한다. 예를 들어 과세 처분, 영업 정지 처분, 건축허가 등의 행정 행위는 공정력, 구속력, 자력집행력 등 특수한 공법적 효력을 갖는다.

② 권리·의무의 내용

- 행정주체는 공법상의 명령권, 재량권, 강제력 등의 권능을 갖고, 행정객체는 공법상의 의무(예: 납세 의무)를 부담하거나 공권(예: 수익적 행정 행위 신청권)을 가진다.

③ 법적 분쟁의 해결

- 권력관계에서 발생하는 분쟁은 원칙적으로 공법상의 분쟁에 해당하므로 행정소송(항고소송 또는 당사자소송)에 의해 해결된다. 예를 들어 과세 처분에 불복하는 사인은 행정소송으로 분쟁을 해결할 수 있다.

(3) 관련 판례

① 행정청의 처분

- 행정청의 처분은 비록 위법하더라도 취소되지 않는 한 공정력을 가지므로, 처분의 근거 법규에 의해 보호되는 개인의 이익이 침해되었다 하더라도 곧바로 민사상 손해배상 청구의 대상이 되는 것은 아니며, 처분 자체의 위법성이 인정되어야 한다.

② 부관 중 부담

- 부관 중 부담은 행정 행위의 일부로서 공법 관계에 속하며, 부담 불이행 시의 법률관계는 공법적으로 처리되어야 한다.

3. 공법관계-관리관계

(1) 개념

- 관리관계는 행정주체가 재산관리주체로서 행정객체와 대등한 지위에서 특정한 공공복리의 실현을 위하여 공물 또는 사업을 관리·경영하는 법률관계를 의미한다. 이는 행정주체가 비권력적인 수단으로 행정 목적을 달성하는 관계이다.

(2) 성립 및 특징

① 관리관계의 성립

- 주로 공물의 이용 관계(예 : 도로, 공원의 일반 사용)나 공기업의 비권력적 활동(예 : 상수도 공급 계약), 공법상의 계약, 행정지도 등 비권력적 수단을 통해 성립한다.

② 권리·의무의 내용

- 당사자가 대등한 지위에 있다는 점에서 사법 관계와 유사하지만, 그 목적이 공익 실현이라는 점에서 공법적 규율을 받는다. (예 : 공공 시설의 특별 사용 허가에 따른 이용 관계)

③ 법적 분쟁의 해결

- 관리관계에서 발생하는 분쟁은 공법상의 분쟁에 해당하지만, 그 성질에 따라 행정소송(주로 당사자소송) 또는 민사소송의 대상이 될 수 있다. 다만, 공법상의 대등한 계약에 따른 분쟁은 당사자소송으로 본다. 예를 들어 국립·공립 대학 학생의 징계 처분은 공법 관계에 해당하며 행정소송의 대상이다.

(3) 관련 판례

① 국립 또는 공립 대학의 학생에 대한 징계 처분

- 국립 또는 공립 대학의 학생에 대한 징계 처분은 공법 관계로서 행정소송의 대상이 되지만, 사립학교 학생에 대한 징계 처분은 사법 관계로서 민사소송의 대상이 된다. 이는 당사자의 지위가 공법상의 지배 복종 관계인지 여부에 따라 구별된다.

② 지방자치단체가 체결하는 공법상 계약

- 지방자치단체가 체결하는 공법상 계약(예 : 국유림 대부 계약)에 관한 분쟁은 민사소송이 아닌 당사자소송으로 해결해야 한다.

4. 사법관계-행정사법관계

(1) 개념

- 행정사법관계는 행정주체가 공익적 목적을 달성하기 위해 사법적 수단을 이용하는 경우 발생하는 법률관계를 의미한다. 이는 행정 목적 달성을 위한 활동이지만, 법률관계 자체의 성질은 사법에 의해 규율된다는 특징을 가진다. 행정사법은 실질적으로 공익적 성격을 띠지만, 형식적으로는 사법의 원리가 적용된다.

(2) 성립 및 특징

① 행정사법관계의 성립

- 행정주체가 사인과 대등한 지위에서 계약(예 : 물품 구매 계약, 용역 계약)을 체결하거나, 토지를 매수하거나, 공법상 사업을 수행하는 과정에서 발생하는 부수적 사법적 관계에서 성립한다. (예 : 국립 병원의 의료 행위, 공기업의 일반적인 경제 활동)

② 권리·의무의 내용

- 법률관계의 내용은 사법(민법, 상법 등)의 규율을 받는다. 당사자는 원칙적으로 대등한 지위에서 권리와 의무를 부담한다.

③ 법적 분쟁의 해결

- 행정주체의 활동이라 할지라도 그 법률관계의 성질이 사법적인 이상, 분쟁은 원칙적으로 민사소송에 의해 해결된다.

(3) 관련 판례

① 공유재산 대부 계약

- 지방자치단체가 사인과 체결하는 공유재산 대부 계약은 사경제 주체로서 행하는 사법상의 계약에 해당하며, 이에 대한 다툼은 민사소송으로 해결해야 한다.

② 국립 또는 공립 병원의 의료 행위

- 국립 또는 공립 병원의 의료 행위에 관한 분쟁은 사법 관계로서 민사소송의 대상이 된다.

5. 사법관계-국고관계

(1) 개념

- 국고관계는 행정주체가 국가 또는 공공단체 그 자체가 아니라 단순한 사경제 주체로서 활동할 때 발생하는 법률관계를 의미한다. 이는 행정 목적의 실현과는 직접적인 관련이 없는, 순수한 재산적 활동을 말한다.

(2) 성립 및 특징

① 국고관계의 성립

- 행정주체가 행정 목적과 직접 관련 없이 국고 재산을 관리하거나(예 : 국유지 매각), 단순한 영리 활동을 하는 경우에 성립한다. (예 : 국가가 국고금을 예치하거나 이자 수입을 얻는 행위, 행정 목적과 무관한 국가 소유 건물의 임대)

② 권리·의무의 내용

- 법률관계의 내용은 전적으로 사법(민법, 상법 등)의 규율을 받는다. 국가나 공공단체는 사인과 완전히 동일한 지위에서 권리와 의무를 갖는다.

③ 법적 분쟁의 해결

- 국고관계에서 발생하는 분쟁은 그 법적 성질이 사법적인 것이 명확하므로, 전적으로 민사소송에 의해 해결된다.

(3) 관련 판례

① 국가나 지방자치단체가 단순한 사경제 주체로서 개인과 맺는 계약

- 국가나 지방자치단체가 단순한 사경제 주체로서 개인과 맺는 계약(예 : 토지 매매, 금전 대차)에 관한 분쟁은 민사소송으로 해결된다.

② 국고금의 출납에 관한 분쟁

- 국고금의 출납에 관한 분쟁은 원칙적으로 사법 관계로 보아 민사소송의 대상이 된다.

N 결론

- 행정상 법률관계는 공익 실현이라는 특수 목적을 가진 행정주체의 활동을 반영하며, 행정조직법 관계와 행정작용법 관계로 그 내용이 구분된다. 특히 대외적 관계인 행정작용법 관계는 행정주체의 우월성 유무와 목적의 공익성 정도에 따라 권력관계(공법), 관리관계(공법), 행정사법관계(사법), 국고관계(사법)로 세분된다. 이러한 구별은 분쟁 발생 시 적용될 법규범과 분쟁 해결 수단을 결정하는 핵심 기준이 된다. 권력관계는 공권력 행사의 측면에서 행

정소송의 중심이 되며, 관리관계는 비권력적 공법 작용으로서 주로 당사자소송의 영역을 형성한다. 반면, 행정사법관계와 국고관계는 사법적 성격이 강하여 민사소송의 대상이 된다. 현대 행정법은 공법 관계에 대한 사법심사의 범위를 확대하고, 법치주의 원리를 강화하여 모든 행정 활동에 대한 통제를 강화하는 방향으로 발전하고 있다.

<입문-제4장 행정법 관계.제4절 공법관계와 사법관계>

I. 행정법 관계

1. 개념

- 행정법 관계는 행정주체가 행정목적 실현하기 위하여 행정객체 등과 맺는 법률관계를 총칭하며, 그 성격에 따라 크게 공법관계와 사법관계로 나뉜다.

2. 공법관계

- 공법관계는 공익 목적을 직접적으로 달성하기 위해 행정주체가 우월적 지위에서 공권력의 주체로서 행하는 활동을 규율하는 관계이다.

3. 사법관계

- 사법관계는 행정주체가 사인(私人)과 대등한 지위에서 사경제의 주체로서 행하는 활동을 규율하는 관계이다.

4. 구별의 중요성

- 행정법 관계에서 공법관계와 사법관계의 구별은 단순한 이론적 분류를 넘어, 당사자의 권리 의무 관계, 분쟁 발생 시 적용되는 법규범, 관할 법원 등을 결정하는 실체적 및 절차적 기준이 된다. 이러한 관계의 이해는 행정주체의 다양한 활동을 법적으로 통제하고 국민의 권익을 보호하는 법치 행정의 근간을 이룬다. 행정주체는 하나의 주체이지만, 어떤 활동을 하느냐에 따라 공권력의 주체로서 공법관계를 맺기도 하고, 사경제의 주체로서 사법관계를 맺기도 한다.

II. 공법관계와 사법관계

1. 구별의 실익

- 공법관계와 사법관계의 구별은 행정법 상 다양한 법적 문제 해결에 결정적인 영향을 미치므로 매우 중요한 실익을 가진다.

(1) 적용 법규의 차이

- 공법관계에는 공법 규범인 헌법, 행정법 등이 적용되며, 법률 우위의 원칙, 법률 유보의 원칙 등 행정법의 일반 원칙이 우선적으로 적용된다. 반면, 사법관계에는 사법 규범인 민법, 상법 등이 적용되며, 사적 자치의 원칙, 계약 자유의 원칙 등 사법상의 일반 원칙이 적용된다. 예를 들어 공법관계에서 행정주체의 채무 불이행 시 손해 배상 책임은 국가배상법에 따르지만, 사법관계에서는 민법상 채무 불이행 책임 규정이 적용된다.

(2) 권리 구제 수단의 차이

- 공법관계에서 행정주체의 위법한 행위로 인해 발생하는 분쟁은 원칙적으로 행정 법원의 관할이 되며, 항고소송, 당사자소송 등 행정소송법상 특별한 구제 수단이 적용된다. 반면, 사법관계에서 발생하는 분쟁은 민사 법원의 관할이 되며, 민사 소송을 통해 해결된다. 관할 법원의 차이는 소송 절차, 심리 방식, 판결의 효력 등에 큰 차이를 가져온다. 예를 들어 토지 수용과 관련된 보상금 증감 청구는 공법상 당사자소송 대상이나, 공유 재산의 단순 매매 계약에 관한 분쟁은 민사 소송 대상이다.

(3) 특수 제도 적용 여부

- 공법관계에는 특유의 법적 효력이나 제도가 인정된다. 예를 들어 행정 행위의 공정력, 집행력, 불가쟁력 등의 효력이 인정되며, 공법상의 시효, 제재 등의 특별 규정이 적용된다. 사법관계에서는 이러한 공법상의 특수 효력은 원칙적으로 인정되지 않으며, 민법상의 소멸 시효 등이 적용된다. 또한, 공법관계에서는 행정의 신속성과 능률성을 위해 행정주체에게 일정한 특권 또는 특혜가 인정되기도 한다.

2. 구별의 기준

- 공법관계와 사법관계의 구별을 위한 기준에 대해서는 다양한 학설이 제시되어 왔으나, 현재는 이들 기준을 종합적으로 고려하는 절충적 접근이 통설 및 판례의 태도이다.

(1) 주체설

- 법률관계의 당사자 중 일방이 행정주체거나 행정기관인 경우를 공법관계로 보는 견해이다. 이는 가장 단순한 기준이지만, 행정주체가 사경제의 주체로서 활동하는 국고관계 등의 사법관계를 설명하지 못한다는 한계가 있다. 따라서 이 기준만으로는 충분하지 않으며, 다른 기준과 함께 고려되어야 한다.

(2) 목적설

- 법률관계의 목적이 공익을 위한 것인지 사익을 위한 것인지를 기준으로 구별하는 견해이다. 공익 목적을 직접적으로 달성하기 위한 것은 공법관계로, 사인의 이익 추구를 목적으로 하거나 수단적 성격이 강한 것은 사법관계로 본다. 이 견해는 행정주체의 행위가 궁극적으로는 모두 공익에 관련된다든 점에서 공법과 사법의 구분이 모호해지는 문제점이 있다.

(3) 수단설(성질설)

- 법률관계에서 행정주체가 어떤 법적 수단을 사용했는지에 따라 구별하는 견해이다. 행정주체가 공권력을 행사하여 우월적 지위에서 일방적으로 법률관계를 형성했으면 공법관계로 보고, 사인과 대등한 지위에서 계약 등의 사법적 수단을 사용했으면 사법관계로 본다. 현재 가장 유력한 기준으로 판례도 이 기준을 중요하게 참고한다. 특히, 공권력의 발동 여부와 법률관계의 일방성이 구별의 핵심이 된다.

(4) 종합설(이익설)

- 위의 세 가지 기준을 모두 종합하여 판단하는 견해이다. 법률관계의 당사자, 목적, 수단 등을 복합적으로 고려하되, 궁극적으로는 어떤 이익(공익 또는 사익)의 보호에 더 밀접하게 관련되는지에 따라 구별한다. 이러한 종합적 접근법이 가장 합리적이며, 개별 사안의 특수성을 반영하여 법률관계의 성격을 결정하는 데 적합하다.

3. 관련 판례

- 판례는 공법관계와 사법관계의 구별에 있어 특정 법률의 규정 내용, 관계의 목적, 행정주체의 활동 형태(공권력 행사 여부)를 종합적으로 고려하는 입장을 취한다. 특히, 행정주체가 사인과 맺는 계약 관계의 성격을 판단하는 데 이러한 기준이 활용된다.

(1) 공유 재산 매각 관련

- 지방자치단체가 일반재산인 공유 재산을 매각하는 행위는 단순히 사경제의 주체로서 재산의 효율적 관리를 도모하는 사법상의 행위로 본다. 따라서 이러한 매각 계약에 관한 분쟁은 민사 소송의 대상이 되며, 매각 결정에 위법이 있더라도 이는 민사상의 계약 무효 사유가 될 뿐, 항고소송의 대상이 되는 행정처분으로 볼 수 없다. 판례는 이러한 행위가 직접적으로 공권력을 행사하는 것이 아니라는 점을 중시한다.

(2) 입찰 참가 자격 제한 관련

- 국가 또는 지방 자치 단체가 체결하는 공공 계약(예 : 공사 도급 계약)에서 부정당 업자에 대해 일정 기간 입찰 참가 자격을 제한하는 조치는 그 자체가 상대방의 권익을 침해하는 공권력의 행사로 본다. 판례는 이러한 입찰 참가 자격 제한 조치는 계약 당사자로서의 지위를 넘어 우월한 지위에서 행

하는 행정처분으로서 공법관계에 속하며, 이의가 있을 경우 항고소송의 대상이 된다고 판시한다. 이 경우 목적이 계약의 적정한 이행 확보라는 공익적 성격을 가지고 있다는 점도 판단에 영향을 미친다.

(3) 공무원 연금 급여 지급 관련

- 공무원 연금 관리 공단이 공무원에게 연금 급여를 지급하는 행위는 공무원이라는 특별한 공법상 지위와 연금 법규라는 공법적 근거에 기초하여 이루어진다. 판례는 연금 수급권의 발생 및 지급 거부 등에 관한 다툼은 공법상의 권리 의무에 관한 것이므로 당사자소송의 대상이 된다고 판시한다. 이는 금전 지급의 형태를 취하더라도 그 법적 근거와 목적이 공법적 영역에 있으면 공법관계로 본다는 것을 명확히 보여준다.

(4) 판례의 종합적 태도

- 행정재산의 사용·수익에 대한 허가, 입찰 참가 자격 제한 조치, 연금 수급권의 발생 및 지급 거부 등에 관한 다툼은 공법관계로 보며, 일반재산 및 잡종재산의 매각은 사법관계로 보는 것이 일반적이다.

III 결론

- 행정법 관계의 핵심 구조는 공법관계와 사법관계의 구별에 있으며, 이는 적용 법규, 관할 법원, 구제 수단의 차이로 이어지는 실무상 중대한 의미를 가진다. 구별의 기준은 행정주체의 특징, 행위의 공익적 목적, 특히 공권력의 행사 여부 등을 종합적으로 고려하는 종합설의 관점에서 판단된다. 판례의 태도 역시 개별 법률의 성격과 행위의 본질을 따져 공권력 행사와 공익적 목적이 결부된 경우 공법관계를 인정하는 경향이 강하다. 이러한 공법과 사법의 구별 원칙은 행정의 효율성을 유지하면서도 국민의 권리 보호를 극대화하기 위한 법치 행정의 필수적인 전제 조건이다.

<입문-제5장 공법행위.제1절 개념 및 종류>

I. 개념

- 공법행위는 공법상의 권리·의무를 발생, 변경, 소멸시키는 행정주체의 법률행위를 의미한다. 이는 사법상의 법률관계 변동을 목적으로 하는 사법행위(민법상의 계약)와 구별된다. 공법행위는 국가 또는 지방자치단체 등의 행정주체가 행하는 행정작용의 핵심을 이루며, 사인 역시 공법상의 권리·의무 변동을 가져오는 행위(행정기관에 대한 신청 또는 신고)를 할 수 있으므로, 행정주체와 사인 모두의 행위를 포함한다. 광의의 공법행위는 행정주체의 법률행위적 행위(행정행위)은 물론, 단순한 사실 행위적 행위(경찰관의 정보 수집)까지 포함하며, 이러한 행위들은 모두 공익을 목적으로 하고 행정법의 규율을 받는다는 특징이 있다. 협의의 공법행위는 주로 공법상의 법률 효과 발생을 의도하는 법률행위적 행위에 한정되어 사용되기도 한다. 행정주체의 공법행위 중 가장 중요한 형태는 일반적으로 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 행정행위이다. 공법행위는 그 본질상 공익 실현을 위한 활동이므로, 법률 우위의 원칙 및 법률 유보의 원칙 등 법치주의 원칙의 적용을 받으며, 민법상의 일부 규정(의사표시의 하자에 관한 규정)이 공법의 특성에 맞게 준용되거나 배제된다. 따라서 공법행위의 개념 정의는 각 행위의 법적 효과와 유효성 여부를 판단하는 기본 전제가 된다.

II. 종류

- 공법행위는 행위의 주체, 법적 성질 등에 따라 분류된다. 이러한 분류는 각 행위에 적합한 법적 원칙과 통제 수단을 적용하기 위해 필수적이다.

1. 행위 주체에 따른 분류

- 공법행위를 행하는 주체가 행정주체인지 사인인지에 따라 공법행위의 법적 특성과 효력이 크게 달라진다.

(1) 행정주체의 공법행위

- 국가, 지방자치단체 등의 행정주체가 공익 실현을 위해 행하는 모든 활동을 포함한다. 이 행위는 공권력의 행사 여부에 따라 다시 세분된다. 공권력을 행사하는 경우는 행정행위로 가장 대표적이며, 비권력적 활동의 경우는 행정상 사실 행위, 공법상 계약 등으로 나뉜다. 행정주체의 공법행위는 법률 우위 및 법률 유보의 원칙이 가장 엄격하게 적용되는 영역이다.

(2) 사인의 공법행위

- 사인이 공법상의 권리·의무 변동을 목적으로 행정주체에 대해 행하는 행위를 의미한다. 이는 사인이 공법관계의 당사자로서 자신의 의사를 표시하는 것으로, 행정주체의 작용을 발동시키거나 법적 효과의 발생에 영향을 미친다. 예를 들어 행정기관에 대한 신청(허가 신청, 특허 신청), 공법상의 신고(납세 신고, 영업 신고), 동의, 철회, 청구 등이 이에 해당한다. 사인의 공법행위는 일반적으로 민법상의 의사표시에 관한 규정(착오, 사기, 강박)이 공법의 특성을 고려하여 준용되거나 적용이 배제된다. 특히 신고의 경우, 수리가 필요한 신고인지 여부에 따라 법적 효력 발생 시점과 분쟁 해결 방식이 달라진다.

2. 법적 성질에 따른 분류

- 공법행위가 법률 효과를 직접 목적으로 하는지 여부에 따라 법률행위적 행위와 사실 행위적 행위로 구분되며, 이는 행위의 법적 통제 방식을 결정하는 중요한 기준이 된다.

(1) 법률행위적 공법행위

- 행위자가 공법상의 법적 효과 발생 또는 변동을 직접적으로 의도하고 그에 따라 법적 효과가 발생하는 행위를 말한다. 이러한 행위는 당사자의 의사 표시를 필수 요소로 한다.

① 행정행위

- 행정주체가 법 아래에서 구체적 사실에 대하여 공권력의 주체로서 일방적으로 행하는 법 행위로서, 국민의 권리·의무에 직접 변동을 초래하는 가장 중요하고 전형적인 공법행위이다. 행정행위는 명령적 행위(허가, 하명, 면제)와 형성적 행위(특허, 대리, 인가)로 다시 나뉜다. 예를 들어 과세 처분, 영업 허가, 공무원 임용 등이 대표적이며, 공정력, 집행력, 불가쟁력 등 특수한 효력이 인정된다.

② 공법상 계약 및 합동 행위

- 공법상 계약은 행정주체가 사인 또는 다른 행정주체와 대등한 지위에서 공익 목적을 위해 체결하는 합의로서, 쌍방의 의사 합치를 요소로 하는 법률행위적 공법행위이다. 예를 들어 공공 시설 위탁 운영 계약, 공무원 채용 계약 등이 있다. 공법상 합동 행위는 다수의 행정주체 또는 사인이 단일한 공익 목적을 위해 같은 방향의 의사 표시를 하는 것을 의미한다.

③ 사인의 법률행위적 공법행위

- 사인의 신고, 신청 등 행위 자체가 법적 효과(신고의 경우 법적 의무의 이행 완료)를 발생시키는 경우를 말한다. 특히 자기완결적 신고는 행정기관의 수리가 없어도 신고서가 도달하는 것만으로 법적 효력이 발생하는 사인의 법률행위적 공법행위로 간주된다.

(2) 사실 행위적 공법행위

- 법적 효과 발생을 직접 목적으로 하지 않고, 단순히 사실적 결과를 가져오는 행위를 말한다. 행정주체가 직접적으로 국민의 권리·의무에 변동을 주지는 않지만, 공익 목적 달성에 필요한 정보 수집, 사실 확인, 서비스 제공 등의 활동이다. 예를 들어 행정지도, 교통 경찰관의 수신호, 공공 정보 제공, 도로 청소 등의 집행 행위 등이 있다. 사실 행위 중 일부는 비록 법률 행위는 아니지만, 사실상의 강제를 수반하거나 국민의 법적 지위에 중대한 영향을 미치는 경우(강제 철거의 실행)에는 예외적으로 항고소송의 대상이 되는 행정 처분으로 인정되기도 한다. 사실 행위는 행정의 재량이 넓게 인정되는 경우가 많지만, 법치주의의 원칙상 위법한 사실 행위에 대해서는 국가 배상 청구 등의 책임이 따를 수 있다.

III. 결론

- 공법행위는 행정주체와 사인의 공법적 활동 전반을 포괄하는 개념이며, 그 종류는 행위 주체에 따라 행정주체의 행위와 사인의 행위로, 법적 성질에 따라 법률행위적 행위와 사실 행위적 행위로 나뉘어진다. 행정행위는 법률행위적 공법행위의 핵심으로서 공정력 등 특수한 법적 효력을 가지는 반면, 사실 행위는 법적 효과가 아닌 사실적 결과를 목표로 한다. 이러한 분류는 각 공법행위에 적용될 법적 통제 원리를 결정하고, 위법한 행위에 대한 국민의 구제 수단을 정립하는 데 있어 행정법상 가장 기초적인 작업이다.

<입문-제5장 공법행위.제2절 신고 및 신청>

I. 사인의 공법행위로서 신고

1. 신고의 의의

- 신고는 사인이 공법상의 일정한 사실을 행정기관에 통지하는 것을 의미하며, 공법상의 효과 발생을 목적으로 하는 사인의 법률행위적 공법행위의 일종이다. 신고의 주된 목적은 법률이 요구하는 공법상의 의무를 이행하고, 행정주체가 해당 사실을 인지하여 적절한 행정작용을 할 수 있도록 정보를 제공하는 데 있다. 신고는 행정의 간소화 및 국민의 자유 보장이라는 관점에서 허가 제도를 대신하여 점차 확대되는 추세이다. 신고가 적법한 요건을 갖추어 제출되면, 그 자체로 법적 효력이 발생하거나 행정기관의 후속 조치를 유발하는 기능을 수행한다. 신고의 형식은 대개 문서로 하도록 법률에 규정되어 있으며, 법률에서 정한 사항을 충족하지 못한 부적법한 신고는 법적 효력을 발생시키지 못한다. 신고의 효력 발생 여부에 관하여 행정기관의 수리를 요하는지 여부에 따라 자기완결적 신고와 행위요건적 신고로 구분된다. 이러한 신고의 유형 구분은 신고가 있음으로써 법적 효력이 발생하는 시점, 행정기관의 관여 정도, 분쟁 발생 시 권리 구제 수단의 유형을 결정하는 가장 핵심적인 기준이 된다.

2. 자기완결적 신고

(1) 개념

- 법적 효력의 발생이 행정기관의 별도 수리를 요하지 않고, 사인(신고인)이 법령에 규정된 요건을 모두 갖추어 행정기관에 신고서를 제출(도달)하는 것만으로 완료되는 신고이다. 신고인이 적법한 요건을 모두 갖추면 신고의 무조건적인 수리 의무가 행정기관에 발생하며, 신고를 함으로써 해당 행위를 적법하게 할 수 있는 효력(영업 개시의 적법성)이 발생한다.

(2) 구체적 내용

- 자기완결적 신고는 주로 단순한 사실을 통지하거나 행정기관의 심사를 필요로 하지 않는 경우에 적용되며, 예를 들어 건축법상 착공 신고, 주민등록법상 전입 신고, 의료법상 의원 개설 신고 등이 이에 해당한다. 이러한 신고에 대해 행정기관이 실체적 심사를 거부하거나 부당하게 수리를 거부할 경우, 이는 신고의 법적 효력에 아무런 영향을 미치지 못한다. 판례는 자기완결적 신고를 거부하는 행정기관의 행위는 국민의 법적 지위에 불가분의 영향을 주는 행정 처분으로 보아 항고소송의 대상이 된다고 본다. 다만, 신고 자체의 적법성 요건 심사가 아닌, 형식적 요건 검토(신고서의 필수 기재 사항 누락) 수준에서의 반려 행위는 처분이 아니라고 볼 여지가 있다.

3. 행위요건적 신고

(1) 개념

- 법적 효력의 발생이 단순한 제출(도달)을 넘어, 행정기관의 수리라는 별도의 행정행위를 요구하는 신고이다. 이러한 신고는 실질적으로 허가와 유사한 기능을 수행하며, 행정기관의 수리가 있어야만 비로소 신고의 효력이 발생하고 행위의 적법성이 인정된다. 수리는 신고의 수리 여부에 대해 행정기관의 실질적인 심사 결과가 반영된 것으로 볼 수 있다.

(2) 구체적 내용

- 행위요건적 신고는 주로 공공의 안녕 질서 유지 등 공익적 심사를 요하는 경우에 적용되며, 예를 들어 주택 건설 사업 계획 승인 신청에 대한 행정기관의 수리 등이 이에 해당한다. 이러한 신고가 적법한 요건을 갖추더라도 행정기관이 수리를 거부하면 법적 효과가 발생하지 않는다. 행정기관의 수리 거부 행위는 신고인의 행위의 적법성을 부정하고 권리·의무에 영향을 미치므로, 항고소송의 대상이 되는 행정 처분으로 본다. 따라서 신고인이 수리 거부에 불복하는 경우에는 취소소송 등을 제기하여 다툴 수 있다.

II. 사인의 공법행위로서 신청

1. 신청의 의의

- 신청은 사인이 행정주체에게 일정한 행정행위를 발동하도록 요구하는 의사 표시로서, 공법상의 권리·의무 변동을 목적으로 하는 사인의 법률행위적 공법행위이다. 신청은 행정주체의 허가, 특허, 인가 등 수익적인 행정행위를 요구하거나, 자신에게 불리한 행정행위를 철회 또는 취소해 줄 것을 요구하는 경우 등 다양한 상황에서 발생한다. 신청은 행정주체의 행정작용을 유발하는 단초가 되며, 행정절차법상 행정기관의 응답 의무를 발생시키는 법적 효력을 가진다. 신고와는 달리 신청만으로는 법적 효과가 완성되지 않고, 반드시 행정기관의 행정행위(예 : 허가 처분)가 뒤따라야만 원하는 법적 결과가 발생한다.

2. 신청의 요건

- 신청이 적법한 효과를 발생시키기 위해서는 일정한 요건을 충족해야 하며, 이는 사인의 법률 행위에 준하는 형식적 및 실질적 요건으로 구성된다.

(1) 형식적 요건

- 신청의 형식적 요건은 법령이 정하는 방식과 절차에 따라 제출되었는지 여부를 말한다. 예를 들어 신청서의 서식 준수, 필요한 첨부 서류 제출, 신청 기간 준수, 관할 행정기관에의 제출 등이 포함된다. 이러한 형식적 요건 중 일부가 결여된 경우에는 행정절차법상 행정기관은 보완을 요구해야 하며, 보완이 이루어지지 않으면 신청은 부적법하게 될 수 있다.

(2) 실질적 요건

- 신청의 실질적 요건은 신청인 자체가 공법상 신청권을 가지고 있는지 여부 등 신청의 내용에 관한 법적 요건을 말한다. 예를 들어 신청의 대상인 행정행위가 법적으로 가능한 것인지, 신청인이 해당 행위를 신청할 수 있는 법적 지위(신청권)를 가지고 있는지 여부 등이 포함된다. 실질적 요건 중 하나인 신청권은 개인의 권익을 보호하기 위해 행정기관에 대해 일정한 행정행위를 해 줄 것을 요구할 수 있는 공법상의 권리를 의미하며, 신청권이 없으면 신청은 각하될 수 있다.

3. 신청의 효과

- 적법한 신청이 행정기관에 도달하면, 다음과 같은 법적 효과가 발생한다. 신청의 효과는 신청 자체가 법적 효과를 완성하는 것이 아니라, 행정기관의 후속 작용을 유발하는 데 중점이 있다.

(1) 응답 의무의 발생

- 행정절차법상 행정기관은 적법한 신청을 받은 경우 신청인에게 신청의 결과를 통지해야 할 의무(응답 의무)를 진다. 이는 거부 처분을 포함하여 신청에 대한 어떤 형태의 결과를 문서로 알려야 하는 의무이다. 응답 의무가 있음에도 불구하고 행정기관이 상당한 기간 내에 아무런 응답을 하지 않는 것을 부작위라고 하며, 이에 대해서는 부작위위법확인소송 등을 통해 권리 구제를 받을 수 있다.

(2) 절차 개시 효과

- 신청은 허가, 특허 등 신청을 전제하는 행정행위의 발동 절차를 개시하는 효력을 가진다. 신청이 없으면 행정기관은 직권으로 수익적 행위를 발동할 수 없으므로, 신청은 행정행위 발동의 절차적 요건이 된다.

(3) 시간적·법적 효과

- 신청 시점을 기준으로 하여 행정기관이 후에 처분을 하더라도 신청 당시의 법령이나 사실 상태를 적용해야 하는 경우가 있다(시간적 효과). 또한, 신청은 공법상의 시효 중단 등 다른 법적 효과를 발생시키기도 한다.

4. 부적법한 신청의 효과

- 신청이 형식적 또는 실질적 요건 중 하나라도 충족하지 못하여 부적법하게 된 경우에는 원칙적으로 법적 효과가 발생하지 않는다.

(1) 형식적 요건 흠결 시

- 신청서의 필수 기재 사항 누락 등 형식적 요건에 흠결이 있는 경우, 행정기관은 행정절차법에 따라 상당한 기간을 정하여 보완을 요구해야 한다. 이러한 보완 요구에도 불구하고 신청인이 기간 내에 보완하지 않으면, 행정기관은 그 신청을 반려할 수 있다. 이러한 반려 행위는 실질적 심사를 거부하는 것이 아니므로 원칙적으로 행정처분으로 보지 않는다.

(2) 실질적 요건 흠결 시

- 신청권이 없거나 신청의 내용이 법적으로 불가능한 경우 등 실질적 요건에 흠결이 있는 경우에는 행정기관은 그 신청을 본안에서 심사하지 않고 각하 해야 한다. 실질적 흠결로 인한 각하 처분은 신청인의 권익에 직접적인 영향을 미치므로, 항고소송의 대상이 되는 행정처분으로 본다. 다만, 판례는 신청권이 없는 자에게 거부 처분을 하더라도 그것이 취소소송의 대상이 되는 처분이 아니라고 보는 경우도 있어 유의해야 한다.

5. 권리구제

- 사인의 적법한 신청에 대하여 행정기관이 위법한 처분을 하거나 부당하게 응답을 거부할 경우, 신청인은 행정소송 등 다양한 수단을 통해 권리 구제를 받을 수 있다.

(1) 거부 처분에 대한 구제

- 신청에 대하여 행정기관이 거부 처분을 한 경우, 신청인은 취소소송 또는 무효등 확인소송을 제기하여 다툴 수 있다. 이때 거부 처분이 처분으로 인정되기 위해서는 신청인에게 행정기관의 응답을 받을 권리(신청권)가 있어야 한다. 판례는 법규상 또는 조리상 신청권이 있는 경우의 거부 행위만을 행정 처분으로 인정하는 입장을 취한다. 취소소송에서 승소하면 거부 처분은 취소되고, 행정기관은 다시 처분을 해야 할 재처분 의무를 진다.

(2) 부작위에 대한 구제

- 적법한 신청이 있었음에도 불구하고 행정기관이 상당한 기간 내에 어떠한 처분(거부 처분 포함)도 하지 않는 부작위 상태에 대해서는 부작위위법 확인소송을 제기할 수 있다. 이 소송은 행정기관의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 것을 목적으로 하며, 승소 판결을 받더라도 곧바로 원하는 처분을 받는 것이 아니라, 행정기관에게 재처분 의무를 발생시키는 효과를 가진다. 부작위위법확인소송의 적법 요건 역시 신청인에게 신청권이 있어야 함이 필요하다.

III. 결론

- 신고와 신청은 사인이 공법관계에서 자신의 의사를 표시하고 법적 효과를 유발하는 대표적인 공법행위이다. 신고는 행정기관의 수리 여부에 따라 자기관결적 신고와 행위요건적 신고로 구분되어 그 법적 효력 발생 시점과 권리 구제 방식이 결정된다. 신청은 행정기관의 행정행위 발동을 요구하는 의사 표시로서, 적법한 요건을 갖추어 행정기관에게 응답 의무를 부과하는 효력을 가진다. 신청에 대한 위법한 거부 처분이나 부작위에 대해서는 신청권의 유무를 중심으로 취소소송 및 부작위위법확인소송 등을 통해 권리 구제를 받을 수 있으며, 이는 국민의 권익 보장을 위한 행정법적 통제 수단으로서 중요한 의미를 가진다.

<입문-제6장 행정행위.제1절 행정행위 일반>

I. 행정행위와 처분 등

1. 행정행위의 개념

- 행정행위란 행정청이 구체적 사실에 관하여 법 아래서 행하는 권력적 단독 행위로서, 직접적으로 법적 효과를 발생시키는 행위를 말한다. 이는 행정법학에서 가장 중요하고 전통적인 개념 중 하나로, 행정청의 다양한 행위 중 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 가져와 사법 심사의 대상이 되는 행위를 포괄적으로 지칭하는 데 사용되어 왔다. 행정행위의 개념은 독일 공법학에서 유래하였으며, 한국 행정법학에서도 오랫동안 항고소송의 대상인 처분을 해석하는 기본 틀로 활용되었다. 행정행위는 법적 안정성과 예측 가능성을 확보하는 기능을 하며, 공정력, 구속력, 집행력 등 특별한 효력을 갖는다는 특징이 있다.

2. 처분과의 구별

- 행정행위와 처분은 밀접하게 관련되지만, 그 의미와 범위는 구별된다.

(1) 개념의 연혁적 구별

- 행정행위는 독일 공법학에서 발전한 학문상의 개념으로, 행정작용의 법적 성격을 분류하기 위한 도구적 개념이다. 반면, 처분은 행정소송법 제2조 제1호에 규정된 실정법상의 개념으로, 행정소송의 대상이 되는 행정작용을 지칭한다.

(2) 범위의 구별 및 확대

- 전통적으로는 행정행위가 곧 처분으로 인식되어 왔으나, 현대 행정소송법의 발전과 함께 처분의 범위가 행정행위의 범위를 초월하여 확대되는 경향을 보인다. 법원은 행정의 다양성과 복잡성을 고려하여, 전통적인 행정행위 개념으로는 포섭되지 않더라도 국민의 구체적인 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 공권력적 행위라면 그 밖에 이에 준하는 행정작용에 해당한다고 보아 처분성을 인정한다. 따라서 행정행위는 처분의 핵심이자 주된 형태이지만, 처분의 개념이 행정행위보다 더 넓은 범위를 포괄하는 상위 개념으로 이해된다.

II. 행정행위의 개념적 요소

- 행정행위로 인정되기 위해서는 다음과 같은 요소를 충족하여야 한다. 이는 행정소송법상 처분의 개념을 이해하는 데 기초가 된다.

1. 행정청이 행하는 것

- 행정행위는 행정주체의 의사를 결정하고 외부에 표시할 권한을 가진 행정청이 행하는 행위여야 한다. 여기서 행정청이란 국가 또는 공공단체의 기관 중에서 행정사무를 자기의 이름으로 처리할 수 있는 권한을 가진 기관을 말한다. 행정청의 보조 기관이나 하부 기관이 행하는 행위는 원칙적으로 행정행위가 아니다.

2. 구체적 사실에 관한 것

- 행정행위는 특정 개인이나 사건과 같은 구체적인 사실에 대하여 행해지는 행위여야 한다. 일반적인 성질을 가진 모든 사람에게 적용되는 추상적이고 일반적인 규율인 법규 명령이나 행정규칙 등은 행정행위가 아니다. 행정행위는 법규의 일반성을 개별적인 구체성으로 전환시키는 법 집행 작용이다.

3. 법적 행위일 것

- 행정행위는 행정청의 의사 표시를 통해 직접적으로 법적 효과를 발생시키는 행위, 즉 법적 행위여야 한다. 단순한 통지, 안내, 정보 제공 등 법적 효과 없이 사실적인 효과만을 발생시키는 사실 행위는 원칙적으로 행정행위가 아니다. 다만, 권력적 사실 행위와 같이 국민의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정될 수 있다.

4. 권력적·단독적인 공법행위일 것

(1) 권력적 공법 행위

- 행정행위는 행정청이 우월한 공권력의 주체로서 일반적으로 국민에게 의무를 부과하거나 권리를 제한하는 권력적인 성격을 가져야 한다. 사인(私人)과의 대등한 지위에서 체결하는 공법상 계약이나 사법상 행위는 행정행위가 아니다.

(2) 단독 행위

- 행정행위는 행정청이 상대방의 동의 여부와 관계없이 일방적인 의사 표시로 법적 효과를 발생시키는 단독 행위여야 한다. 상대방의 신청이나 동의를 받아 비로소 성립하는 행위도 행정청의 의사가 핵심이 된다는 점에서 단독 행위로 본다.

5. 거부행위

- 행정청의 거부 행위는 소극적인 행위이지만, 특정한 요건을 충족할 경우 예외적으로 행정행위(처분)로 인정된다. 거부 행위가 처분으로 인정되기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다.

(1) 법규상 또는 조리상 신청권 존재

- 국민에게 법규상 또는 조리상 신청권이 존재하여야 한다. 신청권이 없는 경우 행정청이 거부하더라도 국민의 권리·의무에 영향을 미치지 않으므로 처분이 될 수 없다.

(2) 법률 관계의 직접적 변동

- 그 거부 행위가 신청인의 법률 관계에 직접적인 변동을 초래하여야 한다. 즉, 신청의 이행을 거부함으로써 신청인에게 불이익이 발생하여야 처분성이 인정된다. 이러한 거부 행위는 소극적 처분으로서 취소소송의 대상이 된다.

III. 행정행위의 분류 기준에 따른 종류

- 행정행위는 다양한 기준에 따라 분류될 수 있으며, 이러한 분류는 각 행정행위의 법적 성격과 효력을 이해하는 데 도움을 준다.

1. 행정행위 대상에 따른 구분

(1) 대인적 행정행위

- 상대방의 지식·학식·기술 등 주관적 사정을 고려하여 행해지는 행정행위이다. 인간문화재지정, 운전면허, 의사면허 등이 이에 해당한다. 대인적 행정행위의 효과는 일신전속적인 것이므로 제3자에게 승계되지 않는다.

(2) 대물적 행정행위

- 그 행위의 대상인 물건이나 시설의 객관적 사정을 고려하여 행해지는 행정행위이다. 차량검시합격 처분, 건축물 준공검사, 채석허가, 건물철거 명령 등이 이에 해당한다. 대물적 행정행위의 효과는 명문규정이 없더라도 제3자에게 이전될 수 있다(다수설, 판례).

(3) 혼합적 행정행위

- 상대방의 주관적 사정과 함께 행정행위의 대상인 물건, 시설의 객관적 사정을 모두 고려하여 행하여지는 행정행위를 말한다. 전당포영업허가 등이 이에 해당한다. 혼합적 행정행위의 이전은 명문의 규정이 있는 경우에 인정되며, 일반적으로 행정청의 승인 또는 허가 등을 받도록 하고 있다.

2. 행정행위 내용에 따른 구분

(1) 법률행위적 행정행위

- 행정청의 의사 표시 내용대로 법적 효과가 발생하는 행정행위를 말한다. 행정행위의 대부분이 여기에 속하며, 다시 명령적 행위(허가, 하명, 면제)와 형성적 행위(특허, 대리, 인가)로 나뉜다.

(2) 준법률행위적 행정행위

- 행정청의 의사 내용과는 관계없이 법률이 그 행위에 부여한 효과가 발생하는 행정행위를 말한다. 예를 들어, 공증, 통지, 수리, 확인 등이 이에 해당한다.

3. 법률효과의 성질에 따른 구분

(1) 수익적 행정행위

- 국민의 권리나 이익을 부여하거나 확대하는 등 국민에게 유리한 법적 효과를 가져오는 행정행위를 말한다. (허가, 특허)

(2) 침익적 행정행위

- 국민의 권리나 이익을 제한하거나 의무를 부과하는 등 국민에게 불리한 법적 효과를 가져오는 행정행위를 말한다. (영업 정지, 과세 처분)

(3) 복효적 행정행위(제3자효 행정행위)

- 하나의 행정행위가 특정인에게는 수익적 효과를, 제3자에게는 침익적 효과를 동시에 발생시키는 행정행위를 말한다. (경쟁 업체에 대한 특허 부여)

4. 법적 구속의 정도에 따른 구분

(1) 기속 행위

- 행정청이 법규에 정해진 요건이 충족되면 반드시 그에 따른 행위를 해야 하며, 재량의 여지가 없는 행위를 말한다. 행정청의 의사가 개입될 여지가 없으므로, 위법성 판단 시 법원의 심사 밀도가 높다.

(2) 재량 행위

- 행정청이 법규에 정해진 요건이 충족되더라도, 행위 여부나 내용을 스스로 선택할 수 있는 판단의 자유가 있는 행위를 말한다. 재량 행위의 심사는 원칙적으로 재량권의 한계를 넘었거나 남용했는지 여부(일탈 · 남용)만을 심사한다.

5. 기존의 법률상태에 변동을 가져오는가에 따른 구분

(1) 적극적 행정행위

- 적극적 행정행위는 현재의 법률상태에 변동을 가져오는 행정행위를 말한다. 허가 · 특허 등이 이에 해당한다.

(2) 소극적 행정행위

- 소극적 행정행위는 현재의 법률상태에 변동을 가져 오지 않는 행정행위를 말한다. 허가 · 특허 등의 신청에 대한 거부처분이 이에 해당한다.

N 결론

- 행정행위는 행정청이 구체적 사실에 관하여 법 아래 행하는 권력적 단독 행위로서, 행정법학에서 항고소송의 대상인 처분의 핵심을 이루는 개념이다. 처분은 행정행위 외에 권력적 사실 행위 등을 포괄하는 상위 개념으로 이해된다. 행정행위는 행정청, 구체적 사실, 법적 행위, 권력성, 단독성 등의 개념적 요소를 가지며, 명령적 행위와 형성적 행위, 기속 행위와 재량 행위 등 다양한 기준으로 분류되어 그 법적 효력과 통제 방식이 달라진다. 행정행위 개념에 대한 정확한 이해는 행정소송에서 위법성을 판단하고 국민의 권익을 구제하는 데 필수적인 기초를 제공한다.

<입문-제6장 행정행위.제2절 행정행위 내용에 따른 구분>

I. 법률행위적 행정행위

1. 의의

- 법률행위적 행정행위란 행정청이 일정한 법률효과의 발생을 의욕하는 의사표시에 의하여 국민의 권리·의무에 직접 법적 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다.

2. 분류

- 행정행위의 대부분이 여기에 속하며, 다시 명령적 행정행위(허가, 하명, 면제)와 형성적 행정행위(특허, 대리, 인가)로 나눌 수 있다.

II. 법률행위적 행정행위-명령적 행정행위

1. 명령적 행정행위의 학설

- 명령적 행정행위의 법적 성질에 대한 학설은 크게 권력설과 법률효과설로 대별될 수 있으나, 현대 행정법에서는 행정행위의 효력이 행정청의 우월한 지위에서 발생한다는 점을 인정하면서도, 궁극적으로는 그 행위의 법률적 효과에 초점을 맞춘다. 특히, 명령적 행정행위는 법규를 집행하여 국민의 권리·의무를 규율하는 행위라는 점에서 법률효과설이 통설적 지위를 차지하며, 개별 행위의 법적 근거와 목적에 따라 성질을 구체화한다.

2. 명령적 행정행위의 의의

- 명령적 행정행위란 행정청이 법규를 근거로 하여 국민의 자유를 제한하거나 의무를 부과 또는 해제하는 법률행위적 행정행위를 말한다. 이는 행정청이 우월한 공권력의 주체로서 행하는 행위라는 특성이 있다.

3. 허가

(1) 허가의 의의

- 허가란 법률이 일반 사인에게 일반적·상대적으로 금지하고 있는 행위(부작위 의무)를 특정인에 대하여 해제하여, 적법하게 그 행위를 할 수 있도록 법률적 자유를 회복시켜 주는 행정행위이다.

(2) 허가의 성질

① 법률행위적 행정행위

- 허가는 행정청의 의사 표시에 따라 법적 효과(금지 해제)가 발생하는 법률행위적 행정행위이다.

② 원칙적 기속행위

- 허가는 법령에 정해진 요건만 충족하면 행정청이 반드시 허가해야 하는 기속행위가 원칙이다. 다만, 공익적 판단이 요구되는 특정 분야에서는 예외적으로 재량이 인정될 수 있다.

(3) 허가의 종류

① 대물적 허가

- 대상 물건이나 시설의 적합성을 심사하여 부여하는 허가(건축 허가)

② 대인적 허가

- 신청인 개인의 능력이나 자격을 심사하여 부여하는 허가(운전면허)

(4) 허가의 형식 및 상대방

① 형식

- 문서주의가 원칙이나, 법령에 특별한 규정이 없는 한 구술 또는 기타 방식으로 가능하다.

② 상대방

- 특정인에게 행하는 개별적 행정행위가 원칙이다.

(5) 허가의 대상

- 허가의 대상은 법령에 의해 금지되어 있는 행위여야 한다. 금지되어 있지 않은 행위(자유 행위)에 대해 행정청이 허가라는 명칭을 사용하더라도, 이는 법적으로 허가가 아닌 확인이나 공증 등 다른 성격의 행위로 해석된다.

(6) 허가의 기준

- 허가 기준은 법적 안정성을 위해 법령에 명확하게 규정되어야 한다. 허가 여부는 법령이 정한 공익적 기준과 신청인의 적격성을 기준으로 심사하며, 법령에 없는 사유로 허가를 거부할 수 없다.

(7) 허가의 신청

- 허가는 신청인의 신청에 의해 절차가 개시되는 것이 원칙이다. 행정청은 신청이 있는 경우 법령에 따라 심사하고 응답할 의무가 있다.

(8) 허가의 효과

- 허가의 효과는 법률적 자유의 회복이다. 즉, 허가받은 행위를 적법하게 할 수 있게 되며, 법률적 불이익(처벌)을 면할 수 있다. 허가는 제3자에게 영향을 미치지 않는다.

(9) 허가 위반의 효과

- 허가 없이 금지된 행위를 하는 경우, 그 행위는 무허가 행위로서 위법해지며, 행정벌(과태료, 징역 등)의 대상이 되거나 행정상 강제집행(이행강제금 부과, 대집행)의 대상이 될 수 있다. 다만, 사법상의 효력(매매 계약의 유효성)에는 원칙적으로 영향을 미치지 않는다.

(10) 인·허가 의제 제도

- 복수의 법령에 따라 여러 개의 허가를 받아야 하는 경우, 주된 하나의 허가 신청 및 발급만으로 나머지 관련 허가를 받은 것으로 의제(간주)하는 제도이다. 행정 절차의 간소화를 목적으로 한다.

① 처분성

- 의제된 인·허가에 대하여 별도로 다룰 수는 없고, 주된 인·허가 처분의 취소소송에서 함께 다투어야 한다.(판례)

② 거부처분

- 주된 인·허가 처분이 거부될 경우, 의제된 모든 인·허가 신청에 대한 거부도 포함된 것으로 보아 주된 인·허가 처분 거부를 다투어야 한다.

(11) 예외적 허가(승인)

- 예외적 허가는 법령상 특정 행위를 원칙적으로 절대적 금지하면서, 특정한 공익적 이유나 극히 예외적인 경우에 한하여 금지를 해제하는 행위이다.

① 성격

- 단순 허가과 달리, 공익적 심사의 범위가 넓어 행정청의 재량이 인정되는 경우가 많다.

② 쟁송

- 거부 시 단순 허가보다 재량의 일탈·남용 심사 범위가 넓어진다.

4. 하명

(1) 하명의 의의

- 하명이란 행정청이 국민에게 새로운 작위, 부작위, 급부, 수인 등의 의무를 부과하는 행정행위이다. 국민의 권리나 자유를 침해하는 침익적 행정행위의 대표적인 형태이다.

(2) 하명의 종류

① 작위 하명

- 일정한 행위를 하도록 명령(건축물 철거 명령)

② 부작위 하명

- 일정한 행위를 하지 않도록 명령(통행 금지 명령)

③ 급부 하명

- 금전 등을 국가에 납부하도록 명령(세금 부과 명령)

④ 수인 하명

- 국가의 행위를 수용하고 참도록 명령(예방접종 의무 부과)

(3) 하명의 대상 및 상대방

- 하명은 주로 특정인에게 부과되는 개별 처분의 형태를 취하나, 불특정 다수인을 대상으로 할 수도 있다. 하명의 대상은 법률에 근거하여 국민에게 의무를 부과하는 행위여야 한다.

(4) 하명의 효과 및 구제

① 효과

- 국민은 하명에 의해 새로운 공법상 의무를 부담하게 된다.

② 구제

- 하명이 위법한 경우, 국민은 취소소송을 통해 그 하명의 취소를 구할 수 있다. 하명 불이행 시 행정 강제(대집행, 강제징수)나 행정벌의 대상이 된다.

5. 면제

(1) 개념

- 면제란 법령에 의해 국민에게 부과된 기존의 의무를 행정청이 해제하여 그 의무로부터 벗어나게 하는 행정행위이다.

(2) 허가과 면제의 구별

① 기존 상태

- 허가는 일반적·상대적 금지(부작위 의무) 상태, 면제는 법령에 의한 작위, 급부 등 의무 상태이다.

② 행위 효과

- 허가는 금지 해제를 통한 자유 회복이며, 면제는 의무 해제를 통한 의무 면탈이다.

③ 예시

- 허가는 영업 허가, 운전면허이며, 면제는 병역 면제, 세금 감면이다.

Ⅲ. 법률행위적 행정행위-형성적 행정행위

1. 형성적 행정행위의 의의

- 형성적 행정행위란 행정청의 의사 표시에 의하여 국민의 공법상 권리나 법률관계를 새롭게 설정하거나, 기존의 법률관계를 변경·보충하여 법적 효력을 완성시키는 법률행위적 행정행위를 말한다. 이는 국민에게 이미 존재하는 자유를 회복시켜주는 명령적 행정행위(허가, 하명, 면제)와는 구별된다. 형성적 행정행위는 주로 특허, 대리, 인가의 형태로 나타나며, 행정청의 적극적인 의사 결정이 국민의 법률관계에 직접적인 변동을 가져온다는 특징이 있다.

2. 특허-상대방을 위한 행위

(1) 특허의 의의

- 특허란 행정청이 특정 개인에게 새로운 공법상 권리나 포괄적 법률관계를 설정해주는 행정행위를 말한다. 본래 국민에게 자유가 없는 영역이거나, 공공의 필요성이나 공익적 독점성 때문에 행정청의 특별한 설정 행위를 통해서만 비로소 권리를 취득할 수 있는 경우에 사용된다. 특허는 공익적 판단이 폭넓게 개입되므로 원칙적으로 재량행위로 해석된다.

(2) 특허의 종류(광의의 특허)

- 광의의 특허에는 특정인에게 새로운 공법상 권리나 지위를 설정하는 협의의 특허(공익 재단 설립 허가) 외에도, 행정 재산이나 공물의 특별 사용권을 설정하는 행위(국유림 사용 허가)와 특정 직업이나 사업을 영위할 자격을 설정하는 행위(의사 면허, 방송국 면허) 등이 포함된다.

(3) 특허의 형식 및 상대방

- 특허는 국민의 권리·의무에 중대한 영향을 미치므로 문서로 행해지는 것이 원칙이다. 특허의 상대방은 특허를 통해 새로운 권리나 지위를 취득하는 특정인이며, 특허는 특정인에 대한 개별 처분의 성격을 가진다.

(4) 특허의 효과

- 특허는 상대방에게 법적으로 보호되는 새로운 공권을 부여하는 수익적 행정행위이다. 특허로 설정된 권리(어업권, 도로 점용 허가권)는 법적 보호를 받으며, 침해 시 행정쟁송을 통해 구제받을 수 있다.

(5) 허가·특허 비교

- 특허는 새로운 권리나 포괄적 법률관계를 설정하는 행위인 반면, 허가는 법률에 의해 일반적·상대적으로 금지된 행위에 대한 금지를 해제하여 국민의 기존 법적 자유를 회복시켜주는 행위이다. 따라서 특허는 공익적 판단이 폭넓게 개입되어 원칙적으로 재량행위이지만, 허가는 원칙적으로 기속행위로 해석된다.

3. 대리

(1) 개념

- 대리는 법령상 특정인이 행해야 할 법적 행위를 그 의무자가 이행하지 않을 때, 행정청이 법정 대리인의 지위에서 그 의무자를 대신하여 행위를 하는 행정작용이다. 대리행위의 법적 효과는 행정청이 아닌 본인(원래 의무자)에게 귀속되며, 그 근거가 공법에 있고 공익을 목적으로 한다는 점에서 사법상의 대리와의 구별된다.

(2) 구별 개념

- 대리는 행정청이 의무 불이행 시 사실 행위를 강제적으로 대신 실현하는 대집행과 구별된다. 대집행은 주로 의무의 이행 그 자체를 목적으로 하는 강제 집행의 일종인 반면, 대리는 국민이 행해야 할 법률행위를 행정청이 대신하는 행위라는 점에서 차이가 있다.

4. 인가-제3자를 위한 행위

(1) 인가의 의의

- 인가란 사인이 행한 법률행위(주된 행위)를 행정청이 보충하여 그 법률적 효력을 완성시켜 주는 행정행위를 말한다. 인가는 주된 행위의 효력을 보충하는 역할을 하며, 행정청의 인가가 있어야 비로소 사인의 행위가 유효하게 된다. 인가는 그 본질상 주된 행위의 상대방인 제3자에게 영향을 미칠 가능성이 크다.

(2) 인가의 대상

- 인가의 대상은 사인의 법률행위이다. 행정청의 행위를 보충하는 것은 인가에 해당하지 않는다. 예컨대 학교 법인의 정관 변경이나 조합 설립 행위 등이 인가의 대상이 된다.

(3) 인가의 형식·상대방 및 출원

- 인가도 국민의 법률관계에 영향을 미치므로 문서로 행해지는 것이 일반적이다. 인가의 상대방은 인가를 신청한 사인(주된 행위의 당사자)이다. 인가는 사인의 신청에 의해 이루어지는 것이 원칙이다.

(4) 수정인가의 가부

- 수정인가란 행정청이 사인이 신청한 내용과 다르게 일부를 수정하여 인가하는 것을 말한다. 인가는 주된 행위의 효력을 보충하는 데 그치므로, 행정청이 사인이 신청한 내용을 임의로 수정하여 인가할 수 없다는 것이 판례 및 통설의 입장이다. 수정인가를 하려면 행정청은 인가를 거부하고 사인에게 수정된 내용으로 재신청하도록 요구해야 한다.

(5) 인가의 효과

- 인가는 주된 행위의 효력을 완성시킨다. 인가가 있어야 비로소 주된 행위가 유효하게 되며, 인가가 없는 주된 행위는 원칙적으로 무효이다. 그러나 인가는 주된 행위를 보충하는 행위일 뿐, 인가 그 자체가 주된 행위의 위법성까지 치유하는 것은 아니다.

(6) 관련 판례

- 쟁송 대상에 관하여 판례는 인가 자체의 위법성(인가 요건 미비)을 다투는 경우, 인가 처분이 항고소송의 대상이 된다고 본다. 그러나 주된 행위(조합 설립 행위)의 하자 다투는 경우, 이는 사법상의 법률관계에 관한 문제이므로 민사소송 또는 당사자소송으로 다투어야 하며, 인가 처분의 취소를 구하는 취소소송은 원칙적으로 적법하지 않다고 판단한다.

(7) 허가·특허·인가 비교

- 세 행위는 모두 법률행위적 행정행위이지만, 법적 효과가 다르다. 허가는 법적 금지를 해제하여 국민의 자유를 회복시키는 데 그치고 원칙적으로 기속행위이다. 특허는 새로운 공권을 설정하는 행위로 원칙적으로 재량행위이다. 반면, 인가는 사인의 행위를 보충하여 그 효력을 완성시키는 행위이다. 이러한 면에서 그 법적 성질이 확연히 구별된다. 인가는 법률이 정한 바에 따라 기속행위일 수도, 재량행위일 수도 있다.

IV 준법률행위적 행정행위

1. 의의

- 준법률행위적 행정행위란 행정청의 판단, 인식, 통지 등 정신 작용의 표시에 대하여 법률이 그 자체로 법적 효과를 부여하는 행정행위를 말한다. 이는 행정청의 의사 내용대로 법적 효과가 발생하는 법률행위적 행정행위와 구별된다. 준법률행위적 행정행위의 효력은 행정청의 의사와 관계없이 법규가 직접 규정하는 바에 따라 발생하며, 주로 공증, 통지, 수리, 확인 네 가지 유형으로 분류된다.

2. 공증

(1) 공증의 개념

- 공증이란 행정청이 특정 사실 또는 법률관계의 존재 여부에 대하여 공적인 권위로서 증명하는 행위를 말한다. 공증은 증명 행위 그 자체에 의해 법적 효과가 발생한다.

(2) 공증의 성질 및 형식

- 공증은 행정청의 판단이 아닌 인식의 표시로서, 그 자체가 법적 안정성을 확보하는 기능을 한다. 공증은 주로 문서의 형식으로 이루어진다.

(3) 공증의 종류

- 공증의 대표적인 예로는 행정청이 사실 관계를 증명하는 등기, 등록, 공증 등이 있다. 특히, 부동산등기법상의 등기는 물건 변동의 효력 요건 또는 대항 요건으로서 중요한 법적 효과를 발생시킨다. 또한, 행정청이 발급하는 각종 증명서나 확인서 역시 공증의 성격을 가진다.

(4) 공증의 효과

- 공증은 증명된 사실이나 법률관계에 대하여 추정적 공신력을 발생시킨다. 즉, 공증된 내용이 진실인 것으로 추정되어 거래의 안전을 도모하는 효력을 갖는다. 그러나 공증된 내용이 실제와 다르다면 이해관계인은 그 내용을 다툴 수 있다.

(5) 공증의 행정행위성(처분성)

- 공증은 특정 사실을 증명하는 행위에 불과하므로, 그 자체로 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하지 않는 한 원칙적으로 처분성이 부정된다. 따라서 공증 행위의 위법성을 다투기 위한 취소소송은 원칙적으로 인정되지 않는다. 다만, 공증이 특정인의 법률상 지위를 결정하거나 특정 권리·의무의 성립 요건이 되는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정될 여지가 있다.

3. 통지

(1) 통지의 개념

- 통지란 행정청이 특정인에게 특정 사실 또는 의사를 알리는 행위이다. 통지는 행정청의 의사 표시를 외부에 전달하는 역할을 한다.

(2) 구별 개념

- 통지는 그 성격상 법률행위적 행정행위의 효력 발생 요건인 도달과 구별되어야 한다. 통지는 그 자체가 법적 효과를 발생시키는 준법률행위적 행정행위이거나, 또는 단순히 사실 행위로서 존재하는 경우가 있다. 또한, 통지는 행정청이 특정 법률관계를 확정하는 확인 행위와도 구별된다.

(3) 통지의 종류

① 사실의 통지

- 객관적인 사실을 알리는 행위(도로 폐쇄 결정의 고시)

② 의사의 통지

- 행정청이 가질 의사를 알리는 행위(대집행 계고 통지) 계고 통지는 국민에게 철거 의무의 이행을 촉구하고, 불이행 시 강제집행을 하겠다는 의사를 알리는 통지로서, 그 자체가 법률효과를 발생시키므로 처분성이 인정된다는 것이 판례의 태도이다.

(4) 통지의 효과

- 통지의 효과는 법률에 따라 다양하다. 통지는 특정 법률 효과의 발생 시점을 정하거나, 법률상 의무 이행의 시한을 알리는 효력을 가질 수 있다. 특히, 계고 통지와 같이 그 내용 자체가 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 통지는 처분성이 인정되어 항고소송의 대상이 된다.

4. 수리

(1) 수리의 개념

- 수리란 행정청이 국민이 행한 일정한 공법적 행위(신고 또는 신청)를 받아들여 법률 효과를 완성시키는 행위를 말한다. 여기서 수리는 단순한 접수 행위와 구별되며, 법률적 의미를 가지는 경우에 한하여 준법률행위적 행정행위로 본다.

(2) 구별 개념

- 수리는 행정청의 의사 표시 내용대로 효력이 발생하는 허가와 구별된다. 수리는 행정청의 의사보다는 법규가 정한 바에 따라 효력이 발생하며, 행정요건적 신고의 경우 그 법적 성질이 중요하게 다루어진다.

(3) 수리의 성질

- 수리는 국민의 행위(신고 등)를 전제로 하며, 그 행위의 효력을 확인·보충하여 법률 효과를 완성시키는 확인적 성격을 가진다.

(4) 수리의 효과

- 수리의 효과는 국민의 공법상 신고나 신청의 법적 효력을 발생시키는 것이다.

① 행정요건적 신고의 수리

- 수리 행위가 있어야 비로소 신고의 법적 효과가 발생하며, 수리 거부하는 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 거부처분으로 취소소송의 대상이 된다.

② 자기완결적 신고의 수리

- 수리는 단순한 접수 사실 행위로서 원칙적으로 처분성이 부정되나, 판례는 예외적으로 수리 거부로 인해 법적 불안정성이 야기될 경우 처분성을 인정하여 국민의 권리 구제를 도모하기도 한다.

5. 확인

(1) 확인의 의의

- 확인이란 행정청이 특정 사실 또는 법률관계의 존부나 정당성에 대하여 공적인 권위로서 판단하고 이를 확정하는 행정행위를 말한다. 확인은 불확정한 법률 상태를 확정하여 법적 안정성을 기하는 것을 목적으로 한다.

(2) 확인의 종류

① 사실의 확인

- 특정 사실의 존재를 확정(토지 대장상의 지목 확인)

② 법률관계의 확인

- 특정 법률관계의 존부나 내용을 확정(당선인 결정, 발명 특허, 출생 신고의 수리)

(3) 확인의 형식

- 확인은 주로 문서의 형식으로 이루어지며, 이해관계인에게 통지된다.

(4) 확인의 효과

- 확인은 법률관계를 확정하는 공정력과 불가쟁력을 가진다. 확정된 내용은 그 후의 법률관계에 구속력을 미치며, 특히 특허와 같이 새로운 권리를 설정하는 행위는 아니지만, 기존 법률관계의 불확실성을 제거하여 법적 안정성을 높이는 결정적인 효과를 가진다.

V. 결론

- 법률적 행정행위의 명령적 행정행위는 국민의 자유와 의무를 직접적으로 규율하는 행정작용의 핵심이며, 허가는 자유를 회복시키고, 하명은 의무를 부과하며, 면제는 의무를 해제한다는 점에서 각각의 법적 성질이 구별된다. 이러한 명령적 행정행위는 대부분 취소소송의 대상인 처분에 해당하므로, 행정쟁송법에서는 그 요건, 효과, 위법성 판단 기준을 명확히 이해하는 것이 중요하다. 법률적 행정행위의 형성적 행정행위인 특허, 대리, 인가는 행정청의 적극적 행위로 국민의 법적 지위를 새롭게 구축하거나 타인의 행위를 완성시키는 기능을 한다. 특히, 특허와 인가는 그 법적 성질과 쟁송 대상에서 중요한 차이를 보이므로, 행정쟁송법상 인가 처분과 주된 행위의 하자를 분리하여 판단하는 법리를 정확히 이해하는 것이 핵심이다. 준법률행위적 행정행위는 행정청의 의사보다는 법규의 힘에 의해 법적 효과가 발생하는 행위로서, 공증, 통지, 수리, 확인의 네 가지 유형으로 분류된다. 이 중 통지와 수리는 특정 유형(계고, 행정요건적 신고 수리)에서 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미쳐 처분성이 인정되는 경우가 많고, 확인은 법률관계를 확정하여 가장 강한 효력을 가지므로 쟁송법상 그 구별과 처분성 여부의 판단이 중요한 쟁점이 된다.

<입문-제4장 행정행위.제3절 법적 구속 정도에 따른 구분>

I. 개설

1. 법적 구속에 따른 구분의 중요성

- 법적 구속의 정도에 따라 기속행위와 재량행위로 구별하는 것은 행정청의 처분에 대한 사법 심사의 범위를 결정하는 핵심 기준이며, 행정쟁송법에서 가장 중요한 쟁점 중 하나이다. 이 구별은 행정청이 법규에 구속되는 정도와 국민의 권리 구제 가능성을 직접적으로 연결한다.

2. 행정법규에 대한 이해

- 행정법규는 행정청에게 특정 행위를 할 의무를 부과(기속)하거나, 혹은 행위 여부나 내용을 선택할 수 있는 권한을 부여(재량)한다.

(1) 기속성

- 법규가 행정청의 의무를 명확히 정하고 선택의 여지를 주지 않는 경우이다.

(2) 재량성

- 법규가 행정청에게 행위의 여부, 시기, 내용 등을 스스로 판단할 수 있는 권한, 즉 재량을 부여하는 경우이다.

3. 요건법규 · 효과법규와의 관련문제

- 행정법규는 크게 요건 법규와 효과 법규로 구성된다.

(1) 요건 법규

- 행정청이 처분을 발동하기 위해 충족되어야 할 사실적 · 법적 조건을 규정한 부분이다.

(2) 효과 법규

- 요건이 충족되었을 때 행정청이 취해야 할 행위의 종류와 내용을 규정한 부분이다. 기속행위와 재량행위의 구별은 주로 효과 법규의 내용에 의해 결정된다. 즉, 요건이 충족되었을 때 '반드시 ... 하여야 한다'고 규정하면 기속행위가 되고, '... 할 수 있다' 또는 '... 할지 여부를 재량으로 한다'고 규정하면 재량행위가 된다.

II. 기속행위

1. 의의

- 기속행위란 행정청이 법규의 구체적인 내용과 취지에 엄격하게 구속되어 행위의 요건이 충족되면 법규가 정한 내용의 행위를 반드시 하여야 하는 행정행위를 말한다. 행정청의 판단 여지(선택의 자유)가 전혀 없다.

2. 구별기준

(1) 문언기준

- '하여야 한다', '의무를 진다', '강행한다' 등의 표현을 사용한다.

(2) 법규의 성질 및 목적

- 주로 국민의 권리 의무에 중대한 영향을 미치거나(예 : 조세 부과), 공익성이 강한 분야(예 : 보건, 환경 규제)에서, 법적 안정성 확보를 위해 기속행위로 해석되는 경향이 있다.

3. 관련판례

- 대법원은 행정청의 조세 부과 처분이나 건축 허가(건축법상 요건 충족 시)와 같이 국민의 권리 · 의무에 직접적인 영향을 미치고 법적 안정성이 강조되는 영역에서는 원칙적으로 기속행위로 해석한다.

III. 재량행위

1. 의의

- 재량행위란 행정청이 법규의 범위 내에서 행위의 발동 여부(선택 재량)나 행위의 내용(결정 재량)을 스스로 판단하여 결정할 수 있는 권한, 즉 재량을 가지는 행정행위를 말한다.

2. 구별기준

(1) 문언적 기준

- '... 할 수 있다', '... 할지 여부를 정한다', '필요하다고 인정하는 때' 등의 표현을 사용한다.

(2) 법규의 성질 및 목적

- 고도의 전문적 · 정책적 판단이 요구되는 영역(예 : 도시 계획, 허가 조건 설정)에서 행정의 탄력성과 효율성을 위해 재량행위로 해석되는 경향이 있다.

(3) 행정행위의 효과

① 침익적 행위

- 국민에게 불이익을 주는 침익적 행위는 일반적으로 재량의 여지가 넓게 인정되는 경우가 많다.

② 수익적 행위

- 국민에게 이익을 주는 수익적 행위 역시 공익과 사익의 형량을 위해 재량이 인정되는 경우가 많다.

3. 관련판례

- 국토 계획 및 이용에 관한 법률상 용도지역 변경 신청 거부나 공무원에 대한 징계 처분 등은 광범위한 공익적 판단이 요구되므로 재량행위로 본다.

4. 재량행위 여부

- 행정청에게 재량권이 부여된 경우, 그 재량권은 다음의 두 가지 차원으로 나뉜다.

(1) 선택 재량 (행위 재량)

- 행정청이 법규가 정한 요건이 충족되었을 때 해당 처분을 할 것인지 말 것인지를 선택할 수 있는 권한이다.

(2) 결정 재량 (내용 재량)

- 처분을 하기로 결정한 후, 그 처분의 내용, 시기, 조건 등을 선택할 수 있는 권한이다.

5. 재량의 하자 일반

- 재량행위는 행정청의 자유로운 선택권을 의미하지만, 이는 법의 범위 내에서 행사되어야 하며, 이를 위반할 경우 재량의 하자로 인해 위법해진다.

(1) 재량권 일탈

- 법이 정한 재량의 범위를 넘어서는 행위를 하는 경우이다. (예 : 법규가 정한 최고 형량을 초과하여 과징금을 부과) 이는 곧바로 위법이다.

(2) 재량권 남용

- 재량의 범위 내에 있지만, 재량의 목적에 위배되거나, 비례의 원칙, 평등의 원칙 등 행정법의 일반 원칙을 위반하여 부당하게 행사되는 경우이다.
(예 : 사적인 감정으로 특정인에게 가혹한 처분을 부과) 이는 곧바로 위법이다.

(3) 재량권 불행사 또는 해태

- 행정청이 재량권이 있음에도 불구하고 이를 행사하지 않거나(불행사), 법이 정한 기간 내에 처분을 미루는 것(해태)을 말한다. 이는 거부 처분 또는 부작위의 문제로 연결될 수 있으며, 재량권이 부여된 행위를 하지 않기로 결정한 것이라면 재량의 남용으로서 위법해진다.

IV. 각종 행정행위의 기속·재량행위 여부

1. 허가

- 기속행위

2. 하명

- 원칙은 기속행위, 예외는 재량행위

3. 면제

- 특별한 구분 없음

4. 특허

- 재량행위

5. 대리

- 특별한 구분 없음

6. 인가

- 원칙은 재량행위, 예외는 기속행위

7. 공증

- 기속행위

8. 통지

- 기속행위

9. 수리

- 기속행위

10. 확인

- 기속행위

V. 결론

- 기속행위와 재량행위의 구별은 취소소송에서 본안 심리의 범위를 확정한다. 기속행위의 위법성은 법규 위반 여부에 대한 엄격한 심사(법률적 판단)로써 법원이 쉽게 판단할 수 있으나, 재량행위의 위법성은 오직 재량권의 일탈 또는 남용이 있었는지 여부만을 심사(재량 통제)할 수 있다. 법원은 재량행위에 대해 행정청의 판단을 존중하는 방향으로 심사하며, 이는 행정의 전문성과 효율성을 존중하는 사법의 소극적 태도를 보여준다.

<입문-제6장 행정행위.제4절 다단계 행정결정>

I. 다단계 행정결정의 의의

- 다단계 행정결정이란 행정청이 하나의 최종적인 행정 목표를 달성하기 위해 곧바로 최종 처분을 하지 않고, 여러 단계의 중간적·부분적 결정을 거쳐 최종 처분을 완성하는 행정작용의 방식을 말한다. 이러한 결정 방식은 행정의 복잡화, 장기화, 전문화 추세에 따라 행정청의 부담을 분산시키고, 국민의 예측 가능성을 높이며, 행정의 효율성과 적법성을 확보하기 위해 활용된다. 행정쟁송법상 다단계 행정결정에서 각 중간 결정이 취소소송의 대상인 처분에 해당하는지 여부는 국민의 권리 구제 측면에서 중요한 쟁점이 된다.

II. 예비결정

1. 의의

- 예비결정이란 장기간과 많은 비용이 소요되는 복잡한 행정계획이나 개발 사업 등에서, 최종 처분의 요건 중 일부 요건에 관하여 미리 행하는 행정청의 구속력 있는 판단을 말한다. 이는 확약 또는 부분허가와 구별되며, 신청인에게 최종 허가를 받을 수 있는 법적 지위(잠정적 권리)를 부여한다.

2. 구별 개념

(1) 잠정적 행정행위

- 잠정적 행정행위는 법적 요건이나 사실 관계가 미확정 상태일 때, 잠정적으로 효력을 인정하고 추후 최종 결정으로 대체하는 행위를 말한다. 이는 최종 결정의 일부 요건을 미리 확정하는 예비결정과는 다르다.

(2) 행정 계획의 결정

- 행정 계획의 결정(예 : 도시기본계획)은 장래에 대한 일반적·추상적인 구상을 정하는 행위로, 특정 사업의 개별적·구체적 요건을 미리 확정하는 예비결정과는 구별된다.

(3) 행위요건적 신고의 수리

- 행위요건적 신고의 수리는 신고를 매개로 법적 효과를 완성하는 확인 행위인 반면, 예비결정은 최종 허가의 일부 요건에 대한 중간적 판단이다.

3. 법적 성질

- 예비결정은 최종 허가의 요건 중 일부를 미리 확정하고, 그 확정된 부분에 대해서는 행정청 자신을 구속하는 기속력(구속력)을 가지는 행정행위이다. ① 예비결정은 최종 처분의 요건 중 일부를 미리 심사하여 확정함으로써, 신청인의 법적 지위를 강화하고 절차적 안정성을 제공한다. ② 예비결정은 신청인의 법률상 이익에 직접적인 영향을 미치므로, 그 거부 행위는 취소소송의 대상인 거부 처분으로 인정된다.

4. 관련 판례

- 판례는 예비결정을 최종 허가와의 구별되는 독립된 행정행위(처분)로 보고 있다.

(1) 거부처분성

- 대법원은 건축법상 사전 결정 제도가 도입되기 전에도, 장기간과 많은 비용이 소요되는 개발 사업에 대하여 관계 행정청이 미리 행한 교통 영향 평가 심의 결과 통보 등은 그 통보가 거부되었을 때 신청인에게 미치는 법률상 불이익이 크므로, 항고소송의 대상인 처분으로 인정하였다.

(2) 기속력

- 예비결정에서 이미 확정된 요건에 대해서는 최종 결정 시 다시 다룰 수 없으며, 행정청은 특별한 사정 변경이 없는 한 이에 구속된다.

III. 부분허가

1. 개념

- 부분허가란 법령상 하나의 허가에 의해 완성되어야 할 사업을, 그 사업의 목적(기능)이나 내용에 따라 가분적인 여러 단계로 나누어 각 단계별로 독립된 허가를 발급하는 것을 말한다. 이는 최종 사업의 전체 요건이 아니라 가분적인 각 단계에 한하여 최종 허가를 부여하는 점에서 예비결정과 구별된다.

2. 법적 성질

- 부분허가는 그 단계에 한하여 최종적인 효력을 가지는 완전한 행정행위(처분)이다.

(1) 독립된 처분성

- 부분허가는 그 자체로 해당 단계의 사업을 완료할 수 있는 법적 권한을 부여하며, 국민의 권리·의무에 직접적인 법률 효과를 발생시키므로 취소소송의 대상인 처분에 해당한다.

(2) 효력의 한계

- 부분허가는 해당 단계에 한하여 효력을 가지며, 다음 단계의 허가를 자동으로 보장하지는 않는다.

3. 법적 근거

- 부분허가는 사업의 성격상 분할이 가능하고, 각 단계의 독립적인 심사를 통해 행정의 효율성을 높일 필요가 있을 때 법률의 근거를 통해 이루어진다. (예 : 환경 영향 평가법상 사업 계획 적정 통보는 후속의 개발 행위 허가와 구별되어 부분허가적 성격을 갖는다.)

IV. 가행정행위

1. 의의

- 가행정행위란 장기간의 복잡한 심사를 요하는 행정작용에서, 최종 결정이 내려지기 전까지 잠정적으로 상황을 규율하기 위해 장래 최종 결정으로 대체될 것을 전제로 행하는 잠정적이고 일시적인 행정행위를 말한다. 이는 불확정 상태에서 임시적인 규율을 목적으로 한다.

2. 가행정행위의 예

- ① 세법상 잠정적인 세액 결정이나 가납 명세 등 ② 공무원 징계 절차에서 최종 징계가 확정되기 전의 직위 해제 처분 등

3. 특징

(1) 잠정성과 대체성

- 가행정행위는 최종적인 결정이 내려지는 시점에 자동적으로 효력을 상실하고 최종 결정으로 대체된다는 잠정성과 대체성을 갖는다.

(2) 처분성

- 가행정행위는 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 행위이므로 취소소송의 대상인 처분에 해당한다. 잠정적인 상태라도 국민의 법적 지위에 영향을 미치기 때문이다.

(3) 법적 구속력

- 가행정행위는 최종 결정 전까지 완전한 구속력을 가진다. 따라서 그 위법성을 다투기 위해서는 일반 행정행위와 마찬가지로 취소소송을 제기해야 한다.

V 결론

- 다단계 행정결정은 복잡한 현대 행정에서 행정 효율성을 확보하기 위한 필수적인 수단이다. 예비결정은 최종 허가의 일부 요건에 대한 중간 확정으로서, 부분허가는 가분적인 단계에 대한 최종 허가로서, 가행정행위는 최종 결정 전까지의 잠정적 규율로서 기능한다. 이 모든 중간 단계 결정들은 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치므로, 행정쟁송법상 처분성이 원칙적으로 인정되어 취소소송의 대상이 된다는 공통점을 가진다.

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제1절 행정행위의 실효성 확보수단>

I. 행정상 실효성 확보수단의 의의

- 행정상 실효성 확보수단이란 행정법상의 의무를 이행하지 않거나 위반하는 경우, 행정주체가 그 의무의 이행을 확보하거나 의무 위반에 제재를 가함으로써, 행정목적의 실현하기 위해 사용하는 모든 공법적 수단을 말한다. 이는 행정의 실효성을 담보하고 법치 행정을 실현하는 데 필수적인 요소이다. 이러한 수단은 국민의 권리·자유를 침해할 우려가 크므로, 반드시 법률의 근거에 의해서만 발동되어야 한다.(법률유보의 원칙)

II. 전통적 행정강제수단

- 전통적인 실효성 확보수단은 주로 의무의 이행을 강제하거나 의무 위반에 대한 벌칙을 가하는 방식으로 이루어진다.

1. 행정강제

- 행정강제란 행정법상 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 장래에 향하여 의무 이행을 확보하기 위하여 가하는 강제 수단을 말한다.

(1) 대집행

- 대집행은 의무자가 행정법상 대체적 작위 의무를 이행하지 않을 때, 행정청이 스스로 의무자가 해야 할 행위를 대신 행하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 수단이다. 행정대집행법에 근거하며, 계고, 통지, 대집행 실행, 비용 징수의 4단계 절차를 거치는 것이 원칙이다. 계고는 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다는 점이 중요하다.

(2) 직접강제

- 직접강제는 행정법상 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 의무자의 신체 또는 재산에 직접적인 힘을 가하여 의무 이행을 실현하는 수단이다. 이는 국민의 기본권에 대한 침해가 매우 크기 때문에 법적 근거가 엄격하게 요구되며, 최후의 수단으로 이용된다.

(3) 강제징수

- 강제징수는 공법상의 금전 급부 의무(조세, 과태료)를 불이행할 때, 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 의무를 이행시키는 수단이다. 국제징수법 등에 근거하며, 독촉, 압류, 매각, 청산의 절차를 거친다. 독촉은 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다.

(4) 즉시강제

- 즉시강제는 급박한 상황에서 의무를 명할 시간적 여유가 없을 때, 또는 의무를 명하는 것만으로는 목적 달성이 곤란할 때, 의무를 부과함이 없이 행정청이 직접 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하여 행정목적의 즉시 실현하는 수단이다. 예를 들어 전염병 환자의 강제 격리, 화재 진압 등이 있으며, 이는 사후에 의무 부과를 대체하는 것이 아니며, 행정 조사와 구별된다.

2. 행정벌

- 행정벌이란 과거의 의무 위반 행위에 대하여 제재를 가하여 일반 예방적 효과를 도모하는 수단이다. 의무 이행 확보가 아닌 제재가 목적이므로, 행정강제와는 성격이 다르다.

(1) 행정형벌

- 행정형벌은 행정법상 의무 위반 행위에 대하여 형법이 정하는 바에 따라 징역, 금고, 벌금 등 형사 처벌을 가하는 것이다. 이는 행정청이 아닌 사법부(법원)의 재판을 통해 부과된다.

(2) 행정질서벌

- 행정질서벌은 행정법상 의무 위반에 대하여 비교적 경미한 처벌인 과태료를 부과하는 것을 말한다. 이는 원칙적으로 행정청이 부과하며, 과태료 부과 처분에 불복하면 비송사건절차법에 따라 법원에서 심판한다.

III. 새로운 행정강제수단

- 행정의 복잡화 및 전통적 수단의 한계(특히 비대체적 작위 의무나 부작위 의무 위반에 대한 미흡성)로 인해 보다 유연하고 실효적인 새로운 수단들이 등장하였다.

1. 등장 배경

(1) 비대체적 의무 증가

- 전문화된 현대 행정에서 단순한 대체적 작위 의무보다 행위자 본인만이 이행할 수 있는 비대체적 작위 의무나 부작위 의무가 증가하였다.

(2) 국민의 권리 보호 강화

- 직접강제와 같은 강력한 수단은 국민의 기본권을 과도하게 침해하므로, 이를 대체할 간접적 강제 수단의 필요성이 대두되었다.

(3) 행정 효율성

- 복잡한 행정 영역에서 행정주체가 직접강제하는 것보다 간접적인 제재를 통해 자발적 이행을 유도하는 것이 효율적이다.

2. 금전적 제재수단

(1) 이행강제금

- 이행강제금은 비대체적 작위 의무 또는 부작위 의무의 불이행 시, 그 의무를 이행할 때까지 반복적으로 금전적 부담을 부과하여 의무자에게 심리적 압박을 가함으로써 간접적으로 의무 이행을 강제하는 수단이다. 건축법상 시정 명령 불이행 시 부과될 수 있다. 이는 처분으로서 항고소송의 대상이 된다.

(2) 과징금

- 과징금은 행정법상 의무를 위반하여 경제적 이익을 얻었을 때, 그 위반 이익을 박탈하고 동시에 제재를 가하는 수단이다. 주로 시장 경제 질서와 관련된 법규 위반에 부과되며, 취소소송의 대상이 된다.

3. 비금전적 제재수단

(1) 공표

- 공표는 의무 위반 사실을 일반에게 공개하여 의무자에게 명예적 불이익을 줌으로써 의무 이행을 간접적으로 압박하는 수단이다. 위반 사실의 공표는 국민의 명예권 등 인권권 침해 우려가 크므로 법적 근거가 반드시 필요하며, 처분성이 인정될 수 있다.

(2) 과태료(행정질서벌)

- 과태료는 전통적 수단으로 분류되기도 하지만, 그 성격상 새로운 제재 수단으로 보는 경향도 있다.

(3) 영업 정지 등 각종 제재 처분

- 법령 위반에 따른 영업 정지, 취소 등은 전통적인 명령적 행정행위(하명)의 한 형태이지만, 실질적으로는 의무 위반에 대한 가장 강력한 제재 수단으로서의 역할을 한다.

IV. 실효성 확보수단 체계

- 행정상 실효성 확보수단은 그 목적과 성격에 따라 다음과 같이 체계화될 수 있다.

1. 의무 이행 확보 수단 (강제)

- 장래의 의무 이행을 목적으로 한다.

(1) 직접적 강제

- 대집행, 직접강제, 강제징수, 즉시강제 등

(2) 간접적 강제

- 이행강제금(집행벌) 등

2. 과거 위반에 대한 제재 수단 (벌칙)

- 과거의 의무 위반에 대한 응징을 목적으로 한다.

(1) 형사 제재

- 행정형벌(징역, 벌금)

(2) 질서 제재

- 행정질서벌(과태료)

(3) 금전적 제재

- 과징금(이익 박탈 및 제재)

3. 기타 수단

- 공표 등 비금전적 간접 제재 및 영업 정지와 같은 직접적 제재 처분.

V. 결론

- 행정상 실효성 확보수단은 행정법상의 의무 이행을 강제하고 행정목적을 달성하는 데 필수적이다. 대집행, 직접강제와 같은 전통적 수단은 직접적 강제력을 가지나 한계가 명확하여, 이행강제금, 과징금과 같은 새로운 금전적 · 간접적 수단이 중요하게 부각되었다. 이러한 수단들은 국민의 권리 · 의무에 직접적인 영향을 미치므로, 반드시 법률유보의 원칙과 비례의 원칙을 준수하여 행사되어야 하며, 국민은 위법한 행정처분에 대하여 행정쟁송을 통해 권리 구제를 받을 수 있다.

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제2절 대집행>

I. 대집행의 의의

1. 개념

- 대집행이란 행정법상 의무자가 공법상 대체적 작위 의무를 이행하지 아니하는 경우, 당해 행정청이 스스로 의무자가 해야 할 행위를 대신 행하거나 제3자로 하여금 대신 행하게 하고, 그 비용을 의무자로부터 징수하는 행정강제 수단을 말한다. 이는 의무 이행을 간접적으로 확보하는 수단으로, 행정의 실효성을 담보하는 핵심적인 제도이다.

2. 법적 근거

- 대집행은 국민의 권리·자유를 침해하는 행정강제이므로 반드시 법률의 근거가 필요하다. 일반법으로는 행정대집행법이 있으며, 이 법에 의하여 대집행이 가능하지 아니한 경우에도 개별법에 특별한 규정이 있으면 그 규정에 따라 대집행을 할 수 있다.

3. 직접강제와의 차이

- 대집행은 대체적 작위 의무의 이행 확보를 목적으로 한다는 점에서, 비대체적 작위 의무 또는 부작위 의무를 불이행할 때 의무자의 신체 또는 재산에 직접적인 실력을 가하여 의무 이행을 실현하는 직접강제와 구별된다. 대집행은 제3자를 통하여 집행할 수 있지만, 직접강제는 제3자를 통할 수는 없고 행정청 자신이 직접 집행하여야 한다. 또한, 대집행의 비용은 의무자가 부담하지만 직접강제는 행정청이 부담한다.

II. 대집행의 주체와 법률관계

1. 당해 행정청

- 대집행의 주체는 원칙적으로 해당 의무를 명한 당해 행정청이다. 행정대집행법 제2조는 대집행 주체를 당해 행정청으로 명시하고 있다. 이는 법률상 대집행을 수행할 권한을 가진 행정기관을 의미한다.

2. 다른 행정청

- 당해 행정청이 직접 대집행을 실행하기 어려운 경우에는 다른 행정청에 대집행을 위탁할 수 있다. 이 경우, 대집행의 권한은 여전히 위탁한 당해 행정청에 있으며, 위탁받은 다른 행정청은 단지 사실 행위를 대행하는 것에 불과하다. 대집행에 관한 모든 법적 책임은 당해 행정청에 귀속된다.

III. 대집행의 요건

- 대집행은 국민의 권리·자유에 대한 강제력이 크기 때문에, 행정대집행법 제2조에 따라 엄격한 요건을 충족해야만 발동될 수 있다.

1. 공법상의 대체적 작위 의무의 불이행

- 대집행이 발동되기 위해서는 먼저 의무가 공법상의 것이어야 하며, 그 의무가 대체적 작위 의무여야 한다.

(1) 공법상의 의무

- 사법상의 의무 불이행에는 대집행이 적용될 수 없다.

(2) 작위 의무

- 부작위 의무(하지 말아야 할 의무)의 위반은 대집행의 대상이 될 수 없으며, 행정청이 철거 명령 등 작위 의무를 부과해야 대집행이 가능해진다.

(3) 대체적 의무

- 의무자 본인이 아니더라도 제3자가 대신하여 이행할 수 있는 의무를 말한다. 건물 철거 의무 등은 대표적인 대체적 작위 의무이다. 비대체적 의무(영업 보고 의무)의 불이행에는 대집행 대신 이행강제금이 적용된다.

(4) 불이행

- 의무를 이행하지 않은 상태여야 한다.

2. 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기가 곤란할 것-보충성

- 대집행은 의무 이행 확보를 위한 행정청의 최후적·보충적 수단으로 기능한다. 즉, 다른 수단(비송사건절차법에 따른 과태료 부과 등)으로는 의무 이행을 확보하기가 어렵거나, 의무자의 자진 이행을 기대할 수 없는 경우에 한하여 대집행이 허용된다. 이 요건은 비례의 원칙과 관련하여 중요한 의미를 가진다.

3. 불이행을 방치함이 심히 공익을 해할 것

- 의무 불이행을 방치하는 것이 심히 공익을 해하거나 또는 인근 주민에게 중대한 위해를 끼칠 우려가 있는 경우에 한하여 대집행이 허용된다. 이 요건은 대집행 발동의 공익적 필요성을 담보하는 기준이다.

IV. 대집행의 절차

- 대집행은 법적 안정성과 의무자의 방어권 보장을 위해 4단계의 엄격한 절차를 거치는 것이 원칙이다.

1. 계고

- 계고는 의무자에게 의무 불이행 사실, 대집행의 내용 및 범위, 대집행에 필요한 비용 등을 문서로써 알리고, 일정한 기간까지 의무를 이행하지 않으면 대집행을 실시한다는 뜻을 사전에 통지하는 행위이다.

(1) 처분성

- 계고는 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 행위로서, 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다는 것이 판례의 태도이다. 다만, 반복된 계고의 경우는 이를 부정한다.

(2) 하자 승계

- 1차 계고와 2차 계고 사이에 하자의 승계 문제가 발생할 수 있다.

2. 대집행 영장에 의한 통지

- 의무자가 계고에 정한 기간 내에 의무를 이행하지 아니한 경우, 행정청은 대집행을 실행하기 전에 대집행 영장을 의무자에게 발부하고 통지해야 한다. 통지서에는 대집행을 행할 시기, 대집행을 행할 책임자의 성명 등을 명시해야 한다. 이 통지는 계고와 달리 처분성이 부정되며, 단순한 사실의 통지로 본다.

3. 대집행의 실행

- 대집행 영장에 기재된 시기에 대집행 책임자(또는 위임을 받은 자)가 현장에 출장하여 실제로 의무를 대신 이행하는 행위이다. 대집행의 실행은 사실 행위로서, 위법한 실행이더라도 그 자체로 처분성이 인정되지 않으며, 손해 발생 시 국가배상의 대상이 된다.

4. 대집행 비용의 징수

- 대집행에 소요된 비용은 의무자로부터 징수한다. 행정청은 비용에 관하여 국세 징수의 예에 따라 강제 징수할 수 있으며, 이 때 비용 납부를 명하는 납부 명령은 강제 징수 절차의 시작으로써 처분성이 인정된다.

V 결론

- 대집행은 공법상 대체적 작위 의무의 이행을 간접적으로 확보하는 행정강제 수단이다. 이는 법률의 근거, 보충성, 공익성의 요건을 엄격히 충족해야 하며, 계고-통지-실행-징수의 4단계 절차를 거쳐야 한다. 특히, 계고 처분의 취소소송 가능성 등 행정법상 쟁점이 중요하게 다루어진다.

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제3절 직접강제>

I. 행정상 직접강제의 의의

1. 개념

- 직접강제란 행정법상의 의무 불이행이 있는 경우, 행정청이 의무자의 신체나 재산에 직접적인 실력을 가하여 의무 이행이 있었던 것과 같은 상태를 실현하거나, 또는 의무 이행을 강제하는 행정강제 수단을 말한다. 이는 의무자에게 심리적 압박을 가하는 이행강제금이나 제삼자가 의무를 대신 이행하는 대집행과는 달리, 행정주체가 의무자에게 직접적으로 실력을 행사하여 의무의 내용을 실현한다는 특징을 가진다.

2. 구별 개념

(1) 대집행과의 구별

- 직접강제는 대체적 작위 의무뿐만 아니라 비대체적 작위 의무 및 부작위 의무의 불이행 시에도 적용될 수 있다는 점에서 대체적 작위 의무의 불이행 시에만 적용되는 대집행과 구별된다. 또한, 대집행은 제삼자가 의무를 대신 이행하는 간접적 강제 성격을 가지지만, 직접강제는 행정청이 직접 실력을 행사한다는 점에서 차이가 있다.

(2) 즉시강제와의 구별

- 직접강제는 원칙적으로 의무 불이행을 전제로 발동되지만, 즉시강제는 급박한 상황에서 의무를 명할 시간적 여유가 없거나 의무를 명하는 것만으로는 목적 달성이 곤란할 때, 의무 부과 없이 곧바로 실력을 행사하는 행위이다. 즉, 의무의 존재 여부가 두 행위를 구별하는 핵심 기준이 된다.

(3) 행정벌과의 구별

- 직접강제는 장래에 향하여 의무 이행을 확보하려는 행정강제 수단인 반면, 행정벌은 과거의 의무 위반에 대한 제재와 응징을 목적으로 하는 징벌적 수단이라는 점에서 성격이 근본적으로 다르다.

II. 직접강제의 근거 및 대상

1. 법적 근거

- 직접강제는 국민의 신체나 재산에 대한 침해가 매우 크고, 최후의 강제 수단으로 기능하므로, 일반법이 아닌 개별 법률에 명확하고 구체적인 근거가 있을 때만 허용된다. 대한민국 행정강제에는 일반법으로 행정대집행법만 존재하고, 직접강제에 대한 일반법은 부재한 상태이다. 따라서 직접강제는 출입국관리법에 따른 강제 퇴거 등 개별법의 명시적인 규정을 통해서만 발동될 수 있다.

2. 대상

- 직접강제는 행정법상 의무의 이행 확보를 위한 최후의 수단으로서, 다른 수단으로는 의무 이행 확보가 곤란한 경우에 적용된다.

(1) 비대체적 작위 의무의 불이행

- 의무자 본인만이 이행할 수 있는 의무(예 : 특정 서류 제출 의무)를 불이행한 경우.

(2) 부작위 의무의 위반

- 하지 말아야 할 의무(예 : 영업 정지 기간 중 영업 행위)를 위반한 경우.

(3) 대체적 작위 의무

- 이론적으로는 가능하나, 실제로는 대집행이 우선적으로 적용되므로, 대집행이 부적합하다고 판단될 때 극히 예외적으로 적용된다.

3. 효용

- 직접강제는 비록 국민의 기본권 침해 위험이 크지만, 그 효용성은 다음과 같다.

(1) 최후의 수단

- 다른 모든 행정강제 수단(대집행, 이행강제금 등)으로도 행정목적 달성을 할 수 없을 때, 실질적인 의무 이행을 확보하는 최종적인 수단이 된다.

(2) 행정목적 달성

- 특히 국민의 신체적 자유를 규율해야만 하는 영역(출입국관리법상 불법 체류자의 강제 퇴거)에서 행정목적 달성을 위해 반드시 필요한 수단이다.

III. 결론

- 직접강제는 행정상 의무 불이행 시 행정청이 의무자의 신체나 재산에 직접 실력을 가하여 의무 이행 상태를 실현하는 행정강제 수단이다. 이는 대집행 및 즉시강제와 구별되며, 국민의 기본권 침해 가능성이 가장 크기 때문에 반드시 개별 법률의 명확한 근거가 있어야만 발동될 수 있다. 또한, 직접강제는 보충성의 원칙이 철저히 요구되는 최후의 수단으로서, 법 집행의 실효성을 담보하는 중요한 역할을 수행한다.

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제4절 강제징수>

I. 행정상 강제징수의 의의

- 행정상 강제징수란 공법상의 금전 급부 의무(조세, 수수료, 과태료, 기타 부담금 등)를 이행하지 않는 경우, 행정청이 국세 또는 지방세 징수 등의 법규에 따라 의무자의 재산에 실력을 행사하여 그 의무를 이행시키는 행정강제 수단을 말한다. 이는 행정상 의무 이행 확보 수단 중 금전 급부 의무에 특화된 것으로, 행정의 실효성을 확보하는 중요한 역할을 수행한다. 강제징수는 행정대집행법상의 대집행과 마찬가지로 국민의 재산권에 직접적인 영향을 미치므로, 법치주의 원칙상 엄격한 요건과 절차에 따라 진행되어야 한다.

II. 행정상 강제징수의 근거

- 행정상 강제징수는 국민의 재산권을 침해하는 강제 수단이므로, 반드시 법률의 근거에 의해서만 발동될 수 있다는 법률유보의 원칙이 적용된다.

1. 일반법

- 대한민국에는 강제징수에 관한 일반법으로 국세징수법이 있으며, 지방세의 경우 지방세기본법과 지방세징수법이 그 절차적 근거를 규정한다. 공법상의 금전 채권은 개별 법률에 특별한 규정이 없는 한, 이들 법규를 준용하여 강제징수 절차를 거치게 된다.

2. 개별법

- 행정벌인 과태료의 부과 징수 절차는 질서위반행위규제법에 규정되어 있으며, 기타 부담금이나 변상금의 징수에 관하여 개별 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법령에 따른다.

III. 행정상 강제징수의 절차

- 행정상 강제징수는 의무 불이행을 전제로, 원칙적으로 독촉과 체납처분의 두 단계로 진행된다.

1. 독촉

- 독촉은 의무자가 납부 기한까지 공법상 금전 급부 의무를 이행하지 않는 경우, 행정청이 의무자에게 납부 기한을 다시 지정하여 기한 내에 이행하지 않으면 강제징수 절차(체납처분)에 들어갈 것을 예고하는 행위이다.

(1) 법적 성질

- 독촉 행위는 체납처분 절차의 시작을 알리고, 의무자에게 새로운 이행 기한을 지정하며, 불이행 시 재산권에 직접 영향을 미칠 강제징수를 예고한다는 점에서 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 공권력의 행사이다. 따라서 독촉 행위는 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다(반복된 독촉은 부정)는 것이 판례의 태도이다.

(2) 가산금 부과

- 독촉을 하는 경우에는 납부 기한이 지난 금액에 대하여 법령이 정하는 바에 따라 가산금이 부과된다. 가산금은 의무 불이행에 대한 일종의 제재 성격을 가진다.

2. 체납처분

- 체납처분은 독촉에도 불구하고 의무자가 지정된 기한까지 금전 급부 의무를 이행하지 않을 때, 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 강제적으로 체납액을 징수하는 일련의 절차를 말한다. 체납처분은 크게 압류, 매각(공매), 청산의 단계로 이루어진다.

(1) 압류

- 압류는 행정청이 체납자의 재산에 대한 사실상의 처분권을 박탈하고, 강제징수 목적물로 확보하는 행위이다.

① 법적 성질

- 압류는 체납자의 재산권 행사에 직접적인 제한을 가하여 권리·의무에 변동은 초래하므로, 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다.

② 압류의 대상

- 체납자의 재산(동산, 부동산, 채권, 유가증권 등)이 대상이 되나, 의무자의 최소한의 생계를 유지하는 데 필요한 재산(생활 필수품, 일정 금액 이하의 예금)은 압류할 수 없도록 법으로 보호된다.

(2) 매각(공매)

- 매각은 압류된 재산을 환가하여 현금으로 바꾸는 절차를 말한다. 주로 공매의 방법을 이용하며, 공매는 국가나 지방자치단체가 압류 재산을 일반에게 매각하는 행위이다.

① 공매 행위의 성질

- 공매는 압류 재산을 현금화하는 절차적 행위로서, 그 자체로는 국민의 권리·의무에 직접 변동을 초래하지 않는 사실 행위 또는 내부적 집행 행위로 해석되어 원칙적으로 처분성이 부정된다.

② 예외적 처분성

- 다만, 공매가 체납자의 권리에 중대한 영향을 미치거나 공매 통지 누락 등의 하자가 있을 경우, 공매 행위 자체의 위법성을 다툴 수 있는 당사자소송 또는 민사소송의 대상이 될 수 있다.

(3) 청산

- 청산은 매각(공매)을 통해 확보된 금액을 가지고 체납된 공법상 채권을 충당하고, 남은 금액이 있을 경우 체납자에게 돌려주는 절차이다. 이로써 강제징수 절차는 종료된다.

IV. 결론

- 행정상 강제징수는 공법상 금전 급부 의무의 이행을 확보하기 위한 핵심적인 행정강제 수단이다. 절차는 독촉과 체납처분(압류, 매각, 청산)으로 구성되며, 이 중 독촉과 압류는 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 행위로서 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다는 점이 행정쟁송법상 중요한 쟁점이다. 강제징수는 국민의 재산권을 침해하므로 법률의 근거와 적법 절차가 철저히 준수되어야 한다.

<입문-제7장.행정의 실효성 확보수단.제5절 즉시강제>

I. 행정상 즉시강제의 의의

1. 개념

- 즉시강제란 행정목적 달성을 위해 급박한 상황에서 미리 의무를 명할 시간적 여유가 없거나, 또는 의무를 명하는 것만으로는 그 목적을 달성하기 곤란할 때, 행정청이 직접 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하여 행정상 필요한 상태를 실현하는 행정작용을 말한다. 이는 다른 행정강제 수단과는 달리 의무의 존재를 전제로 하지 않거나 의무 부과 절차를 생략하고 곧바로 실력을 행사한다는 특징이 있다.

2. 구별 개념

(1) 행정상 강제집행과의 구별

- 행정상 강제집행(대집행, 직접강제, 강제징수)은 이미 발생한 의무의 불이행을 전제로 하여 장래의 의무 이행을 확보하기 위해 발동되는 행위이다. 반면, 즉시강제는 의무 불이행을 전제로 하지 않고 급박한 상황에서 행정의 즉각적인 필요에 의해 발동되는 조치라는 점에서 가장 명확하게 구별된다. 즉시강제는 행정목적 달성을 위해 응급적인 조치를 취하는 성격을 가진다.

(2) 행정조사와의 구별

- 행정조사(검사, 질문)는 행정주체가 정책을 수립하거나 직무를 수행하는 데 필요한 자료나 정보를 수집하기 위한 사실 행위이다. 반면, 즉시강제는 위험 제거와 같은 행정목적 달성을 직접적으로 실현하기 위해 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 강제적인 공권력 행사라는 점에서 그 목적과 성격이 다르다.

3. 법적 성질

- 즉시강제는 국민의 신체와 재산에 직접적인 영향을 미치는 공권력의 행사이므로, 행정행위 또는 행정작용으로 본다. 다만, 의무 부과 없이 곧바로 실력을 행사하는 사실 행위적 성격도 가지고 있어 법적 성질에 대해 다툼이 있다. 통설은 권력적 사실 행위로 보거나, 강제 처분의 일종으로 보아 처분성이 인정되는 것으로 해석한다. 처분성이 인정될 경우, 국민은 그 위법성에 대해 항고소송(특히 무효확인소송)을 제기하여 구제받을 수 있다.

4. 행정상 즉시강제의 근거

- 즉시강제는 국민의 기본권을 중대하게 침해할 가능성이 높으므로, 반드시 법률의 근거에 의해서만 발동되어야 한다는 법률유보의 원칙이 철저히 적용된다. 즉시강제에 관한 일반법은 없으며, 개별 법률에 근거하여 행해진다. 예를 들어 경찰관직무집행법상의 보호조치, 위험 발생 방지 조치 등이 있다. 이 경우, 국민의 권리 침해를 최소화하기 위해 비례의 원칙(최소침해의 원칙)이 특히 중요하게 요구된다.

II. 행정상 즉시강제의 종류

- 즉시강제는 그 대상이 되는 객체에 따라 대인적 강제, 대물적 강제, 대가택 강제로 분류된다.

1. 대인적 강제

- 대인적 강제란 사람의 신체나 행동의 자유에 실력을 행사하여 행정목적 달성을 즉시강제를 말한다. 이는 국민의 기본권 중에서도 신체의 자유를 직접적으로 제한하므로 가장 엄격한 법적 통제가 필요하다. 예를 들어 감염병 예방을 위한 환자의 강제 격리 또는 수용, 경찰관직무집행법상의 보호조치(술에 취하여 심신 상실 상태에 있는 자 등의 보호) 등을 들 수 있다.

2. 대물적 강제

- 대물적 강제란 사람의 소유물이나 기타 재산에 실력을 행사하여 행정목적 달성을 즉시강제를 말한다. 이는 주로 물건이 초래하는 위험을 제거하거나 손해를 예방하는 것을 목적으로 한다. 예를 들어 화재 발생 시 소방관이 주변 건물이나 물건을 파괴하여 불길의 확산을 막는 소방상의 조치, 교통 안전을 위해 위험한 물건을 일시적으로 수거하는 행위 등이 있다.

3. 대가택 강제

- 대가택 강제란 행정청이 국민의 주거지나 기타 사적인 공간(가택)에 출입하여 행정상 필요한 조치를 취하는 즉시강제를 말한다. 이는 주거의 자유를 침해하는 행위이므로 역시 엄격한 요건 하에서만 허용된다. 예를 들어 감염병 확산을 막기 위해 방역 당국이 감염 우려가 있는 가택에 강제 진입하여 소독을 실시하거나, 범죄 수사를 위해 법원의 영장 없이 긴급 상황에서 건물에 진입하는 행위 등이 있으나, 주거의 자유 보호를 위해 매우 제한적으로 인정된다.

III. 결론

- 즉시강제는 급박성과 보충성을 특징으로 하는 행정강제 수단으로, 의무의 존재를 전제로 하지 않고 곧바로 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 조치이다. 이는 처분성이 인정되어 국민은 항고소송을 통해 권리 구제를 받을 수 있으며, 국민의 기본권 침해 가능성이 높으므로 반드시 개별 법률의 명확한 근거와 비례의 원칙을 엄격히 준수하여 행사되어야 한다.

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제6절 이행강제금(집행법)>

I. 이행강제금의 의의

1. 개념

- 이행강제금이란 행정법상 의무자가 비대체적 작위 의무 또는 부작위 의무를 이행하지 아니하는 경우, 그 의무를 이행할 때까지 반복적으로 금전적 부담을 부과하여 의무자에게 심리적인 압박을 가함으로써 간접적으로 의무 이행을 강제하는 행정강제 수단을 말한다. 이는 의무 불이행에 대한 제재(벌)의 성격보다는 의무 이행의 확보를 주된 목적으로 하는 점에서 집행법이라고도 불린다.

2. 이행강제금(집행법)과 행정벌의 비교

- 이행강제금은 행정법상 의무 위반에 대한 제재라는 점에서 행정벌과 유사하나, 그 목적과 성질에서 명확히 구별된다.

(1) 목적

- 이행강제금은 장래에 향하여 의무자에게 심리적 압박을 가함으로써 의무의 이행을 확보하는 데 그 목적이 있다. 반면, 행정벌(행정형벌 및 행정징벌)은 과거의 의무 위반 행위에 대한 제재와 응징을 목적으로 한다.

(2) 병과 가능성

- 이행강제금은 의무 이행 확보가 주된 목적이므로, 과거의 의무 위반에 대한 제재로서의 행정벌과 병과하는 것이 허용된다. 즉, 위반 행위에 대해 과태료를 부과하고, 동시에 의무 이행을 촉구하기 위해 이행강제금을 부과할 수 있다.

(3) 일사부재리 원칙

- 이행강제금은 의무를 이행할 때까지 반복적으로 부과될 수 있으므로, 과거의 벌칙에 적용되는 일사부재리의 원칙이 적용되지 않는다. 행정벌은 일사부재리 원칙이 적용되어 동일 위반 행위에 대해 중복 처벌이 금지된다.

II. 이행강제금의 부과 요건 등

1. 이행강제금(집행법)의 부과 요건 및 절차

- 이행강제금은 건축법, 농지법 등 개별 법률에 명확한 근거가 있을 때만 부과될 수 있으며, 일반적인 부과 요건 및 절차는 다음과 같다.

(1) 법적 근거

- 이행강제금은 국민의 재산권을 침해하는 강제 수단이므로, 반드시 개별 법률의 명확한 근거가 있어야 한다.

(2) 비대체적 작위 의무 또는 부작위 의무의 불이행

- 이행강제금은 대집행이 불가능한 비대체적 작위 의무(영업 중지 의무, 신고 의무) 또는 부작위 의무의 불이행 시에만 적용된다. 대체적 작위 의무의 불이행에는 대집행이 원칙적으로 적용된다.

(3) 시정 명령 등의 선행

- 의무자에게 이행을 촉구하는 시정 명령, 철거 명령 등 행정청의 선행적인 처분이 있어야 하며, 의무자가 그 정해진 기간 내에 의무를 이행하지 않아야 한다.

(4) 부과 통지 및 의견 제출

- 행정청은 이행강제금을 부과하기 전에 그 부과 금액, 사유 등을 의무자에게 문서로 통지하고, 의견 제출 기회를 부여해야 한다. 이는 행정절차법상의 절차적 의무이다.

(5) 반복 부과

- 이행강제금은 의무자가 의무를 이행할 때까지 법이 정한 횟수 또는 기간 동안 반복적으로 부과될 수 있다.

2. 납부의 독촉

- 행정청이 이행강제금을 부과했음에도 불구하고 의무자가 이를 기한 내에 납부하지 않는 경우, 행정청은 독촉장을 발부하여 납부를 촉구할 수 있다. 이 독촉에도 불구하고 납부하지 않으면 국세 징수 또는 지방세 징수의 예에 따라 강제 징수 절차에 돌입할 수 있다.

3. 이행강제금(집행법) 부과와 성질

- 이행강제금의 부과는 국민의 재산권에 직접적인 영향을 미치는 공권력의 행사이다.

(1) 처분성

- 이행강제금 부과 행위는 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 행위이므로, 취소소송의 대상인 처분에 해당한다. 따라서 의무자는 이행강제금 부과 처분에 불복하는 경우 항고소송을 제기하여 다툴 수 있다.

(2) 사법 심사 범위

- 행정청이 법령에 따라 이행강제금 부과 여부를 결정하는 것은 재량 행위로 해석되는 경우가 많으므로, 법원은 그 위법성 심사에서 재량권 일탈·남용 여부에 한하여 심사한다.

III. 결론

- 이행강제금은 비대체적 의무의 이행 확보를 위한 간접적 강제 수단으로서, 행정벌과는 달리 의무 이행 확보에 주된 목적을 두는 집행법의 성격을 가진다. 이는 반복 부과와 행정벌과의 병과가 가능하다는 특징을 가지며, 그 부과 행위는 처분으로서 국민은 이에 대하여 취소소송을 통해 권리 구제를 받을 수 있다. 이행강제금 제도는 복잡해진 현대 행정에서 행정의 실효성을 담보하는 데 필수적인 수단으로 그 중요성이 크다.

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단. 제7절 행정조사>

I. 행정조사의 의의

1. 개념[행정조사기본법 제2조 제1호]

- 행정조사는 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 조사대상자에게 보고요구·자료제출요구 및 출석·진술요구를 행하는 활동을 말한다. 이는 행정조사기본법 제2조 제1호에 규정된 정의이다. 행정조사는 행정목적 실현을 위한 사전적인 준비 행위로서, 행정청이 특정한 권리의 의무 관계를 설정하거나 법적 효과를 직접적으로 발생시키는 행정행위와는 구별되는 성격을 가진다. 행정조사는 그 성격상 국민의 사생활이나 영업의 자유를 침해할 우려가 있으므로, 행정조사기본법에 따라 엄격한 절차적 통제를 받는다.

2. 즉시강제와 행정조사의 구별

- 행정조사는 국민의 신체나 재산에 실력을 행사할 수 있다는 점에서 즉시강제와 혼동될 수 있으나, 그 목적과 법적 성격에서 명확한 차이를 보인다.

(1) 목적

- 행정조사는 행정기관이 정책을 수립하거나 직무 수행에 필요한 자료 및 정보를 수집하는 데 그 목적이 있다. 이는 행정목적 달성을 위한 사전 준비 행위이다. 반면, 즉시강제는 급박한 상황에서 국민의 권리 의무에 직접 실력을 행사하여 위험을 제거하거나 행정목적 즉시 실현하는 데 목적이 있다.

(2) 강제성 및 법적 성격

- 행정조사는 원칙적으로 조사 대상자의 자발적인 협력을 전제로 하는 비권력적 행위이다. 다만, 조사 거부 시 과태료 등의 제재가 부과될 수 있다는 간접적 강제성은 존재한다. 이에 반해, 즉시강제는 의무를 부과할 시간적 여유 없이 국민의 신체나 재산에 직접적인 실력을 행사하는 권력적 행위이다.

(3) 법적 근거

- 행정조사는 행정조사기본법에 따라 최소한의 원칙과 중복 방지 원칙 등 일반적인 절차적 근거가 적용되나, 즉시강제는 국민의 기본권 침해가 크므로 반드시 개별 법률의 명확한 근거가 요구된다.

II. 행정조사의 법적 근거

- 행정조사는 국민의 권익을 침해할 가능성이 있으므로, 법률에 근거하여 이루어져야 한다. 이 근거는 행정기관의 조직과 권한을 정하는 조직법적 근거와 구체적인 권리·의무의 발생을 규율하는 작용법적 근거로 나눌 수 있다.

1. 조직법적 근거

- 조직법적 근거는 행정기관이 그 임무를 수행하는 데 필요한 일반적·추상적인 권한을 부여하는 근거를 말한다.

(1) 법적 성격

- 행정기관은 조직법에 규정된 고유의 임무 및 소관 사무를 수행하기 위하여 필요한 범위 내에서 행정조사를 실시할 수 있다. 이는 행정기관의 권한을 설정하는 근거가 된다.

(2) 예시

- 정부조직법이나 각 부처의 직제 등은 행정기관의 일반적인 조사 권한을 부여하는 조직법적 근거가 된다. 그러나 조직법적 근거만으로는 국민에게 조사에 응할 의무를 부과하거나 조사 거부 시 제재를 가할 작용법적 근거로는 부족하다.

2. 작용법적 근거

- 작용법적 근거는 행정조사 행위를 할 수 있는 구체적인 권한과 이에 대응하는 국민의 의무 및 제재에 관한 근거를 말한다.

(1) 법률유보의 원칙

- 행정조사가 강제적인 성격을 띠거나, 국민에게 조사에 응할 의무를 부과하고 조사 거부 시 제재(과태료)를 가하는 경우에는 반드시 개별 법률에 명확한 근거가 있어야 한다. 이는 국민의 권익을 보호하기 위한 최소한의 요건이다.

(2) 예시

- 세무조사 관련 법규는 납세 의무자에게 세무 조사에 응할 의무를 부과하고 거부 시 제재를 규정하는 구체적인 작용법적 근거이다. 또한, 행정조사 기본법은 행정조사에 관한 일반적 절차 규정으로서 작용법적 통제 기능을 수행한다. 행정조사기본법에 따라 행정기관은 조사 대상자의 자발적인 협력을 얻어 조사를 실시하는 것이 원칙이다.

III. 결론

- 행정조사는 행정목적 실현을 위한 사전적 정보 수집 활동으로서, 즉시강제와는 그 목적과 강제성에서 구별된다. 행정조사는 국민의 권익을 침해할 가능성이 있으므로, 행정기관의 권한을 정하는 조직법적 근거뿐만 아니라, 강제성을 수반하는 경우에는 국민에게 의무를 부과하는 작용법적 근거가 개별 법률에 명확히 규정되어야 한다. 이러한 법적 통제는 행정조사기본법을 중심으로 이루어지며, 이는 행정의 효율성과 국민의 권익 보호를 조화시키기 위한 필수적인 제도이다.

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제8절 행정벌>

I. 행정벌의 의의

1. 개념

- 행정벌은 과거의 행정법상 의무 위반 행위에 대하여 제재와 응징을 목적으로 부과되는 벌칙을 의미한다. 이는 행정 목적 달성을 위한 법규 준수 강제의 수단이며, 의무 위반에 대한 일반 예방적 효과를 통해 장래의 행정법규 준수를 유도하는 기능을 수행한다. 행정벌은 국민의 자유와 재산권을 제한하는 침익적 공권력 행사로서, 반드시 법률의 근거에 의해서만 부과될 수 있다는 법률유보의 원칙이 엄격하게 적용된다.

2. 특성

- 행정벌의 본질적인 특성은 다음과 같다.

(1) 과거 행위에 대한 제재

- 행정벌은 이미 종료된 과거의 행정법상 의무 위반 행위를 대상으로 하며, 그에 대한 응징을 목적으로 한다. 이는 장래의 의무 이행을 확보하려는 행정강제 구별되는 가장 큰 특징이다.

(2) 법률주의의 적용

- 행정벌은 국민의 자유와 재산권을 제한하므로, 처벌 대상 행위와 벌칙의 종류 및 정도는 반드시 법률로 정해져야 한다. 특히 행정형벌에는 형사법의 기본 원칙인 죄형법정주의가 준용된다.

(3) 책임주의의 원칙

- 고의나 과실 없이 발생한 의무 위반 행위에 대해서는 원칙적으로 벌칙을 부과할 수 없다. 이는 행정질서벌에도 질서위반행위규제법에 의하여 적용되는 원칙이다.

(4) 준법률행위적 성격

- 행정벌은 행정주체의 의사와 관계없이 법규가 정한 요건이 충족되면 법규가 정한 벌칙이 부과되는 준법률행위적인 성격이 강하다.

3. 구별 개념

(1) 행정강제와의 구별

- 행정강제 즉 대집행, 직접강제, 강제징수 등은 행정법상 의무 불이행에 대하여 장래에 향하여 의무 이행을 확보하는 것을 목적으로 하는 수단이다. 반면, 행정벌은 과거의 의무 위반에 대한 제재와 응징을 목적으로 한다. 이처럼 목적과 시점이 다르므로, 하나의 의무 위반 행위에 대하여 행정벌과 행정강제를 병과하는 것이 허용된다. 예를 들어, 무허가 건축물에 대한 철거 명령 불이행 시 대집행을 실시함과 동시에 벌금(행정형벌)을 부과할 수 있다.

(2) 이행강제금(집행벌)과의 구별

- 이행강제금(집행벌)은 비대체적 의무의 장래 이행을 확보하기 위해 반복적으로 금전적 압박을 가하는 간접적 강제 수단이다. 반면, 행정벌은 과거 위반에 대한 응징을 목적으로 한다. 이행강제금은 의무 이행 시 부과를 중지하지만, 행정벌은 과거 위반 사실에 대한 것이므로 의무 이행 여부와 관계없이 부과된다. 이 역시 목적이 다르므로 병과가 가능하다.

(3) 과징금과의 구별

- 과징금은 행정법상 의무 위반으로 얻은 경제적 이익을 박탈함과 동시에 제재를 가하는 새로운 형태의 금전적 제재 수단이다. 행정벌과 마찬가지로 과거의 위반 행위에 대한 제재 성격을 가지지만, 부당 이득의 환수라는 특수한 목적을 동시에 가진다는 점에서 순수한 응징만을 목적으로 하는 행정벌과는 다소 차이가 있다. 과징금 역시 행정벌과 병과하는 것이 허용된다.

II. 행정벌의 종류

- 행정벌은 그 제재의 강도와 부과 절차에 따라 행정형벌과 행정질서벌의 두 가지 유형으로 분류된다.

1. 행정형벌

(1) 개념 및 내용

- 행정형벌이란 행정법상의 의무 위반에 대하여 형법이 정하는 벌칙인 징역, 금고, 벌금, 구류, 과료, 몰수 등의 형사 처벌을 가하는 것을 말한다. 행정 목적 달성을 위해 형벌을 수단으로 이용한다는 의미에서 광의의 행정작용에 포함되지만, 사법부의 재판을 통해 부과된다는 특성을 가진다.

(2) 부과 주체 및 절차

- 행정형벌은 행정청이 직접 부과하지 않으며, 행정기관이 의무 위반 사실을 발견하면 수사기관에 고발하고, 검사의 공소 제기에 따라 사법부(법원)의 형사 재판을 통해 최종적으로 확정된다. 이 과정에서 행정기관은 수사에 필요한 자료를 제공하는 등의 협력 역할을 수행한다.

(3) 적용 원칙

- 행정형벌의 적용에는 형법의 원칙이 그대로 적용되거나 준용된다. 특히 다음과 같은 원칙이 적용된다.

① 죄형법정주의

- 처벌의 대상 행위와 벌칙의 종류는 법률로 명확히 규정되어야 한다.

② 책임주의

- 고의 또는 과실이 없는 행위에 대해서는 벌을 부과할 수 없다.

③ 일사부재리의 원칙

- 한 번 판결이 확정된 사건에 대해서는 다시 처벌할 수 없다. 따라서 행정형벌이 부과된 행위에 대해서는 행정질서벌(과태료)을 다시 부과할 수 없다.

2. 행정질서벌

(1) 개념 및 내용

- 행정질서벌이란 행정법상의 경미한 의무 위반에 대하여 과태료를 부과하는 것을 말한다. 이는 행정상의 질서 유지를 목적으로 하며, 형벌이 아니므로 형법이 적용되지 않으며, 전과가 남지 않는다. 행정질서벌에 관한 일반법으로 질서위반행위규제법이 있다.

(2) 부과 주체 및 절차

- 행정질서벌은 원칙적으로 행정청이 위반 행위자에게 과태료 부과 처분의 형식으로 부과한다. 이 부과 처분은 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치므로 행정행위(처분)의 성격을 가진다. 행정청의 과태료 부과 처분에 불복하는 의무자는 행정청에 이의를 제기할 수 있다. 이의 제기가 있는 경우 행정청의 처분은 효력을 상실하고, 사건은 관할 법원으로 이송된다. 법원에서는 비송사건절차법에 따른 과태료 재판을 통해 과태료 부과 여부와 금액을 최종적으로 결정하게 된다. 이와 같이 불복 절차에 사법부가 관여함으로써 국민의 권익을 보호하고 있다.

(3) 적용 원칙

- 행정질서벌은 형벌은 아니지만, 질서위반행위규제법에 따라 다음과 같은 주요 원칙이 적용된다.

① **법률주의**

- 과태료 부과는 법률에 근거해야 한다.

② **책임주의**

- 고의 또는 과실이 없는 경우에는 과태료를 부과할 수 없다.

③ **일사부재리의 원칙**

- 행정질서벌의 경우, 법원의 과태료 재판이 확정되면 동일한 행위에 대해 다시 과태료를 부과할 수 없다.

Ⅲ **결론**

- 행정벌은 과거의 의무 위반 행위에 대한 응징과 제재를 목적으로 하는 실효성 확보 수단이다. 행정형벌은 사법 절차를 통해 징역, 벌금 등 강력한 형벌이 부과되고, 행정질서벌은 행정청의 과태료 부과를 원칙으로 하며 불복 시 법원의 재판을 거치게 된다. 행정벌은 그 본질상 행정강제와 병과가 가능하며, 국민의 기본권 침해와 직결되므로 법률유보의 원칙과 책임주의가 엄격하게 적용된다.

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제9절 새로운 실효성 확보수단>

I. 개설

- 새로운 실효성 확보수단이란 전통적인 행정강제(대집행, 직접강제, 즉시강제)나 행정벌(행정형벌, 행정질서벌)만으로는 복잡하고 전문화된 현대 행정의 실효성을 확보하는 데 한계가 드러남에 따라 등장한 수단들을 말한다. 이는 특히 비대체적 의무 위반이나 경제적 이익이 큰 불법 행위에 효과적으로 대응하고, 국민의 기본권 침해를 최소화하면서도 행정 목적을 달성하기 위해 고안되었다. 주요 유형으로는 과징금, 부과금, 가산세·가산금, 명단공표, 관허사업의 제한, 공급거부 등이 있다.

II. 과징금

1. 의의

- 과징금이란 행정법상의 의무 위반 행위를 통해 경제적 이익을 얻은 경우, 그 위반으로 얻은 이익을 박탈함과 동시에 의무 위반에 대한 제재(벌)를 가하기 위하여 부과하는 금전적 부담을 말한다. 이는 본래 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 시장 지배적 지위 남용 등 불공정 거래 행위의 억제에 위해 도입된 수단이나, 현재는 환경, 보건, 금융 등 다양한 분야의 행정법규에서 사용되고 있다. 과징금은 과거의 의무 위반을 대상으로 한다는 점에서 행정벌과 유사하지만, 위반 이익의 환수라는 특수한 목적을 동시에 가진다는 점에서 순수한 응징만을 목적으로 하는 행정벌과 구별된다. 또한, 의무 이행 확보를 목적으로 하는 이행강제금과도 구별되며, 목적이 다르므로 행정벌이나 이행강제금과 병과하는 것이 허용된다. 과징금 부과 행위는 국민의 권리 의무에 직접 영향을 미치므로 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다.

2. 종류

- 과징금은 그 성격과 목적에 따라 다음과 같이 분류될 수 있다. 현실적으로 과징금은 아래 두 가지 성격을 모두 가지는 경우가 일반적이며, 행정법규마다 그 강조점이 다를 수 있다.

(1) 금전적 제재금

- 이는 위반 행위를 억제하는 벌과금의 성격이 강하다. (예 : 공정거래법상의 과징금)

(2) 이득 환수금

- 이는 위반 행위로 얻은 부당한 경제적 이익을 박탈하는 데 주된 목적이 있다.

III. 부과금

1. 개념

- 부과금이란 행정주체가 특정 사업의 수행에 필요한 비용을 충당하거나, 특정 공익 목적을 달성하기 위하여 특정 의무자나 수익자에게 부과하는 금전을 말한다. 부과금은 주로 환경 개선, 교통 유발 등의 영역에서 사용되며, 이는 조세와는 달리 특정한 목적을 위해 징수된다는 특징이 있다. 이는 행정청의 행위로 처분에 해당한다.

2. 과징금과 부과금의 구별

- 과징금은 의무 위반 행위에 대한 제재 및 부당이득에 대한 환수를 목적으로 하는 반면, 부과금은 의무 위반 행위를 전제로 하지 않고, 특정 사업의 비용 충당 또는 공익적 부담의 분담을 목적으로 한다. 즉, 과징금은 제재적 성격이 강하지만, 부과금은 부담금적 성격이 강하다. 예를 들어, 교통 혼잡을 유발하는 시설물에 부과하는 교통유발부담금은 부과금에 해당하며, 이는 위반 행위와 무관하게 부과된다.

IV. 가산세·가산금·증가산금

1. 가산세

- 세법상 의무를 성실하게 이행하지 아니한 경우, 세법이 정하는 바에 따라 본세에 가산하여 징수하는 금액을 말한다. 가산세는 세법상 의무 이행을 확보하는 목적 외에도, 불성실한 의무 이행에 대한 제재의 성격도 동시에 가지는 것이 특징이다. 가산세는 본세와 함께 징수되며, 이는 처분에 해당하여 항고소송의 대상이 될 수 있다.

2. 가산금

- 국세 또는 지방세의 납부 기한까지 납부하지 아니한 경우에 연체 이자의 성격으로 징수하는 금액을 말한다. 이는 의무 불이행에 대한 지연 이자 성격과 제재 성격을 동시에 가진다. 원칙적으로 법률 규정에 의해 당연히 발생하는 것으로 보아 처분성을 인정하지 않는다.

3. 증가산금

- 납부 기한이 지난 후 일정 기간이 지나도 계속 납부하지 않을 경우, 가산금에 더하여 징수하는 금액을 말한다. 장기간의 의무 불이행에 대한 강화된 제재의 성격을 가진다. 가산금과 같이 별도의 처분성을 인정하지 않는 것이 일반적이다.

V. 명단 공표

1. 개념

- 명단공표란 행정주체가 법령상의 의무를 위반한 사실 또는 의무 불이행 사실을 일반에게 공개하여 의무자에게 명예적 불이익을 줌으로써, 간접적으로 의무 이행을 압박하거나 재발을 방지하는 새로운 행정강제 수단이다. 이는 특히 공익과 관련된 중대한 의무 위반 (예 : 고액 체납자, 부정식품 제조 등) 분야에서 사용된다.

2. 법적 성질-비권력적 사실 행위

- 명단 공표는 그 성격상 국민의 명예권이나 인격권을 침해할 수 있지만, 행정청이 직접 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 권력적 작용은 아니다. 이는 단순히 사실을 외부에 알리는 행위로서, 행정법적으로는 비권력적 사실 행위로 보는 것이 일반적이다. 따라서 원칙적으로 처분성이 부정되어 취소소송의 대상이 되지 않는다. 다만, 공표로 인해 법률상 이익이 침해될 경우 국가배상 청구나 헌법소원의 대상이 될 수는 있다. 명단 공표를 하기 위해서는 법률의 명확한 근거가 반드시 필요하다.

VI. 관허사업의 제한

1. 개념

- 관허사업의 제한이란 행정주체의 허가, 인가, 특허 등 (관허)을 받아 영위하는 사업자가 법령상의 의무를 위반하거나 특정 조건을 충족하지 못할 경우, 행정청이 그 관허를 취소, 정지, 철회하는 것을 말한다. 이는 행정법규 위반에 대한 가장 강력한 제재 수단 중 하나이며, 사업자의 영업의 자유를 직접적으로 제한한다. 따라서 처분성이 인정되어 항고소송의 대상이 된다.

2. 종류

- 관허사업의 제한은 그 형태에 따라 다음과 같이 구분된다.

(1) 관허의 철회

- 이미 부여된 관허를 장래에 향하여 소멸시키는 행위이다.

(2) 관허의 취소

- 이미 부여된 관허를 소급하여 효력을 소멸시키는 행위이다. 다만, 신뢰 보호의 원칙상 소급 취소는 제한적으로 인정된다.

(3) 영업 정지

- 일정 기간 동안 사업의 영위를 정지시키는 행위이다.

3. 한계

- 관허사업의 제한은 국민의 생계 수단인 영업의 자유를 직접적으로 제한하므로, 비례의 원칙이 엄격하게 적용된다. 위반의 정도에 비해 과도하게 관허를 취소하는 것은 재량권의 일탈·남용으로 위법하게 될 수 있다. 행정청은 최소한의 침해 수단인 영업 정지 등을 우선적으로 고려해야 한다.

VI. 공급 거부

1. 개념

- 공급 거부란 행정주체가 행정 목적을 달성하기 위하여 법령상의 의무를 위반한 자에게 전기, 수도, 가스 등 공공 서비스의 공급을 거부하거나 제한하는 행위를 말한다. 이는 의무자에게 불편을 초래함으로써 간접적으로 의무 이행을 강제하는 수단이다.

2. 법적 성질

- 공급 거부는 행정청이 법령에 근거하여 서비스 공급 계약을 일방적으로 중단하는 행위이다. 이는 국민의 생활에 필수적인 요소의 이용을 제한하므로, 단순한 사법상의 계약 해지로 볼 수 없다. 판례는 특정 공급 거부 행위가 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 처분성을 인정하여 항고소송의 대상이 될 수 있다고 본다. 이는 국민의 기본적 생활을 보호하려는 관점에서 중요한 법적 해석이다.

VII. 결론

- 과징금, 명단공표, 관허사업의 제한 등으로 대표되는 새로운 실효성 확보수단은 전통적인 행정강제 및 행정벌의 한계를 극복하고 복잡한 행정 현실에 효율적으로 대응하기 위해 등장하였다. 과징금은 위반 이익 환수와 제재를 병행하고, 명단공표는 비권력적 사실 행위로서 간접적인 압박을 가한다. 관허사업의 제한은 가장 강력한 제재 수단으로서 비례의 원칙이 엄격히 적용된다. 이러한 새로운 수단들 역시 국민의 권익을 침해할 수 있으므로, 반드시 법률의 근거에 따라 비례의 원칙 등 행정법의 일반 원칙을 준수하여 행사되어야 하며, 국민은 위법한 처분에 대하여 행정쟁송을 통해 구제를 받을 수 있다.

<입문-제8장 행정쟁송-제1절 행정심판 개관>

I. 행정심판의 의의

1. 개념

- 행정심판이란 행정청의 위법·부당한 처분이나 공권력의 행사·불행사 등으로 인하여 권리나 이익을 침해받은 국민이 행정청 또는 상급 행정기관에 그 처분의 취소·변경 등을 청구하여 신속하고 간이하게 구제받을 수 있도록 하는 행정기관 내부의 심판 절차를 말한다. 행정심판은 행정부 내부에서 스스로 행정 통제를 실현하고, 사법 절차인 행정소송에 앞서 행정의 전문성과 효율성을 살려 분쟁을 해결한다는 의의를 가진다. 행정심판에 관한 일반법은 행정심판법이다.

2. 행정심판과 이의신청의 구별

- 이의신청은 행정청의 위법·부당한 처분으로 인해 권리나 이익이 침해된 자가 처분청에 그 시정을 구하는 신청을 말한다. 행정심판과 이의신청은 모두 행정기관에 대한 불복 절차이지만, 다음과 같은 점에서 구별된다.

(1) 법적 근거

- 행정심판은 행정심판법이라는 일반법에 근거하여 통일적인 절차에 따라 진행된다. 반면, 이의신청은 개별법에서 특정 처분에 대한 불복 절차로 규정될 때만 인정되는 특별 불복 절차이다.

(2) 심판 기관

- 행정심판은 원칙적으로 처분청의 직급 상급 행정기관에 설치된 행정심판위원회가 독립적으로 심리·재결한다. 그러나 이의신청은 주로 처분청 자신이 하거나, 처분청의 내부 기관이 심사한다.

(3) 불복 대상의 범위

- 행정심판은 처분의 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사할 수 있다. 그러나 이의신청은 개별 법규에 명시된 범위 내에서만 심사가 가능하며, 주로 위법성에 국한되는 경우가 많다.

(4) 전치주의 적용

- 행정심판은 행정소송 제기 요건인 필요적 행정심판 전치주의가 적용될 수 있지만, 이의신청은 원칙적으로 행정소송의 제기에 영향을 미치지 않는다. 다만, 개별법에서 이의신청을 거치도록 규정한 경우에는 예외이다.

3. 행정심판과 행정소송의 구별

- 행정심판과 행정소송은 모두 행정작용에 대한 국민의 권리 구제 절차이지만, 다음과 같은 점에서 근본적으로 다르다.

(1) 심판 기관

- 행정심판은 행정부 소속의 행정심판위원회에서 관장하는 행정 통제 절차이다. 반면, 행정소송은 사법부 소속의 법원에서 관장하는 사법 통제 절차이다.

(2) 심판 범위

- 행정심판은 처분의 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사할 수 있다. 행정청의 재량 행위에 대해서도 행정심판위원회는 그 부당성을 이유로 취소나 변경의 재결을 할 수 있다. 그러나 행정소송은 원칙적으로 처분의 위법성만을 심사하며, 재량 행위에 대해서는 재량권의 일탈·남용 여부만을 판단한다.

(3) 절차의 성격

- 행정심판은 간이·신속성을 중시하여 서면 심리를 원칙으로 하고 구술 심리를 보충적으로 이용하며, 비공개 진행이 가능하다. 행정소송은 공개 재판을 원칙으로 하며, 증거 조사 등 엄격한 법적 절차에 따라 진행된다.

(4) 효력

- 행정심판의 재결은 당사자와 관계 행정청을 기속하는 효력 외에 처분청의 재처분 의무를 발생시키는 등 강력한 효력을 가지며, 특히 위원회가 스스로 처분을 취소하거나 변경할 수 있는 형성력을 가진다. 행정소송의 판결은 관계 행정청을 기속하는 효력 외에 기판력 등을 가진다.

II. 행정심판의 종류

1. 일반적 종류

- 행정심판은 그 심판 기관의 성격에 따라 다음과 같이 분류된다.

(1) 일반 행정심판

- 일반 행정심판은 행정심판법에 근거하여 행정심판위원회가 행하는 심판을 말한다. 이는 행정심판의 가장 보편적인 형태이다.

(2) 특별 행정심판

- 특별 행정심판은 개별 법률에서 행정심판법과는 다르게 특별한 사항을 규정하여 행하는 심판을 말한다. 이 경우에도 행정심판법의 기본적인 원칙과 절차가 준용된다. 특별 행정심판의 존재는 행정심판법의 적용을 배제하지 않는 것이 원칙이나, 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 예외적으로 배제될 수 있다.

2. 행정심판법상 종류

- 행정심판법 제5조는 행정심판의 유형을 세 가지로 규정하고 있다.

(1) 취소심판

- 취소심판은 행정청의 위법 또는 부당한 처분의 취소 또는 변경을 구하는 행정심판이다. 행정소송의 취소소송에 대응하는 개념으로, 가장 흔하게 제기되는 심판 유형이다.

(2) 무효등확인심판

- 무효등확인심판은 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부의 확인을 구하는 행정심판이다. 행정소송의 무효등확인소송에 대응하는 개념으로, 주로 처분의 중대하고 명백한 하자를 다룰 때 이용된다.

(3) 의무이행심판

- 의무이행심판은 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 의무의 이행을 구하는 행정심판이다. 행정소송에는 명확하게 대응하는 소송 유형이 없었으나, 행정심판의 실효성을 높이기 위해 도입된 심판 유형이다. 거부처분뿐만 아니라 행정청이 아무런 처분도 하지 않고 있는 부작위에 대해서도 제기될 수 있다.

III. 행정심판의 절차

- 행정심판 절차는 국민의 신속한 권리 구제를 위해 비교적 간소하게 진행된다.

1. 청구인 자격 및 피청구인

- 청구인은 처분의 상대방 등 권리 또는 이익을 침해받은 자가 된다. 피청구인은 원칙적으로 처분청 또는 부작위의 주체가 된다.

2. 청구 기간

- 행정심판은 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내 또는 처분이 있었던 날로부터 180일 이내에 제기되어야 한다. 이는 국민의 권리 구제와 행정의 안정성 확보를 조화시키기 위한 것이다.

3. 심리 방식

- 행정심판위원회는 원칙적으로 서면 심리를 통해 심리를 진행한다. 다만, 당사자의 신청이나 행정심판위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 구술 심리를 할 수 있다.

4. 재결

- 행정심판의 심리를 마친 후, 행정심판위원회는 최종적으로 재결을 한다. 재결의 종류에는 심판 청구가 부적법(청구요건 불충족)할 때 내리는 각하 재결, 심판 청구의 이유가 없다고 판단할 때 내리는 기각 재결, 심판 청구가 이유 있다고 판단할 때 내리는 인용 재결 등이 있다.

5. 재결의 효력

- 재결은 당사자와 관계 행정청을 기속하며, 처분을 취소하거나 변경하는 인용 재결은 처분청에게 재처분 의무를 발생시킨다. 특히 행정심판위원회는 스스로 처분의 효력을 형성하거나 취소할 수 있는 형성력을 가진다.

IV. 결론

- 행정심판은 행정청의 위법·부당한 처분 등에 대한 행정부 내부의 자율적인 통제 및 권리 구제 절차이다. 이는 행정심판법을 일반법으로 하여 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판의 세 가지 유형으로 나뉜다. 행정심판은 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사할 수 있어 행정소송에 비해 폭넓은 권리 구제가 가능하며, 간소하고 신속한 절차를 통해 국민의 권익을 두텁게 보호하는 역할을 수행한다.

<입문-제8장 행정쟁송.제2절 행정소송 개관>

I. 행정소송의 의의

1. 개념

- 행정소송이란 행정청의 위법한 처분이나 공권력의 행사·불행사 등으로 인하여 권리나 이익을 침해받은 국민이 사법부인 법원에 제소하여 그 위법성을 다투고 구제를 받는 절차를 말한다. 행정소송에 관한 일반법은 행정소송법이다. 행정소송은 행정부 내부의 통제 절차인 행정심판과 구별되는 사법부의 통제 절차이다.

2. 목적

- 행정소송은 행정 권력에 대한 사법 통제를 통해 국민의 권익을 최종적으로 보장하고, 행정의 적법성을 확보하여 법치 행정을 실현하는 데 궁극적인 목적이 있다.

II. 행정소송의 종류

1. 내용에 따른 분류

(1) 주관적 소송

- 주관적 소송이란 국민의 권리 또는 이익의 보호를 목적으로 제기하는 소송을 말한다. 행정소송법은 주관적 소송으로서 항고소송과 당사자소송을 규정하고 있으며, 이는 국민의 권리 구제를 주된 목적으로 하는 행정소송의 핵심적인 형태이다.

(2) 객관적 소송

- 객관적 소송이란 개인의 권리 또는 이익의 보호와 관계없이 행정법 질서의 유지와 적정한 집행을 보장하기 위하여 제기하는 소송을 말한다. 행정소송법은 객관적 소송으로서 민중소송과 기관소송을 규정하고 있다. 민중소송은 국가 또는 공공단체의 기관이 아닌 일반 국민이 제기하는 소송이며, 기관소송은 국가 또는 공공단체의 기관 상호 간에 권한의 존부 또는 행사에 관하여 다툼이 있을 때 제기하는 소송이다.

2. 성질에 따른 분류

(1) 형성의 소

- 형성의 소란 법원의 판결에 의하여 새로운 법률 관계를 형성시키거나 기존의 법률 관계를 변경·소멸시키는 것을 목적으로 하는 소송이다. 행정소송 중 취소소송은 법원의 판결로 행정처분을 취소하여 그 효력을 소멸시킨다는 점에서 대표적인 형성의 소에 해당한다.

(2) 이행의 소

- 이행의 소란 법원의 판결로 상대방에게 일정한 행위를 할 것을 명하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 행정소송에서 의무 이행을 직접 구하는 소송은 행정소송법상 명시적으로 인정되지 않으며, 당사자소송 중 공법상 금전 급부 청구 소송 등이 이에 해당할 수 있다.

(3) 확인의 소

- 확인의 소란 법원의 판결에 의하여 특정한 권리 또는 법률 관계의 존부를 확인하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 행정소송 중 무효등확인소송은 처분의 효력 유무나 존재 여부를 확인한다는 점에서 대표적인 확인의 소에 해당한다. 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 위법하다는 사실 자체를 확인하는 소송이다.

III. 행정소송의 절차(취소소송)

- 취소소송은 행정소송의 중심적인 유형으로서, 그 절차는 다음과 같다.

1. 피고 적격

- 취소소송의 피고는 원칙적으로 그 처분을 행한 행정청이 된다.

2. 제소 기간

- 취소소송은 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내 또는 처분 등이 있었던 날부터 1년 이내에 제기되어야 한다. 이는 국민의 권리 구제와 행정의 안정성 확보를 조화시키기 위한 것이다.

3. 관할 법원

- 피고의 소재지를 관할하는 행정법원이 관할 법원이 된다.

4. 심리

- 법원은 당사자가 제출한 증거와 자료를 바탕으로 처분의 위법성을 심리한다. 법원은 직권으로 증거 조사를 할 수 있는 직권 탐지주의가 일부 가미되어 있다.

5. 판결

- 심리 결과에 따라 각하, 기각, 인용 등의 판결을 내린다.

IV. 처분 등 개념 요소

- 취소소송의 대상이 되는 처분 등의 개념은 행정소송법 제2조 제1호에 규정되어 있으며, 이는 항고소송의 대상을 한정하는 핵심적인 요소이다.

1. 행정청의 행위

- 처분은 행정청이 행하는 행위여야 한다. 여기서 행정청이란 국가 또는 공공단체의 의사를 외부에 표시할 권한을 가진 기관을 말한다.

2. 구체적 사실에 관한 행위

- 처분은 구체적 사실에 관한 행위여야 하며, 일반적이고 추상적인 규정인 법규 명령은 원칙적으로 처분이 될 수 없다. 다만, 일반적·추상적 규정이라도 그 규정만으로 직접적이고 구체적인 권리 의무에 영향을 미치는 경우(집행 행위의 매개 없이)에는 예외적으로 처분성이 인정될 수 있다(법규명령의 처분성).

3. 법 집행 행위(규율 행위)

- 처분은 법률을 집행하는 행위, 즉 법규에 의한 규율 행위여야 한다. 법 집행과 관계없는 사실 행위는 원칙적으로 처분이 될 수 없다. 다만, 권력적인 사실 행위는 예외적으로 처분성이 인정될 수 있다.

4. 공권력의 행사

- 처분은 행정청이 우월한 지위에서 행하는 공권력의 행사여야 한다. 사법상의 계약이나 공법상의 계약은 원칙적으로 처분이 아니다.

5. 거부 행위-소극적 처분

- 행정청의 거부 행위는 국민에게 법규상 또는 조리상 신청권이 인정되고, 그 거부 행위가 신청인의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 소극적 처분으로 인정되어 취소소송의 대상이 된다.

6. 그 밖에 이에 준하는 행정작용

- 행정소송법은 처분 외에 그 밖에 이에 준하는 행정작용도 포함한다고 규정하고 있다. 이는 행정청의 처분은 아니지만, 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 공권력 행사를 포괄적으로 소송 대상으로 인정하려는 취지이다.

V. 취소소송의 심리

1. 개념

- 취소소송의 심리란 법원이 처분 등의 위법성 유무를 판단하기 위하여 사실 관계를 확정하고 법률을 해석·적용하는 절차를 말한다. 행정소송은 민사소송과 달리 공익성을 고려하여 변론주의가 적용되면서도 직권탐지주의가 일부 가미된 형태를 취한다.

2. 심리의 내용

(1) 위법성 심사

- 법원은 행정청의 처분이 법률에 위반되는지 여부만을 심사한다. 행정심판과 달리 처분의 부당성은 심사 대상이 되지 않는다. 처분의 위법성은 처분 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단하는 것이 원칙이다(처분 시 기준설).

(2) 재량 행위의 심사

- 행정청에게 법률상 재량권이 부여된 경우에는, 법원은 행정청의 재량 행위가 재량권의 한계를 넘거나 남용되었는지 여부만을 심사한다. 법원이 재량권 행사의 내용까지 직접 심사하여 대체하는 것은 권력 분립의 원칙에 위반되므로 허용되지 않는다.

(3) 직권 심리

- 법원은 필요하다고 인정할 때에는 당사자가 주장하지 않은 사항에 대해서도 직권으로 심리할 수 있는 직권 심리권을 가진다. 이는 공익과 관련된 행정 사건의 특성을 반영한 것이다.

VI. 취소소송의 판결

1. 판결의 의의

- 판결이란 법원이 소송 절차를 통해 사건을 심리한 후, 그 소송에 대한 최종적인 판단을 외부에 표시하는 행위를 말한다. 취소소송의 판결은 국민의 권리 구제와 행정의 적법성 확보에 결정적인 영향을 미친다.

2. 판결의 종류

(1) 소송판결(각하판결)

- 소송요건의 적부에 대한 판결로서 요건심리의 결과, 당해 소송을 부적합한 것으로 각하하는 판결이다.

(2) 본안판결

- 본안심리(= 처분의 위법성 여부 심리)의 결과, 청구의 전부 또는 일부를 인용하거나 기각하는 판결이다(인용판결·기각판결).

(3) 기타

- 전부판결·일부판결, 중간판결·종국판결이 있다.

3. 종국 판결

(1) 각하판결

- 각하판결은 소송 요건을 갖추지 못하여 본안 심리를 할 수 없을 때, 본안에 대한 판단 없이 소송을 배척하는 판결이다. (제소 기간 초과, 원고 적격 흠결 등)

(2) 기각판결

- 기각판결은 소송 요건은 갖추었으나, 본안 심리 결과 처분의 위법성이 인정되지 않을 때 원고의 청구를 배척하는 판결이다.

(3) 인용판결

- 인용판결은 소송 요건을 갖추었고, 본안 심리 결과 처분의 위법성이 인정될 때 원고의 청구를 받아들여 처분을 취소하는 판결이다. 법원은 취소 판결 외에 처분의 변경 판결도 내릴 수 있다.

4. 판결의 방식과 절차

- 판결은 원칙적으로 공개 변론을 거쳐 선고되며, 판결서에는 주문과 이유를 명시해야 한다. 판결이 선고되면 당사자에게 송달된다.

5. 판결의 효력

(1) 기속력

- 기속력이란 판결의 취지에 따라 당사자인 행정청과 관계 행정청이 동일한 위법을 반복하지 않도록 구속하는 효력을 말한다. 행정청은 판결의 취지에 따라 재처분할 의무를 지게 된다.

(2) 기판력

- 기판력이란 확정된 판결의 내용이 후소에 구속력을 가지는 것을 말한다. 취소소송의 판결 역시 기판력을 가지며, 동일한 소송물에 대해서는 다시 소송을 제기할 수 없다.

(3) 형성력

- 형성력이란 취소 판결이 확정되면 그 판결에 의해 행정 처분의 효력이 소멸되는 것을 말한다. 취소 판결은 그 처분을 받은 당사자 외의 제3자에 대해서도 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다.

VI. 결론

- 행정소송은 행정청의 위법한 공권력 행사에 대한 사법 통제로서 국민의 권익을 구제하는 최종적인 절차이다. 행정소송은 항고소송, 당사자소송, 민중소송, 기관소송으로 분류되며, 항고소송중 취소소송은 행정소송의 가장 중심이며, 법원의 위법성 심사를 거쳐 형성력, 기속력을 가지는 판결을 통해 행정의 적법성을 확립한다.

<제1장 행정소송의 일반론.제1절 행정소송의 일반론 개관>

I. 행정소송의 의의

1. 개념

- 행정소송은 행정기관의 위법한 공권력 행사 등으로 인하여 침해된 국민의 권리 또는 이익을 구제하고, 공법상의 분쟁을 해결함으로써 행정의 적법성을 확보하기 위하여 법원에 제기하는 소송이다. 우리나라 행정소송법 제1조는 행정소송의 목적을 행정청의 위법한 처분 그 밖의 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함에 둔다고 명시한다. 이는 행정소송이 단순한 사인의 권리 구제를 넘어 국가 행정작용의 적법성 확보라는 공익적 목적을 동시에 추구함을 보여준다. 행정소송은 행정 법규의 적용 문제를 다루는 공법상의 쟁송이며, 그 대상은 주로 행정청의 우월적 지위에서 이루어지는 행정처분에 대해 집중된다. 따라서 행정소송은 일반적인 사법 관계를 다루는 민사소송과는 구별되는 특유한 소송 형식과 절차를 가진다.

2. 민사소송과의 구별

- 행정소송은 민사소송과 달리 공법 관계의 특수성을 반영하는 다양한 차이점을 보인다. 이러한 구별은 소송의 대상, 당사자 관계, 심리 범위, 판결의 효력 등 전반에 걸쳐 나타난다.

(1) 소송 대상의 특수성

- 민사소송의 대상은 사인 상호간의 대등한 사법 관계에 관한 분쟁인 반면, 행정소송의 대상은 행정주체가 공권력을 행사하는 우월적 지위에서 행한 행정처분이다. 행정처분은 공정력, 집행력 등의 특수 효력을 가지므로, 이를 다투는 행정소송에서는 소송의 적법성을 위해 제소 기간, 관할 등 민사소송보다 엄격한 요건이 요구된다. 판례는 어떤 행위가 항고소송의 대상이 되는 처분인지 여부를 매우 중요한 문제로 취급하며, 단순한 사실 행위나 내부 행위를 처분으로 보지 않는 것이 일반적이다.

(2) 당사자 관계의 특수성

- 민사소송의 당사자는 대등한 지위의 사인 상호간인 반면, 행정소송의 경우 원고는 권리 침해를 당한 사인이지만, 피고는 공권력 행사의 주체인 행정주체(행정청)이다. 특히, 항고소송에서는 처분청이 피고가 되어야 하며(피고 적격), 이러한 특수성은 사법상의 평등 원칙과는 다른 공법상의 대립 구조를 형성한다.

(3) 심리 범위의 특수성

- 민사소송은 당사자의 변론주의 원칙을 중심으로 사건을 심리하며, 법원은 당사자가 주장한 사항에 구속되는 경향이 강하다. 그러나 행정소송에서는 공익과의 관련성, 행정처분의 적법성 확보 필요성 등으로 인하여 직권 심리주의가 일부 가미된다. 예를 들어 직권으로 증거 조사 및 심리를 할 수 있도록 행정소송법에 명시되어 있으며, 이는 실체적 진실 발견이라는 공익적 목적을 위한 것이다.

(4) 판결의 효력의 특수성

- 민사소송의 확정 판결은 당사자 및 승계인 등에게만 효력을 미치는 것이 원칙인 반면, 행정소송의 취소 판결은 제3자에게도 효력을 미치는 대세효(제3자효) 및 처분청을 구속하는 기속력을 가진다. 이러한 대세효와 기속력은 법원의 판단에 의해 일단 위법으로 확정된 행정처분은 더 이상 유효하지 않으며, 모든 국가 기관과 국민에게 그 효력이 미친다는 행정법의 특수성을 반영하는 것이다. 기속력으로 인해 행정기관은 동일한 사유와 근거로 동일한 처분을 반복할 수 없다.

II. 행정소송의 기능

- 행정소송은 일반적인 사법 작용으로서 분쟁 해결 기능을 수행함과 동시에, 행정법 관계의 특수성 때문에 공익 보호와 행정 통제라는 고유한 기능을 수행한다. 이러한 이원적 기능은 행정소송의 이념적 기초가 된다.

1. 권리구제기능

- 행정소송의 가장 본질적인 기능은 위법한 행정작용으로 인하여 침해되거나 침해될 우려가 있는 국민의 구체적이고 개별적인 권리 또는 법률상 이익을 사법적 절차를 통해 회복하고 보호하는 것이다. 권리구제기능은 행정청의 위법한 처분 그 밖의 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제함이라는 행정소송법 제1조의 목적 규정에서 명시되어 있다. 이러한 기능은 개인적 권익 보호의 측면이 강하며, 헌법이 보장하는 재판청구권의 일환으로서 국민의 기본권 보장이라는 법치국가적 이념에 기초한다. 취소소송, 무효등 확인소송, 당사자소송 등 행정소송의 다양한 유형은 모두 궁극적으로 침해된 국민의 권리 구제를 목표로 한다.

2. 행정통제기능

- 행정소송은 개인의 권리 구제를 넘어, 행정기관이 법률이 정한 범위 내에서 적법하게 권한을 행사하도록 간접적으로 통제하는 공익적 기능을 수행한다. 행정처분의 위법성을 법원의 판단을 통해 객관적으로 확인하고 시정함으로써, 행정의 법률 적합성 및 일반적인 공정성을 확보하는 데 기여한다. 이러한 행정통제기능은 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함이라는 행정소송법의 또 다른 목적 규정에서 확인된다. 행정기관은 패소할 경우 발생하는 기속력 등의 법적 부담을 예상하여 사전에 행정작용의 적법성을 철저히 검토하게 되므로, 행정소송 제도 자체가 행정작용에 대한 일반적 억제 및 예방 효과를 가져온다. 이는 궁극적으로 행정작용의 발전과 민주적 정당성 확보에 기여하는 것이다.

3. 양 기능의 조화

- 행정소송의 권리구제기능과 행정통제기능은 서로 대립되는 개념이 아니라, 서로 상호 보완적인 관계에 있다. 개인의 권리 구제는 위법한 행정처분을 배제함으로써 달성되며, 이 과정에서 필연적으로 행정작용의 위법성이 판단되고 시정되므로 행정통제기능이 자연스럽게 수행된다. 다만, 두 기능 간에 우선순위를 정해야 할 경우, 행정소송은 개인의 권리 구제를 궁극적인 목표로 하는 사법 절차이므로, 권리구제기능이 우선적인 지위를 가진다고 볼 수 있다. 하지만, 우리 행정소송법이 객관소송 등 공익적 소송 형식을 인정하고 있는 점을 고려할 때, 두 기능을 균형 있게 발전시키는 것이 현대적 행정소송 제도의 이상적인 모습이다. 예를 들어 취소소송에서 승소하여 개인의 권리를 회복하는 것은 권리 구제이며, 이 판결의 기속력이 행정청의 향후 처분 방향을 법에 맞게 이끌어가는 것은 행정 통제이다. 따라서 두 기능은 별개가 아니라 하나의 제도 내에서 서로 목적과 수단이 되는 역할을 수행하며 조화를 이룬다.

III. 결론

- 행정소송은 위법한 행정작용으로부터 국민의 권익을 구제하고 행정의 적법성을 확보하는 중요한 사법 절차이다. 이는 공법 관계의 특수성으로 인해 소송의 대상, 당사자, 심리 범위, 판결 효력 등 다양한 측면에서 민사소송과 구별되는 특징을 보인다. 행정소송은 개인의 권리 회복을 목표로 하는 권리구제기능과 행정작용의 적법성을 담보하는 행정통제기능이라는 이원적 기능을 수행하며, 이 두 기능은 상호 보완적으로 작용하여 법치행정의 이념 실현에 기여한다.

<제1장 행정소송의 일반론.제2절 행정소송의 유형>

I. 내용에 따른 분류

- 행정소송의 내용에 따른 분류는 소송의 목적이 개인(주관적)의 권익 구제에 있는지, 아니면 행정의 객관적인 법률 적합성 확보에 있는지를 기준으로 나누는 것이다. 우리나라 행정소송법 제3조는 주관적 소송을 항고소송과 당사자소송으로, 객관적 소송을 민중소송과 기관소송으로 구분하고 있으며, 이는 행정소송의 두 가지 이념인 권리구제기능과 행정통제기능을 법적으로 구현한 것이다.

1. 주관적 소송

- 주관적 소송은 개인의 구체적인 권리 또는 법률상 이익의 침해를 구제하고 보호하는 것을 주된 목적으로 하는 소송이다. 이 유형의 소송은 행정기관의 위법한 공권력 행사 등으로 인한 피해를 회복하여 사인의 법적 지위를 강화하는 데 초점이 맞춰져 있다. 행정소송법상 주관적 소송에는 항고소송과 당사자소송 두 가지 유형이 있다. 주관적 소송을 제기하기 위해서는 원고에게 반드시 법률상 이익이 있어야 하며, 단순한 사실상의 이익 또는 경제적 이익만으로는 소송을 제기할 자격(원고 적격)이 인정되지 않는다. 이는 소송의 남용을 방지하고 법원 심리의 효율성을 확보하기 위한 제한이다.

(1) 항고소송

- 항고소송은 행정청의 처분등이나 부작위에 대하여 제기하는 소송이다. 여기에는 위법성 확인을 구하는 취소소송, 처분의 효력 유무를 구하는 무효 등 확인소송, 행정기관의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 부작위위법확인소송이 포함된다. 항고소송은 행정소송의 대부분을 차지하며, 위법한 행정 처분으로부터 국민의 권익을 구제하는 가장 대표적인 수단이다. 항고소송의 대상인 처분의 개념은 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력 행사 또는 그의 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 의미하며, 판례는 처분의 개념 인정에 신중한 태도를 보인다.

(2) 당사자소송

- 당사자소송은 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다. 예를 들어 공법상의 계약에 관한 분쟁이나, 공무원의 보수 청구, 세금 환급 청구 등 이미 행정청의 처분이 있었는지와 무관하게 공법상의 권리 의무 관계 자체를 다투는 경우에 활용된다. 당사자소송은 실질적으로는 민사소송과 유사한 대등한 당사자 구조를 가지지만, 공법상의 법률관계를 다룬다는 점에서 민사소송과 구별되며, 행정소송법 규정이 우선적으로 적용된다.

2. 객관적 소송

- 객관적 소송은 개인의 권리 구제와는 무관하게, 행정작용의 적법성을 보장하고 객관적인 법질서의 유지를 목적으로 하는 소송이다. 따라서 이러한 소송을 제기하는 데에는 원고에게 자신만의 고유한 법률상 이익이 있을 것을 요구하지 않으며, 법률에서 정한 특정 자격 있는 자만이 제기할 수 있도록 엄격하게 제한하고 있다. 행정소송법상 객관적 소송에는 민중소송과 기관소송 두 가지 유형이 있다. 객관적 소송은 주관적 소송과는 달리 법치주의의 실현이라는 공익적 목적이 더욱 강하게 부각된다.

(1) 민중소송

- 민중소송은 국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 한 때에 직접 자기의 법률상 이익과 관계없이 그 시정을 구하기 위하여 제기하는 소송이다. 이는 선거권자 등 공직선거법에 따른 특정 지위를 가진 자가 선거 결과 등의 위법성을 다투는 경우 등 국민 전체에게 영향을 미치는 공익적인 문제에 대해 법원의 심판을 받고자 할 때 주로 활용된다. 민중소송은 법률이 특별히 정하는 경우에만 제기할 수 있으므로, 행정소송법 외의 개별 법률에 그 근거가 있는 경우가 대부분이다.

(2) 기관소송

- 기관소송은 국가 또는 공공단체의 기관상호간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때에 이에 대하여 제기하는 소송이다. 예를 들어 지방자치단체 상호간의 권한 쟁의 또는 중앙 행정기관과 지방자치단체 간의 권한 분쟁 등이 이에 해당한다. 기관소송은 행정기관 내부의 적절한 권한 분배 및 행사를 보장하여 행정의 객관적인 법적 질서를 유지하는 데 목적이 있으며, 마찬가지로 법률이 특별히 정하는 경우에만 제기할 수 있다.

II. 형식에 따른 분류

- 행정소송의 형식에 따른 분류는 법원의 판결이 어떤 형태의 법적 효과를 발생시키는가를 기준으로 분류한다. 즉, 소송을 통해 구하고자 하는 궁극적인 권리 구제 형태를 기준으로 나누는 것이다. 주로 사법 상의 소송 형태 분류를 공법 관계에 적용한 것이다.

1. 형성의 소

- 형성의 소는 법원의 판결이 기존의 법률관계를 발생, 변경, 소멸시키는 등 직접적인 법적 효과를 형성시키는 것을 목적으로 하는 소송이다. 행정소송에서는 취소소송이 대표적인 형성의 소에 해당한다. 위법한 행정처분을 취소하는 판결이 확정되면, 그 처분의 효력은 장래를 향해서뿐만 아니라 소급적으로 소멸하며, 이는 법원의 판단에 의해 법률관계가 직접적으로 변동되는 효과이다. 형성의 소에서 나온 판결은 대체효 및 기속력을 가진다는 특징이 있다.

2. 이행의 소

- 이행의 소는 법원의 판결이 피고에게 특정 작위(행동)나 부작위(금지) 또는 급부(지급) 의무를 명명하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 이는 민사소송에서 일반적으로 사용되는 소송 형식이다. 행정소송법상 명시적인 이행소송은 규정되어 있지 않지만, 당사자소송 중 공법상의 금전 지급 청구 등을 구하는 경우 실질적으로 이행의 소의 성격을 가진다. 예를 들어 공무원이 퇴직 연금 지급을 청구하는 소송 등이 이에 해당한다. 또한, 위법한 거부 처분에 대하여 취소 판결을 받더라도 곧바로 원하는 처분을 얻을 수 없으므로, 행정소송의 실효성 확보를 위해 의무이행소송 등 적극적인 이행의 소의 도입 필요성이 계속해서 논의되고 있다. 부작위위법확인소송 역시 간접적으로 행정청의 재처분 의무 이행을 강제한다는 점에서 일부 이행적 기능을 내포한다.

3. 확인의 소

- 확인의 소는 법원의 판결이 특정한 권리 관계나 법적 사실의 존재 또는 부존재를 확인하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 이는 원고의 현존하는 불안 상태를 해소하고 법적 안정성을 확보하는 데 기여한다. 행정소송에서는 무효등 확인소송과 부작위위법확인소송 등이 확인의 소에 해당한다.

(1) 무효등 확인소송

- 무효등 확인소송은 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송이다. 처분의 위법성이 중대하고 명백하여 당연 무효인 경우 등에 이용되며, 처분의 효력이 아예 없다는 것을 확인함으로써 원고의 불안정한 법적 지위를 해소한다. 취소소송과 달리 제소 기간의 제한이 없다는 특징이 있다. 또한, 처분 존부 확인소송은 행정기관이 처분을 했는지 여부 자체를 다투는 것으로 역시 확인의 소 성격을 가진다.

(2) 부작위위법확인소송

- 부작위위법확인소송은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 해야 할 법률상의 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 않는 것(부작위)이 위법하다는 것을 확인하는 소송이다. 이는 법원의 확인 판결을 통해 행정청에게 재처분 의무를 발생시키고, 궁극적으로 신청에 대한 응답을 유도하는 효과를 가진다. 부작위위법확인소송은 행정기관의 소극적인 공권력 불행사를 다루는 유일한 소송 형식이다.

III. 행정소송의 유형별 정리

- 우리나라 행정소송법은 제3조에서 행정소송의 유형을 항고소송, 당사자소송, 민중소송, 기관소송 총 네 가지로 규정하고, 이를 다시 주관적 소송과 객관적 소송으로 구분한다. 이러한 분류는 행정소송의 실제 운영 및 권리 구제 수단의 선택에 있어서 핵심적인 기준이 된다.

1. 행정소송법상의 유형

- 항고소송과 당사자소송은 개인의 권리 구제라는 주관적 이익을 위한 소송이며, 민중소송과 기관소송은 객관적인 법질서 유지라는 공익적 목적을 위한 소송이다. 각 소송 유형별로 소송의 요건, 피고 적격, 심리 범위, 판결의 효력 등에 있어 차이가 있으므로, 원고는 자신의 분쟁 유형에 가장 적합한 소송 유형을 선택해야 한다.

2. 각 유형의 연관성

- 행정소송의 각 유형은 내용에 따른 분류와 형식에 따른 분류가 복합적으로 결합되어 있다. 예를 들어 항고소송의 하나인 취소소송은 주관적 소송인 동시에 형성의 소의 성격을 가지며, 무효등 확인소송은 주관적 소송인 동시에 확인의 소의 성격을 가진다. 당사자소송은 주관적 소송인 동시에 그 구하는 내용에 따라 확인의 소 또는 이행의 소의 성격을 가질 수 있다. 이러한 구분 및 결합은 국민이 자신의 권리 침해 상태를 가장 효과적으로 구제할 수 있는 사법 심사의 틀을 제공한다. 특히, 행정처분의 취소를 통해 법적 지위를 회복하는 것이 원칙이지만, 처분 자체가 무효인 경우 별도의 제소 기간 제한 없이 무효등 확인소송을 제기할 수 있도록 함은 확인의 소 형식을 통해 권리 구제의 길을 넓힌 것이다.

3. 소송 선택의 중요성

- 실무상 행정소송 제기 시 가장 중요한 문제는 원고의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 적절한 소송 유형을 선택하는 것이다. 잘못된 소송 유형의 선택은 법원의 각하 판결로 이어져 결국 권리 구제에 실패하게 할 수 있다. 예를 들어 행정처분이 무효인 경우 취소소송으로 제기하면 제소 기간 도과 등으로 각하될 수 있으므로, 처분의 위법성 정도에 따라 무효등 확인소송 등 정확한 유형을 선택해야 한다. 또한, 부작위위법확인소송은 행정청의 재처분 의무만을 강제할 뿐, 원하는 처분을 직접 받는 것을 보장하지는 않으므로, 소송 유형별 판결의 효력을 명확히 인지해야 한다.

IV. 결론

- 행정소송의 유형 분류는 개인의 권리 구제와 행정의 법적 통제라는 두 가지 목적을 효율적으로 달성하기 위한 제도적 장치이다. 내용에 따른 주관적 소송과 객관적 소송의 구분은 소송 제기의 이익(원고 적격) 기준을 제시하며, 형식에 따른 형성의 소, 이행의 소, 확인의 소 분류는 법원 판결의 효력 및 권리 구제 방식을 결정한다. 행정소송법은 항고소송, 당사자소송, 민중소송, 기관소송 네 가지 유형을 제시하며, 각 유형이 가지고 있는 특징 및 제한 요건을 정확히 이해하는 것은 국민이 위법한 행정작용으로부터 자신의 권익을 구제받기 위한 가장 기본적이고 핵심적인 전제가 된다.

<제1장 행정소송의 일반론.제3절 행정소송의 한계>

I. 사법 본질적 한계

- 행정소송은 본질적으로 사법 작용의 일환이므로, 법원의 사법적 심사 기능이 가질 수밖에 없는 일반적인 한계를 가지게 된다. 이는 법원이 국민의 구체적인 분쟁 해결 기관으로서 추상적인 법규 제정 또는 정책 집행 기관이 아니라는 사법의 특성에서 기인한다.

1. 구체적 사건성에 따른 한계

- 행정소송을 포함한 모든 사법 절차는 구체적인 사건에 대한 법적 판단을 목표로 한다. 이러한 특성은 다음과 같은 한계를 초래한다.

(1) 일반·추상적 법규에 대한 한계

- 법원은 일반적이고 추상적인 법률 또는 행정 입법 자체의 위법성을 직접적으로 다루거나 취소할 수 없다. 행정소송법상 항고소송의 대상은 처분등 구체적인 법 집행 행위로 한정되기 때문이다. 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 법규 명령이라 할지라도, 그것이 구체적인 집행 행위(처분)의 형태를 띠지 않는 이상, 항고소송의 대상이 되지 않는다. 다만, 판례는 구체적인 사건에 적용되는 법규 명령의 위헌·위법성을 해당 처분에 대한 소송 심리 과정에서 간접적으로 심사할 수 있다고 본다. 이를 규범 통제라 하며, 이는 법원이 처분의 위법성 판단의 전제로서 법규 명령의 위법성을 확인하는 것이다.

(2) 사실적 행위에 대한 한계

- 단순한 사실적 행위는 법적 효과를 수반하지 않기 때문에 원칙적으로 행정소송의 대상인 처분으로 인정되지 않는다. 예를 들어 행정기관의 단순한 조언이나 행정 지도 등은 법적 구속력이 없으므로 소송 대상이 될 수 없다. 그러나, 최근에는 권력적 사실 행위의 경우 국민의 권리 침해 가능성이 높으므로, 그것이 실질적으로 국민의 권리 의무에 영향을 미친다면 처분성을 인정하여 항고소송의 대상으로 보는 경향도 일부 나타나고 있다. 이러한 경향은 권리 구제 범위를 확대하려는 노력의 일환이다.

(3) 사법심사의 대상이 되지 않는 사항

- 법원의 심사 기능 자체가 미치지 못하는 영역이 있는데, 이를 사법 심사 불가능 영역이라고 한다. 예를 들어 통치 행위가 대표적이다. 통치 행위는 국가 기관의 고도의 정치적 결단을 필요로 하는 행위로서, 사법적 심사 기준이 마땅치 않거나 심사하는 것이 권력 분립 원칙상 바람직하지 않다고 판단되는 행위를 말한다. 대통령의 계엄 선포나 외교 행위 등이 논의의 대상이 되는데, 판례는 행위의 성격 및 그것이 국민의 기본권에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 사법심사 여부를 결정한다.

2. 법 적용상 한계

- 법원은 법률 문제를 다루는 기관이지 정책 또는 전문적 사실 판단을 직접 대신하는 기관이 아니다. 이러한 법원의 법 적용상의 한계는 행정작용의 재량성 영역에서 두드러진다.

(1) 재량행위의 한계

- 행정기관이 법률에 따라 자유로운 판단을 내릴 수 있는 재량행위에 대해서는, 법원은 행정기관의 판단 자체를 자신들의 판단으로 대체할 수 없다. 법원은 오직 재량권의 일탈 또는 남용 여부만을 심사할 수 있다. 재량권의 일탈 또는 남용이란 행정기관이 재량권의 한계를 넘어서 행위하거나, 재량권 내에서 행위했다라도 그 목적이 정당하지 않거나, 비례 원칙 등 일반적인 법 원칙에 위반되는 것을 의미한다. 이러한 심사 한계는 행정의 전문성 및 정책적 판단의 존중이라는 권력 분립적 요청에 기반한다.

(2) 판단 여지 영역의 한계

- 행정기관에게 법률이 전문적 또는 기술적인 사항에 대해 광범위한 사실 인정 및 평가권(판단 여지)을 부여한 경우, 법원의 심사는 더욱 제한된다. 예를 들어 공무원의 징계 양정, 시험의 합격 여부 판단, 환경 영향 평가 등 고도의 전문성이 요구되는 영역이다. 법원은 판단 여지가 부여된 영역에 대해서는 사실 오인 여부, 비례 원칙 위반 여부 등 행정기관의 판단 과정에 하자가 있는지 여부만을 심사하며, 행정기관의 판단을 대체하는 실질적인 판단은 하지 않는다. 이는 사법기관이 행정기관의 전문성을 존중하고 권한 범위를 지키기 위한 사법 자체의 원칙에서 비롯된다.

II. 권력 분립적 한계

- 행정소송은 행정권을 통제하는 기능을 수행하지만, 헌법상 권력 분립 원칙에 따라 법원이 행정권의 고유한 영역을 침범할 수 없다는 근본적인 한계를 가진다. 특히, 행정기관이 아무런 행위를 하지 않거나 장래에 위법한 행위를 할 우려가 있을 때, 법원이 적극적으로 개입하여 행정기관의 행위를 명령하거나 금지할 수 있는지 여부가 주요한 문제가 된다.

1. 의무이행소송

- 의무이행소송은 행정청이 국민에 대하여 특정한 작위(처분)를 할 의무가 있음에도 불구하고 이를 이행하지 않을 때, 법원이 직접 행정기관에게 그 처분 또는 행위를 하도록 명령하는 소송 형식을 말한다.

(1) 현행법상 의무이행소송의 부정

- 우리나라 현행 행정소송법은 의무이행소송을 명시적으로 인정하고 있지 않다. 이는 법원이 행정기관의 적극적인 행위를 명령하는 것이 행정권의 고유한 판단 영역을 침해하고 권력 분립 원칙에 위배될 수 있다는 권력 분립적 한계 때문이다. 행정청의 거부 처분이나 부작위가 있을 때, 현행법상 국민은 부작위위법확인소송이나 거부 처분 취소소송을 제기하여 승소 판결을 받을 수 있으며, 법원은 기속력에 따라 행정기관에게 재처분 의무만을 부과할 뿐, 직접 어떤 처분을 하라고 명령하지는 않는다.

(2) 학설 및 입법론상의 논의

- 그러나 국민의 권리 구제를 실효성 있게 확보하기 위해서는 의무이행소송의 도입이 필요하다는 주장이 지속적으로 제기된다. 취소판결만으로는 행정기관이 또다시 다른 사유를 들어 거부 처분을 반복할 수 있기 때문이다. 판례 역시 재량권이 없거나 기속행위의 경우 등 예외적인 상황에서는 사실상 특정한 처분 의무를 인정하는 경향이 있으나, 법적으로 의무이행소송 자체를 인정하는 것은 여전히 신중한 태도를 보인다.

2. 예방적 금지소송(예방적 부작위청구소송)

- 예방적 금지소송은 장래에 행정기관의 위법한 처분 등 공권력 행사로 인하여 회복하기 어려운 손해를 입을 우려가 있을 때, 미리 법원에 그 행위의 금지를 청구하는 소송 형식을 말한다.

(1) 현행법상 원칙적 부정

- 우리나라 행정소송법은 예방적 금지소송을 명시적으로 규정하고 있지 않으며, 학설과 판례는 원칙적으로 이를 부정한다. 그 주된 이유는 미래의 처분을 대상으로 법원이 미리 판단하는 것이 행정기관의 장래 권한 행사를 과도하게 제약하여 권력 분립 원칙에 위배될 수 있다는 점이다. 또한, 법원의 사법 심사는 구체적 사건에 국한되어야 하는데, 장래의 처분은 아직 현실화되지 않은 추상적인 문제일 수 있다는 사법 본질적 한계도 작용한다.

(2) 예외적 긍정 논의

- 다만, 예외적으로 행정기관이 장래에 위법한 처분을 할 것이 거의 확실시되며, 그 처분이 이루어진 후에 취소소송을 제기하더라도 회복하기 현저히 곤란한 손해가 발생할 우려가 있는 경우에는, 권리 구제 측면에서 예방적 금지소송의 필요성이 제기된다. 판례는 일부 사안에서 민사소송법상의 가처분 등 민사적 구제 수단을 제한적으로 인정하거나, 무명 항고소송의 일환으로 예방적 금지소송의 가능성을 논의하기도 하였으나, 현행 법제 하에서는 여전히 이러한 소송 형식의 인정에는 매우 엄격한 기준을 적용하고 있다.

Ⅲ. 결론

- 행정소송의 한계는 사법의 본질에서 비롯되는 구체적 사건성 및 법 적용상의 제한과 행정권과의 권력 분립 원칙에서 비롯되는 제한으로 나눌 수 있다. 사법 본질적 한계는 일반 법규나 사실 행위 등 처분이 아닌 사항에 대한 직접적인 심사 금지 및 재량행위와 판단 여지 영역에 대한 심사 자제로 나타난다. 권력 분립적 한계는 법원이 행정기관의 적극적인 행위를 명령하는 의무이행소송과 장래의 행위를 미리 금지하는 예방적 금지소송을 현행법상 원칙적으로 부정하는 형태로 구체화된다. 이러한 한계는 행정소송의 존재 이유인 권리 구제 및 행정 통제 기능을 유지하면서도, 사법권 남용을 방지하고 행정의 전문성과 정책 집행권을 존중하기 위한 불가피한 제한이라 할 수 있다.

<제2장 취소소송의 대상적격.제1절 소송요건의 일반론>

I. 소송요건의 의의

- 소송요건이란 법원이 본안 심리에 들어가 원고의 청구가 정당한지 여부를 판단하기 전에 소송 자체가 법적으로 적법하게 제기되었는지를 심사하기 위한 절차적 요건을 말한다. 이는 당사자 간의 실체적 권리 관계의 존부를 다루는 본안요건과는 구별되며, 오직 소송 절차의 적법성 확보에 그 목적이 있다. 행정소송은 행정기관의 공권력 행사를 다루는 특수성을 가지므로, 민사소송보다 더욱 엄격하고 다양한 소송요건을 요구한다. 소송요건은 법원의 직권 조사 사항이므로, 설령 당사자가 이를 주장하지 않더라도 법원은 직권으로 조사해야 한다. 만약 소송요건 중 어느 하나라도 결여되면, 법원은 본안 판단을 거부하고 소송 부적법이라는 이유로 원고의 소 자체를 각하하는 판결을 내린다. 따라서 소송요건의 구비는 취소소송의 적법성을 유지하는 가장 기본적인 전제라 할 수 있다.

II. 취소소송의 소송요건

- 취소소송은 행정처분의 취소를 구하는 소송으로서, 행정소송의 유형 중 가장 중심적인 지위를 차지한다. 취소소송이 적법하게 제기되기 위해서는 다음과 같은 특정 요건들을 모두 충족해야 한다.

1. 대상적격

- 대상적격은 소송 심사의 대상이 되는 행정작용이 법이 정한 요건을 충족하는지 여부에 관한 요건이다. 취소소송의 대상은 행정소송법 제19조에 따라 처분등으로 한정되며, 이는 법원이 심사할 수 있는 행정작용의 범위를 확정하는 가장 중요한 기준이 된다. 만약, 원고가 처분이라고 볼 수 없는 행정기관의 단순한 사실 행위나 내부 행위를 대상으로 소송을 제기하면, 대상적격 결여로 각하된다.

2. 원고적격

- 원고적격은 소송을 제기하는 자(원고)가 법률상 소송을 수행할 수 있는 자격을 갖추었는지 여부에 관한 요건이다. 행정소송법 제12조는 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정한다. 여기서 법률상 이익은 단순한 사실상의 이익이나 경제적인 이익을 넘어, 공익 보호의 관점에서 구체적 법규범에 의해 보호되는 개인의 권익을 말한다. 이 요건은 소송의 남용을 방지하고 법원 심리의 효율성을 확보하는 역할을 한다.

3. 피고적격

- 피고적격은 소송을 당하는 자(피고)가 법률상 소송의 상대방이 될 수 있는 자격을 갖추었는지 여부에 관한 요건이다. 행정소송법 제13조는 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다고 규정한다. 이러한 규정은 처분을 실제로 발한 행정기관 자체를 소송의 상대방으로 함으로써 판결의 기속력 등 소송 효과가 행정 집행 주체에게 직접적으로 미치도록 하기 위함이다.

4. 협의의 소의 이익

- 협의의 소의 이익은 원고가 소송에서 승소 판결을 받음으로써 법적으로 유효한 권리 구제를 받을 필요성이 있는지 여부에 관한 요건이다. 설령 위법한 처분을 취소하더라도 이미 그 처분의 효력이 소멸했거나, 인용판결을 받아도 원고의 권리 구제가 불가능한 경우 등에는 소의 이익이 없다고 판단되어 각하된다. 다만, 판례는 인용판결의 기속력으로 인해 장래에 동일하거나 유사한 처분이 반복될 위험을 방지할 필요성이 있는 경우 등 예외적으로 소의 이익을 넓게 인정하기도 한다.

5. 제소기간

- 제소기간은 취소소송을 일정한 기간 내에 제기해야 하는 요건이다. 행정소송법 제20조는 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내 또는 처분등이 있는 날부터 1년 이내에 제기해야 한다고 규정한다. 이러한 제한은 위법한 행정처분이라도 일정 기간이 지나면 더 이상 다툴 수 없도록 하여 행정 법률관계의 안정성을 확보하기 위한 것이다. 제소기간은 불변기간이며, 이를 도과하면 소송요건 결여로 각하된다.

III. 취소소송의 대상으로서의 처분등[행소법 제4조 제19조]

- 취소소송의 대상적격은 행정소송의 심사 대상을 정의하는 핵심 요건이다. 행정소송법 제19조는 취소소송은 처분등을 대상으로 한다고 규정하며, 여기서 처분등의 정의는 제2조 제1항 제1호에 명시되어 있다.

1. 처분의 법적 개념

- 행정소송법상 처분등이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(이하 처분) 및 행정심판에 대한 재결을 말한다. 이러한 법적 정의는 다음과 같은 요소를 포함한다.

(1) 행정청의 행위일 것

- 처분은 국가 또는 지방자치단체 등 행정주체에 속하는 행정청의 행위여야 한다. 여기서 행정청은 행정에 관한 의사를 결정하여 대외적으로 표시할 수 있는 기관을 말하며, 공무 수탁 사인의 행위도 처분으로 포함된다.

(2) 구체적 사실에 관한 법집행일 것

- 처분은 특정 개인 및 특정 사건에 적용되는 구체적인 행위여야 하며, 일반적이고 추상적인 법규 명령 제정 등은 처분에서 제외된다. 다만, 고시 또는 공고 등의 형식을 취하더라도 그 내용이 실질적으로 특정인에게 권리 의무를 설정하는 구체적 효력을 가진다면 처분성을 인정한다는 것이 판례의 일관된 태도이다.

(3) 공권력의 행사 또는 그 거부일 것

- 처분은 행정주체가 공법상 우월한 지위에서 일방적으로 국민에게 법적 효과를 발생시키는 공권력의 행사여야 한다. 또한, 국민의 신청에 대해 행정청이 거부하는 행위도 법률상 거부 의무가 있다면 처분으로 포함된다. 거부 행위가 처분으로 인정되기 위해서는 신청인에게 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다는 것이 판례의 입장이다.

(4) 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미칠 것

- 가장 중요한 판단 기준으로서, 행위의 성격이 대외적으로 국민의 법적 지위에 직접적이고 구체적인 변동을 가져와야 한다. 단순한 내부 행위나 사실 행위, 또는 행정기관 상호간의 협의 등은 이 요건을 결여하여 처분으로 인정되지 않는다. 예를 들어 행정 지도나 단순 통보 등은 처분성을 부정하며, 오직 법적 효력을 발생시키는 행위만이 소송의 대상이 된다.

2. 처분등의 유형 및 확장된 개념

- 행정소송법 제19조가 처분등이라고 규정한 것은 처분 외에도 재결 역시 취소소송의 대상이 됨을 명확히 한 것이다. 재결은 행정심판 절차를 거쳐 나오는 판단을 의미한다. 우리 행정소송법은 원처분 주의를 채택하고 있지만 행정소송법 제19조 단서에서 재결자체에 고유한 위법이 있는 경우 예외적으로 대상으로 인정한다. 또한, 판례는 처분의 개념을 확장하여 공무원 징계 등 특별 권력 관계 내의 행위 중 국민의 기본권에 직접 영향을 미치는 행위 등에 대해서도 처분성을 인정함으로써 국민의 권리 구제 범위를 넓히고 있다.

N. 결론

- 취소소송의 소송요건 중 가장 기본이 되는 것은 대상적격으로서, 소송 심사의 대상이 처분등이라는 법적 요건을 충족해야 한다. 행정소송법이 정의하는 처분의 개념은 행정청의 공권력 행사로서 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 구체적 법 집행 행위를 요구하며, 이러한 요건의 충족 여부에 따라 소송의 적법성이 좌우된다. 취소소송의 대상적격을 정확히 판단하는 것은 법원의 사법 심사 범위를 확정하고 행정 법률관계의 안정성을 유지하는 동시에, 침해된 국민의 권리 구제 가능성을 결정하는 핵심적인 문제이다.

<제2장 취소소송의 대상적격.제2절 처분>

I. 처분의 의의

1. 정의[행소법 제2조 제1항 제1호]

- 행정소송법 제2조 제1항 제1호에 따르면 처분이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다. 처분은 취소소송의 대상적격을 정하는 가장 핵심적인 개념이며, 행정작용의 다양성을 포괄하기 위해 공권력 행사라는 본질적 요소와 함께 그 밖에 이에 준하는 행정작용이라는 보충적 요소를 규정하고 있다. 따라서 처분으로 인정되기 위해서는 행정청의 작위가 국민의 권리 의무에 직접적으로 영향을 미치는 대외적 효력을 가져야 한다. 국민의 권리 의무에 아무런 변동을 초래하지 않는 행위는 처분성이 부정된다.

2. 처분 개념의 논쟁★

(1) 문제점

- 행정처분은 실체법상 개념으로 강학상으로는 행정행위라는 용어가 사용되고 있다. 처분과 행정행위를 같은 개념으로 보는 견해(실체법상 개념설 또는 일원론)와 처분을 행정행위보다 넓은 개념으로 보는 견해(쟁송법상 개념설 또는 이원론)로 나뉘는데, 논의의 실익은 사실행위를 취소소송을 통해 다룰 수 있는지 여부이다.

(2) 학설

① 실체법상 개념설(일원론)(판례)

- 쟁송법상 처분 개념을 강학상 행정행위와 동일하게 보는 견해로, 취소의 대상은 공권력을 가지는 법적 행위인 행정행위에 한정된다. 따라서 사실행위는 처분에 해당하지 않아 대상적격을 충족하지 못한다.

② 쟁송법상 개념설(이원론)

- 국민의 권리구제 확대를 도모하기 위하여 쟁송법상 처분 개념을 실체법상 행정행위는 물론, 국민의 권익에 영향을 미치는 사실행위 등도 포함하는 광의의 개념으로 보는 견해이다.

(3) 판례

- 판례는 기본적으로 강학상 행정행위를 항고소송의 주된 대상으로 보고 있다. 다만, 권력적 사실행위라고 보이는 단수조치, 교도소 이송조치 및 제소자에 대한 지속적 감시행위에 대하여 처분성을 인정하였고, 비권력적 사실행위인 국가인권위원회의 성희롱 결정에 따른 시정조치를 성희롱 행위자로 결정된 자의 인격권에 영향을 미침과 동시에 공공기관의 장 또는 사용자에게 일정한 법률상 의무를 부담시키는 것이라는 점을 이유로 처분에 해당한다고 하여 처분개념을 확대하고 있다.

(4) 검토

- 처분 개념의 정의규정이나 입법취지, 국민의 권리구제의 실효성 등을 고려하면 현행 행정소송법상 처분을 행정행위보다 넓은 개념으로 보는 쟁송법상 개념설(이원론)이 타당하다고 판단된다.

II. 처분 개념의 분설

1. 행정청의 행위

- 처분은 행정청이 행하는 행위여야 한다. 행정청이라 함은 국가나 지방자치단체 등의 행정주체를 위하여 대외적으로 의사를 결정하고 표시할 권한을 가진 기관을 의미한다. 따라서 단순한 보조기관의 행위나 내부적인 절차 행위는 원칙적으로 처분성이 부정된다. 다만, 법률에 의해 공무를 위탁받은 사인 등의 행위도 그 작용의 대외적 효력 발생 여부에 따라 처분으로 인정될 수 있다.

2. 구체적 사실에 관한 행위

- 처분은 불특정 다수인을 대상으로 하는 일반적 추상적인 법규범 제정이 아닌, 특정인이나 특정 사건에 관한 규율로서 구체성을 가져야 한다. 일반적 규율인 법령이나 조례 등의 제정 행위는 원칙적으로 처분성이 부정되지만, 비록 일반적인 형식을 취하더라도 그 규율의 대상과 내용이 사실상 특정되어 집행 행위의 개입 없이 직접적인 법률효과를 발생시키는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정된다.

3. 법집행의 행위

- 처분은 법률 등 법규범의 규율을 구체적 사실에 적용하여 실현하는 법집행의 행위여야 한다. 이는 행정청의 작위가 자의적이어서는 안 되며, 반드시 법적 근거를 가지고 법률우위의 원칙을 준수해야 함을 의미한다. 이러한 특성은 처분의 위법성 심사가 법규범의 적합성 여부를 중심으로 이루어짐을 보여준다.

4. 공권력 행사로서의 행위

- 처분은 행정청이 국민에 대하여 우월한 지위에서 일방적으로 명령하거나 강제함으로써 국민의 권리 의무에 직접적인 변동을 초래하는 공권력의 행사여야 한다. 이는 대등한 당사자 지위에서 이루어지는 공법상 계약 등과는 구별되는 핵심 요소이다. 공권력의 행사에는 명령이나 강제 등 침익적 작용 뿐만 아니라, 국민의 법적 지위를 설정하는 형성적 작용도 포함된다.

5. 소극적 처분으로서 거부처분

- 행정소송법은 공권력의 행사 외에 그에 대한 거부 역시 처분으로 규정한다. 거부처분이 처분으로 인정되기 위해서는 두 가지 요건이 충족되어야 한다. 첫째, 국민이 행정청에 특정 행위를 신청할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 하며, 둘째, 그 거부 행위가 신청인의 권리·의무에 직접적인 영향을 미쳐야 한다. 이러한 신청권이 결여된 상태에서의 거부 행위는 단순한 사실적 응답에 불과하여 처분성이 부정된다.

6. 그 밖에 이에 준하는 행정작용

- 행정소송법이 규정한 그 밖에 이에 준하는 행정작용은 전통적인 행정행위 개념으로는 포괄하기 어려운 다양한 행정작용을 사법 심사의 대상으로 포섭하려는 취지이다. 이는 행정작용의 형식에 구애받지 않고 실질적으로 국민의 권리 의무에 직접적인 법률적 효과를 발생시키는 모든 행정작용을 의미하며, 판례는 이 규정을 근거로 처분 개념의 범위를 확대하여 권력적 사실행위 등의 처분성을 인정하는 데 활용하고 있다.

III. 처분 해당 여부의 구체적 검토

1. 의회의 의결

- 지방자치단체 의회의 의결은 원칙적으로 법규 제정 작용 또는 내부적 의사 결정 과정에 해당하여 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 처분성이 부정된다. 그러나 예외적으로 의회 의결 자체가 특정인의 법적 지위를 직접적으로 규율하고 변동을 초래하는 경우에는 처분성이 인정된다. 예를 들어 지방 의회 의원에 대한 징계 의결은 해당 의원의 권한 행사에 직접 영향을 미치므로 처분으로 본다.

2. 법령·조례·고시

- 법령이나 조례 등 일반적 추상적 법규범은 원칙적으로 처분성이 부정된다. 다만, 고시 등이 비록 일반적인 형식을 취하고 있더라도, 그 내용이 집행행위의 개입 없이 직접적으로 국민의 권리 의무 관계를 규율하는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정될 수 있다. 판례는 특정 고시가 행정처분의 기준을

정하여 재량권을 제한하거나 법률의 위임 범위 내에서 법규 사항을 보충하는 경우 처분성을 인정한 바 있다.

3. 중간행위

- 중간행위는 최종적인 처분이 있기 전의 예비적이거나 절차적인 행위로서, 원칙적으로 그 자체만으로는 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 처분성이 부정된다. 예를 들어 사전 결정이나 내부적인 심사 결과 등은 최종 처분을 통해서만 대외적 효력을 발생시킨다. 다만, 중간행위가 후행 처분의 전제가 되어 사실상 국민의 법적 지위에 직접적인 불이익을 초래하여 돌이킬 수 없는 영향을 주는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정되기도 한다.

4. 일반처분

- 일반처분은 특정인이 아닌 불특정 다수인을 대상으로 하지만, 특정 장소나 사건에 관한 규율로서 구체성을 가지므로 처분성이 인정된다. 예를 들어 특정 도로 구간의 통행 금지 처분 등은 그 대상이 불특정 다수일 지라도 내용이 구체적인 사실에 관한 법집행이므로 취소소송의 대상이 된다. 일반처분은 처분의 구체성을 인정하는 데 있어 그 대상의 특정성을 요하지 않는다는 특징이 있다.

5. 행정계획

- 행정계획은 장래의 일정 목표를 설정하고 그에 따른 수단을 종합적으로 조정하는 작용으로서, 원칙적으로 처분성이 부정된다. 그러나 도시 관리 계획 결정 등과 같이 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미쳐 법적 구속력을 가지는 구속적 행정계획의 경우 예외적으로 처분성이 인정된다. 이러한 계획은 계획 확정 처분으로서 항고소송의 대상이 되며, 계획 재량의 한계를 벗어난 경우 위법으로 판단될 수 있다.

6. 사실행위

- 사실행위는 법적 효과를 목적으로 하지 않고 단순히 사실적인 결과를 가져오는 행위로서, 원칙적으로 처분성이 부정된다. 그러나 행정청이 우월한 공권력을 행사하여 국민의 권리 의무에 직접적인 불이익을 주는 권력적 사실행위의 경우에는 예외적으로 처분성이 인정된다. 예를 들어 단수 단전 조치나 행정 대집행의 고고 등은 국민의 법적 지위에 직접적인 영향을 미치므로 처분으로 본다. 비권력적 사실행위는 처분성이 부정된다.

7. 공시지가결정

- 표준지 공시지가의 결정은 토지 수용 보상액 산정, 각종 조세 부과 등의 기준이 되어 토지 소유자의 법률상 이해관계에 직접적인 영향을 미치므로 처분성이 인정된다. 이는 비록 개별 토지 소유자에게 개별적으로 통지되는 행위는 아니지만, 개별적인 재산권 행사에 중대한 구속력을 발휘하는 준사법적 행위로 인정되기 때문이다. 따라서 공시지가 결정에 위법이 있으면 취소소송의 대상이 된다.

8. 반복된 행위

- 기존 처분과 동일한 내용의 행위를 반복하는 경우, 이는 새로운 처분으로서의 법적 효력이 없으므로 원칙적으로 처분성이 부정된다. 이는 제소기간 규정을 잠탈하거나 법적 안정성을 해치는 것을 방지하기 위함이다. 다만, 반복된 행위가 기존의 처분과 별도로 새로운 법률적 효과를 발생시키거나 이해관계인에게 새로운 권리 의무 관계를 설정하는 경우에는 예외적으로 새로운 처분으로 인정될 수 있다.

9. 조세경정처분

- 조세 부과처분 후 세액을 변경하는 경정처분은 원칙적으로 종전의 부과처분을 흡수하여 소멸시키고 새로운 부과처분으로서의 효력을 가진다. 따라서 납세자는 증액 경정처분인 경우 변경된 경정처분을 소송의 대상으로 삼아야 한다. 감액 경정처분의 경우에는 변경된 당초처분을 대상으로 다투어야 한다. 경정처분은 종전 처분의 법률관계 전체를 재규율하는 성격을 갖는다.

10. 변경처분

- 행정청이 이미 내린 처분을 사후적으로 수정하거나 변경하는 변경처분은, 당초 처분과 변경처분을 합한 변경 후의 처분이 소송의 대상이 된다. 이는 변경처분이 당초 처분의 효력 범위를 수정하여 국민의 법적 지위에 새로운 변동을 가져오기 때문이다. 다만, 변경처분이 당초 처분의 본질적인 내용을 전부 대체하는 경우 등에는 변경된 처분만이 소송의 대상이 된다.

11. 내부적 행정행위

- 내부적 행정행위는 행정기관 내부에서만 효력을 발생하는 행위로서, 예를 들어 상급기관의 지시나 내부 결재 등이 있다. 이러한 행위는 대외적으로 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 처분성이 부정된다. 따라서 항고소송은 내부적 행정행위 자체를 대상으로 할 수 없고, 반드시 그 내부 행위의 결과로 나타난 대외적인 처분을 대상으로 다투어야 한다.

12. 행정행위의 부관

- 행정행위의 부관(조건, 기한, 부담 등)은 주된 행정행위의 효력을 제한하기 위해 덧붙여진 종된 규율이다. 원칙적으로 부관 자체만으로는 독립된 처분성이 부정되어 주된 행정행위와 함께 다투어야 한다. 다만, 부관 중 부담의 경우 독립된 법률 행위로서의 성격을 가지고 별도의 의무를 부과하는 것으로 보아, 부담만 분리하여 독립된 소송의 대상으로 삼을 수 있다는 것이 판례의 입장이다.

13. 신고

- 신고 행위의 처분성은 신고의 종류에 따라 달라진다. 신고만으로 법적 효과가 완성되는 자기완결적 신고에 대한 행정청의 수리 행위는 단순한 사실 행위 또는 법률 효과를 확인하는 행위에 불과하여 처분성이 부정된다. 반면, 행정청의 수리 여부에 따라 법적 효과 발생이 좌우되는 행정요건적 신고에 대한 행정청의 수리 거부 행위는 국민의 법적 지위에 직접적인 영향을 미치므로 처분으로 인정된다.

14. 그 밖에 처분성이 문제되는 경우

- 이 외에도 처분성이 문제되는 행정작용은 다양하다. 예를 들어 행정지도는 원칙적으로 처분성이 부정되지만, 상대방의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 권력적 행정지도는 처분성이 인정될 수 있다. 또한, 공무원의 인사 발령(직위해제, 강등 등) 중 징계 성격이 강하거나 법률상의 불이익을 초래하는 행위는 처분성이 인정되지만, 내부적 인사 발령(전보 등)은 처분성이 부정되는 것이 일반적이다. 판례는 행정작용이 국민의 법적 지위에 미치는 영향 정도를 종합적으로 고려하여 처분성을 판단하고 있다.

IV. 결론

- 취소소송의 대상적격으로서 처분 개념은 행정소송법상 법적 안정성과 국민의 권리 구제라는 두 가치 사이에서 균형점을 찾는 역할을 수행한다. 현행 법과 판례는 형식적 개념에 얽매이지 않고 실질적으로 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 법적 효과 유무를 중심으로 처분성을 넓게 인정하는 추세이다. 이는 다양화되는 현대 행정작용에 대한 사법 심사의 필요성을 반영하는 것이며, 개별 사안별로 구체적인 법적 효과 및 침해의 중대성을 면밀히 검토하여 처분성 여부를 판단해야 한다.

<제2장 취소소송의 대상적격.제3절 재결>

I. 재결의 의의

1. 정의[행심법 제2조 제3호]

- 재결이라 함은 행정심판청구에 대하여 행정심판위원회 등 재결기관이 행하는 판단을 말하며, 행정심판법 제2조 제3호에 규정되어 있다. 재결은 행정심판의 결론으로서 당사자의 권리 의무 관계에 직접적인 영향을 미치는 준사법적 행정행위의 성격을 갖는다. 재결의 종류로는 청구 요건 미달 시의 각하재결, 청구 이유 없음 시의 기각재결, 청구 이유 있음 시의 인용재결 등이 있다. 재결은 특유의 효력인 기속력을 가져 피청구인 등 관계 행정청을 구속한다.

2. 원처분주의

- 원처분주의는 행정심판을 거친 후 취소소송을 제기하는 경우, 원칙적으로 소송의 대상이 되는 것은 행정심판 청구의 대상이 되었던 원래의 행정처분이며, 재결 자체는 소송의 대상이 되지 않는다는 원칙이다. 이 원칙은 취소소송의 대상적격을 원처분에 한정함으로써 소송의 범위를 명확히 하고, 재결기관의 권한이 사법 심사의 대상으로 포섭되는 것을 방지하여 행정의 능률성을 보호하려는 취지를 갖는다.

3. 재결주의

- 재결주의는 원처분주의와 대비되는 개념으로서, 행정심판을 거친 경우 원처분을 완전히 배제하고 재결 자체만을 취소소송의 대상으로 삼아야 한다는 원칙이다. 재결주의를 채택하는 경우 행정심판 단계에서 원처분의 위법·부당 여부가 종합적으로 심리되므로, 사법 심사는 재결의 당부에 국한되어 효율적인 권리 구제를 도모할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 재결 자체에 고유한 위법이 없다면 원천적으로 원처분은 배제되어 그 위법성을 다룰 수 없게 되는 단점이 있어, 현행 행정소송법은 원칙적으로 원처분주의를 채택하고 있다.

4. 원처분주의의 채택[행소법 제19조]

- 행정소송법 제19조 본문은 취소소송은 처분등을 대상으로 한다고 규정하여 원칙적으로 원처분주의를 채택하고 있음을 명확히 한다. 이는 재결이 단지 원처분의 적법성을 확인하거나 취소하는 효력을 가질 뿐, 별도의 법적 지위 변동을 일으키지 않는다는 인식에 기초한다. 따라서 국민이 원하는 권리 구제의 핵심 대상은 여전히 원처분이며, 소송의 대상을 원처분으로 함으로써 실질적인 위법 심사를 보장한다.

II. 원처분주의에 따라 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우

1. 각하재결을 한 경우

- 각하재결은 행정심판 청구가 제기 요건을 갖추지 못하였을 때 본안 심사를 거부하는 재결이다. 이 경우 재결 자체는 원처분의 위법성에 대해 아무런 판단을 내리지 않았으므로, 재결에 고유한 위법이 있다고 보기 어렵다. 따라서 각하재결에 대해서는 취소소송을 제기할 수 없으며, 청구인은 여전히 원처분을 소송의 대상으로 삼아 원처분의 위법성을 다투어야 한다. 다만, 예외적으로 행정심판 청구 요건을 충족하였음에도 재결기관이 이를 오판하여 각하재결을 한 경우에는, 재결 자체에 고유한 위법이 있다고 보아 취소소송의 대상이 될 여지가 있다.

2. 기각재결을 한 경우[행심법 제47조 제1항·제2항]

- 기각재결은 행정심판 청구가 요건을 갖추었으나 청구의 이유가 없다고 판단하여 원처분의 적법성을 유지하는 재결이다. 행정심판법 제47조 제1항 및 제2항에 따라 기각재결은 청구인에게 원처분과 별도로 새로운 법적 불이익을 가져오지 않으므로, 원칙적으로 취소소송의 대상이 되지 않는다. 소송의 대상은 여전히 원처분이다. 다만, 기각재결에 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에는 예외적으로 재결 취소소송의 대상이 될 수 있다. 예를 들어 재결기관의 구성 위법이나 절차상 중대한 하자가 있는 경우 등이 이에 해당한다.

3. 인용재결을 한 경우(취소심판 대상)

- 취소심판에 대한 인용재결은 원처분의 전부 또는 일부를 취소하는 재결이다. 이 경우 인용재결은 원처분의 효력을 소멸시키거나 변경시키는 법적 효과를 발생시키므로, 청구인에게는 만족스러운 결론이 된다. 따라서 인용재결 자체를 취소해달라는 소송을 제기할 실익이 없으므로 취소소송의 대상이 되지 않는다. 만약 인용재결의 내용 중 일부 인용 등으로 인해 여전히 불이익이 남아있는 경우에는, 당초 원처분 중 남아있는 부분을 대상으로 다투어야 한다.

4. 인용재결을 한 경우(의무이행심판 대상)

- 의무이행심판에 대한 인용재결은 행정청에게 특정 처분을 하라고 명령하는 내용을 가지는 재결이다. 이 재결은 처분 자체가 아니라 처분 명령이므로 그 자체로 직접적인 권리 의무의 변동을 일으키지 않는다. 따라서 인용재결 자체를 취소소송의 대상으로 삼는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 이러한 재결은 후속 처분을 유도하는 효과를 가지며, 만약 행정청이 재결의 기속력에 따른 처분을 하였음에도 불구하고 청구인에게 불이익이 남아있다면, 청구인은 그 후속 처분을 대상으로 소송을 제기해야 한다.

III. 행정소송법 제19조 단서를 위반한 경우의 처리

- 행정소송법 제19조 단서는 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다.라고 규정하여, 재결에 고유한 위법이 있다면 예외적으로 재결 자체를 취소소송의 대상으로 삼을 수 있음을 명시한다. 재결 고유의 위법이라 함은 원처분의 위법 사유와 관계없이 재결 자체에 내재하는 위법 사유를 의미한다. 예를 들어 재결기관의 관할 위반, 재결의 참가인 누락 등 절차적 위법, 행정심판의 대상이 아닌 사항에 대해 재결을 한 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우, 원처분의 위법성 여부와 별개로 재결의 취소를 구하는 소송이 가능하며, 재결이 취소되면 원처분은 다시 살아나게 된다. 다만, 판례는 재결 자체에 고유한 위법을 상당히 제한적으로 인정하는 경향이 있다.

IV. 예외적인 재결주의의 적용

1. 중앙노동위원회의 재심판정[노위법 제27조 제1항]

- 노동위원회법은 지방노동위원회의 처분이 아닌 중앙노동위원회의 재심판정 및 처분에 대하여만 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하여 재결주의를 명시적으로 채택하고 있다. 이는 지방노동위원회의 초심 판정에 대하여 불복하는 경우 반드시 중앙노동위원회의 재심을 거쳐야 하며, 그 재심 판정만이 사법 심사의 대상이 됨을 의미한다. 노동 사건의 특성상 전문성 있는 기관의 심사를 최대한 활용하고, 분쟁의 조속한 해결을 도모하려는 입법적 취지이다.

2. 감사원 재심의 판정[감사원법 제40조 제2항]

- 감사원법은 감사원의 변상 판정이 아닌 재심의 판정이 있을 경우, 그 재심의 판정을 대상으로 행정소송을 제기하도록 규정하여 재결주의를 채택한다. 감사원의 변상 판정은 준사법적인 성격을 갖는 고도의 전문적인 판단이므로, 재심의 판정을 거쳐 최종적인 판단을 구하도록 한 것이다. 따라서 당사자는 원래의 변상 판정이 아닌 재심의 판정을 취소소송의 대상으로 삼아 다투어야 한다.

3. 특허심판 심결[특허법 제186조, 제189조]

- 특허법에서는 심사관의 거절사정이 아닌 특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 소송을 제기하도록 규정하여 재결주의를 취하고 있다. 특허 분야는 고도의 기술적 전문성이 요구되는 영역이므로, 행정심판 단계에 해당하는 특허심판원의 심결을 최종적인 처분으로 간주하여 소송의 대상이 되도록 한 것이다. 이는 전문 행정기관의 판단을 존중하고 사법 심사의 효율성을 높이려는 목적이 있다. 따라서 특허 관련 소송은 심결 자체를 대상으로 한다.

V. 결론

- 취소소송의 대상적격에 있어 재결의 지위는 원칙적으로 원처분주의 하에 보충적 역할을 수행하며, 행정소송법 제19조 단서에 따라 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에만 예외적으로 소송의 대상이 된다. 이는 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하면서도 법적 안정성을 해치지 않으려는 입법자의 의도를 반영한다. 다만, 중앙노동위원회 재심판정 등 일부 전문 영역에서는 행정심판 기관의 전문성 및 분쟁 조기 해결의 필요성을 고려하여 명문으로 재결주의를 채택하고 있다. 따라서 취소소송 제기 시 소송의 대상이 원처분인지 재결인지 여부를 개별 법률 규정 및 행정소송법의 기본 원칙에 따라 신중하게 판단해야 한다.

<제3장 취소소송의 당사자자격.제1절 원고적격>

I. 원고적격의 의의

1. 개념

- 원고적격이라 함은 취소소송을 제기하는 원고가 되어 본안 판결을 받을 수 있는 법률상의 자격을 말한다. 행정소송법 제12조는 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자만이 원고적격을 가진다고 규정하여, 원고적격의 범위를 법률상 이익이 있는 자로 제한한다. 이는 단순한 사실상의 이익이나 반사적 이익을 가진 자는 포함하지 않으며, 공익 소송이나 객관적 소송으로서의 민중소송과 기관소송과는 구별되는 주관적 소송 요건이다. 원고적격은 당사자적격 중 원고 측에 해당하는 요건이다.

2. 법적 성격

- 원고적격은 취소소송의 본안 판단에 앞서 법원이 심리해야 하는 소송요건에 해당한다. 소송요건은 법원의 직권조사사항이므로, 당사자의 주장 유무에 관계없이 법원이 직권으로 조사해야 하며, 만약 원고적격이 결여된 경우에는 법원은 본안 심리를 거부하고 각하판결을 해야 한다. 이는 불필요한 소송 남발을 방지하고 행정의 효율성을 유지하기 위함이다. 다만, 직권조사사항이라 하더라도 변론주의의 적용을 배제하는 것은 아니므로, 법원은 당사자의 주장 및 증거 제출 결과를 참작하여 판단한다.

II. 원고적격의 범위

1. 법률상 이익의 의미

- 행정소송법 제12조의 법률상 이익의 의미에 대하여 학설은 권리구제설, 법적 이익구제설, 적법성 보장설 등으로 나뉘어 대립해왔다. 현재 통설과 판례는 법적 이익구제설의 입장을 취하며, 이는 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 직접적·구체적 이익을 말한다. 이 이익은 단순한 반사적 이익이나, 사실상·경제적 이해관계를 넘어, 공익 일반의 침해가 아닌 자신의 개별적 이익에 대한 침해가 있어야 한다. 판례는 최근 환경 관련 소송 등에서 법률상 이익의 범위를 점차 확대하여 해석하는 경향을 보여, 법률의 취지와 목적을 고려하여 보호할 가치가 있는 이익이라면 이를 법률상 이익으로 인정한다.

2. 법률상 이익에서 법률의 범위

- 원고적격을 판단하는 기준이 되는 법률은 당해 처분의 근거가 되는 법규 뿐만 아니라, 당해 처분과 관련된 모든 관계 법규를 포괄적으로 의미한다. 여기서 관계 법규라 함은 처분으로 인해 침해되는 이익을 직접 보호하는 규정 뿐만 아니라, 관련 제도의 취지나 목적 등을 고려할 때 간접적으로 사익 보호 기능을 가지고 있는 법규까지 포함된다. 따라서 원고적격 판단 시에는 해당 법규가 공익 보호 목적 외에 사익 보호 목적도 가지고 있는지 여부를 면밀히 검토해야 한다. 단순히 처분의 적법성을 확보하기 위한 조직 규정이나 훈령 등의 내부 규정은 원칙적으로 포함되지 않는다.

III. 원고적격 인정 여부의 유형별 검토

1. 처분의 상대방

- 침익적 처분의 상대방은 당연히 그 처분으로 인해 직접적으로 권리 의무에 변동을 겪게 되므로, 원칙적으로 법률상 이익이 있는 자로 인정되어 원고적격이 인정된다. 예를 들어 영업 정지 처분의 직접 상대방인 영업주는 해당 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다. 다만, 수익적 처분의 상대방은 원칙적으로 취소를 구할 이익이 없지만, 그 수익적 처분이 특정 제한을 포함하거나 부관 등으로 인해 일부 침익적 성격을 띠는 경우에는 그 침익적 부분에 대해서 원고적격이 인정될 수 있다.

2. 공법인과 국가기관

- 공법인은 법인으로서 행정주체 또는 공무 수행의 주체가 될 수 있으나, 그 자체의 공법상 권리의 의무에 대한 침해가 있다면 사법상의 권리 주체와 마찬가지로 원고적격이 인정된다. 예를 들어 지방자치단체가 국가의 처분에 대하여 자치권 침해 등 법률상 이익의 침해를 주장하는 경우 원고적격이 인정될 수 있다. 한편, 국가기관 간의 권한 쟁의 등은 취소소송이 아닌 헌법재판소의 권한쟁의심판의 대상이 되는 것이 원칙이므로, 국가기관 자체는 원칙적으로 행정소송의 원고적격이 부정된다.

3. 법인 및 단체의 구성원

- 법인 및 단체의 구성원은 당해 처분이 법인 또는 단체 자체를 대상으로 한 경우, 그 구성원이 아무리 사실상 불이익을 받더라도 원칙적으로 원고적격이 부정된다. 이는 법인과 구성원의 법적 인격이 분리되어 있기 때문이다. 다만, 처분의 효력이 법인 자체에 미치는 것을 넘어 구성원 개개인의 법적 지위나 권리의 의무에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 예외적으로 구성원에게 원고적격이 인정될 수 있다. 예를 들어 특정 전문직 단체에 대한 인가 취소 처분이 구성원 개인의 업무 수행 자격 등에 직접적인 제한을 가져오는 경우 등이 이에 해당한다.

4. 제3자요 행정행위에서의 원고적격

- 제3자요 행정행위는 특정인에게 수익적인 처분을 함과 동시에 제3자에게는 침익적인 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다. 이때 불이익을 받는 제3자에게 원고적격이 인정되는지 여부가 문제된다. 제3자요 행정행위의 유형은 크게 세 가지로 나뉜다.

(1) 경업자 소송

- 기존 사업자가 경쟁 관계에 있는 제3자에게 행정청이 동일한 사업 허가를 내주었을 때, 그 허가 처분으로 인해 자신의 영업상 이익이 침해되었다고 주장하며 제기하는 소송이다. 판례는 근거 법규가 기존 사업자의 이익 보호를 목적으로 하는 경우에만 원고적격을 인정하며, 단순한 사실상 이익의 감소만으로는 원고적격이 부정된다.

(2) 경원자 소송

- 하나의 허가나 특허 등이 특정인에게만 가능하여 신청인 상호간에 경쟁 관계가 성립하는 경우, 자신이 배제되고 타인에게 허가된 처분의 취소를 구하는 소송이다. 경원자 관계에 있는 패소한 신청인은 자신이 허가를 받을 가능성이 있었으므로, 원칙적으로 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정된다. 이는 허가 처분이 경쟁 관계에 있는 다른 신청인의 기회를 박탈하는 효과를 가지기 때문이다.

(3) 인인 소송

- 타인에게 행해진 처분이 인근 주민의 환경권, 일조권, 조망권 등 생활 이익을 침해할 때 제기하는 소송이다. 판례는 침해된 이익이 근거 법규 또는 관련 법규에 의해 개별적 이익으로 보호되는 경우에 한하여 원고적격을 인정한다. 예를 들어 환경영향평가법 등 관계 법규가 주민의 생활 환경 보호를 목적으로 하고 있다고 판단되는 경우 인근 주민에게 원고적격이 인정될 수 있다.

IV. 그 밖에 원고적격 인정 여부가 문제되는 경우

1. 원고적격을 인정한 사례

- 법률상 이익의 확대 해석 경향에 따라 다양한 경우에 원고적격이 인정되어왔다. 예를 들어 환경영향평가 대상 지역 내 주민은 법적 추정하에 직접적인 환경상 이익의 침해를 입을 가능성이 있으므로 원고적격이 인정된다. 또한, 의료법상 의료기관 개설 허가 처분에 대하여 기존 의료기관이 근거

법규의 목적에 비추어 경업자로서 공익적 보호 가치가 있는 이익이 침해된다고 인정되는 경우 원고적격이 인정된다. 도시계획 결정 변경 신청 거부 처분에 대하여 토지 소유자에게 신청권이 인정되는 경우, 그 거부처분 취소 소송의 원고적격이 인정된 사례도 있다.

2. 원고적격을 부정한 사례

- 단순히 사실상 또는 경제적으로 불이익을 받는 경우에는 원고적격이 부정된다. 예를 들어 학교 법인 이사 해임 처분의 취소를 구하는 소송에 대하여 그 학교 법인이 학교 운영에 관여하는 권한이 침해되었다는 주장만으로는 원고적격이 부정된다. 이는 해임 처분의 직접 상대방이 아니기 때문이다. 또한, 특정 도로 통행 제한 처분에 대하여 인근 상가 주인이 매출 감소라는 경제적 손해를 주장하는 경우, 그것이 관련 법규의 직접적인 보호 대상이 아니라면 원고적격이 부정된다. 순수한 공익 보호 목적으로만 설립된 환경 단체가 환경 침해를 이유로 처분 취소를 구하는 경우에도, 개별적 법률상 이익의 침해가 입증되지 않으면 원고적격이 부정된다.

V. 결론

- 원고적격은 취소소송의 가장 핵심적인 소송요건으로서, 법률상 보호되는 이익의 유무를 기준으로 판단된다. 판례는 법률상 이익의 범위를 탄력적으로 해석하여 단순히 처분의 직접 상대방뿐만 아니라, 제3자요 행정행위 및 환경 영향 관련 소송 등에서 개별적 법률 보호 이익을 가진 제3자에게도 원고적격을 인정함으로써 권리 구제의 폭을 넓혀왔다. 이러한 경향은 현대 행정의 복잡성과 다양화된 침해 양상에 대응하여 사법 통제를 확대하고 국민의 재판 받을 권리를 실질적으로 보장하려는 취지이다. 따라서 개별 사안별로 근거 법규와 관계 법규의 목적 및 취지를 종합적으로 고려하여 원고적격 유무를 판단해야 한다.

<제3장 취소소송의 당사자적격.제2절 피고적격>

I. 피고적격의 의의

1. 개념[행소법 제13조]

- 피고적격이라 함은 취소소송을 제기하는 경우 피고가 될 수 있는 법률상의 자격을 말한다. 행정소송법 제13조 제1항은 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다라고 규정한다. 따라서 피고적격은 원처분등을 자신의 이름으로 대외적으로 행한 행정청이 갖는 것이 원칙이며, 이는 취소소송의 소송요건 중 당사자적격 중 피고 측에 해당한다. 법원은 피고적격 유무를 직권으로 조사해야 하며, 결여된 경우에는 각하판결을 내린다.

2. 취지

- 취소소송의 피고적격을 행정청에 부여하는 취지는 행정청이 그 처분등을 행하는 기관으로서 처분 관련 자료를 보유하고 있어 소송 수행에 가장 적합하며, 소송에서 패소할 경우 판결의 기속력에 따라 후속 조치를 이행해야 할 책임이 있기 때문이다. 행정소송법이 행정주체가 아닌 행정청을 피고로 정함으로써 소송 수행의 능률성을 높이고, 국민은 복잡한 행정주체를 특정할 필요 없이 자신에게 불이익을 가한 행정기관을 직접 상대할 수 있어 권리 구제의 편의성을 제공한다.

II. 행정청

1. 처분청

- 취소소송의 피고는 원칙적으로 당해 처분등을 자신의 이름으로 대외적으로 행한 처분청이 된다. 여기서 처분청이라 함은 처분 당시 그 권한을 행사한 행정기관을 의미하며, 처분 후 기관의 장 등이 변경되어도 처분청 자체는 동일하다. 다만, 재결 취소소송의 경우 행정소송법 제19조 단서에 따라 재결 자체에 고유한 위법이 있을 때에는 재결청이 피고가 된다. 이는 처분청과 재결청이 분리되어 존재하는 경우 발생하며, 대다수 취소소송에서는 원처분청이 피고적격을 갖는다.

2. 권한승계[행소법 제13조 제1항 단서]

- 처분청이 처분 후 사무를 다른 행정청에 승계시킨 경우에는 행정소송법 제13조 제1항 단서에 따라 그 권한을 승계한 행정청이 피고가 된다. 이는 소송 수행의 효율성을 위한 규정이며, 권한의 승계 사실은 법원이 직권으로 조사하여 판단한다.

3. 기관폐지[행소법 제13조 제2항]

- 처분청이 처분 후 폐지되어 더 이상 존재하지 않게 된 경우에는 행정소송법 제13조 제2항에 따라 그 처분등이 속하는 국가 또는 공공단체가 피고가 된다. 이때 피고로 된 국가 또는 공공단체를 대표하는 자가 소송을 수행하게 된다. 이는 국민의 권리 구제를 확보하기 위해 행정주체를 예외적으로 피고로 인정하는 경우이다.

III. 피고적격 인정 여부의 유형별 검토

1. 권한의 위임·위탁

- 권한의 위임·위탁은 법적 근거에 따라 행정청의 권한 자체가 수임청 또는 수탁청에 이전되는 것을 의미한다. 이 경우 수임청 또는 수탁청은 자신의 권한으로 처분을 행하는 것이므로, 대외적으로 처분 명의를 표시한 수임청 또는 수탁청이 피고적격을 갖는다. 판례 역시 위임 또는 위탁을 받은 기관이 자신의 이름으로 처분을 행한 경우에는 그 수임청 등이 피고가 된다고 일관되게 판시한다.

2. 권한의 내부위임

- 권한의 내부위임은 권한 자체의 이전 없이 위임청의 결재 권한을 수임청 등에게 내부적으로 부여하는 것에 불과하다. 따라서 대외적인 처분 권한은 여전히 위임청에 있으며, 실령 수임청 등이 자신의 이름으로 처분 명의를 표시하였더라도 그것은 위임청의 처분으로 간주된다. 결과적으로 권한의 내부 위임이 있을 경우 피고적격은 위임청이 갖는 것이 원칙이다. 다만, 대외적으로 수임청 등이 자신에게 권한이 있는 것처럼 표시한 경우 신뢰 보호의 원칙상 수임청 등을 피고로 인정할 수 있는지 여부가 학설상 논의된다.

3. 권한대리

- 권한대리는 피대리청을 대신하여 대리청이 피대리청의 권한을 행사하는 것을 말한다. 이때 처분 명의를 피대리청의 이름으로 대리청이 행한다는 형식을 취해야 한다. 처분 명의를 피대리청으로 표시된 경우 피고적격은 피대리청이 갖는 것이 원칙이다. 다만, 수권대리의 경우 대리청이 자신의 이름으로 처분 명의를 표시하였더라도 그 실질이 피대리청의 권한 행사라면 피대리청이 피고가 되며, 대리청의 명의로 처분을 행한 경우에는 대리청이 피고가 된다는 견해가 대립한다.

4. 합의제 행정기관[노위법 제27조]

- 중앙노동위원회와 같은 합의제 행정기관의 처분 또는 재결에 대한 취소소송의 피고적격은 노동위원회법 제27조 제1항 등 개별 법률에 따라 규정된다. 노동위원회법 제27조 제1항은 중앙노동위원회의 재심판정에 대한 소송은 중앙노동위원회 위원장을 피고로 하도록 명문으로 규정한다. 이처럼 합의제 기관의 경우 일반적으로 그 합의제 기관 자체가 아닌, 그 기관의 대표자인 위원장 등 기관의 장을 피고로 규정하는 것이 특징이다. 이는 소송 수행의 편의를 위한 것이다.

5. 지방의회와 지방자치단체의 장

- 지방의회는 원칙적으로 법규 제정 등 의결 기관의 성격이 강하여 대외적으로 처분을 행하는 행정청으로 보기 어렵다. 따라서 지방의회 의결은 처분성이 부정되는 것이 일반적이며, 지방의회의 피고적격 또한 부정된다. 다만, 지방의회 의원 징계 의결과 같이 예외적으로 처분성이 인정되는 경우에는, 그 의결을 행한 지방의회 자체가 피고적격을 갖는다는 것이 판례의 입장이다. 한편, 지방자치단체의 장은 자체 행정청으로서 처분을 행하는 기관이므로 피고적격이 인정된다.

6. 공법인의 경우[행소법 제2조 제2항]

- 공법인이 공권력을 행사하는 주체로서 처분을 행한 경우 피고적격이 문제된다. 행정소송법 제2조 제2항은 행정청에는 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관, 공공단체 및 그 기관 또는 사인이 포함된다고 규정한다. 따라서 법령에 따라 행정권한을 위임 또는 위탁받아 자신의 이름으로 처분을 행한 공법인 또는 그 기관은 피고적격이 인정된다. 예를 들어 공기업, 공단 등이 법률에 따라 권한을 받아 처분을 행한 경우 해당 공법인이 피고적격을 갖는다.

7. 다른 법률에 특별규정이 있는 경우

- 행정소송법 제13조 제1항 본문은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 처분청을 피고로 한다고 규정하여, 개별 법률에서 피고적격에 관해 달리 정한 경우에는 그 특별규정이 우선됨을 명시한다. 예를 들어 앞서 살펴본 노동위원회법 제27조 제1항이 중앙노동위원회 위원장을 피고로 규정한 것 등이 이에 해당한다. 이러한 특별규정은 해당 행정 분야의 특수성을 반영하여 소송 수행의 편의를 도모하기 위함이다. 따라서 소송 제기 전에 반드시 관련 개별 법률의 특별규정 존재 여부를 확인해야 한다.

N. 피고경정

1. 피고경정의 의의

- 피고경정이라 함은 원고가 처음 소송을 제기할 때 피고적격이 없는 자를 피고로 잘못 지정하거나, 피고적격은 있으나 다른 자가 피고로 되어야 할 경우, 법원의 허가를 받아 피고를 정당한 피고로 변경하는 것을 말한다. 이는 피고 특정의 오류로 인해 발생하는 소송 각하의 위험을 방지하고 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하기 위한 제도이다.

2. 피고경정이 허용되는 경우[행소법 제14조 제1항·제6항, 제21조 제4항]

- 행정소송법 제14조 제1항 및 제6항, 제21조 제4항은 피고경정이 허용되는 경우를 규정한다.

(1) 피고 오지정의 경우[행소법 제14조 제1항]

- 원고가 피고를 잘못 지정하여 피고적격이 없는 자를 피고로 삼은 경우, 행정소송법 제14조 제1항에 따라 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 의해 정당한 피고로 경정할 것을 허가할 수 있다.

(2) 권한승계 및 기관폐지의 경우[행소법 제14조 제6항]

- 처분등이 있는 뒤에 권한이 다른 행정청에 승계된 경우에는 승계한 행정청으로, 처분등을 한 행정청이 없게 된 경우에는 그 처분등에 관한 사무가 귀속되는 국가 또는 공공단체로 피고를 경정한다.

(3) 소의 변경이 있는 경우[행소법 제21조 제4항]

- 항고소송과 당사자소송 간 소의 변경이 있는 경우에는 피고의 변경을 수반하므로, 법원은 새로이 피고가 될 자의 의견을 들어 피고를 경정할 수 있다.

3. 피고경정의 요건

- 피고경정이 허용되기 위해서는 다음과 같은 요건이 충족되어야 한다. 첫째, 원고가 피고를 잘못 지정했을 것. 둘째, 법원이 사실심 변론종결 전까지 허가 결정을 할 것. 셋째, 새로운 피고에 대한 소송이 적법할 것. 넷째, 종전의 피고와 새로운 피고 모두에게 현저한 불이익을 줄 우려가 없을 것 등이 요구된다. 특히 제소기간 내에 정당한 피고에 대하여 소송을 제기할 수 있었는지 여부가 중요한 판단 기준이 된다.

4. 피고경정의 절차 및 효력

- 피고경정은 원고의 신청 또는 법원의 직권으로 이루어지며, 법원은 결정으로 이를 허가한다. 결정이 있으면 종전 피고에 대한 소송은 취하된 것으로 간주되고, 새로운 피고에 대한 소송이 처음부터 제기된 것으로 본다. 이러한 소급효는 제소기간 준수 여부를 판단할 때 매우 중요한 효력을 발휘하여, 원고가 당초 소송을 제기한 시점에 새로운 피고에 대해 소송을 제기한 기산점으로 보아 제소기간 준수 여부를 판단한다.

V. 결론

- 취소소송의 피고적격은 당해 처분을 자신의 이름으로 대외적으로 행한 행정청이 갖는 것이 원칙이며, 이는 소송의 효율성과 판결의 기속력 확보를 위한 제도적 선택이다. 권한의 위임이나 내부위임, 대리 등 행정청의 다양한 권한 행사 형태에 따라 피고적격 유무가 달라지므로, 처분 명의가 누구에게 있는지 및 실질적인 권한의 이전 여부를 엄격하게 구별해야 한다. 또한, 피고 오지정의 경우 행정소송법상 피고경정 제도를 통해 제소기간 준수 등 국민의 권리 구제를 위한 구제 수단을 마련하고 있다.

<제3장 취소소송의 당사자적격.제3절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

I. 소의 이익의 의의

1. 개념

- 소의 이익이라 함은 원고가 취소소송을 통해 본안 판결을 받아 자신이 주장하는 권리 또는 법률상 이익을 구제받을 필요성을 말한다. 이는 원고적격이 소송 제기 당시 법률상 이익의 침해 가능성에 주안점을 두는 데 비하여, 소의 이익은 소송이 계속되는 동안 판결을 받을 실효성과 계속적인 법률상 이익의 존재 필요성을 의미한다. 협의의 소의 이익은 소송의 종료 시점까지 원고의 권리 구제에 실질적인 도움이 되는지 여부로 판단된다.

2. 법적 근거

- 소의 이익의 법적 근거는 행정소송법 제12조 후문에 있다. 동 조항은 처분등의 효과가 기간의 경과, 처분등의 집행 그 밖의 사유로 인하여 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자의 경우에는 또한 같다.고 규정한다. 이 규정은 원칙적으로 소멸된 처분에 대한 소의 이익을 부정하지만, 예외적으로 회복되는 법률상 이익이 있는 경우에는 소의 이익을 인정함으로써 소의 이익의 범위 확장 근거를 마련한다.

3. 행정소송법 제12조 후문의 법적 성질

- 행정소송법 제12조 후문은 소의 이익의 존부를 판단하는 기준 규정으로서, 취소소송의 소송요건을 구성하는 규정이다. 이 규정은 취소소송의 가치가 단순히 원처분의 효력 제거에 국한되는 것이 아니라, 나아가 위법 상태의 재발 방지나 가중된 불이익 배제 등 다른 법률상 이익의 회복 필요성까지 포함함을 명확히 한다. 소의 이익이 결여되면 법원은 직권으로 조사하여 본안 판단을 거부하고 각하판결을 내려야 한다.

4. 회복되는 법률상 이익의 범위

- 행정소송법 제12조 후문에서 말하는 회복되는 법률상 이익은 취소 판결의 결과로 원고에게 돌아가는 이익을 의미한다. 이 이익은 단순히 사실상 이익이나 감정적 만족을 넘어 법적으로 보호되는 가치를 가져야 한다. 구체적으로 이는 ① 가중된 불이익 제거 가능성, ② 후속 처분의 적법 요건 확보 가능성, ③ 명예나 신용 등 법률상 보호되는 무형의 이익 회복 가능성 등을 포함한다. 이러한 이익이 존재하는 경우에만 처분의 효력이 소멸했더라도 소의 이익이 인정될 수 있다.

II. 소의 이익의 일반적 판단기준

1. 판단기준[행소법 제12조 후문]

- 소의 이익은 원칙적으로 처분의 취소를 통해 원상회복이 가능하거나 침해된 법률상 이익이 회복될 실질적인 가능성이 있어야 인정된다. 판단의 기준 시점은 사실심 변론종결 시이다. 행정소송법 제12조 후문의 취지에 따라, 설령 처분의 효력이 소멸했다 하더라도, 취소 판결의 기속력을 통해 장래의 가중된 불이익을 방지할 수 있거나, 기타 법률상 이익을 회복할 수 있다면 소의 이익은 인정된다. 따라서 판단은 형식적인 처분 효력 유무가 아닌 실질적인 법률상 이익의 회복 가능성에 초점을 맞춘다.

2. 소의 이익의 범위 확장

- 소의 이익의 범위 확장은 주관적인 권리 구제 외에 객관적인 행정의 적법성 확보 및 법질서의 유지라는 공익적 목적을 고려하여 이루어진다. 특히 ① 반복될 위험성이 있는 유사 위법 처분에 대해 취소 판결의 기속력을 미치게 함으로써 장래의 침해를 예방하는 경우, ② 당해 처분의 취소가 다른 법률관계의 선결 문제가 되어 원고의 법적 지위에 영향을 미치는 경우에 소의 이익이 인정되어 그 범위가 확장된다. 이러한 확장은 법원의 재량적 판단 영역이 아니라 행정소송법 제12조 후문의 취지에 따른 법률상 이익의 인정 문제로 파악된다.

III. 소의 이익 인정 여부의 유형별 검토

1. 처분의 효력이 소멸한 경우

- 처분의 효력이 기간의 경과 등으로 소멸한 경우, 원칙적으로 처분을 취소하더라도 원상회복이 불가능하므로 소의 이익이 부정된다. 예를 들어 단기 간의 영업 정지 기간이 만료된 경우 등이다. 다만, 소멸된 처분이 장래의 법률 관계에 영향을 미쳐 원고에게 불이익을 초래할 때는 예외적으로 소의 이익이 인정된다. 가장 대표적인 예는 선행 처분이 가중된 제재 처분의 전제 조건이 되는 경우이다. 이때 취소 판결을 통해 가중 제재를 면할 수 있는 법률상 이익이 회복되는 것으로 본다.

2. 처분 후의 사정변경에 의하여 권리침해상태가 해소된 경우

- 처분이 있은 후 원고의 사망, 목적물의 멸실, 양도 등 사실상의 사정 변경으로 인해 침해된 권리 상태가 해소된 경우, 더 이상 취소 판결을 구할 실익이 없으므로 소의 이익이 부정된다. 예를 들어 운전면허 취소 처분 후 원고가 사망한 경우 등이다. 다만, 사정변경이 단순한 사실상의 해소에 그치지 않고 다른 법률상의 이익 회복 필요성을 남기는 경우에는 소의 이익이 인정될 수 있다. 예를 들어 징계 처분 후 퇴직하였더라도 퇴직금 등 법률상의 권리에 영향을 미치는 경우 등이다.

3. 원상회복이 불가능한 경우

- 처분의 취소를 신고하더라도 이미 원상회복이 물리적 또는 법적으로 불가능하게 된 경우 소의 이익은 부정된다. 예를 들어 토지 수용 처분 후 이미 공사가 완료되어 원상회복이 극히 곤란한 경우 등이다. 그러나 원상회복이 불가능하다 하더라도, 처분의 취소 판결이 국가배상청구 등 다른 구제 절차의 선결 요건이 되거나, 원고의 명예나 신용 등 무형의 법률상 이익 회복에 실질적인 도움이 되는 경우에는 예외적으로 소의 이익이 인정된다.

4. 보다 실효적인 권리구제절차가 있는 경우

- 원고에게 취소소송 외에 민사소송이나 헌법소원 등 보다 간이하고 실효적인 권리 구제 절차가 별도로 있는 경우 취소소송의 소의 이익은 부정될 수 있다. 다만, 행정소송법상 취소소송은 다른 구제 절차와 독립적으로 인정되는 것이 원칙이다. 따라서 취소소송의 판결이 장래의 법률 관계나 다른 법률상의 이익 회복에 필수적이거나 중요한 영향을 미치는 경우에는, 손해배상청구 등 다른 구제 수단이 있더라도 소의 이익은 인정된다. 예를 들어 부당이득 반환 청구를 위해 선행 처분의 취소가 필요한 경우 등이다.

5. 위법한 처분의 반복가능성이 있는 경우

- 단기적 처분의 효력이 소멸했더라도 동일한 상황에서 유사한 위법 처분이 반복될 위험성이 높아 취소 판결의 기속력을 통해 장래의 침해를 예방할 필요성이 있는 경우에는 소의 이익이 인정된다. 이는 단기 처분의 특성상 소송 도중 효력이 만료되어 국민의 재판 받을 권리가 형해화되는 것을 방지하기 위함이다. 판례는 운전면허 정지 처분등 반복적이고 단기적인 제재 처분의 경우에 이를 인정하는 경향을 보인다.

6. 단계적 행정결정의 경우

- 선행처분과 후행처분이 단계적인 일련의 절차로 연속하여 행하여져 후행처분이 선행처분의 적법함을 전제로 이루어짐에 따라, 선행처분의 하자가 후행처분에 승계된다고 볼 수 있어 이미 소를 제기하여 다투고 있는 선행처분의 위법성을 확인하여 줄 필요가 있는 경우 등에는 행정의 적법성 확보와 그에 대한 사법통제, 국민의 권리구제의 확대 등의 측면에서 여전히 그 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

7. 원고의 청구가 이론적 의미만 있을 뿐 실제적 효용이 없는 경우

- 원고의 청구가 단순히 법적인 의미 확인이나 위법 선언이라는 추상적 목적만을 가질 뿐, 구체적인 법률상 이익의 회복 가능성이 없는 경우에는 소의 이익이 부정된다. 예를 들어 이미 완전히 해소된 법적 분쟁에 대하여 단순히 역사적 사실 확인을 구하는 경우 등이다. 취소소송은 주관적 소송으로서 개인의 권리 구제를 목표로 하므로, 객관적 소송의 성격을 띄는 순수한 이론적 주장만으로는 소의 이익을 인정할 수 없다.

IV. 결론

- 협의의 소의 이익은 취소소송의 원고적격 확보 이후에도 소송 계속의 정당성을 유지하는 핵심적인 소송요건이다. 행정소송법 제12조 후문의 규정에 따라, 설령 기간의 경과 등으로 처분의 효력이 소멸하거나 사정변경으로 인해 원상회복이 불가능해졌더라도, 취소 판결의 기속력을 통해 장래의 가중된 불이익을 배제하거나 다른 법률상 이익을 회복할 수 있는 실질적 필요성이 존재한다면 소의 이익은 예외적으로 인정된다. 특히 단기 처분의 반복 위험성에 대한 판례의 입장은 국민의 재판 받을 권리를 실질적으로 보장하기 위한 적극적인 해석 결과이다. 따라서 소의 이익 판단 시에는 취소 판결이 원고의 법적 지위 회복에 미치는 구체적이고 실효적인 법률상의 영향을 종합적으로 고려해야 한다.

<제3장 취소소송의 당사자적격.제4절 소송참가>

I. 소송참가의 의의

1. 개념

- 소송참가라 함은 취소소송이 법원에 계속되어 있는 중에 당사자 이외의 제3자 또는 관련 행정청이 자신의 이익을 위하여 소송에 가입하는 것을 말한다. 행정소송법은 취소소송의 특수성을 고려하여 제3자의 소송참가와 행정청의 소송참가를 민사소송법과 달리 별도로 규정하고 있다. 이는 취소 판결의 효력이 당사자 이외의 자에게도 미치는 특성 때문에 도입된 제도이다.

2. 필요성

- 소송참가 제도의 필요성은 주로 행정소송의 객관적 효력에서 비롯된다. 취소소송의 확정 판결은 제3자에게도 효력을 미치는 제3자효와 처분청 및 다른 행정청을 구속하는 기속력을 갖는다. 따라서 소송의 결과에 이해관계가 있는 제3자에게 자신의 권리 또는 이익을 방어할 기회를 주기 위해 제3자의 참가가 필요하며, 관련 행정청 간의 법률관계 조정과 판결의 실효성 확보를 위해 행정청의 참가 역시 필요하다.

3. 참가형태[행소법 제16조, 제17조, 제38조 제2항, 제44조, 제46조 제1항]

- 행정소송법상 소송참가 형태는 아래와 같은 형태로 나뉘며, 이는 다른 소송 유형에도 준용된다.

(1) 제3자의 소송참가

- 행정소송법 제16조에 따라 소송의 결과로 인하여 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 참가하는 것이다.

(2) 행정청의 소송참가

- 행정소송법 제17조에 따라 법원이 직권으로 또는 신청에 의해 다른 행정청을 소송에 참가시키거나 참가하게 하는 것이다.

(3) 기타 소송예의 준용

- 무효등 확인소송과 부작위위법확인소송의 경우 행정소송법 제38조 제2항에 따라 제16조와 제17조가 준용되며, 당사자소송에 대해서는 제44조 및 제46조 제1항에 따라 준용 규정이 적용된다.

II. 제3자의 소송참가

1. 의의[행소법 제16조]

- 행정소송법 제16조의 제3자의 소송참가라 함은, 취소소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 스스로 원고나 피고 측에 가담하여 소송에 참여하는 것을 말한다. 이는 제3자효 행정행위의 취소소송에서 자신의 수익적 처분의 효력을 유지하려는 수익자의 참가 등이 대표적이다.

2. 참가의 요건

- 제3자의 소송참가가 허용되기 위해서는 다음과 같은 요건이 필요하다. 첫째, 적법한 취소소송이 법원에 계속되어 있을 것. 둘째, 참가하려는 자가 제3자일 것. 셋째, 소송의 결과에 따라 자신의 권리 또는 이익의 침해를 받을 우려가 있을 것이다. 여기서 권리 또는 이익의 침해라 함은 취소소송의 결과 제3자의 법률상 지위에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 있어야 하며, 단순한 사실상 이익 또는 경제적 이해관계의 손실만으로는 참가 요건이 충족되지 않는다.

3. 참가의 절차[행소법 제16조]

- 제3자의 소송참가는 행정소송법 제16조에 따라 이루어진다. 참가하려는 제3자는 소송이 계속된 법원에 서면으로 참가 신청을 해야 한다. 참가 신청이 있으면 법원은 당사자 및 다른 참가인의 의견을 들어 결정으로 참가를 허가하거나 기각해야 한다.

4. 참가인의 지위

- 제3자로 소송에 참가한 자는 일반 공동 소송인과 유사하게 소송 당사자로서의 지위를 갖는다. 참가인은 원고 또는 피고를 보조하는 것이 아니라 독립된 당사자로서 자신의 주장과 증거를 제출할 수 있으며, 소송 지연을 초래하지 않는 범위 내에서 모든 소송 행위를 할 수 있다. 다만, 당사자의 처분권적 행위인 청구의 포기, 인낙, 화해 등에는 영향을 미칠 수 없다.

5. 불복[행소법 제16조 제3항]

- 법원이 제3자의 참가 신청에 대하여 이를 기각하는 결정을 내린 경우, 참가 신청인은 행정소송법 제16조 제3항에 따라 그 결정에 대해 불복할 수 있다. 이러한 불복은 민사소송법상 즉시항고의 형식으로 이루어지며, 이는 제3자의 방어권 보장을 위한 제도적 장치이다. 참가를 허가하는 결정에 대해서는 당사자나 다른 참가인이 원칙적으로 불복할 수 없다.

III. 행정청의 소송참가

1. 의의

- 행정청의 소송참가라 함은 취소소송의 결과에 따라 권한이 침해되거나 법률상 이익이 영향을 받을 다른 행정청이 소송에 참여하는 것을 말한다. 이는 주로 처분청과 관련된 다른 행정청 간의 권한 분쟁이나 이해관계를 조정하고 법원의 직권 조사 범위를 보충하기 위해 필요하다.

2. 참가의 요건

- 행정청의 소송참가 요건은 다음과 같다. 첫째, 적법한 취소소송이 법원에 계속되어 있을 것. 둘째, 참가하려는 행정청이 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 권리 또는 이익의 침해를 받을 우려가 있을 것이다. 여기서 침해될 이익은 주로 행정권한의 행사 또는 법률이 정한 직무 수행과 관련된 법률상 이익을 의미한다.

3. 참가의 절차[행소법 제17조]

- 행정청의 소송참가는 행정소송법 제17조에 따라 법원의 직권 또는 당사자 및 참가 행정청의 신청에 의해 결정된다. 법원은 결정으로 다른 행정청을 소송에 참가시키거나 참가하게 할 수 있다.

4. 참가행정청의 지위

- 행정청의 참가는 민사소송법상 공동소송인에 준하는 지위를 갖는다. 참가한 행정청은 독립된 당사자로서 원고 또는 피고 측의 주장과 증거를 보강할 수 있으며, 자신의 이익을 위하여 모든 소송 행위를 할 수 있다. 다만, 처분청으로서의 피고적격을 갖는 것은 아니며, 소송의 주도권을 행사할 수는 없다.

5. 불복

- 행정청의 소송참가 결정에 대해 행정소송법은 명시적인 불복 규정을 두고 있지 않다. 그러나 참가 신청을 기각하는 법원의 결정은 참가하려는 행정청의 권리 또는 이익에 영향을 미치므로, 민사소송법상 즉시항고를 통해 불복할 수 있다는 견해가 일반적이다.

IV. 민사소송법상 보조참가

1. 허용 여부

- 민사소송법상의 보조참가(민사소송법 제71조)는 타인 간의 소송 결과에 대해 법률상 이해관계가 있는 제3자가 일방 당사자를 승소시키기 위해 소송에 참가하는 제도이다. 행정소송법은 제3자의 소송참가 규정을 별도로 두고 있으므로, 원칙적으로 행정소송법상의 특별규정이 민사소송법상 보조참가를 배제한다고 본다. 이는 제3자의 소송참가가 행정소송의 특수성을 반영한 필수적 공동소송 유사 형태이기 때문이다.

2. 허용 범위

- 판례는 행정소송법 제16조의 참가 요건인 권리 또는 이익의 침해 우려에는 해당하지 않으나, 소송 결과에 대해 사실상 또는 경제상 이해관계를 가지는 제3자의 경우에는 민사소송법상의 보조참가를 준용하여 허용할 수 있다고 판시한다. 이러한 보조참가는 행정소송법상 참가가 부정되는 영역에서 사실상의 이익을 가진 제3자에게 소송 관여의 기회를 제공하여 실질적인 권리 구제를 확대하는 의미를 갖는다. 보조참가인은 독립된 당사자가 아니라 피보조자를 승소시키기 위해 소송 행위를 할 수 있다.

V. 결론

- 소송참가 제도는 취소소송 판결의 객관적 효력(제3자효 및 기속력)으로 인해 발생하는 이해관계의 충돌 및 권한 관련 문제를 해결하기 위한 필수적인 소송 구조이다. 행정소송법은 이해관계 있는 제3자 및 다른 행정청의 참가 절차와 요건을 명확히 규정하여, 당사자의 권리 방어 기회를 보장하고 판결의 실효성을 높인다. 특히, 제3자의 참가 요건인 법률상 이익의 침해 우려 여부가 가장 핵심적인 판단 기준이며, 민사소송법상 보조참가는 행정소송법상 특별규정이 배제되지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용된다.

<제4장 취소소송의 기타 소송요건.제1절 행정심판전치주의>

I. 행정심판전치주의의 의의

1. 개념[행소법 제18조 제1항]

- 행정심판전치주의라 함은 취소소송을 제기하기 전에 법률이 정한 행정심판 절차를 반드시 거치도록 강제하는 제도를 말한다. 행정소송법 제18조 제1항은 취소소송은 법령의 규정에 따라 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다고 규정하여 임의적 전치주의를 원칙으로 선언한다.

2. 현행제도

- 현행 행정소송법 체계 하에서 행정심판전치주의는 임의적 전치주의가 원칙이다. 따라서 개별 법률에서 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다고 명시적으로 규정하고 있는 경우에만 필요적 전치주의가 적용된다. 현행 제도는 국민의 권리 구제 편의성을 증진하고 신속한 재판을 받을 권리를 강화하는 방향으로 설정되어 있다.

II. 행정심판전치주의의 요건

1. 심판청구의 적법성

- 행정심판전치주의가 적용되는 경우, 취소소송의 제기 전에 청구된 행정심판은 적법한 요건을 갖춘 것이어야 한다. 즉, 청구기간 준수, 피청구인 적격 등 행정심판의 청구 요건을 구비해야 한다. 행정심판이 부적법하다는 이유로 각하재결이 나온 경우에는 원칙적으로 전치 요건을 충족하지 못한다. 다만, 심판기관이 실질적인 심리를 하여 본안에 대한 재결을 한 경우에는 설령 심판 청구가 다소 부적법했더라도 전치 요건은 충족된 것으로 본다.

2. 인적 관련성

- 행정심판 청구인과 후속 취소소송의 원고 간에 인적 동일성이 요구되는지 여부가 문제된다. 판례는 심판 청구인과 소송 원고가 엄격히 동일인일 필요는 없으며, 법률상 이익을 공유하는 관계에 있거나 사실상 동일인으로 볼 수 있는 경우에는 인적 관련성이 인정된다고 본다. 예를 들어 법인의 대표자 변경, 공동 신청인 중 1인의 심판 청구 및 다른 1인의 소송 제기 등의 경우 인적 관련성이 인정될 수 있다.

3. 사물적 관련성

- 행정심판의 대상인 처분과 취소소송의 대상인 처분은 기본적인 동일성을 유지해야 한다. 사물적 관련성은 처분의 취소 소송을 제기한 것이 심판 대상 처분의 위법성 판단을 구하는 것과 동일한 실질을 가지는지 여부로 판단된다. 다만, 처분청이 행정심판 청구 후 원처분을 변경하는 처분을 하였을 때 원고가 변경 후의 처분을 다투면서 소를 변경하는 경우에는 전치주의의 예외 규정(행소법 제18조 제3항 제2호)이 적용되어 사물적 관련성 여부와 상관없이 전치 요건이 충족된 것으로 간주된다.

4. 주장사유의 관련성

- 행정심판 단계에서 주장한 위법 사유와 취소소송 단계에서 주장하는 위법 사유가 동일해야 하는지 여부가 문제된다. 판례는 전치주의는 국민에게 행정심판 절차를 거치도록 요구하는 것에 불과할 뿐, 행정심판 단계에서 주장하지 않은 위법 사유를 소송에서 새로이 주장하는 것을 금지하는 취지까지는 아니라고 본다. 따라서 심판 단계에서 적법한 청구를 하였다면, 소송에서는 심판 단계에서 주장하지 않은 다른 위법 사유도 자유롭게 주장할 수 있다.

5. 전치요건의 충족시기

- 행정심판전치주의의 요건 충족 시기는 사실심 변론종결 시이다. 취소소송의 소송요건은 사실심 변론종결 시까지 유지되어야 하기 때문이다. 따라서 설령 원고가 소송 제기 당시 아직 재결을 받지 못했더라도, 사실심 변론종결 시까지 재결이 있다면 그 요건은 충족된 것으로 보아 적법한 소송이 된다. 이는 국민의 권리 구제 기회를 확대하기 위한 조치이다.

III. 행정심판전치주의의 적용범위

1. 항고소송의 종류와 적용범위[행소법 제38조 제2항·제1항]

- 행정심판전치주의를 규정한 행정소송법 제18조는 취소소송에 관한 규정이다. 행정소송법 제38조 제1항은 무효등 확인소송에 대하여 취소소송의 규정을 준용하도록 하고 있으나, 동조 제2항은 제18조 등 일부 규정을 무효등 확인소송에 명시적으로 준용하고 있지 않다. 따라서 취소소송과 부작위위법확인소송(제18조를 명시적으로 준용하지 않지만 제20조를 준용하고 있어 의무이행심판을 전치한다)에 한하여 전치주의가 적용되며, 무효등 확인소송에는 전치주의가 원칙적으로 적용되지 않는다.

2. 예외적인 개별법상 필요적 전치주의[국세기본법 제56조 제2항, 국가공무원법 제16조 제1항, 교육공무원법 제53조 제1항, 도로교통법 제142조]

- 행정소송법의 임의적 전치주의 원칙에도 불구하고, 개별 법률에서 특정 처분에 대하여 필요적 전치주의를 규정하는 경우가 있다. 이러한 법률 규정은 행정소송법 제18조 제1항의 단서 규정으로서 우선적으로 적용된다. 예를 들어 국세 부과 처분에 대해서는 국세기본법 제56조 제2항에 따라 심판청구 등을 거치도록 규정하며, 공무원에 대한 징계 등 불이익 처분에 대해서는 국가공무원법 및 교육공무원법 등에서 소청심사 등을 필수적으로 거치도록 한다. 도로교통법 제142조 역시 운전면허에 관한 처분에 대하여 행정심판 또는 이의신청을 거치도록 규정한다.

3. 무효확인을 구하는 취소소송

- 무효등 확인소송에는 행정심판전치주의가 적용되지 않으나, 처분의 무효를 구하는 의미의 취소소송에 전치주의가 적용될 것인지에 대하여는 학설이 대립한다. 판례는 행정처분의 당연무효를 선언하는 의미에서 그 취소를 구하는 행정소송을 제기하는 경우에는 전치절차와 그 제소기간의 준수 등 취소소송의 제소요건을 갖추어야 한다고 판시하여 긍정설의 입장이다.

4. 제3자효 행정행위

- 제3자효 행정행위에 대하여 그 행정행위로 인해 자신의 권리 또는 이익이 침해된 제3자가 제기하는 취소소송은 통상의 취소소송과 동일한 성격을 갖는다. 따라서 해당 처분이 개별 법률상 필요적 전치주의 적용 대상인 경우에는 제3자에게도 전치주의가 적용된다. 다만, 제3자는 처분 사실을 알기 어려울 수 있으므로, 심판 청구 기간 준수 등 요건 완화의 필요성이 있다. 판례는 일반적으로 제3자효 행정행위에 대해서도 필요적 전치주의의 규정이 적용된다고 본다.

5. 2단계 이상의 행정심판절차가 규정되어 있는 경우

- 관계법령이 하나의 처분에 대하여 2단계 이상의 행정심판절차를 규정한 경우에는 당해 절차를 모두 거치게 한다면 제소자에게 과도한 부담을 줄 수 있으므로 명문의 규정이 없는 한 그중의 하나만 거치면 행정심판전치주의의 요건은 충족된 것으로 보는 것이 학설의 일반적 태도이다.

IV. 행정심판전치주의의 적용 제외

1. 행정심판의 재결 없이 행정소송을 제기할 수 있는 경우[행소법 제18조 제2항]

- 행정소송법 제18조 제2항은 행정심판을 청구했더라도 재결 없이 소송을 제기할 수 있는 경우를 규정한다.

(1) 재결을 거치지 아니하면 회복하기 어려운 손해 발생 우려

- 행정심판 절차를 거치는 동안 시간적 지연으로 인해 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있고, 그 손해 방지를 위해 긴급한 필요가 있는 때에는 재결 전이라도 소송을 제기할 수 있다.

(2) 법령에 의한 행정심판기관의 의결 또는 재결을 하지 못할 사유가 있는 때

- 행정심판기관이 사정 변경 등으로 인하여 사실상 기능을 상실하거나 법률상의 이유로 의결 또는 재결을 할 수 없는 경우 등이 이에 해당한다.

(3) 그 밖의 정당한 사유가 있는 때

- 행정심판 청구 후 상당한 기간이 경과하도록 재결이 없거나, 재결의 기대가 불가능한 경우 등 위의 사유에 준하는 정당한 사유가 있는 때이다.

2. 행정심판의 청구 없이 행정소송을 제기할 수 있는 경우[행소법 제18조 제3항]

- 행정소송법 제18조 제3항은 행정심판 청구 자체를 하지 않았더라도 소송을 제기할 수 있는 경우를 규정한다.

(1) 동종 사건에 대하여 이미 기각재결이 있는 때

- 동일한 당사자가 아니더라도 동일한 사실 관계를 가진 사건에 대하여 이미 적법한 행정심판 절차를 거쳐 기각재결이 있는 때에는 행정심판 절차의 반복 낭비를 피하기 위해 전치 요건이 면제된다.

(2) 사실심 변론종결 후 처분을 변경한 때

- 원고가 소송을 제기한 후 피고 행정청이 당해 처분을 변경하는 처분을 하였을 때 원고가 그 변경된 처분을 다투기 위하여 소 변경을 하는 경우에는 소송 경계를 고려하여 변경된 처분에 대해 별도의 전치 절차를 요하지 않는다.

(3) 피고가 행정심판을 거칠 필요가 없다고 잘못 알린 때

- 피고 행정청이 원고에게 행정심판을 거치지 않고 바로 소송을 제기할 수 있다고 잘못 안내한 경우, 원고의 신뢰 보호를 위해 전치 요건이 면제된다.

V. 행정심판전치주의의 이행 여부의 판단

1. 적법한 행정심판청구

- 전치주의의 이행 여부는 원칙적으로 당해 처분에 대한 적법한 행정심판 청구가 있었는지 여부로 판단된다. 부적법 각하재결이 나온 경우 전치 요건은 미충족된다. 다만, 행정심판기관이 본안 심리를 실질적으로 행하여 기각 또는 인용 재결을 한 경우에는 설령 청구 절차가 다소 흠이 있었더라도 전치 요건이 충족된 것으로 본다.

2. 직권조사사항

- 행정심판전치주의는 취소소송의 소송요건에 해당한다. 소송요건은 법원이 직권으로 조사하여 판단해야 할 사항이므로, 법원은 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 행정심판 청구 및 재결의 존부, 적법성 등을 조사해야 한다. 전치 요건이 결여된 경우에는 법원은 취소소송을 각하해야 한다.

3. 판단의 기준 시

- 행정심판전치주의의 이행 여부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 이는 전치주의의 요건 충족 시기에 관한 판단과 동일하다. 따라서 원고가 소송 제기 이후에라도 사실심 변론종결 전까지 적법한 재결을 받는다면 전치 요건은 충족된 것으로 보아 소송은 적법하게 된다.

VI. 결론

- 행정심판전치주의는 취소소송의 소송요건 중 하나로 필요적 전치 규정이 있는 개별 법률에 한하여 적용된다. 헌행법상 임의적 전치주의가 원칙이므로, 필요적 전치주의가 적용되는 경우 적법한 심판 청구가 있었고 재결을 거쳤는지 여부는 소송 적법성 판단의 핵심이다. 전치주의는 행정 자율성 존중 및 사전 권리 구제라는 목적을 갖지만, 긴급한 상황이나 소송 경계 등을 고려하여 다양한 적용 제외 규정을 두어 국민의 재판 받을 권리를 실질적으로 보장하고 있다.

<제4장 취소소송의 기타 소송요건 제2절 제소기간>

I. 제소기간의 의의[행소법 제20조]

- 제소기간이라 함은 취소소송을 제기할 수 있는 법률이 정한 기간을 말한다. 이는 위법한 행정처분의 취소를 통한 개인의 권리 보호와 이미 발생한 법률 관계의 안정 및 행정 운영의 예측 가능성을 확보하기 위하여 설정된 제도이다. 행정소송법 제20조는 제소기간을 주관적 제소기간과 객관적 제소기간으로 구분하여 이중적인 제한을 가하고 있다. 제소기간은 법원의 직권 조사 사항인 소송요건에 해당하므로, 기간이 경과된 후 제기된 소송은 본안 심리를 거치지 않고 각하된다. 이 기간은 소송의 적법성 판단에 결정적인 요소이다.

II. 행정심판을 거친 경우

1. 재결서의 정본을 송달받은 경우[행소법 제20조 제1항]

- 취소소송 제기 전에 필요적 전치주의에 따라 행정심판 절차를 적법하게 거친 경우, 취소소송의 제소기간은 행정심판의 재결서 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내이다(행정소송법 제20조 제1항). 여기서 재결서 정본을 송달받은 날이 제소기간의 기산점이 된다. 이는 재결의 내용에 따라 원처분의 효력이 유지 또는 변경될 수 있으므로, 원고에게 재결 결과 확인 후 소송 제기 여부를 결정하도록 충분한 고려 기간을 주기 위한 취지이다.

2. 재결서의 정본을 송달받지 못한 경우

- 청구인이 행정심판 절차를 거쳤으나 행정심판법에 따른 재결서의 정본을 적법하게 송달받지 못한 경우에는 행정소송법 제20조 제1항의 90일 기간이 적용될 수 없다. 따라서 이 때는 행정심판을 거치지 아니한 경우에 적용되는 객관적 제소기간인 처분이 있는 날로부터 1년이 적용된다. 재결서 송달 사실은 행정청이 입증해야 할 사항이며, 입증이 되지 않는다면 객관적 제소기간인 1년 기간이 최종적인 제한 기간이 된다.

3. 제소기간 준수 여부의 유형별 검토

- 행정심판을 거친 후의 취소소송은 재결 자체의 위법성이 아닌 원처분의 위법성을 다투는 것이 원칙(원처분주의)이다. 따라서 제소기간은 원처분에 대하여 재결서 송달일로부터 90일 이내이다. 다만, 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우 예외적으로 재결의 취소소송을 제기할 수 있으며, 이 때는 재결서 송달일로부터 90일 이내에 소송을 제기해야 한다. 또한, 재결 없이 소송을 제기하는 경우 행정소송법 제18조 제2항 각호의 사유 충족 여부가 필요하며, 이 때 제소기간은 원처분을 안 날 등을 기준으로 90일 이내이다.

III. 행정심판을 거치지 아니한 경우

1. 처분이 있음을 안 날로부터 90일[행소법 제20조 제1항]

- 행정심판 절차를 거치지 않고 취소소송을 제기하는 경우, 제소기간은 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내이다(행정소송법 제20조 제1항). 이는 원고의 주관적 제소기간으로, 원고가 당해 처분의 존재와 주요 내용을 현실적으로 알게 된 날을 기산점으로 한다. 단순한 추측만으로는 부족하며, 처분서 송달 등을 통해 명확히 알게 된 때로 본다. 다만, 귀책사유 없는 객관적인 장애로 인해 기간을 준수할 수 없었던 경우 등 정당한 사유가 있는 때에는 90일 기간이 경과했더라도 제소기간 준수가 가능하다.

2. 처분이 있는 날로부터 1년[행소법 제20조 제2항]

- 처분이 있는 날로부터 1년은 객관적 제소기간으로서 원고의 인지 여부와 상관없이 행정법 관계의 안정을 위해 설정된 최종적인 제한 기간이다. 처분이 있는 날은 처분이 효력을 발생한 날을 의미하며, 일반적으로 상대방에게 도달 또는 고지된 때이다. 이 1년의 기간은 원칙적으로 제한 없이 적용되나, 행정소송법 제20조 제2항 단서는 극히 제한적인 경우 적용되는 정당한 사유가 있는 때에 예외적으로 기간 경과 후에도 소송을 제기할 수 있도록 규정한다.

3. 처분이 있음을 안 경우와 알지 못한 경우의 관계

- 취소소송의 제소기간은 안 날로부터 90일의 주관적 기간과 있는 날로부터 1년의 객관적 기간을 모두 만족해야 한다는 이중 기간제를 채택한다. 따라서 원고는 두 기간 중 하나라도 경과하면 원칙적으로 소송을 제기할 수 없다. 즉, 처분을 알게 된 후 90일이 지나지 않았더라도 1년의 객관적 기간이 경과하면 제소 요건을 결하게 된다.

4. 제소기간 준수 여부의 유형별 검토

(1) 처분서가 송달된 경우

- 처분서 정본을 송달받은 날이 처분이 있음을 안 날이 되어 90일 기간이 기산된다. 송달 사실은 행정청이 입증해야 한다.

(2) 공고 또는 고시의 방법으로 처분된 경우

- 불특정 다수인을 상대로 하는 처분이 공고 또는 고시로 이루어진 경우, 일반적으로 공고일로부터 일정한 기간 경과 후 효력이 발생하지만, 이는 객관적 기간의 기산점이 될 뿐, 주관적 제소기간인 90일의 기산점은 되지 않는다. 판례는 이러한 경우 당해 처분의 취소를 구하는 원고가 현실적으로 처분 사실을 알았을 때 주관적 기간을 기산해야 하며, 알지 못한 경우에는 객관적 기간인 1년의 제한을 받는다고 본다.

(3) 처분을 알지 못한 경우

- 처분이 있음을 알지 못한 경우에도 처분이 있는 날로부터 1년의 객관적 제소기간은 적용됨이 원칙이다. 다만, 1년의 기간 경과 후에도 소송을 제기할 수 있는 정당한 사유가 있는지 여부가 판단의 쟁점이 된다.

IV. 관련 논점

1. 소의 변경 및 추가적 병합

- 취소소송 제기 후 행정소송법 제21조 등에 따라 소의 변경이 있거나 다른 처분에 대한 소송이 추가적으로 병합되는 경우, 원칙적으로 새롭게 다투어지는 처분에 대해서도 제소기간 요건이 충족되어야 한다. 다만, 소 변경이 적법하게 이루어진 경우 최초의 소 제기 시에 제소기간이 준수된 것으로 간주될 수 있으며, 특히 처분의 변경으로 인한 소 변경 시 제소기간 특례가 인정된다.

2. 이의신청을 거쳐 취소소송을 제기하는 경우

- 개별 법률에서 행정심판 외에 이의신청 절차를 규정하고 있고, 그 이의신청 절차가 행정심판 절차에 준하는 것으로 인정될 때는, 이의신청 결정서 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내에 취소소송을 제기할 수 있다는 것이 판례의 태도이다. 이러한 이의신청은 행정심판 전치주의의 특례 규정이 유추 적용되는 것으로 본다.

3. 변경명령재결의 경우

- 행정심판위원회가 원처분을 변경하라는 취지의 변경명령재결을 내려 그에 따라 처분청이 변경된 처분을 한 경우, 원고가 그 변경된 처분의 위법을 다투기 위한 취소소송을 제기할 수 있다. 이 때 제소기간은 재결서 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내이다. 재결이 있었으므로 행정심판을 거친 경우의 제소기간이 적용된다.

4. 거부처분의 경우

- 거부처분에 대한 취소소송의 제소기간 기산점은 다른 처분과 동일하다. 거부처분 통지서를 송달받은 날이 처분이 있음을 안 날이 되어 주관적 기간이 기산되며, 행정심판 기각 재결을 거친 경우 재결서 송달일로부터 90일 이내에 제기해야 한다. 거부처분 역시 객관적 제소기간인 1년의 제한을 받는다.

5. 헌법재판소의 위헌결정으로 취소소송의 제기가 가능하게 된 경우

- 행정처분의 근거 법규가 나중에 헌법재판소의 위헌결정을 받아 비로소 처분의 위법성을 주장할 수 있게 된 경우, 판례는 일반적인 제소기간 규정을 적용하는 것이 국민의 권리 구제 측면에서 부당하다고 본다. 따라서 이 때는 위헌결정이 있는 날 등 권리 주장이 가능하게 된 시점을 새롭게 처분이 있음을 안 날로 보아 제소기간을 기산할 수 있다는 예외적인 해석을 적용한다.

6. 경정처분

- 당초 처분의 내용에 대한 오류 정정 등 경미한 내용의 경정처분은 원처분과 동일성을 유지하므로, 경정처분 시에 제소기간이 새로이 기산되지 않는다. 다만, 경정처분이 당초 처분의 내용을 실질적으로 변경하여 새로운 처분을 만드는 경우에는 경정처분을 새로운 처분으로 보아 그 때부터 제소기간이 새로이 기산된다. 두 처분 간의 주요 내용 변경 여부가 판단의 기준이 된다.

V. 결론

- 제소기간은 취소소송의 필수적인 소송요건으로서 개인의 권리 구제와 행정법 관계의 안정을 도모하는 중요한 기능을 수행한다. 행정심판 이행 여부에 따라 제소기간의 기산점이 달라지며, 주관적 기간(안 날로부터 90일)과 객관적 기간(있는 날로부터 1년)을 이중적으로 제한한다. 정당한 사유 등 예외 규정을 두어 엄격한 제한 속에서도 국민의 재판 받을 권리를 보호하고 있으나, 소송 제기 전에 제소기간의 적법한 준수 여부를 면밀히 검토해야 할 필요가 있다.

<제4장 취소소송의 기타 소송요건.제3절 관할법원>

I. 재판관할

1. 재판관할의 의의

- 재판관할이라 함은 특정 법원이 어떤 사건에 대하여 심판권을 가지는지 여부에 대한 법률적 기준을 말한다. 행정소송법은 취소소송을 비롯한 항고소송의 관할을 특별히 규정하고 있으며, 이는 행정 사건의 특수성을 고려한 것이다. 재판관할은 크게 법원의 직능 분배에 관한 사무관할과 토지 구역 분배에 관한 토지관할로 구분되는데, 행정소송법 제9조는 주로 토지관할을 규정하고 있다. 관할은 소송요건 중 하나이므로, 관할법원에 소가 제기되지 않으면 법원은 소송을 적절히 처리해야 한다.

2. 항고소송상 재판관할

- 행정소송법 제9조 제1항은 취소소송의 관할법원을 규정한다. 이에 따르면 취소소송은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원에 제기함이 원칙이다. 다만, 재결 취소소송의 경우 재결청을 피고로 하게 되므로, 재결청의 소재지를 관할하는 행정법원에 제기할 수 있다. 여기서 피고의 소재지라 함은 처분등을 행한 행정청의 소재지를 의미한다. 행정소송법 제9조 제2항은 예외적인 관할 규정을 두고 있다. 이는 피고를 정할 수 없는 경우나 피고의 소재지 이외의 법원에 소송을 제기하는 것이 관련 사건의 심리 및 증거조사 등에 편의가 있다고 인정되는 경우 등을 포함한다. 특히, 제3항은 토지 수용 등 부동산 또는 특정 장소에 관한 처분에 대하여는 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에도 소를 제기할 수 있도록 규정하여 원고의 소송 수행 편의를 도모한다.

3. 행정소송의 관할의 성격

- 행정소송의 관할은 전속관할의 성격을 가진다. 전속관할이라 함은 법률이 특정 법원에 사건의 심판권을 배타적으로 귀속시키는 것으로, 당사자 합의나 응소에 의해 관할을 발생시킬 수 없다. 행정소송법 제9조의 관할 규정은 관할 위반 시 반드시 관할법원으로 이송하도록 규정하고 있다는 점에서 전속관할로 해석된다. 이러한 전속관할의 설정은 행정 사건의 전문적인 심리를 보장하고 행정소송의 특수성을 살리기 위한 것이다. 다만, 사무관할은 행정법원이 관할하며, 제1심 관할은 행정법원에 전속한다.

4. 관할위반으로 인한 소송

- 관할위반으로 인한 소송이 제기된 경우, 법원은 소송을 각하하지 않고 관할법원에 이송하는 것이 원칙이다. 행정소송법 제7조에 따라 법원은 소송의 이송 결정을 내려야 하며, 이 규정은 민사소송법 제34조 제1항을 준용한다. 전속관할의 특성상 관할 위반 시 반드시 관할법원으로 이송해야 하며, 이는 소송 경제와 국민의 재판 받을 권리를 보장하기 위한 취지이다.

5. 당사자소송상 재판관할[행소법 제40조]

- 당사자소송의 관할법원은 행정소송법 제9조를 준용하여 취소소송의 경우와 같다. 다만, 국가 또는 공공단체가 피고인 경우에 관계 행정청의 소재지를 피고의 소재지로 본다.

6. 민중소송과 기관소송의 재판관할

(1) 민중소송[공직선거법 제222조, 제223조, 국민투표법 제92조]

- 대통령, 국회의원 및 광역자치단체장의 선거무효소송 또는 당선무효소송은 대법원이 관할하고, 지방의회의원 또는 지방자치단체장의 선거무효소송 또는 당선무효소송은 고등법원이 관할하며, 국민투표무효소송은 대법원이 관할한다.

(2) 기관소송[지방자치법 제120조, 제192조, 지방교육자치에 관한 법률 제28조]

- 지방의회나 교육·학예에 관한 시·도의 회의 재의결 무효소송은 대법원이 관할한다.

7. 관할위반의 효과[행소법 제7조]

- 행정소송법 제7조는 민사소송법 제34조 제1항을 준용하고 있으며, 이 규정은 원고의 고의 또는 중대한 과실 없이 행정소송이 심급을 달리하는 법원에 잘못 제기된 경우에도 적용한다. 현행 행정소송법은 종래 판례가 관할위반으로 인한 사건의 이송을 인정하지 아니함에 따라 선의의 제소자를 보호할 수 없는 문제점을 시정하고자, 이같은 관할이송을 인정한 것이다.

II. 소송의 이송

1. 의의

- 소송의 이송이란 어느 법원에 일단 계속된 소송을 그 법원의 재판에 의하여 다른 법원의 관할로 이전하는 것을 의미한다.

2. 관할위반으로 인한 소송

(1) 심급을 달리하는 법원에 제기한 경우[행소법 제7조]

- 민사소송법 제34조 제1항의 규정은 원고의 고의 또는 중대한 과실 없이 행정소송이 심급을 달리 하는 법원에 잘못 제기된 경우에도 적용한다.

(2) 행정사건을 민사사건으로 제기한 경우[행소법 제8조 제2항, 민소법 제34조]

- 원고가 고의 또는 중대한 과실 없이 행정소송으로 제기하여야 할 사건을 민사소송으로 잘못 제기한 경우, 수소법원으로서의 만약 그 행정소송에 대한 관할도 동시에 가지고 있다면 이를 행정소송으로 심리·판단하여야 하고, 그 행정소송에 대한 관할을 가지고 있지 아니하다면 당해 소송이 행정소송으로서의 소송요건을 결하고 있음이 명백하여 행정소송으로 제기되었더라도 어차피 부적법하게 되는 경우가 아닌 이상, 부적법한 소라고 하여 각하할 것이 아니라 관할법원에 이송하여야 한다.

(3) 이송의 효력

- 이송결정이 확정되면, 민사소송법 제40조 제1항에 의하여 소 제기에 의한 시효 중단이나 법률상 기간 준수의 효력은 그대로 유지된다.

3. 심판편의에 의한 이송

(1) 관련 청구소송의 이송[행소법 제10조]

- 관련 청구소송의 이송이란 취소소송 등과 관련 청구소송이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우, 관련 청구소송이 계속된 법원이 상당하다고 인정하는 때에 이를 취소소송이 계속된 법원으로 이송하는 것을 의미한다.

(2) 손해나 지연을 피하기 위한 이송[행소법 제8조 제2항, 민소법 제35조]

- 전속관할이 정하여진 소를 제외하고는, 법원은 소송에 대하여 관할권이 있는 경우라도 현저한 손해 또는 지연을 피하기 위하여 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로써 소송의 전부 또는 일부를 다른 법원에 이송할 수 있다.

III. 결론

- 취소소송의 관할법원은 행정소송법 제9조에 의해 원칙적으로 피고 소재지 법원으로 정해지며, 이는 전속관할의 성격을 가진다. 따라서 관할위반으로 소가 제기된 경우 법원은 행정소송법 제7조에 따라 직권으로 관할법원에 이송해야 하며, 소송을 각하할 수 없다. 당사자소송 등 기타 소송의 관할은 특별

한 규정이 없는 한 민사소송법의 규정을 준용하지만, 역시 행정소송의 특수성을 고려한 예외 규정들이 적용된다. 관할은 소송 절차의 안정성과 효율성을 확보하는 중요한 요건이다.

<제5장 취소소송의 심리.제1절 심리>

I. 심리의 의의

1. 개념

- 심리라 함은 법원이 소송 당사자의 주장과 증거를 통하여 사실 관계와 법률 관계를 파악하고 판결의 기초를 형성하는 일련의 재판 활동을 말한다. 이는 소송 요건의 적법성 여부를 따지는 요건심리와 청구 내용의 당부를 판단하는 본안심리를 포함한다.

2. 행정소송의 심리

- 행정소송의 심리는 일반 민사소송의 심리 원칙을 기본으로 하되, 행정처분의 공정력 등 행정 사건의 특수성을 고려한 행정소송법상 특유의 규정이 적용된다. 행정소송법 제8조 제2항은 민사소송법의 규정을 준용하도록 정하고 있으나, 행정처분 특유의 직권심리주의 강화 등을 통하여 실질적인 공정 확보를 도모한다.

II. 심리의 내용

1. 요건심리

- 요건심리라 함은 법원이 소송을 본안심리할 수 있는지 여부에 대하여 그 적법성을 직권으로 조사하는 것을 말한다. 요건심리의 대상은 취소소송의 소송요건인 원고격적, 피고격적, 협의의 소의 이익, 제소기간, 관할 법원, 행정심판 전치 요건(필요적 전치 시) 등이다. 요건심리 결과 소송요건을 결한 경우 법원은 본안심리를 하지 않고 각하판결을 선고한다.

2. 본안심리

- 본안심리라 함은 소송요건이 충족되어 소송이 적법하다고 인정된 경우, 원고의 청구 내용 자체의 당부 즉, 행정처분의 위법성 여부를 심사하는 것을 말한다. 취소소송의 본안심리 대상은 원처분의 위법성이며, 법원은 처분 당시를 기준으로 사실 인정과 법률 해석을 통해 처분의 취소 사유 존재 여부를 판단한다. 위법성이 인정되면 취소판결을, 인정되지 않으면 기각판결을 선고한다.

III. 심리의 범위

1. 불고불리의 원칙에 따른 범위

- 불고불리의 원칙은 법원이 당사자가 청구한 범위 내에서만 심판해야 한다는 소송법상 원칙이다. 행정소송에서도 이 원칙이 적용되어 법원은 원고가 청구한 취소의 범위를 넘어 판결할 수 없다. 다만, 취소 사유의 제한에 있어서는 행정소송법 제26조에 따른 직권심리주의가 적용되어 원고가 주장하지 않은 위법 사유라도 법원은 직권으로 조사하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

2. 재량문제에 따른 범위

- 재량문제에 있어서 법원의 심리 범위는 행정청이 재량권을 행사할 때 법률이 정한 한계를 일탈하거나 남용했는지 여부에 국한된다(행정소송법 제27조). 법원은 행정청의 재량 판단을 대신하여 자신의 판단으로 대체할 수 없다는 점이 특징적이다. 재량권 일탈·남용의 판단은 비례의 원칙, 평등의 원칙, 신뢰보호의 원칙 등 행정법의 일반원칙 위반 여부를 중심으로 심사한다.

3. 법률문제·사실문제에 따른 범위

- 법률문제는 처분에 적용된 법령의 해석 및 적용의 위법성 여부로서, 법원의 전적인 심사 대상이 된다. 사실문제는 처분의 기초가 되는 사실 인정의 객관성 및 정당성 여부이다. 행정소송의 심리 구조는 직권심리주의의 적용으로 인해 사실문제 심리에 있어서는 법원의 직권 조사 권한이 강화되며, 행정청이 제출한 처분 근거 자료의 신뢰성 등을 중심으로 심사한다.

IV. 심리의 절차

1. 심리에 관한 일반원칙

- 행정소송의 심리 절차에 관하여는 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법의 규정이 준용되므로, 변론주의, 공개심리주의, 구술심리주의 등의 일반원칙이 적용된다. 다만, 행정소송에서는 직권심리주의의 존재로 인해 변론주의가 민사소송보다 완화된 형태로 적용된다.

2. 행정소송법상 특수한 소송절차

- 행정소송법상 특수한 소송절차로는 법원의 직권 조사 및 증거 수집 권한을 규정한 직권심리주의(제26조), 소송 경제를 위한 관련청구소송의 병합(제10조), 판결의 효력을 받는 제3자의 소송참가(제16조), 행정청이 보유한 처분문서 제출 명령 등이 있다. 이러한 특수 절차는 행정청과 국민 간의 실질적 소송 능력 격차를 보완하기 위한 취지이다.

V. 주장책임

1. 의의

- 주장책임이라 함은 당사자가 자신에게 유리한 사실을 주장하지 않아 불이익한 판결을 받게 되는 위험을 말한다. 행정소송은 직권심리주의의 적용으로 인하여 민사소송보다 주장책임이 완화된다. 법원은 당사자가 명시적으로 주장하지 않은 위법 사유도 직권으로 조사할 수 있기 때문이다.

2. 판례

- 판례는 행정소송에서 주장책임의 완화를 인정한다. 원고가 절차상 위법 사유를 명시적으로 주장하지 않았더라도, 법원은 기록 상 명백히 존재하는 위법 사유가 있다면 이를 직권으로 조사하여 취소 판결을 할 수 있다. 다만, 법원의 직권 조사 권한은 당사자의 변론을 보충하는 한도 내에서 행사되어야 하며, 청구 취지를 초월하여 판단할 수는 없다.

VI. 입증책임

1. 의의

- 입증책임이라 함은 어떤 사실의 존재 또는 부존재가 심리 결과 불명확할 때, 그 불명확함으로 인하여 불리한 판결을 받게 되는 위험을 말한다. 이는 증명책임이라고도 하며, 소송 결과에 직접적인 영향을 미친다.

2. 문제점

- 행정소송에서의 입증책임 분배 문제는 행정청이 처분 근거 자료나 정보를 독점하고 있어 국민 측이 입증에 어려움을 겪을 수 있다는 점에서 특수한 문제가 된다. 이로 인해 민사소송의 원칙인 법규요건분류설을 그대로 적용하기 어렵다는 주장이 제기된다.

3. 학설

- 입증책임 분배에 대한 학설 중 법규요건분류설은 처분의 위법성 요소는 원고가, 적법성 요소는 피고가 책임을 져야 한다고 본다. 이에 반해 권리근거규정설은 행정처분의 적법성 자체에 대하여 행정청이 책임을 져야 한다고 주장한다. 절충설 등 다양한 견해가 있으나, 일반적으로 법규요건분류설이 다수설의 입장을 취한다.

4. 판례

- 판례가 입증책임 분배에 관하여 어떠한 입장인지는 분명하지 않다. 행정소송에서의 입증책임도 원칙적으로 민사소송의 일반원칙(법률요건분류설)에 따라 당사자 간에 분배되어야 한다고 하면서도, 항고소송의 특성도 고려하여야 하는 것으로 이해한다.

5. 검토

- 입증책임 분배는 법규요건분류설을 기본으로 하되, 행정소송의 특수성을 고려하여 법원의 직권심리 강화 및 행정청의 적법성 입증책임 강화 방향으로 나아가야 한다. 특히, 행정청의 처분 근거 자료 제출 의무를 강화하여 원고의 실질적인 입증 곤란을 해소해야 한다.

6. 구체적 사례

- 과세처분 취소소송의 경우, 과세 처분의 요건 사실(세금 부과 대상이 되는 소득 발생 사실)의 존재에 대한 입증책임은 과세권자인 피고 행정청에 있다. 반면, 원고가 주장하는 특정 감면 요건 사실(비과세 요건 충족 사실)의 존재에 대한 입증책임은 그것을 주장하여 이익을 얻으려는 원고에게 있다.

VI. 결론

- 취소소송의 심리는 행정 사건의 특수성을 반영한 직권심리주의 등의 특례 규정이 적용되는 핵심적인 절차이다. 특히, 입증책임의 분배에 있어서 행정청에게 자신이 내린 처분의 적법성 입증책임을 부과함으로써 행정청과 국민 사이의 정보 및 능력 격차를 보완하고 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하는 방향으로 운영되고 있다.

<제5장 취소소송의 심리.제2절 위법성 판단의 기준시>

I. 의의

- 위법성 판단의 기준시 문제는 취소소송에서 심리의 핵심 쟁점 중 하나이다. 행정처분 이후 법원의 판결까지 기간 동안 처분의 근거가 되는 법령이 변경되거나 처분의 기초가 되는 사실 상태에 변동이 발생하는 경우가 있다. 이러한 경우 법원이 처분의 위법 여부를 판단할 때 언제를 기준 시점으로 삼아야 하는지에 대한 견해 대립이 발생한다. 이는 법적 안정성의 요청과 구체적 타당성 및 국민의 실질적 권리 구제 요청이 충돌하는 지점이며, 특히 행정청의 재량 행위 심사 범위와도 밀접하게 관련된다. 이하에서는 취소소송과 거부처분취소소송에서의 위법성 판단 기준시를 검토한다.

II. 취소소송에서의 위법성 판단의 기준시

1. 학설

(1) 처분시설

- 처분시설은 행정처분의 위법성 판단은 처분 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 해야 한다는 견해이다. 취소소송은 행정청이 이미 행한 처분의 적법 여부를 사후적으로 심사하는 소송이므로, 처분 당시를 기준으로 판단해야 법적 안정성이 확보되고 행정청의 적법한 권한 행사가 존중될 수 있다고 본다. 이 견해에 따르면 처분 후 사정 변경은 위법성 판단에 영향을 미치지 않는다.

(2) 판결시설

- 판결시설은 행정처분의 위법성 판단은 법원의 판결 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 해야 한다는 견해이다. 행정소송의 목적이 위법한 상태의 제거 및 국민의 현실적인 권리 구제에 있으므로, 현재 시점의 법질서에 비추어 처분의 위법 여부를 판단하는 것이 타당하다는 입장이다. 이 견해는 구체적 타당성 확보에 유리하지만, 행정청의 처분 시 판단 권한이 과도하게 침해될 수 있다는 문제점이 있다.

(3) 절충설

- 절충설은 사실 인정의 기준시는 처분시로 하되 법률 적용의 기준시는 판결시로 해야 한다는 등의 다양한 입장을 취하며, 처분시설과 판결시설의 장점을 절충하려는 시도이다. 그러나 사실 인정과 법률 적용을 엄격하게 분리하기 어렵다는 점에서 실질적인 적용이 용이하지 않다.

2. 판례

- 판례는 일반적인 취소소송에서 위법성 판단의 기준시를 처분시설로 일관되게 보고 있다. 행정처분의 위법 여부는 행정처분이 있을 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단해야 하며, 처분 후 법령이 개정되거나 사실 상태가 변동되었다고 하더라도 이를 고려하여 위법 여부를 다시 판단할 수는 없다는 것이다. 이는 취소소송이 처분의 적법성을 심사하는 소극적인 기능에 충실하고자 하는 태도이다. 다만, 처분 후 사정 변화가 있는 경우 그것이 현저히 공공복리에 적합하지 않다고 인정되면 위법성을 인정하면서도 사정판결을 내릴 수 있다는 예외 규정이 존재한다.

3. 검토

- 취소소송의 위법성 판단 기준시로서는 처분시설이 타당하다. 취소소송은 행정청이 권한을 행사한 시점의 판단이 정당했는지 여부를 심사하는 것이 본질이기 때문이다. 행정청은 처분 당시 존재하는 법규와 사실에 기초하여 처분할 의무가 있으며, 그 당시의 법규 상태를 벗어나 처분의 적법 여부를 논할 수는 없다. 처분 후 발생한 법령 변화 등을 이유로 처분을 취소하게 되면 행정청의 처분 시 판단이 정당했음에도 불구하고 사후적으로 위법하게 취급되는 불합리가 발생한다. 구체적 타당성 문제는 사정판결 제도 등을 통하여 보완할 수 있다.

III. 거부처분취소소송에서의 위법성 판단의 기준시

1. 학설

(1) 처분시설

- 거부처분 역시 일반 행정처분과 마찬가지로 처분시설이 적용되어야 한다고 보는 견해이다. 거부처분도 하나의 행정처분이므로 법적 안정성 확보 및 행정청의 권한 존중이라는 일반 취소소송의 논리가 그대로 적용되어야 한다는 입장이다. 따라서 거부 당시의 법령 및 사실 상태를 기준으로 위법 여부를 판단해야 한다.

(2) 판결시설

- 거부처분취소소송의 궁극적인 목적은 신청에 따른 인용 처분을 받아내는 데 있으므로, 가장 최근의 사실심 변론종결시 즉, 판결시를 기준으로 행정청이 처분을 해줄 의무가 현재 존재하는지 여부를 판단해야 한다는 견해이다. 이는 거부처분 취소판결의 실효성 확보 및 국민의 실질적인 권리 구제 측면에서 유리하다는 논거를 든다.

(3) 절충설

- 거부처분 자체의 위법성 판단은 처분시를 기준으로 하되, 취소판결에 따른 행정청의 재처분 의무 이행 시 판단의 기준시는 판결시를 기준으로 해야 한다는 견해이다. 이는 법원의 심사 범위와 행정청의 재처분 범위를 구별하는 입장이다.

2. 판례

- 판례는 거부처분취소소송에서도 원칙적으로 일반 취소소송과 마찬가지로 처분시설을 채택하고 있다. 즉, 거부처분의 위법 여부는 그 거부처분 당시의 법령 및 사실 상태를 기준으로 판단해야 한다는 것이다. 따라서 거부처분 후 관계 법령이 개정되어 신청인에게 유리하게 되었다 하더라도, 이는 재처분 시 행정청이 고려할 사정일 뿐, 기존 거부처분의 위법성 판단에는 영향을 미치지 않는다. 다만, 거부처분이 취소되어 행정청이 재처분을 할 때에는 판결의 기속력에 따라 처분시를 기준으로 할 수 없고 재처분 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 하여 다시 처분해야 한다는 입장이다.

3. 검토

- 거부처분취소소송에서는 거부처분 자체의 위법성 판단 기준시는 처분시설이 타당하다. 이는 취소소송의 본질이 기존 행위의 적법성 심사에 있기 때문이다. 그러나 거부처분 취소판결의 실효성을 확보하기 위해서는 판결의 기속력을 통해 행정청이 재처분을 할 때 판결시 또는 재처분시의 법률 및 사실 상태를 반영하도록 해야 한다. 판례는 이러한 두 가지 측면을 고려하여 위법성 판단 자체는 처분시설에 따르되, 재처분 의무에는 당시의 사정을 반영하도록 하는 절충적 태도를 취하고 있다고 볼 수 있다.

IV. 결론

- 취소소송에서 위법성 판단의 기준시는 원칙적으로 법적 안정성을 위해 처분시설을 취하는 것이 타당하며, 판례 역시 이러한 입장이다. 거부처분취소소송에서도 거부 행위 자체의 위법성 판단은 처분시설에 의하는 것이 원칙이지만, 취소판결 후 행정청의 재처분 의무 이행 시에는 판결의 기속력에 따라 재처분 당시의 법률 및 사실 상태를 기준으로 처분해야 한다. 이는 위법한 행정행위의 제거라는 취소소송의 본질과 국민의 실질적인 권리 구제라는 목표를 동시에 달성하기 위한 접근이다.

<제5장 취소소송의 심리.제3절 처분사유의 추가·변경>

I. 처분사유의 추가·변경의 의의

1. 개념

- 처분사유의 추가·변경이라 함은 취소소송의 피고인 행정청이 소송 계속 중 당초 처분 당시에 제시한 처분 사유 이외의 다른 사실 또는 법률적 근거를 추가하거나 변경하여 당해 처분의 적법성을 정당화하려는 소송상 행위를 말한다. 이는 행정절차법상 이유제시 흠결 등으로 인해 실체적으로는 적법한 처분이 단순히 절차적 흠으로 인해 취소되는 것을 방지하고, 소송 경제에 이바지하여 실질적 정의를 구현하기 위한 제도적 논의의 대상이다. 행정처분의 위법성 판단 기준시가 처분이라는 원칙을 전제로 논의된다.

2. 타 제도와의 구별

- 처분사유의 추가·변경은 행정청이 소송 계속 중에 새로운 처분 절차를 거쳐 당초 처분 자체를 소급적 또는 장래적으로 취소하거나 철회 또는 변경하는 처분의 취소·철회·변경과는 구별된다. 후자는 별개의 행정처분이므로 원고는 소를 변경하여 다투어야 한다. 또한, 직권심리주의와도 구별된다. 직권심리주의는 법원이 원고가 주장하지 않은 위법 사유를 직권으로 조사하여 처분의 위법성을 판단하는 법원의 권능이지만, 처분사유의 추가·변경은 피고 행정청이 당초 처분의 적법성을 옹호하기 위해 행하는 소송상 방어 주장이다.

II. 처분사유의 추가·변경의 인정 여부

1. 문제점

- 처분사유의 추가·변경 인정 여부는 행정처분의 적법성 심사의 범위와 관련하여 가장 첨예하게 대립하는 쟁점이다. 국민의 방어권 보장이라는 측면에서 보면, 처분 당시 제시되지 않은 사유를 소송 중에 제시하는 것은 국민의 예측 가능성을 침해하고 이유제시 제도의 취지를 몰각시킨다는 문제가 있다. 반면, 소송 경제 및 실체적 진실 발견이라는 측면에서는 실체적으로는 적법한 처분이 단순한 절차적 하자(이유제시 미비)로 취소되는 것은 행정 효율성 측면에서 바람직하지 않다는 주장이 제기된다.

2. 학설

(1) 부정설

- 처분사유의 추가·변경은 행정절차법상 이유제시 제도의 취지를 정면으로 위배하고 원고의 방어권을 심대하게 침해하므로 절대적으로 허용될 수 없다는 견해이다.

(2) 긍정설

- 소송 경제 및 처분의 실체적 적법성 유지를 위해 일정한 제한 없이 추가·변경을 허용해야 한다는 견해이다. 원고의 방어권 침해 문제는 변론 기회 부여 등 소송 절차를 통해 해결할 수 있다고 본다.

(3) 제한적 긍정설

- 원고의 방어권을 실질적으로 침해하지 않는 범위 내에서 일정한 요건 하에 추가·변경을 허용해야 한다는 견해이다. 이는 현재 통설 및 판례의 입장으로, 기본적 사실관계의 동일성 유무를 제한 요건으로 제시한다.

3. 판례

- 판례는 제한적 긍정설의 입장을 취하면서, 처분사유의 추가·변경이 허용되기 위해서는 당초의 처분사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되어야 한다고 본다. 이러한 판례의 입장은 당초 처분시부터 존재했던 사실에 대한 법률적 평가나 적용 법조만 달리하는 경우에 한하여 추가·변경을 허용함으로써, 행정청의 방어권을 보장함과 동시에 원고의 방어권을 실질적으로 해치지 않도록 조화를 꾀한다. 판례는 기본적 사실관계의 동일성 여부는 단순히 법률적 관점이 아닌, 구체적 사실관계의 사회적·역사적 동일성 여부에 따라 판단되어야 한다고 본다.

4. 검토

- 처분사유의 추가·변경은 제한적 긍정설에 따라 허용되는 것이 타당하다. 부정설은 절차법적 측면만을 과도하게 강조하여 실체적으로 정당한 처분을 취소하게 하는 불합리를 초래하고, 긍정설은 원고의 방어권 침해 가능성이 높다. 따라서, 판례가 제시하는 기본적 사실관계의 동일성 요건을 통해 그 범위를 엄격하게 제한함으로써, 행정처분의 적법성 유지 필요성과 국민의 방어권 보장 사이의 균형을 이루어야 한다.

III. 처분사유의 추가·변경의 인정 범위

1. 객관적 범위

- 처분사유의 추가·변경이 허용되는 객관적 범위는 당초 처분사유와 추가 사유가 기본적 사실관계의 동일성을 갖는 경우에 한정된다. 기본적 사실관계의 동일성이 인정되기 위해서는, 추가되는 사유가 당초 처분 사유를 구성하는 개별적인 사실 중 일부 또는 당초 사유와 밀접하게 관련된 주변 사실에 해당하여 원고가 이미 알고 있었거나 알았다고 인정되는 경우여야 한다. 새로운 별개의 사실을 추가하여 처분 사유로 삼는 것은 허용되지 않는다. 이는 법률적 평가를 달리하는 것에 불과한지, 아니면 전혀 다른 새로운 사실 관계를 주장하는 것인지 여부를 기준으로 판단된다.

2. 시간적 범위

- 처분사유의 추가·변경은 사실심 변론종결시 이전까지만 허용된다. 이는 법원의 심리 및 판결의 기초가 되는 사실 인정이 사실심 변론종결시를 기준으로 하기 때문이다. 다만, 추가·변경되는 사유 자체는 처분시를 기준으로 이미 존재하고 있었던 것이어야 하며, 처분 후 새롭게 발생한 사정 변화를 추가 사유로 삼아 처분의 적법성을 주장하는 것은 위법성 판단의 기준시 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

IV. 처분사유의 추가·변경의 인정 여부의 유형별 검토

1. 기본적 사실관계의 동일성을 인정한 사례

- 판례가 기본적 사실관계의 동일성을 인정한 사례는 주로 하나의 비위 행위나 사건에 대하여 당초 적용한 법률 조항이나 법률적 평가만 달리하는 경우이다. 예를 들어 음주운전 행위에 대해 당초 면허취소 처분의 근거를 특정 법규 위반에서 소송 중 동일 행위에 대한 다른 법규 위반으로 변경하는 경우 등이다. 또한, 공무원의 징계 사유 중 복종의무 위반을 소송 중 성실의무 위반으로 변경하는 것도 동일한 행위 자체에 대한 법률적 평가 변경에 불과하여 동일성을 인정하였다. 이는 원고가 이미 자신의 행위 자체에 대해서는 충분히 방어 준비를 할 수 있다고 보기 때문이다.

2. 기본적 사실관계의 동일성을 부정한 사례

- 판례가 기본적 사실관계의 동일성을 부정한 사례는 당초 처분 사유가 된 사실 외에 전혀 별개의 새로운 사실 또는 다른 시점에 발생한 사실을 추가하여 주장하는 경우이다. 예를 들어 당초 면허취소 처분의 사유가 특정 날짜의 교통사고였는데, 소송 중 전혀 다른 날짜의 음주운전 사실 등을 추가하여 주장하는 경우에는 동일성이 부정된다. 또한, 당초 처분 사유인 허가 조건 미이행과 추가 사유인 허위 문서 제출은 서로 독립된 행위로 간주되어 동일성이 부정된다. 이러한 경우 원고에게는 추가된 사유에 대해 방어할 예측 가능성이 전혀 없었기 때문에 방어권이 실질적으로 침해된다고 판단한다.

V. 처분사유의 추가·변경의 효과

- 처분사유의 추가·변경이 법원에 의해 허용되면, 추가 또는 변경된 사유는 당초 처분사유와 함께 법원의 심리 대상이 된다. 법원은 이러한 모든 사유를 종합하여 처분의 적법 여부를 판단한다. 만약, 당초 처분사유는 위법성이 인정되더라도, 추가된 사유가 적법하여 결과적으로 처분이 정당화된다면 원고의 청구는 기각된다. 반대로, 추가·변경이 허용되지 않은 경우 법원은 행정청이 추가·변경한 사유를 전혀 고려하지 않고 당초 처분사유만을 심리하여 위법성 여부를 판단하게 된다.

VI. 결론

- 처분사유의 추가·변경 제도는 행정처분의 실체적 적법성 유지 필요성과 국민의 방어권 보장 사이의 조화를 추구하는 중요한 심리 쟁점이다. 판례는 이를 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서만 제한적으로 허용함으로써, 행정청의 방어 기회 보장과 국민의 권리 보호를 균형있게 도모하고 있다.

<제6장 취소소송의 종료.제1절 법원의 판결>

I. 의의

- 법원의 판결이라 함은 취소소송의 심리를 종료하면서 법원이 그 결과에 따라 최종적으로 내리는 재판 형식이다. 판결은 소송요건 흠결 여부에 따라 소송판결과 본안판결로 나뉘며, 행정심판과는 달리 기속력, 제3자효, 형성력 등의 확정적인 법적 효력을 발생시킨다. 이는 행정처분의 위법성을 확정하고 그 효력을 변동시키는 최종적인 사법 심사 결과이다.

II. 소송판결

- 소송판결이라 함은 법원이 취소소송의 소송요건을 심리한 결과, 원고 적격, 협의의 소의, 제소 기간 등의 소송요건이 결여되거나 흠결이 있어 본안에 대한 심리를 하지 않고 소송 절차를 종료시키는 판결 형식이다. 소송판결의 대표적인 예는 각하판결이다. 각하판결은 처분의 위법성 유무에 대한 판단 없이 원고의 청구 자체를 배척하는 것이며, 판결이 확정되면 기판력이 발생한다. 다만, 소송요건의 흠결이 치유될 수 있는 경우에는 판결이 아닌 결정 형식으로 처리될 수도 있다.

III. 본안판결

1. 의의

- 본안판결이라 함은 법원이 취소소송의 소송요건이 모두 적법하게 갖추어졌다고 인정하여 처분의 위법성 유무에 대한 실질적인 심리를 거쳐 내리는 판결이다. 본안판결에는 원고의 청구가 이유 없는 경우에 내리는 기각판결, 원고의 청구가 이유 있다고 인정하여 처분을 취소하는 인용판결, 처분이 위법함에도 공익적 이유로 청구를 기각하는 사정판결이 있다.

2. 기각판결

- 기각판결이라 함은 법원이 본안 심리 결과 원고가 주장하는 처분의 위법 사유가 없다고 판단하여 원고의 청구를 배척하는 판결이다. 기각판결의 사유는 해당 처분이 실제적으로 적법한 경우뿐만 아니라, 처분의 위법성이 존재하더라도 그것이 취소할 정도의 중대한 것이 아니라고 판단되는 경우 등이 포함될 수 있다. 또한, 처분이 위법함에도 불구하고 공공 복리 등의 사정으로 사정판결의 요건이 충족되어 청구를 기각하는 경우도 판결 형식은 기각판결이다. 기각판결이 확정되면 처분은 적법한 것으로 확정되며, 기판력이 발생한다.

3. 인용판결

- 인용판결이라 함은 법원이 본안 심리 결과 처분의 위법성이 인정되어 원고의 청구를 받아들여 당해 처분을 취소하는 판결이다. 인용판결은 처분의 전부를 취소하는 전부 취소 판결 또는 일부만을 취소하는 일부 취소 판결 형태로 나타난다. 인용판결이 확정되면, 그 판결에 따라 처분의 효력이 소급적으로 소멸되는 형성력이 발생하며, 관련 행정청에 동일한 사유로 재처분을 할 수 없도록 하는 기속력이 발생하고, 제3자에게도 효력이 미치는 제3자효가 발생한다.

IV. 사정판결

1. 의의[행소법 제28조]

- 사정판결이라 함은 행정소송법 제28조에 근거한 판결 형식으로서, 법원이 심리한 결과 원고의 청구가 이유 있다고 인정되어 처분이 위법함에도 불구하고, 그 처분을 취소함으로써 공공 복리에 현저히 위반된다고 인정될 때 원고의 청구를 기각하는 판결이다. 사정판결은 개별적 정의의 요청보다 공익적 필요성을 우선시하여 처분의 효력을 예외적으로 유지시키는 본안판결 중 하나이다.

2. 요건

(1) 처분이 위법할 것

- 사정판결이 내려지기 위해서는 법원이 심리한 결과 해당 행정처분이 취소할 정도의 위법성을 가진다고 인정되어야 한다. 위법성이 없다면 일반적 인 기각판결이 내려진다.

(2) 취소하는 것이 공공 복리에 현저히 위반될 것

- 처분의 취소로 인하여 야기되는 공익상의 손해가 그 처분의 위법성으로 인한 개인의 불이익을 정당화할 수 있을 정도로 현저하게 큰 경우에 해당한다. 예를 들어 도시계획 등 대규모 행정처분을 취소함으로써 발생하는 막대한 사회적 혼란 및 국가 재정 손실 등이다.

(3) 원고에게 손해 배상 등 구제 수단을 명시할 것

- 법원은 사정판결의 주문 또는 이유 속에 해당 처분이 위법함을 명시하여야 하며, 원고가 입게 될 손해를 배상할 방법 등 적절한 구제 조치를 취할 것을 명해야 한다. 이는 위법한 처분을 유지함으로써 침해되는 원고의 권리 구제를 위한 보완 조치이다.

3. 불복

- 사정판결은 실질적으로는 청구를 기각하는 판결이지만, 원고는 자신의 청구가 인용되지 않은 데 대하여 상소를 통해 불복할 수 있다. 다만, 상소심 법원 역시 사정판결의 요건이 갖추어졌다고 판단하면 스스로 사정판결을 할 수 있다.

4. 효과

- 사정판결은 주문상으로는 청구를 기각하는 판결이지만, 처분의 위법성을 인정하고 있다는 점에서 일반 기각판결과 차이가 있다. 사정판결에 의해 처분의 효력은 유지되므로 형성력은 발생하지 않는다. 그러나 법원은 판결 주문 또는 이유에 처분의 위법성을 명시해야 하며, 행정소송법 제28조 제3항에 따라 원고는 손해 배상 등 적절한 구제 방법의 청구를 당해 취소소송이 계속된 법원에 병합하거나 별도로 청구할 수 있다.

5. 무효등 확인소송의 경우

- 판례는 처분의 효력 유지를 전제로 하는 사정판결의 성격상, 처분 자체에 중대하고 명백한 하자가 있어 그 효력이 당연히 없는 것으로 확인하는 무효등 확인소송에는 사정판결 규정을 유추 적용할 수 없다고 본다. 무효인 처분의 효력을 공익적 이유로 유지시키는 것은 법적 안정성 및 행정법의 기본 원리에 위배된다는 것이다.

6. 부작위위법확인소송의 경우

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위(예 : 신청에 대한 응답 의무 불이행)의 위법성만을 확인하는 소송이다. 부작위위법확인소송은 처분 자체를 취소하는 것이 아니라 부작위의 위법성 확인만을 구하는 것이므로, 부작위를 유지해야 할 공익적 필요성이라는 사정판결의 요건이 성립할 여지가 없다. 따라서 부작위위법확인소송에서는 사정판결이 인정되지 않는다.

V. 결론

- 취소소송의 종료 단계에서 법원의 판결은 소송요건 심사를 통한 소송판결과 본안 심사를 통한 본안판결로 구분된다. 특히 본안판결 중 사정판결은 처분의 위법성 인정과 공익 보존 사이의 균형 장치로서 위법한 처분으로 인한 행정의 안정성을 도모하면서 개인의 손해 구제를 보완한다는 특수한 의의를

가진다. 각 판결 형식은 확정 시 기판력, 기속력 등 행정청과 제3자에게 미치는 효력이 달라 소송 수행 전략의 기초가 된다.

<제6장 취소소송의 종류.제2절 판결의 효력>

I. 불가변력-선고법원에 대한 효력

- 불가변력이란 일단 법원이 판결을 선고하거나 고지하면, 그 판결을 선고한 법원 스스로는 그 판결을 취소하거나 변경할 수 없게 되는 효력을 말한다. 이는 자박력이라고도 한다. 불가변력은 소송의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위한 원칙이다. 불가변력은 판결이 성립함과 동시에 발생하며, 판결의 확정 여부와는 관계가 없다. 선고법원은 오직 재판의 누락이나 계산의 착오 등 법이 인정한 경정 사유에 한하여 판결 내용을 바로잡을 수 있다.

II. 불가쟁력-소송당사자에 대한 효력

- 불가쟁력이란 상소기간이 경과하거나 당사자가 상소를 포기한 경우 또는 모든 심급을 거친 경우 당해 판결이 그 소송절차 내에서의 취소·변경 가능성을 상실하는 효력을 말한다. 이는 판결이 확정됨으로써 발생하는 효력이다. 당사자가 상소 기간 내에 상소권을 행사하지 않거나, 상소를 할 수 없는 중간 판결 등이 내려진 경우에 발생한다. 불가쟁력은 당사자가 더 이상 동일한 소송 절차에서 그 판결의 위법성이나 부당성을 주장할 수 없도록 제한하여, 분쟁의 종국적인 해결과 법률 관계의 안정을 도모한다.

III. 기판력-후소의 당사자와 법원에 대한 효력

1. 의의

- 기판력이란 확정된 중국 판결의 판단 내용이 소송 당사자와 후소 법원을 구속하여, 당사자가 후소에서 이에 모순되는 주장을 할 수 없게 하고, 법원도 이에 반하는 판단을 할 수 없게 하는 효력을 말한다. 기판력은 소송물에 대한 법원의 판단에 부여되는 최종적인 구속력이다. 이는 동일한 사항에 대한 반복적인 소송을 방지하고 법적 안정성을 확보하기 위한 소송법상의 제도이다.

2. 범위

(1) 주관적 범위

- 기판력은 원칙적으로 소송 당사자와 그 승계인에게 미친다. 다만, 취소소송의 형성력이 제3자에게도 미치기 때문에, 행정소송에서는 기판력의 주관적 범위가 행정청의 처분에 대해서는 상대화되어 적용될 필요성이 제기된다.

(2) 객관적 범위

- 기판력은 판결의 주문에 포함된 소송물에 대한 판단에만 미친다. 판결 이유에서 실시된 판단이나 선결적 문제에 대한 판단에는 원칙적으로 기판력이 미치지 않는다. 취소소송의 소송물은 처분의 위법성 일반이다.

(3) 시적 범위

- 기판력은 소송의 사실심 변론 종결 시를 기준으로 발생하며, 그 이후에 발생한 사유에 대해서는 기판력이 미치지 않는다.

3. 취소판결의 국가배상청구소송에 대한 기판력

- 취소소송에서 취소 판결이 확정된 경우, 이 판결의 기판력이 후소로 제기된 국가배상청구소송에 미치는지 여부가 문제된다.

(1) 위법성의 상이성

- 취소소송에서의 위법성 판단은 적법 요건에 중점을 두는 공법상의 위법성인 반면, 국가배상소송에서의 위법성 판단은 공무원의 고의·과실 및 손해 배상 책임의 발생 여부에 중점을 두는 사법상의 위법성 판단이라는 차이가 있다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 취소소송의 판결이 원처분의 위법성을 인정한 경우, 이 판단이 후소인 국가배상청구소송의 공무원의 과실 여부 판단에 결정적인 영향을 미친다고 본다. 즉, 취소 판결의 위법성 판단은 국가배상소송의 선결 문제로서 강한 사실적 구속력을 가지며, 이를 통해 모순된 판결을 방지하고 있다. 그러나 형식적으로는 두 소송의 소송물이 다르므로 기판력이 직접 미친다고 보지는 않는다.

IV. 형성력-소송당사자와 제3자에 대한 효력

1. 의의

- 형성력이란 취소소송에서 취소 판결이 확정되면, 그 판결의 효력이 처분의 법률 관계를 형성적으로 변경시켜 원처분을 실효시키는 효력을 말한다. 이러한 형성력은 판결의 효력이 소송 당사자뿐만 아니라 제3자에게까지 미치는 대세적 효력을 가진다는 특징이 있다.

2. 세부내용

(1) 처분의 실효

- 취소 판결이 확정되면, 그 처분은 판결의 확정 시에 소급하여 효력을 잃는다.

(2) 재결 취소 소송의 경우

- 재결 취소 소송에서 재결 취소 판결이 확정되면, 재결뿐만 아니라 재결의 대상이 된 원처분까지도 실효된다.

3. 제3자의 보호

- 취소 판결의 형성력은 대세적 효력을 가지므로, 처분의 직접 상대방이 아닌 제3자에게도 그 효력이 미친다. 예를 들어 특허 취소 판결은 특허권자가 아닌 제3자에게도 특허가 없어진다는 효력을 미친다. 그러나 이로 인해 제3자가 예기치 못한 불이익을 입을 수 있으므로, 행정소송법은 제3자의 권익을 보호하기 위한 규정을 둔다.

(1) 제3자의 재심 청구

- 취소소송에서 고의 또는 과실 없이 소송에 참가하지 못함으로써 판결의 효력으로 인해 권리 또는 이익을 침해당한 제3자는 그 판결이 있음을 안 날부터 90일 이내, 판결이 확정된 날부터 1년 이내에 재심을 청구할 수 있다.

(2) 재판 관여 등

- 제3자가 소송에 참가하거나(참가), 법원이 직권으로 제3자를 소송에 참여시키는(소송 고지) 등의 제도를 통해 제3자에게 방어권 행사 기회를 제공한다.

V. 기속력-행정기관에 대한 효력

1. 의의[행소법 제30조 제1항]

- 기속력이란 취소 판결이 확정되면, 그 판결의 내용에 따라 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 동일한 사안에 대하여 반복되는 위법 행위를 할 수 없도록 구속하는 효력을 말한다. 행정소송법 제30조 제1항은 판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다고 규정하여 기속력의 핵심적 내용을 명시한다.

2. 기속력의 성질과 기판력

(1) 성질

- 기속력은 취소 판결의 실효성을 확보하고 행정의 법적 안정성을 유지하며 반복되는 행정쟁송을 방지하기 위한 행정소송 특유의 효력이다. 이는 소송법적 효력인 동시에 행정청의 작용을 구속하는 공법적 효력의 성질을 가진다.

(2) 기판력과 관계

- 기판력이 소송 당사자와 법원을 구속하는 반면, 기속력은 행정청을 구속한다는 점에서 차이가 있다. 또한 기판력은 소송물에 한정되지만, 기속력은 판결의 이유 중 위법 판단의 근거가 된 사실 인정과 법률 적용에까지 미친다.

3. 범위

(1) 시적 범위

- 기속력은 판결이 확정된 때 발생하며, 소송의 사실심 변론 종결 시 이후의 새로운 사실 관계에는 미치지 않는다.

(2) 객관적 범위

- 기속력은 판결의 주문뿐만 아니라 판결 이유 중 처분의 위법성을 판단하는 구체적인 근거가 된 사실 인정과 법률 적용에 관한 판단에까지 미친다.

(3) 주관적 범위

- 기속력은 처분청인 피고 행정청과 그 처분청을 지휘·감독하는 상급 행정청, 다른 관계 행정청에게까지 미친다.

4. 실질적 의무

- 기속력은 행정청에게 다음과 같은 실질적인 의무를 부과한다.

(1) 반복 금지 의무

- 행정청은 동일한 사실 관계와 법률적 판단 아래에서 같은 내용의 위법 처분을 반복해서는 안 된다.

(2) 재처분 의무

- 판결에 의해 신청을 거부하는 처분이 취소된 경우, 처분청은 그 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 해야 한다. 즉, 거부 사유를 달리 하더라도 판결의 취지에 반하는 재처분을 할 수 없다.

(3) 결과 제거 의무

- 취소 판결의 형성력에 따라 처분이 실효되더라도, 그 처분으로 인해 발생한 사실적인 결과는 행정청이 적절한 조치를 통해 제거하여야 할 의무가 있다.

5. 간접강제

- 행정소송법은 거부 처분 취소 판결이 확정되었음에도 행정청이 재처분 의무를 이행하지 않을 경우, 법원의 결정으로 간접강제를 할 수 있도록 규정한다. 간접강제란 배상금을 명하는 등의 방식으로 행정청을 압박하여 재처분을 이행하도록 하는 제도이다. 이는 기속력의 실효성을 확보하기 위한 강력한 수단이다.

6. 기속력 위반의 효과

- 기속력을 위반하여 행정청이 반복 금지 의무나 재처분 의무를 이행하지 않고 새로운 처분을 한 경우, 그 새로운 처분은 위법하게 된다. 이 경우 당사자는 재차 취소소송을 제기할 수 있으며, 이 소송에서 법원은 기속력 위반을 이유로 그 새로운 처분을 취소하여야 한다. 기속력 위반은 처분 자체의 위법성을 구성한다.

V. 결론

- 취소소송의 판결은 불가변력(법원), 불가쟁력(당사자), 기판력(후소 법원), 형성력(제3자 포함), 기속력(행정기관) 등의 광범위한 효력을 가진다. 특히 형성력은 처분을 소급적으로 실효시켜 대세적 효력을 가지므로 제3자 보호 규정이 중요하며, 기속력은 행정청에 반복 금지 의무와 재처분 의무를 부과하여 판결의 실효성을 담보하며, 위반 시 해당 처분은 위법하게 된다.

<제6장 취소소송의 종류.제3절 재심>

I. 민사소송법에 의한 재심청구

- 재심이라 함은 이미 확정된 중국 판결에 대하여 재심 사유를 이유로 그 판결의 취소와 사건의 재심판을 구하는 비상적인 불복 방법이다. 이는 판결의 기판력과 불가쟁력으로 인해 더 이상 다룰 수 없는 확정판결의 안정성을 해치는 예외적인 제도이므로, 중대하고 명백한 하자가 있는 경우에만 허용된다. 행정소송법 제8조 제2항에서 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 민사소송법의 규정을 준용한다고 명시하고 있다. 따라서 취소소송의 확정판결에 대하여도 원칙적으로 민사소송법 제451조에 규정된 재심 사유를 근거로 재심 청구를 할 수 있다.

- 민사소송법상 재심 사유는 법관의 제척 또는 기피 사유가 있음에도 판결에 관여한 때, 법정대리권이나 소송대리권의 흠결이 있었던 때, 판결의 기초가 된 증거 서류나 증언이 위조 또는 번조된 것으로 밝혀진 때, 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 대하여 법관이 직무에 관한 죄를 범한 때 등 소송 절차나 판결의 기초가 된 사실 인정에 중대한 오류가 있음을 전제로 한다. 이러한 재심 사유는 판결의 확정으로 발생한 기판력과 불가쟁력의 구속력으로부터 당사자를 구제하고 실질적인 정의를 회복하는 데 목적이 있다. 특히 행정소송에서는 처분의 위법성 유무에 대한 최종 판단을 뒤집을 수 있는 비상적 수단으로서의 중요성을 지닌다. 재심 청구는 당사자가 재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 제기해야 하며, 판결 확정일로부터 5년을 경과하면 제기할 수 없다. 이러한 엄격한 기간 제한은 확정판결의 법적 안정성을 최대한 유지하기 위한 조치이다.

II. 제3자의 재심청구

1. 청구적격자[행소법 제31조]

- 제3자의 재심청구적격자라 함은 행정소송법 제31조 제1항에 명시된 바와 같이 처분등을 취소하는 판결에 의하여 자신의 권리 또는 법률상 이익의 침해 받은 제3자를 말한다. 여기서 제3자는 당해 취소소송의 원고나 피고 등 소송 당사자가 아닌 자로서, 소송이 진행되는 동안 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못한 자를 의미한다. 권리 또는 법률상 이익의 침해는 취소소송의 원고적격 요건에서 요구되는 법률상 보호되는 이익의 침해와 동일한 개념으로 해석된다. 즉, 단순히 사실적·경제적 이해관계의 침해만으로는 부족하고, 해당 처분의 근거 법규 또는 관련 법규에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익의 침해를 받은 자만이 재심을 청구할 자격이 있다. 예를 들어, 갑에 대한 면허 처분을 취소하는 판결로 인해 직접적인 경쟁 관계에 있는 을의 법률상 이익이 침해된 경우 등이 이에 해당한다.

2. 인정필요성

- 제3자의 재심청구 제도가 인정되어야 할 필요성은 취소소송 판결의 특유한 효력인 형성력과 제3자효에서 비롯된다. 취소판결이 확정되면 그 판결은 소송 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 효력을 미치며, 처분의 효력은 소급적으로 소멸된다. 이는 제3자가 해당 소송이 진행되는 사실을 알지 못하였거나 알 수 없었던 경우에도 판결의 효력을 부정할 수 없게 하여 제3자의 권익을 침해할 위험을 내포한다. 행정소송법 제16조와 제17조에서 제3자 참가 제도를 두어 이러한 침해 가능성을 사전에 방지하고자 하지만, 제3자가 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못하였을 경우 구제 수단이 없게 된다. 따라서 제3자의 재심청구 제도는 이러한 취소소송 판결의 형성력과 제3자효로 인한 피해를 사후적으로 구제하고, 소송 절차의 공정성과 실질적인 정의를 실현하기 위한 필수적인 보완 장치로 기능한다. 즉, 이 제도는 확정판결의 안정성 유지라는 대원칙 속에서, 책임 없는 사유로 권익을 침해당한 제3자의 권익 구제라는 정의의 요청을 조화시키기 위해 도입된 것이다.

3. 요건

- 제3자가 재심 청구를 제기하기 위해서는 일반적인 민사소송법상 재심 사유가 존재해야 한다는 점은 당연한 전제이며, 이에 더하여 행정소송법 제31조가 정하는 두 가지 특유의 요건을 충족해야 한다.

(1) 판결에 의한 침해

- 판결에 의하여 자신의 권리 또는 법률상 이익의 침해를 받았어야 한다. 이는 청구적격자 요건과 동일하며, 판결의 직접적인 효과로 법률상 이익이 침해되는 결과가 발생해야 한다.

(2) 책임 없는 사유로 소송 참가 불가능

- 자기에게 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못하였어야 한다. 이 요건은 제3자에게 소송 참가의 기회가 있었음에도 불구하고 소송이 진행되는 사실을 알지 못하였거나, 소송에 참가하지 못한 것에 대하여 제3자에게 고의나 과실이 없었음을 의미한다. 판례는 행정청이 소송 고지 의무를 이행하지 않은 경우 등 제3자가 소송 계속 사실을 알 수 없었던 객관적인 사정이 있었음을 중요하게 판단한다. 단순히 소송의 결과를 예측하지 못했다거나 소송에 대한 무관심 등은 책임 없는 사유로 인정되지 않는다.

(3) 청구 기간

- 재심 청구 기간은 일반 재심과 마찬가지로 재심 청구의 사유, 즉 판결이 있었음을 안 날부터 30일 이내에 제기해야 한다. 여기서 판결이 있었음을 안 날은 판결 내용뿐만 아니라 그 판결이 자신의 법률상 이익을 침해한다는 사실까지 안 날을 의미한다. 또한 판결 확정일로부터 1년이 경과하면 제기할 수 없다. 이 기간 제한은 제3자 보호의 요청과 확정판결의 안정성이라는 두 법익의 충돌을 조정하는 기준이 된다.

III. 결론

- 재심 제도는 확정판결의 법적 안정성을 유지하는 대원칙에 대한 예외로서, 판결 성립 과정에 중대한 하자가 있는 경우에 한하여 비상적으로 인정되는 권리 구제 수단이다. 취소소송에서는 민사소송법의 일반 규정을 준용하여 당사자의 재심 청구를 인정함은 물론이다. 나아가, 취소소송의 판결이 가지는 형성력과 제3자효로 인해 자신의 책임 없이 권익을 침해당한 제3자를 구제하기 위해 행정소송법 제31조는 제3자의 재심청구라는 특칙을 마련하고 있다. 이 제도는 행정소송의 결과가 제3자에게 미치는 광범위한 영향을 고려하여, 개인의 권익 구제와 행정의 안정성 확보라는 공익적 요청을 조화시키고자 하는 행정쟁송법의 중요한 제도적 장치이다.

<제6장 취소소송의 종료.제4절 취소소송의 종료 사유>

I. 당사자의 행위에 의한 종료

- 취소소송은 공법상 법률관계를 다루는 소송이지만, 당사자의 의사에 따른 소송 종류가 일부 인정된다.

1. 소의 취하

(1) 의의[민사소송법 제266조]

- 원고가 제기한 소송의 전부 또는 일부를 철회하는 법원에 대한 일방적인 의사표시이다. 소가 취하되면 소송은 처음부터 계속되지 않았던 것으로 본다.

(2) 요건

① 판결 확정 전

- 소는 판결이 확정될 때까지 그 전부나 일부를 취하할 수 있다.

② 상대방 동의

- 상대방(피고 행정청)이 본안에 관하여 준비서면을 제출하거나 변론준비기일에서 진술하거나 변론을 한 뒤에는 상대방의 동의를 받아야 효력이 발생한다. 행정소송은 공익적 성격을 가지지만, 소 취하 시에는 민사소송법의 규정이 준용되므로 이러한 동의 요건이 적용된다.

③ 방식

- 서면으로 하는 것이 원칙이지만, 변론 또는 변론준비기일에서는 구두로 할 수 있다.

(3) 효과[민사소송법 제267조]

- 소 취하가 적법하게 이루어지면 소송 계속은 소급적으로 소멸한다. 본안에 대한 종국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 경우에는 다시 같은 소를 제기하지 못하는 재소금지의 효력이 발생한다.

2. 청구의 포기 및 인낙 (제한적 인정)

(1) 의의

① 청구의 포기

- 원고가 자기의 청구가 이유 없음을 스스로 인정하는 법원에 대한 일방적인 의사표시로, 원고 패소 판결(청구 기각)과 동일한 효과를 가진다.

② 청구의 인낙

- 피고가 원고의 청구가 이유 있음을 스스로 인정하는 법원에 대한 일방적인 의사표시로, 원고 승소 판결(청구 인용)과 동일한 효과를 가진다.

(2) 취소소송에서의 인정 여부

- 취소소송은 공법상의 법률관계를 대상으로 하며, 그 판결은 제3자에게도 효력이 미치는 형성력을 가지는 등 공익적 성격이 강하다. 따라서 원칙적으로 당사자가 임의로 처분할 수 없는 소송물로 보아 청구의 포기나 인낙이 허용되지 않는다고 보는 것이 일반적이다. 판례 역시 청구의 포기나 인낙은 사인 간의 대등한 사법 관계에서 주로 인정되는 것으로, 공법 관계인 행정소송에는 부적합하다고 본다.

3. 소송상 화해 및 조정 (제한적 인정)

(1) 의의

① 소송상 화해

- 소송 계속 중 당사자 쌍방이 상호 양보하여 소송물인 권리관계에 관한 다툼을 해결하는 합의를 의미한다. 화해조서가 작성되면 확정판결과 동일한 효력을 가진다.

② 조정

- 법원의 관여 하에 당사자 쌍방의 양보를 통해 분쟁을 해결하는 절차이다. 조정에 갈음하는 결정 등도 있다.

(2) 취소소송에서의 인정 여부

- 청구의 포기·인낙과 마찬가지로, 취소소송은 공익적 성격이 강하고 제3자효를 가지므로 원칙적으로 소송상 화해나 조정은 허용되지 않는다. 다만, 예외적으로 행정청이 재량행위인 재처분의 수위를 낮추어 재처분을 하고 원고는 소를 취하하도록 유도하는 형태의 조정 권고가 이루어지는 경우가 있다. 이는 엄밀한 의미의 소송상 화해나 조정과는 다르지만, 소송을 실질적으로 종결시키는 기능을 한다.

4. 기타 : 당사자 대립구조의 소멸

(1) 의의

- 소송이 계속되는 도중에 원고와 피고의 지위가 혼동되거나(예 : 원고가 피고 법인을 합병), 소송물인 권리관계의 성질상 승계가 허용되지 않는 경우(예 : 일신전속적 권리인 해고무효확인소송에서 원고가 사망한 경우)에는 더 이상 소송을 유지할 당사자 대립관계가 없어져 소송이 종료된다.

(2) 취소소송에서의 적용

- 취소소송은 공법상 권리관계의 확인이므로 당사자 대립구조의 소멸이 민사소송에서와 같이 다양하게 적용되지는 않지만, 법인 합병 등 유사한 사정이 발생할 경우 소송이 종료될 수 있다.

II. 법원의 재판에 의한 종료 (종국판결 외)

- 종국판결에 이르지 않고 법원의 재판으로 소송이 종료되는 경우도 있다.

1. 소장 각하 명령

(1) 의의[민사소송법 제254조]

- 소장에 필수적으로 기재되어야 할 사항이 누락되었거나, 법원이 보정명령을 하였음에도 원고가 이를 이행하지 않는 경우, 법원이 재판장 명의로 소장을 각하하는 명령을 말한다. 이는 판결이 아닌 명령의 형식으로 이루어진다.

(2) 효과

- 소송은 처음부터 계속되지 않았던 것으로 본다. 원고는 소장 각하 명령에 대해 즉시항고로 다툴 수 있다. 소장 각하 명령은 소송 요건의 흠결이 명백하여 본안 심리 자체를 시작할 수 없는 경우에 내려진다.

2. 소송종료선언 판결

(1) 의의

- 소송 계속 중 소의 취하 등 다른 사유로 인해 이미 소송이 종료되었음에도 불구하고, 법원이 이를 간과하고 계속 심리한 경우에 나중에 그 사실을 발견하여 소송의 종료를 선언하는 판결을 말한다.

(2) 요건

- 소송이 소의 취하 등 종국판결 외의 사유로 이미 종료되었을 것을 요건으로 한다.

(3) 효과

- 소송이 이미 종료되었음을 확인하는 의미만을 가지며, 소송 종료의 효력은 소송종료선언 판결 시가 아니라 실제 소송이 종료된 시점에 발생한다.

Ⅲ. 결론

- 취소소송은 법원의 종국판결에 의해 종료되는 것이 일반적이지만, 당사자의 행위 또는 소송 요건의 흠결 등으로 인해 종국판결에 이르지 않고 종료되는 경우가 있다. 주요 사유는 소의 취하이며, 이는 상대방의 동의 요건이 적용된다. 청구의 포기·인낙, 소송상 화해 및 조정은 취소소송의 공익적 성격과 형성력 등으로 인해 원칙적으로 인정되지 않는다. 또한 법원의 재판 형태로는 소장 각하 명령이나 소송종료선언 판결이 있을 수 있고, 마지막으로 당사자 대립구조의 소멸과 같은 기타 사유로도 소송이 종료될 수 있다. 이러한 종국판결 외의 종료 사유들은 소송 경제와 당사자의 의사 존중을 고려하면서도 행정소송의 특수성을 반영하여 제한적으로 인정된다.

<제7장 취소소송의 가구제.제1절 집행정지>

I. 집행정지의 의의

1. 개념[행소법 제23조 제2항]

- 집행정지란 행정소송이 제기된 처분의 효력이나 그 집행, 또는 절차의 속행을 종국 판결이 있을 때까지 잠정적으로 정지시키는 제도를 말한다. 행정소송법 제23조 제2항은 취소소송이 제기된 경우에 처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는 본안이 계속되고 있는 법원은 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지를 결정할 수 있다.고 규정하여 집행정지의 개념과 요건을 명시한다. 집행정지는 행정의 공정력으로 인해 취소소송 제기만으로는 처분의 효력이 정지되지 않는다는 집행부정지의 원칙에 대한 예외로서, 국민의 권리 구제 실효성을 확보하기 위한 수단이다.

2. 현행법의 태도

- 현행 행정소송법은 집행정지 제도를 명문으로 규정함으로써, 소송 제기만으로는 처분의 효력이 정지되지 않는다는 집행부정지의 원칙을 채택하고 있다. 이는 행정의 집행력과 공정력을 존중하고 행정의 효율성을 유지하려는 취지이다. 그러나 이 원칙을 무한정 관철할 경우, 본안 판결이 확정될 때까지 처분이 집행되어 당사자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 수 있다. 따라서 현행법은 집행부정지의 원칙을 고수하면서도, 일정 요건 하에 법원이 직권 또는 신청에 의해 집행정지 결정을 내릴 수 있도록 하여 사익 보호와 공익 보호의 균형을 도모하고 있다. 법원은 집행정지 결정을 통해 본안 소송의 승소 가능성이 있는 당사자에게 잠정적인 구제를 제공하여 행정소송 제도의 실질적인 기능을 강화한다.

II. 집행정지의 요건

- 집행정지 결정은 다음과 같은 적극적 요건과 소극적 요건을 모두 충족할 때 가능하다.

1. 적극적 요건[행소법 제23조 제2항]

(1) 본안 소송의 계속

- 집행정지는 본안 소송의 부수 절차이므로, 취소소송이 적법하게 제기되어 법원에 계속되어 있어야 한다. 본안 소송의 청구 자체가 부적법하여 각하될 가능성이 명백한 경우에는 집행정지 신청은 부적법하게 된다. 다만, 본안 청구가 이유 없음이 명백하더라도 집행정지 요건의 충족 여부와는 직접적인 관계가 없으며, 이는 뒤에서 설명할 소극적 요건과 연관된다.

(2) 처분등의 존재

- 집행정지의 대상이 되는 행정 처분 또는 재결이 존재하여야 한다. 이는 처분의 집행이나 효력을 정지하는 것이 목적이므로, 집행이 완료되었거나 효력이 소멸된 처분에 대해서는 집행정지를 구할 실익이 없어 부적법하다.

(3) 회복하기 어려운 손해 발생 우려

- 처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인해 당사자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어야 한다. 여기서 회복하기 어려운 손해란 금전으로 보상이 불가능하거나, 금전 보상으로는 충분한 구제를 받을 수 없는 유·무형의 손해를 의미한다. 단순히 손해가 발생한다는 것만으로는 부족하며, 손해를 금전 배상으로 전보하는 것이 가능하더라도, 그 손해를 참고 본안 판결을 기다리는 것이 사회 통념상 현저히 곤란하다고 인정되는 경우도 포함된다.

(4) 긴급한 필요

- 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있어야 한다. 이는 본안 판결을 기다릴 만한 시간적 여유가 없으며, 즉시 집행정지 결정을 내리지 않으면 회복하기 어려운 손해가 발생하거나 확대될 우려가 있다는 것을 의미한다.

2. 소극적 요건

(1) 공공복리에 중대한 영향 미칠 우려가 없을 것[행소법 제23조 제3항]

- 집행정지 결정으로 인해 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있어서는 안 된다. 법원은 집행정지 신청을 심리할 때, 신청인의 사익 보호 필요성과 집행정지로 인해 발생할 수 있는 공익 침해의 정도를 형량하여야 한다. 사익 보호의 필요성이 공익 침해의 우려보다 크지 않다면 집행정지 신청은 기각된다. 여기서 공공복리는 단순한 공익이 아니라, 집행정지를 통해 발생하는 영향이 사회 일반의 이익에 중대하고 회복하기 어려운 결과를 초래할 정도의 공익을 의미한다.

(2) 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않을 것[판례]

- 판례는 집행정지 신청 시 본안 청구의 이유 유무에 대한 소명을 요구하지는 않지만, 본안 청구가 이유 없음이 명백한 경우에는 집행정지를 허용할 필요성이 없으므로, 이러한 경우를 소극적 요건으로 간주하여 집행정지를 불허한다. 여기서 이유 없음이 명백한 경우란 본안에서 원고가 승소할 가능성이 전혀 없다는 것이 명백히 드러나는 경우를 말한다.

III. 집행정지결정

1. 신청 및 법원의 직권 발동

- 집행정지는 원칙적으로 당사자의 신청에 의해 이루어지지만, 법원은 직권으로도 집행정지 결정을 할 수 있다.

2. 관할 법원

- 집행정지 결정은 본안이 계속되고 있는 법원이 관할한다. 본안 소송이 고등법원이나 대법원에 계류 중인 경우에도 해당 법원이 관할 법원이 된다.

3. 심리 방식

- 집행정지는 결정의 형식으로 이루어진다. 법원은 심리 시 당사자의 주장과 관계 서류를 검토하는 것이 일반적이며, 필요하다고 인정하는 경우에는 당사자를 신문할 수 있다. 심리는 변론을 거치지 않고 이루어지는 것이 원칙이다.

4. 법원의 판단

- 법원은 집행정지 요건의 충족 여부를 종합적으로 판단하여, 요건이 충족되면 집행정지 결정을 하고, 요건이 충족되지 않거나 소극적 요건에 해당하면 집행정지 신청을 기각한다.

IV. 집행정지결정의 내용

- 법원은 집행정지 신청을 인용하는 경우, 처분의 효력, 처분의 집행, 절차의 속행 중에서 필요한 범위 내에서 그 전부 또는 일부를 정지할 수 있다.

1. 처분의 효력정지

- 처분의 효력정지란 처분의 법률적 효과 발생을 잠정적으로 정지시키는 것을 말한다. 이는 세 가지 정지 형태 중 가장 강력한 효력을 가지며, 그 효과는 본안 소송에서 취소 판결이 내려진 것과 유사하다. 법원은 처분의 집행정지 또는 절차의 속행정지만으로 그 목적을 달성할 수 있는 경우에는 효력정지를 허용하지 않는다. 이는 행정의 공정력을 최대한 유지하려는 취지이다.

2. 처분의 집행정지

- 처분의 집행정지란 처분으로 인해 발생한 집행 행위 또는 강제 집행 절차를 잠정적으로 정지시키는 것을 말한다. 예를 들어 납세 고지 처분의 효력은 유지되지만, 그에 따른 재산 압류 등 강제 징수 절차는 정지된다.

3. 절차의 속행정지

- 절차의 속행정지란 처분으로 인해 후속적으로 이어지는 행정 절차의 진행을 잠정적으로 정지시키는 것을 말한다. 예를 들어 징계 처분이 내려진 후 징계 절차에 따른 다음 단계의 조치를 정지시키는 것이다.

V. 집행정지의 효력

1. 형성력

- 집행정지 결정은 처분의 효력, 처분의 집행, 절차의 속행을 잠정적으로 정지시킨다는 점에서 형성력을 가진다. 그러나 이는 본안 판결의 형성력처럼 처분의 효력을 소급하여 상실시키는 것이 아니라, 장래를 향하여 그 작용을 잠정적으로 정지시키는 일시적인 효력을 가진다.

2. 기속력

- 집행정지 결정은 결정의 내용에 따라 피고인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하는 기속력을 가진다. 행정청은 집행정지 결정의 취지에 반하여 처분의 집행을 계속하거나, 정지된 절차를 속행하는 등 위반되는 행위를 할 수 없다. 이러한 기속력은 집행정지 결정의 실효성을 확보하는 중요한 근거가 된다.

3. 시간적 효력

- 집행정지의 효력은 결정이 있는 때부터 발생하며, 중국 판결이 확정될 때까지 지속되는 것이 원칙이다. 다만, 법원은 결정에서 정지 기간을 따로 정할 수도 있다. 집행정지 결정의 효력은 본안 소송에서 각하나 기각 판결이 선고되면 특별한 사정이 없는 한 소멸한다. 이는 본안 판결이 정지된 처분의 위법성이 없음을 최종적으로 확정했기 때문이다.

VI. 집행정지결정에 대한 불복[행소법 제23조 제5항]

1. 즉시항고

- 행정소송법 제23조 제5항 전문은 집행정지 결정 또는 기각 결정에 대하여 불복이 있는 당사자는 즉시항고를 할 수 있도록 규정한다. 즉시항고는 법원의 집행정지 결정에 대한 신속한 상급심의 판단을 받기 위한 제도이다.

2. 항고의 효력

- 행정소송법 제23조 제5항 후문은 즉시항고가 제기되더라도 그 항고는 집행정지 결정의 집행을 정지하는 효력이 없다는 것을 규정한다. 즉, 집행정지의 효력은 유지된다는 뜻이다. 이는 집행정지의 목적인 긴급한 사익 보호를 우선하기 위한 조치이다. 다만, 항고 법원은 집행정지 결정의 집행을 정지할 필요가 있다고 인정하는 경우, 직권으로 항고 법원이 집행을 정지시킬 수는 있다.

VI. 집행정지결정의 취소[행소법 제24조 제1항·제2항, 제23조 제4항]

1. 취소 사유

- 집행정지 결정은 잠정적인 효력을 가지므로, 그 결정의 기초가 된 사유가 소멸되거나 변경된 경우 법원은 이를 취소할 수 있다. 행정소송법 제24조 제1항은 집행정지 결정 후에 집행정지 사유가 소멸되거나, 사정 변경으로 인해 집행정지 결정의 유지가 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다고 판단될 때, 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 의해 집행정지 결정을 취소할 수 있도록 규정한다.

2. 취소 절차 및 불복

- 행정소송법 제24조 제2항은 집행정지 결정의 취소 결정에 대하여도 즉시항고를 할 수 있도록 규정한다. 이는 당사자의 권리 구제 기회를 보장하기 위함이다. 이 때에도 행정소송법 제23조 제4항을 준용하여 그 이유를 소명하여야 한다.

VII. 결론

- 집행정지는 행정소송의 집행부정지원칙에 대한 예외로서, 본안 소송 계속, 회복하기 어려운 손해 발생 우려, 긴급한 필요 등의 적극적 요건과 공공복리에 중대한 영향 미칠 우려가 없을 것이라는 소극적 요건이 충족될 때 법원의 결정으로 이루어진다. 그 내용은 효력, 집행, 절차의 속행 정지 중 필요한 범위에서 정해지며, 결정은 형성력과 기속력을 가진다. 결정에 대한 불복은 즉시항고로 가능하며, 사정 변경 시에는 법원이 직권이나 신청에 의해 결정을 취소할 수 있다. 집행정지 제도는 신속한 사익 보호를 통해 행정소송의 실효성을 높이는 핵심적인 가구제 수단이다.

<제7장 취소소송의 가구제.제2절 가처분>

I. 가처분의 의의

- 가처분이라 함은 민사소송법상 인정되는 가구제 제도로서, 다툼의 대상이 되는 권리 관계에 대하여 현상 변경을 금지하거나 임시적인 지위를 정하여 본안 소송의 판결이 확정될 때까지 권리자의 손해를 방지하는 법원의 잠정적 처분을 말한다. 행정소송은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 특별한 규정이 없는 한 민사소송법의 규정이 준용되므로, 민사집행법상의 가처분 규정이 행정소송에도 적용될 수 있는지가 주요 논의 대상이 된다. 가처분의 목적은 장기간 소요되는 본안 소송으로 인해 권리자가 회복할 수 없는 손해를 입거나, 승소하더라도 실질적인 권리 구제를 받지 못하는 상황을 미리 방지하여 실효성을 확보하는 데 있다. 취소소송에서는 집행정지라는 특유의 가구제 제도가 마련되어 있으나, 그 한계로 인해 가처분 제도의 보충적 역할이 필요하다는 주장이 제기된다.

II. 집행정지의 한계

- 행정소송법상 집행정지 제도는 취소소송의 가구제 수단으로서 중요하지만, 그 본질적인 특성으로 인해 권리 구제에 있어 다음과 같은 한계를 가진다. 이러한 한계가 항고소송에서의 가처분 인정 필요성의 근거가 된다.

1. 소극적인 조치에 한정

- 집행정지는 처분의 효력, 처분의 집행, 절차의 속행을 정지시키는 소극적인 조치에 한정된다. 집행정지는 이미 존재하는 처분의 법률 효과를 일시적으로 잠재우는 것에 그칠 뿐, 행정청에게 특정한 작위 의무를 부과하거나 법률 관계를 적극적으로 변경시키는 것은 불가능하다. 예를 들어 원고에게 특정 자격이나 지위를 임시적으로 부여하는 등의 조치는 집행정지의 범위를 벗어난다.

2. 적극적인 처분에 대해서만 적용

- 집행정지는 적극적인 처분에 대해서만 적용될 수 있다. 행정소송법 제23조 제2항은 처분등의 효력 등을 정지시키는 것을 규정하고 있어, 그 대상이 되는 것은 구체적인 행정처분이다. 따라서 행정청의 거부 처분이나 부작위위법확인소송의 대상인 부작위에 대해서는 정지할 효력이나 집행이 존재하지 않으므로 집행정지를 신청할 수 없다. 거부 처분 취소소송에서 원고가 본안에서 승소하더라도 판결 확정 시까지 행정청의 응답이나 새로운 처분을 강제할 수 없어 발생하는 실질적인 피해는 집행정지로 구제할 수 없다.

3. 공정력 자체가 문제 되지 않는 다툼에서는 미적용

- 집행정지는 행정처분의 공정력과 집행력 유지를 전제로 하는 특례이므로, 공정력 자체가 문제 되지 않는 공법상 계약이나 기타 공법상 법률 관계의 다툼에 대해서는 적용되지 않는다. 이러한 행정소송법상 가구제 수단의 미비는 행정 구제의 공백을 발생시키며, 이를 해소하기 위해 민사집행법상의 가처분 규정을 활용할 필요성이 제기된다.

III. 항고소송에서의 가처분 인정 여부

1. 학설

- 항고소송(취소소송)에서의 가처분 인정 여부에 대하여는 학설이 대립한다.

(1) 부정설

- 부정설은 행정소송법이 집행정지라는 항고소송의 특수성을 반영한 특별 규정을 이미 마련하고 있으므로, 집행정지 이외의 민사 가처분을 보충적으로 적용하는 것은 허용되지 않는다고 주장한다. 특히 가처분이 행정청에 작위 의무를 부과하거나 행정처분의 공정력을 본질적으로 훼손할 위험이 있다는 점을 주요 근거로 든다. 이는 행정의 안정성과 합목적성 유지를 중시하는 입장이다.

(2) 긍정설

- 긍정설은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법이 준용되므로, 집행정지가 포괄하지 못하는 영역(거부 처분이나 부작위 등)에 대해서는 가처분을 보충적으로 적용하여 원고의 실질적인 권리 구제를 도모해야 한다고 주장한다. 특히 소극적 처분 관련 소송의 실효성 확보를 위해 임시의 지위를 정하는 가처분은 필수적이며, 이는 국민의 재판 청구권과 생존권을 보장하는 측면에서 필요하다고 본다.

(3) 절충설

- 절충설은 집행정지의 대상이 되지 않는 영역(거부 처분이나 부작위)에 대해서는 가처분의 적용을 긍정하되, 이미 집행정지 제도가 마련된 적극적 처분에 대해서는 가처분 적용을 부정하는 입장이다. 이는 행정소송법의 규정을 최대한 존중하면서도 권리 구제의 공백을 메우려는 시도이다.

2. 판례

- 판례는 일관되게 항고소송에서의 가처분 적용을 부정하는 입장이다. 대법원은 행정소송법이 집행 정지에 관하여 행정처분의 공정력과 행정의 안정성을 고려한 특별 규정인 집행정지 제도를 마련하고 있으므로, 행정처분의 효력이나 집행 정지를 구하는 소송에서는 민사집행법상의 가처분 규정을 준용할 수 없다고 판시하고 있다. 즉, 집행정지 규정을 민사 가처분 규정의 특별 규정으로 보아 그 적용을 배제하는 것이다. 다만, 판례는 최근 거부 처분 취소소송의 경우 실효성 확보를 위한 가처분의 필요성은 인식하고 있으나, 헌법상의 해석론으로는 인정을 유보하는 태도를 유지하고 있다.

3. 검토

- 항고소송에서의 가처분 인정 여부는 행정소송의 실효성 확보라는 권리 구제 측면과 행정의 법적 안정성 유지라는 공익적 측면이 충돌하는 지점이다. 현행 행정소송법의 명문 규정은 집행정지 외의 가처분을 인정하고 있지 않으며, 이미 처분 취소를 전제로 하는 집행정지 제도가 마련되어 있다는 점에서 판례의 부정설은 해석론상 타당성을 가진다. 그러나 거부 처분 취소소송과 같이 집행정지로 구제될 수 없는 영역에 대해서는 원고가 장기간 권리 구제를 받지 못하여 심각한 피해를 입을 수 있으므로, 입법적인 개선이 절실하다. 해석론적으로는 집행정지의 대상이 될 수 없는 소극적 처분등에 한정하여 임시 지위를 정하는 가처분을 보충적으로 인정하는 절충설이 권리 구제에 보다 적합하다고 판단된다.

IV. 당사자소송에서의 가처분

- 당사자소송이라 함은 행정청의 처분등을 직접 다투는 것이 아니라, 공법상의 법률 관계에 대하여 그 한 쪽 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송을 말한다. 당사자소송은 공법적 법률 관계를 다투는 점에서 항고소송과 유사하지만, 처분의 효력을 다투는 것이 아니며, 법률 관계의 다툼이라는 점에서 민사소송과도 유사한 성격을 지닌다. 행정소송법은 당사자소송에 대하여 집행정지 제도를 별도로 규정하고 있지 않다. 이는 집행정지 제도가 공정력을 가진 행정처분을 전제로 한다는 특수성에 기인한다. 따라서 당사자소송의 가구제 수단에 대하여는 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사집행법상의 가처분 규정이 제한 없이 준용된다. 즉, 당사자소송에서는 원고가 본안 청구권의 존재와 보전의 필요성을 소명하면, 법원은 임시의 지위를 정하는 가처분 또는 다툼의 대상에 관한 가처분 등을 허용할 수 있다. 예를 들어 공무원 지위 확인 소송에서의 임시 지위 가처분이나, 공법상 금전 지급을 구하는 소송에서의 다툼의 대상에 대한 가처분 등이 이에 해당한다.

V. 결론

- 항고소송에서의 가처분 인정 여부는 학설의 대립에도 불구하고 판례는 집행정지 규정을 특별 규정으로 보아 가처분 적용을 부정하고 있다. 반면, 당사자소송은 처분의 공정력이 문제 되지 않아 집행정지 제도가 적용될 수 없으므로, 민사집행법상의 가처분 규정이 준용되어 폭넓게 인정된다. 행정소송의 실효성 제고 및 국민의 권리 구제를 위해 행정소송법의 가구제 영역에 대한 입법적 보완, 특히 항고소송에서의 보충적 가처분 인정의 필요성이 매우 크다고 할 수 있다.

<제8장 청구의 병합과 소의 변경.제1절 관련청구소송의 병합·이송>

I. 관련청구소송의 병합

1. 의의

- 관련청구소송의 병합이란 행정소송에 관련된 민사소송이나 다른 행정소송을 함께 심리하고 재판하기 위해 하나의 소송 절차에 결합시키는 제도를 말한다. 이 제도는 당해 처분등과 관련된 청구를 하나의 법원에서 일괄하여 심리하도록 함으로써 소송 절차의 중복을 피하고, 심리 절차를 간편하게 하며, 재판의 모순 저축을 방지하여 당사자의 권리 구제를 실효성 있게 도모하는 데 그 취지가 있다. 주로 행정소송인 취소소송에 그 처분을 전제로 하는 손해배상 청구 등 민사소송을 병합하는 경우가 가장 일반적이다.

2. 관련청구소송의 범위

- 행정소송법 제10조 제1항은 취소소송에 병합할 수 있는 관련청구소송의 범위를 다음과 같이 규정한다.

(1) 당해 처분등과 관련되는 손해배상·부당이득반환·원상회복 등 청구소송

- 이 청구들은 행정처분 등의 위법을 선결 문제로 하는 경우가 많으며, 해당 처분의 취소 여부에 따라 청구의 인용 여부가 결정되므로 주된 취소소송과의 관련성이 높다. 예를 들어 위법한 과세처분 취소소송과 그 처분으로 납부한 세금에 대한 부당이득반환청구소송의 병합을 들 수 있다. 이러한 병합은 심리 범위를 한정하여 소송의 신속한 심판을 도모하려는 취지도 갖는다.

(2) 당해 처분등과 관련되는 취소소송

- 이는 동일한 처분등을 둘러싸고 여러 개의 취소소송이 제기된 경우뿐만 아니라, 동일한 법률관계나 사실관계에 기초한 처분등에 대한 여러 취소소송 상호 간의 병합도 포함한다.

3. 병합의 종류

- 행정소송에서 관련청구소송의 병합은 민사소송법상의 청구 병합 규정을 준용하며, 그 형태는 다음과 같이 구분할 수 있다.

(1) 단순 병합

- 주된 청구와 관련 청구가 독립적으로 병존하며, 법원이 그 모두에 대하여 심리하고 재판하는 형태이다. 두 청구 모두 인용되거나 기각될 가능성이 있다. 단순 병합은 상호 관련성의 유무를 불문하고 당사자만 동일하면 허용된다.

(2) 선택적 병합

- 원고가 주된 청구와 관련 청구 중 어느 하나를 선택적으로 구하는 경우이다. 법원은 두 청구 중 어느 하나를 인용할 수 있다. 논리적으로 관계가 없는 청구들을 선택적 또는 예비적 청구로 병합하여 청구하는 것은 원칙적으로 부적법하다는 것이 판례의 입장이지만, 청구 사이의 관련성을 파악하여 논리적 관련성이 짙은 경우에는 부진정 예비적 병합의 법리를 적용할 여지도 있다는 논의가 있다.

(3) 예비적 병합

- 원고가 주된 청구의 인용을 구할 것을 1차적 희망으로 하고, 그것이 받아들여지지 않을 경우를 대비하여 2차적으로 관련 청구의 인용을 구하는 형태이다. 행정소송에서 가장 흔히 볼 수 있으며, 주된 행정소송(취소소송)이 기각될 경우를 대비하여 관련 민사소송(부당이득반환청구)을 병합하는 경우가 대표적이다.

4. 요건

- 관련청구소송을 병합하기 위한 요건은 다음과 같다.

(1) 주된 청구가 적법하게 계속 중일 것

- 관련청구소송의 병합은 주된 행정소송(주로 취소소송)이 적법하게 제기되어 법원에 계속 중인 것을 전제로 한다.

(2) 관련성 요건 충족

- 병합하고자 하는 청구가 당해 처분등과 관련되는 것이어야 하며, 이 관련성은 행정소송법 제10조 제1항 각호의 범위 내에 속해야 한다. 이는 청구의 내용이나 발생 원인이 주된 처분등과 법률상 또는 사실상 공통되거나, 처분의 효력이나 존부가 선결문제로 되는 관계에 있어야 함을 의미한다.

(3) 사실심 변론종결시까지 병합 제기

- 관련청구소송은 사실심 법원의 변론종결시까지 병합하여 제기할 수 있으며, 이는 소송 계속 중인 법원에 추가하여 병합하는 후발적 병합과 최초 소 제기 시부터 함께 하는 원시적 병합을 모두 포함한다.

(4) 피고의 동일성 불요

- 관련청구소송은 주된 청구소송의 피고가 아닌 다른 자를 상대로 한 것이라도 취소소송이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다. 예를 들어 행정청을 피고로 하는 취소소송에 국가 또는 공공단체를 피고로 하는 국가배상청구소송을 병합하는 경우가 이에 해당한다.

5. 병합요건의 조사

- 병합요건은 소송요건으로서 법원의 직권조사사항이다. 법원은 관련청구소송이 병합된 경우 그 병합이 적법한 요건을 갖추었는지 직권으로 조사한다. 주된 청구소송이 부적법하여 각하되는 경우, 그에 병합된 관련청구소송의 운명에 대하여 견해가 대립한다. 판례는 원칙적으로 주된 청구소송이 부적법하여 각하되면 그에 병합된 관련청구소송도 병합 요건을 흠결하여 부적법하므로 함께 각하되어야 한다는 입장을 취한다. 다만, 관련청구소송이 독립하여 적법한 요건을 갖추고 있다면 이를 별개의 소송으로 분리 심판하거나 관할 법원으로 이송하는 것이 소송 경제 측면에서 바람직하다는 견해도 있다.

6. 병합된 관련청구소송의 판결

- 병합된 관련청구소송에 대하여 법원은 주된 청구와 관련 청구를 하나의 절차에서 심리하여 하나의 종국 판결로써 동시에 재판한다. 관련청구소송이 민사소송인 경우에도 행정소송이 계속된 법원이 이를 함께 심리하고 판결하게 되며, 이 경우 병합된 민사소송에는 그 본질이 행정소송으로 변하는 것은 아니므로 민사소송법이 적용되어야 할 것이다. 특히 처분의 취소를 전제로 하는 부당이득반환 청구가 취소소송에 병합된 경우, 해당 부당이득반환 청구가 인용되기 위해서는 그 소송 절차에서 판결에 의해 당해 처분이 취소되면 충분하고, 그 처분의 취소가 확정되어야 하는 것은 아니라는 것이 판례의 태도이다.

II. 관련청구소송의 이송

1. 의의[행소법 제10조 제1항]

- 관련청구소송의 이송이란 취소소송과 관련청구소송이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우, 관련청구소송이 계속된 법원의 재판에 따라 그 사건을 취소소송이 계속된 법원으로 이전하는 것을 말한다. 행정소송법 제10조 제1항은 취소소송과 관련청구소송이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우에 관련청구소송이 계속된 법원이 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 이를 취소소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있다.고 규정하고 있다. 이는 소송 경제와 재판의 통일을 위한 제도적 장치이다.

2. 이송의 요건

- 이송이 허용되기 위한 요건은 다음과 같다.

(1) 취소소송과 관련청구소송이 각각 다른 법원에 계속되어 있을 것

- 두 소송이 이미 별개의 법원에 제기되어 진행 중인 상태여야 한다.

(2) 관련청구소송이 계속된 법원이 이송을 상당하다고 인정할 것

- 법원은 심리의 중복 방지, 재판의 모순 저축 방지 등 이송의 필요성을 종합적으로 고려하여 판단한다. 이송은 법원의 재량에 따른 임의적 이송이며, 관할 위반을 이유로 하는 민사소송법상 의무적 이송과는 구별된다.

(3) 이송은 취소소송이 계속된 법원으로 할 것

- 이송은 소송 집중의 원칙에 따라 관련청구소송을 취소소송이 계속된 법원으로 행하는 것이 원칙이다. 이송을 받은 법원은 원래 그 관련청구소송에 대한 관할권이 없더라도 행정소송법 제10조 제1항에 따라 관할권을 갖게 된다.

3. 이송의 효과

- 이송 결정이 확정되면 다음과 같은 효과가 발생하며, 이는 민사소송법 규정의 준용을 통해 나타난다.

(1) 법원의 구속력

- 이송 결정이 확정되면 이송받은 법원은 이송 결정에 따라야 하며, 그 사건을 다시 다른 법원에 이송하지 못한다. 이를 이송 결정의 기속력이라고 한다. 이 기속력은 반복되는 이송으로 인한 본안의 심리 지연을 막기 위함이며, 원칙적으로 전속관할 규정을 위반하여 이송한 경우에도 미친다. 다만, 심급 관할 위반의 경우 상급심에는 미치지 않아 당사자의 심급의 이익을 보장한다.

(2) 소송 계속의 이전

- 이송 결정이 확정된 때에는 소송은 처음부터 이송받은 법원에 계속된 것으로 본다. 따라서 소 제기에 의한 시효 중단이나 기간 준수의 효력은 이송 결정 시점이 아니라 소송이 최초 제기된 때로 소급하여 유지된다.

(3) 절차의 속행

- 이송받은 법원은 이미 진행된 소송 절차를 그대로 승계하여 심리를 속행한다.

4. 불복

- 이송 결정 및 이송 신청을 기각하는 결정에 대하여 당사자는 즉시항고를 할 수 있다. 이는 이송 결정이 소송의 계속을 변경하는 중요한 결정이므로, 당사자에게 불복의 기회를 주어 결정의 신중성을 기하기 위함이다.

Ⅲ. 결론

- 관련청구소송의 병합 및 이송 제도는 행정소송 절차에서 심리의 중복과 재판의 모순 저축을 회피하고, 행정처분을 둘러싼 모든 법률관계를 하나의 법원에서 집중적으로 해결함으로써 소송 경제를 도모하고 당사자의 실질적 권리 구제를 강화하는 데 그 목적이 있다. 병합은 원고의 소송상 선택을 통해, 이송은 법원의 재량적 판단을 통해 소송의 효율성을 높이는 중요한 행정소송법상의 제도이다.

<제8장 청구의 병합과 소의 변경.제2절 소의 변경>

I. 소의 변경의 의의

1. 개념

- 소의 변경이란 소송 계속 중 원고가 청구의 기초를 동일하게 유지하면서 종래의 청구 즉 구소(舊訴)를 새로운 청구 즉 신소(新訴)로 교환하거나 추가하는 행위를 말한다. 행정소송에서는 행정소송법 제21조·제22조의 특별 규정과 함께, 특별한 규정이 없는 경우 민사소송법 제262조의 일반 규정을 준용하여 이루어진다. 이 제도는 소송 절차의 중복을 피하고 원고의 권리 구제를 실질적으로 보장하기 위한 소송법적 기술이다.

2. 취지

- 소의 변경 제도의 주된 취지는 소송 경제의 도모와 원고의 권리 구제 실효성 확보이다. 원고가 소송 과정에서 자신의 청구를 수정하거나 보완할 수 있도록 허용함으로써 심리의 중복을 피하고, 특히 행정소송의 경우 복잡한 소송 종류 중에서 구제 목적에 맞는 소송을 정확하게 선택하는 것이 어려울 때 소 변경을 통해 적절한 구제 기능을 유지하도록 돕는다. 즉, 소송 종류를 잘못 선택한 경우에도 소송 절차를 처음부터 다시 시작할 필요 없이 동일한 소송 계속의 효과를 유지하면서 청구를 바로잡을 수 있게 한다.

II. 「행정소송법」에 의한 소의 변경

1. 소송 종류 변경을 위한 소의 변경[행소법 제21조]

(1) 정의

- 소송 종류 변경을 위한 소의 변경은 취소소송을 당사자소송 또는 취소소송 외의 항고소송(무효등 확인소송, 부작위위법확인소송)으로 변경하는 것을 원고의 신청에 의해 법원의 허가를 받아 허용하는 제도이다.

(2) 내용 및 요건

- 이 제도는 행정소송 종류 간에 청구의 기초의 동일성을 전제로 하여 소의 변경을 통해 행정구제 기능을 강화하려는 행정소송법의 특칙이다. 소의 변경을 위해서는 청구의 기초에 변경이 없어야 하고, 사실심의 변론종결 시까지 신청해야 하며, 법원이 소 변경이 상당하다고 인정하여 허가를 해야 한다. 또한, 변경되는 신소는 제소기간 등 적법한 제소 요건을 갖추어야 하는데, 법원은 허가 결정을 할 때 구소가 제기된 때에 신소가 제기된 것으로 보아 제소기간 준수 여부를 판단한다. 피고를 달리하게 될 때에는 새로이 피고로 될 자의 의견을 들어야 한다.

(3) 효과

- 소의 변경이 허가되면 구소는 취하되고 신소가 그 자리를 차지하게 되며, 소송은 구소가 제기된 때에 신소가 제기된 것으로 보아 소송 계속의 효과가 소급하여 발생한다.

2. 처분변경으로 인한 소의 변경[행소법 제22조]

(1) 정의

- 처분변경으로 인한 소의 변경은 소송의 대상인 처분이 소 제기 후 행정청에 의해 변경된 경우, 원고가 변경된 처분을 대상으로 청구의 취지 또는 원인의 변경을 신청하여 법원의 허가를 받는 제도이다.

(2) 취지 및 요건

- 이 제도는 행정청의 처분 변경에 대응하여 원고가 다시 새로운 처분에 대해 소를 제기해야 하는 번거로움을 피하고, 새로운 처분에 대한 제소기간 준수의 어려움을 해소하여 원고를 보호하려는 취지에서 마련되었다. 원고는 처분의 변경이 있음을 안 날로부터 60일 이내에 소의 변경을 신청해야 한다. 다만, 변경되는 청구는 종전 처분에 대한 취소소송의 제기로서 행정심판을 거치지 아니하고 제기된 경우의 요건을 갖춘 것으로 본다.

(3) 효과

- 이 소 변경이 허가되면 소송 계속의 효과는 처분이 변경된 시점이 아니라 당초 소를 제기한 때로 소급하며, 변경된 처분에 대한 소송 절차를 계속하여 진행할 수 있다.

III. 「민사소송법」에 의한 소의 변경

1. 문제점

- 행정소송법 제8조 제2항은 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 민사소송법의 규정을 준용하도록 규정하고 있다. 따라서 민사소송법 제262조가 규정하는 청구의 교환적 또는 추가적 변경이 행정소송에도 준용되는지 문제가 된다. 특히 항고소송과 민사소송 간의 교환적 소 변경을 허용할 수 있는지 여부가 학설 및 판례상 주된 쟁점이 된다. 행정소송법 제21조가 항고소송 간 또는 항고소송과 당사자소송 간의 변경만을 특별히 규정하고 있기 때문이다.

2. 학설

- 항고소송과 민사소송 간의 교환적 소 변경 허용 여부에 대하여 학설은 다음과 같이 대립한다.

(1) 긍정설

- 행정구제의 확대와 원고의 소송 경제 측면을 고려하여, 청구의 기초의 동일성이 인정되는 한 민사소송법 제262조를 준용하여 항고소송과 민사소송 간의 교환적 변경도 허용해야 한다는 견해이다. 소 변경은 당사자의 권리 구제를 위한 보충적인 수단이므로 폭넓게 인정해야 한다는 논리이다.

(2) 부정설

- 행정소송과 민사소송은 공법 관계와 사법 관계를 그 대상으로 하며 소송 구조가 본질적으로 다르다는 점을 강조한다. 행정소송법 제21조가 소송 종류 변경을 특별히 규정한 것은 이에 한정되어야 하며, 민사소송법상의 일반 규정을 준용하여 소송의 종류 자체를 바꾸는 것은 허용되지 않는다는 견해이다. 이는 공법 관계의 특수성을 유지하려는 관점에 기초한다.

3. 판례

- 판례는 행정소송으로 제기해야 할 청구를 민사소송으로 잘못 제기하였다가 이후 행정소송(항고소송)으로 소 변경을 한 경우, 항고소송의 제소기간 준수 여부는 처음 소를 제기한 때를 기준으로 판단해야 한다고 보아 원고에게 유리한 입장을 취한다. 이는 오제기(誤提起)된 민사소송을 관할 법원으로 이송한 뒤 소 변경이 이루어진 사안에서 나타난 태도로, 원칙적으로 항고소송을 민사소송으로 변경하는 것이 허용되는지에 대한 명시적인 판단이라기보다는, 행정구제의 실효성 확보라는 행정소송의 특수성을 고려하여 오제기된 경우에 한하여 절차적 편의를 제공한 것으로 해석된다. 따라서 항고소송과 민사소송 간의 단순 교환적 소 변경은 여전히 제한적으로 해석될 여지가 크다.

4. 검토

- 행정소송법 제21조와 제22조가 소의 변경에 관한 특별 규정이므로, 이에 해당하지 않는 소 변경에 대해서는 민사소송법 제262조가 준용될 여지가 있다. 그러나 항고소송과 민사소송 간의 교환적 변경은 소송의 본질적 차이로 인해 원칙적으로는 부정설의 입장에서 제한적으로 해석함이 타당하다. 다

만, 판례의 태도처럼 소송경제와 행정구제 실효성 확보를 위해 오제기의 경우에 한해 예외적으로 구소 제기 시점을 기준으로 제소기간 준수 여부를 판단하는 등 유연한 해석이 필요하다. 이는 소의 변경 제도가 가지는 권리 구제 기능을 행정소송에서 극대화하려는 합리적인 노력으로 평가할 수 있다.

IV 결론

- 소의 변경은 행정소송에서 원고의 권리 구제를 실질적으로 보장하고 소송 경제를 도모하는 핵심적인 제도이다. 행정소송법은 소송 종류의 변경(제21조)과 처분 변경에 대한 대응(제22조)에 관한 특별 규정을 두어 행정소송의 특수성을 반영하고 있다. 특별 규정이 없는 경우 민사소송법이 준용되지만, 항고소송과 민사소송 간의 교환적 변경은 소송 본질의 차이로 인해 제한적으로 해석되는 것이 일반적이다. 법원은 소 변경 제도를 통해 제소기간 준수 문제 등을 해결함으로써 행정소송의 구제 기능을 강화하는 방향으로 제도를 운용한다.

<제9장 무효등 확인소송.제1절 무효등 확인소송의 의의>

I. 개념[행소법 제4조 제2호]

- 무효등 확인소송이란 행정청의 처분등(재결 포함)의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송을 말한다. 행정소송법 제4조 제2호는 항고소송의 한 종류로서 무효등 확인소송을 명시한다. 여기서 무효등은 해당 처분등에 중대하고 명백한 하자가 있어 처음부터 법적 효력이 발생하지 않았음을 확인하는 무효 확인을 핵심으로 하면서, 처분의 유효 확인, 부존재 확인, 실효 확인 등 처분등의 효력 또는 존재와 관련된 모든 확인 소송을 포괄하는 개념이다. 이 소송은 법적으로 불명확한 상태에 놓여 있는 처분등의 법적 상태를 재판을 통해 명확히 함으로써, 그 처분을 둘러싼 법률관계의 불안정성을 제거하고 국민의 권리 또는 법률상의 이익을 보호하는 것을 목적으로 한다. 처분의 효력 자체를 다투는 점에서 위법한 처분의 취소를 구하는 취소소송과는 구별되는 독자적인 소송 유형이다.

II. 종류

- 무효등 확인소송은 확인을 구하는 대상 및 내용에 따라 그 종류를 구별할 수 있다.

1. 무효확인소송

(1) 의의와 성격

- 무효확인소송은 행정처분등에 중대하고 명백한 하자가 존재하여 처음부터 법적 효력(공정력)이 발생하지 않았음을 확인하는 소송이다. 이는 행정행위의 하자가 취소 사유에 그치는 경우(위법하지만 일단 유효)와 달리, 행정행위가 아예 권한을 넘어서거나 절차상 본질적인 하자를 포함하여 법적 존재 자체가 부정되는 경우에 제기된다. 무효인 처분은 법적으로 누구에게나 효력이 없으나, 재판을 통해 그 무효임을 공적으로 확인받아 공적인 증명력을 부여하고 법률관계의 불확실성을 완전히 해소하기 위해 제기된다.

(2) 취소소송과의 관계

- 무효확인소송과 취소소송은 모두 행정행위의 위법성을 다투는 항고소송이라는 점에서 공통점을 가진다. 그러나 양자는 처분의 하자의 정도와 소송 요건에서 중대한 차이가 있다. 취소소송은 제소기간의 제한을 받고(안 날로부터 90일, 있은 날로부터 1년), 행정심판 전치주의가 적용될 수 있으나, 무효확인소송은 그 처분의 효력이 처음부터 없으므로 제소기간의 제한을 받지 않으며, 행정심판 전치주의도 적용되지 않는다. 판례는 이 두 소송을 병렬 관계로 보아, 원고가 소송 요건을 충족하는 한 목적을 가장 효과적으로 달성할 수 있는 항고소송의 종류를 선택할 수 있다고 본다.

2. 유효·부존재·실효확인소송

(1) 유효확인소송

- 유효확인소송은 이미 발생한 행정처분등의 효력이 유효함을 확인하는 소송이다. 이는 처분의 효력에 대하여 다툼이 있어 무효의 위험이 존재하는 경우, 그 법적 불확실성을 제거하고 처분의 공정력과 집행력을 확고히 하기 위해 제기되며, 주로 처분의 효력을 주장하는 이해관계인이나 행정청 자신이 제기한다.

(2) 부존재확인소송

- 부존재확인소송은 행정청의 행위가 외형상 존재하는 것처럼 보일지라도, 행정행위로서의 성립 요건을 갖추지 못하여 아예 행정처분 자체가 성립되지 않았음을 확인하는 소송이다. 이는 처분등에 대한 오인으로 인한 법률관계의 불안을 해소한다.

(3) 실효확인소송

- 실효확인소송은 이미 유효하게 성립한 처분등의 효력이 특정한 사유(법령의 폐지, 부관의 성취, 적법한 철회 등)로 인해 장래를 향하여 소멸하였음을 확인하는 소송이다. 이는 처분의 효력이 소멸한 시점 이후의 법률관계의 안정성을 확보하는 데 그 필요성이 있다.

III. 필요성

- 무효등 확인소송은 행정소송의 기능, 특히 국민의 권리 구제 측면에서 다음과 같은 필수적인 기능을 수행한다.

1. 권리 구제의 실효성 확보

- 무효등 확인소송, 특히 무효확인소송은 취소소송의 제소기간 제한을 극복하여 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장한다. 처분의 무효는 시간의 경과로도 치유되지 않으므로, 제소기간이 도과된 후에도 언제든지 무효확인소송을 제기할 수 있어 국민의 쟁송 기회를 항구적으로 보장한다. 이는 행정의 위법성 통제를 영구적으로 유지하여 행정의 적법성을 확보하게 한다.

2. 공정력 통제의 최종 수단

- 행정행위의 하자는 정도에 따라 무효 사유(중대하고 명백한 하자)와 취소 사유(중대하고 명백하지 않은 하자)로 나뉜다. 무효확인소송은 공정력이 미치지 않는 당면 무효인 처분을 대상으로 하여, 법적 불안정을 해소하는 사법 통제의 최종적인 수단이 된다. 비록 무효인 처분은 법적으로 효력이 없으나, 이해관계가 얽힌 복잡한 법률관계에서 법원의 공적 확인을 받지 못하면 제3자나 후행 행정청과의 분쟁이 계속될 수 있으므로, 소송을 통한 확인은 법적 안정성을 위해 필수적이다.

3. 확인의 소의 보충성 배제

- 민사소송법상 일반적인 확인의 소는 다른 직접적인 구제 수단(이행 소송)이 없는 경우에만 인정되는 보충성이 요구된다. 그러나 행정소송법 제35조에 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부의 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정하고 있으며, 이와 별도로 보충성이 요구되지 않는다는 것이 판례의 확립된 태도이다. 이는 무효확인판결 자체에 취소판결의 기속력에 관한 규정이 준용됨으로써 판결의 실효성이 확보되고, 무효확인소송이 취소소송을 보충하는 기능을 수행할 수 있기 때문이다. 따라서 이행 소송 등 직접적인 구제 수단이 존재하는 경우에도 무효확인소송을 제기할 수 있어 국민의 구제 경로를 넓힌다.

IV. 결론

- 무효등 확인소송은 행정처분등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 항고소송의 한 종류이다. 이 소송은 중대하고 명백한 하자가 있는 처분을 대상으로 하여 취소소송의 제소기간 제한을 극복하고, 법률관계의 불안정성을 공적으로 해소함으로써 국민의 쟁송 기회와 권리 구제의 실효성을 최대한으로 보장하는 데 그 핵심적 필요성이 있다. 특히 판례가 확인 소송의 보충성을 요구하지 않는 태도를 취함으로써, 무효등 확인소송은 행정의 위법성을 통제하고 국민의 권익을 보호하는 데 있어 중요한 최종적인 사법적 수단으로 확고히 기능한다.

<제9장 무효등 확인소송.제2절 무효등 확인소송의 요건>

I. 대상적격

- 무효등 확인소송의 대상적격은 행정소송법 제38조 제1항이 취소소송의 대상적격에 관한 규정인 제19조를 준용함으로써 정해진다. 즉, 무효등 확인소송의 대상은 행정청의 처분 또는 재결이다.

1. 처분

- 처분이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다. 처분성이 인정되어야 무효등 확인소송의 대상이 될 수 있으며, 법규적 성격을 가지는 행정입법이나 단순한 사실행위 등은 원칙적으로 대상이 될 수 없다.

2. 재결

- 재결이란 행정심판의 심리 결과에 따라 행정심판위원회가 행하는 판단이다. 재결 자체에 고유하고 위법한 하자가 있는 경우에 한하여 무효확인을 구할 수 있다.

3. 처분의 존재

- 무효등 확인소송은 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송이므로, 그 확인을 구하는 대상인 처분등은 외형상 존재해야 한다. 다만, 부존재확인소송의 경우처럼 외형상 존재는 하나 법적으로 처분의 요건을 갖추지 못하여 처음부터 행정행위로서 성립하지 않은 경우도 대상이 될 수 있다.

II. 당사자적격

- 당사자적격은 무효등 확인소송을 제기할 수 있는 당사자(원고 및 피고)의 자격을 말하며, 권리보호의 필요성 및 참가인에 관한 요건도 포함된다.

1. 원고적격

- 원고적격은 행정소송법 제35조에 독자적으로 규정되어 있다. 원고적격은 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자를 의미한다.

(1) 법률상 이익이 있는 자의 의미

- 법률상 이익이 있는 자는 취소소송의 원고적격(제12조)과 마찬가지로, 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 침해당한 자를 의미한다. 단순히 사실상의 이익이나 간접적인 경제적 이해관계만으로는 부족하다.

(2) 제3자의 원고적격

- 처분의 직접 상대방이 아니더라도, 그 처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당하거나 침해될 우려가 있는 제3자에게도 무효등 확인을 구할 법률상 이익이 인정되는 경우 원고적격이 인정된다.

2. 피고적격

- 피고적격은 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 제13조가 준용된다.

(1) 원칙

- 소송의 대상인 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다. 이때 행정청은 처분 당시의 행정청을 의미한다.

(2) 예외

- 처분등을 행한 행정청이 없게 된 때에는 그 처분등에 관한 사무가 귀속되는 국가 또는 공공단체를 피고로 한다.

3. 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)

- 권리보호의 필요성이란, 소송을 통해 원고가 주장하는 권리 또는 법률관계의 현존하는 불안정성을 제거하고 법적 안정을 기하는 데 소송 제기가 가장 유효하고 적절한 수단일 때 인정되는 요건이다. 무효등 확인소송에서는 이를 확인의 이익이라는 형태로 표현한다.

(1) 보충성 배제(판례)

- 민사소송상 확인의 소는 다른 직접적인 구제 수단(이행 소송)이 있는 경우 보충성이 요구된다. 그러나 무효등 확인소송에 대해서 대법원 전원합의체 판결은 무효확인소송의 보충성을 요구하지 않는다고 판시한다. 이는 무효확인판결의 실효성(기속력 등)이 취소판결에 준하여 인정되기 때문이며, 이행 소송 등 직접적인 구제 수단이 있는 경우에도 무효확인소송을 제기할 수 있어 국민의 구제 경로를 넓힌다.

(2) 확인의 이익

- 따라서 무효등 확인소송에서는 법률상 이익이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 권리보호의 필요성(확인의 이익)은 충족된 것으로 본다. 처분의 무효가 확인될 경우 그로 인해 법률관계의 불안정성이 해소되고 원고의 지위가 안정되는지 여부가 핵심이다.

4. 참가인(행소법 제38조 제1항)

- 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 참가인에 관한 규정인 제16조(제3자의 소송참가)와 제17조(행정청의 소송참가)가 준용된다.

(1) 제3자의 소송참가

- 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 있을 때 법원은 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권으로 제3자를 소송에 참가시키거나 의견을 진술하게 할 수 있다. 무효확인소송의 판결은 제3자에게도 효력이 미치므로 제3자의 참가는 중요하다.

(2) 행정청의 소송참가

- 법원은 당사자의 신청 또는 직권으로 다른 행정청을 소송에 참가시키거나 소송에 참가하여 의견을 진술하게 할 수 있다.

III. 기타 요건

- 무효등 확인소송은 취소소송의 절차적 요건 중 일부를 배제한다.

1. 행정심판전치주의 및 제소기간(행소법 제38조 제1항)

(1) 행정심판전치주의

- 행정소송법 제38조 제1항은 취소소송의 전치주의에 관한 제18조를 준용하지 않는다. 따라서 무효등 확인소송에서는 행정심판전치주의가 적용되지 않는다. 무효인 처분은 공정력이 없어 처음부터 효력이 발생하지 않았으므로, 행정심판을 반드시 거치게 할 필요가 없기 때문이다.

(2) 제소기간

- 행정소송법 제38조 제1항은 취소소송의 제소기간에 관한 제20조를 준용하지 않는다. 처분이 무효인 경우에는 시간의 경과에 따라 그 효력이 회복되지 않으므로, 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없어 언제든지 제기할 수 있다.

2. 재판관할(행소법 제38조 제1항, 제9조)

- 재판관할은 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 제9조(관할)가 준용된다.

(1) 원칙

- 피고의 소재지를 관할하는 행정법원에 제기한다.

(2) 예외

- 중앙행정기관 또는 그 장이 피고인 경우, 또는 국가의 사무를 위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 장이 피고인 경우에는 대법원 소재지(서울)의 행정법원에도 제기할 수 있다. 부동산 또는 특정의 장소에 관련된 처분등에 대한 소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에도 제기할 수 있다.

Ⅳ. 결론

- 무효등 확인소송의 요건은 행정소송의 특수성을 반영하여 취소소송의 요건과 차이를 보인다. 대상적격은 처분등으로 동일하나, 권리보호의 필요에서 직접적 구제 수단이 있어도 보충성이 요구되지 않는다는 판례의 태도가 확고하다. 특히 제소기간과 행정심판전치주의가 모두 배제되어 국민의 권리 구제에 있어 취소소송보다 광범위한 기능을 수행하는 것이 무효등 확인소송의 소송 요건상 중요한 특징이다.

<제9장 무효등 확인소송.제3절 무효등 확인소송의 심리>

I. 심리의 기본원칙

- 무효등 확인소송의 심리는 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 심리에 관한 규정(제26조)이 준용된다.

1. 직권심리주의

- 행정소송법 제26조는 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다.라고 규정한다 무효등 확인소송에서도 이 규정이 준용되어 직권심리주의가 적용된다. 이는 행정소송이 공익성을 띠고 있으며, 처분의 위법성 판단이 공익과 관련되므로, 법원이 당사자의 주장에만 얽매이지 않고 실체적 진실을 발견할 의무를 진다는 취지이다. 다만, 직권심리주의가 적용된다고 하여 당사자의 주장 책임이나 입증 책임이 완전히 면제되는 것은 아니며, 이는 법원의 권한이자 의무를 규정한 것으로 해석된다.

2. 구술심리주의 및 공개심리주의

- 무효등 확인소송 또한 다른 항고소송과 마찬가지로 민사소송법의 규정이 준용되어 구술심리주의(변론은 구술로 진행)와 공개심리주의(심리와 판결은 공개)가 원칙으로 적용된다.

II. 주장책임과 입증책임

- 주장책임과 입증책임은 소송에서 당사자의 권리 구제 여부를 결정하는 중요한 요소이다.

1. 주장책임

- 주장책임이란 소송의 당사자가 자기에게 유리한 판결을 얻기 위해 소송 요건이나 청구 원인에 관한 사실을 주장해야 하는 책임을 말한다.

(1) 원고의 주장책임

- 원고는 처분의 위법성을 입증하기 위해 소송 요건과 청구 원인(처분의 무효 사유)에 해당하는 구체적인 사실을 주장해야 한다. 무효확인소송에서는 특히 처분등에 중대하고 명백한 하자가 있음을 구체적으로 주장해야 한다.

(2) 피고의 주장책임

- 피고인 행정청은 자신의 처분이 적법하다는 사실과 청구 원인 이외의 항변 사실을 주장해야 한다. 법원이 직권으로 심리할 수 있다고 하더라도, 당사자는 자신의 주장을 명확히 정리하여 법원에 제출할 의무가 있다.

2. 입증책임

- 입증책임이란 법관이 어떤 사실의 존재 여부를 확신할 수 없을 때, 그 사실의 존부가 불분명함으로 인해 불이익을 받게 되는 당사자가 지는 책임을 말한다.

(1) 원칙

- 행정소송법에 입증책임에 관한 특별한 규정은 없으므로, 민사소송법상의 일반 원칙에 따라 원고가 처분의 위법성을, 피고가 처분의 적법성을 입증해야 한다는 원칙이 적용된다. 즉, 소극적 사실을 주장하는 자가 아니라 적극적 사실을 주장하는 자가 그 사실에 대한 입증책임을 진다. 따라서 처분의 무효 사유(중대하고 명백한 하자)의 존재는 원고가 입증해야 하며, 처분의 적법 사유나 항변 사유는 피고가 입증해야 한다.

(2) 행정소송의 특수성

- 다만, 행정소송에서는 처분 과정에 관한 자료가 대부분 피고인 행정청에 편중되어 있으므로, 단순히 형식적인 입증책임 분배 원칙을 고수할 경우 원고에게 가혹할 수 있다. 따라서 법원은 직권심리주의를 활용하거나 입증책임을 경감하는 방향으로 운영하는 경향이 있다. 예를 들어 피고에게 관련 문서를 제출하게 하거나, 법률 요건을 충족했음을 주장하는 측에 입증책임을 부담하게 하는 등 실질적 평등을 기하려는 노력을 한다.

III. 위법성 판단의 기준시

- 위법성 판단의 기준시란, 법원이 처분의 위법성 유무를 판단할 때 언제 시점을 기준으로 해당 처분의 법적합성을 판단해야 하는지의 문제이다.

1. 문제의 소재

- 취소소송에서는 처분 시를 기준으로 할 것인지, 아니면 사실심 변론종결 시를 기준으로 할 것인지가 주된 쟁점이 된다. 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없어 소송이 장기간 계속될 수 있고, 처분 후에 법령이나 사실 관계의 변경이 있을 수 있으므로 기준시의 설정이 중요하다.

2. 판례의 태도

- 판례는 무효확인소송 역시 취소소송의 법리와 마찬가지로 처분의 위법성 유무는 처분 당시를 기준으로 판단해야 한다고 본다. 처분 시를 기준으로 해야 하는 이유는 다음과 같다.

(1) 법적 안정성 확보

- 행정처분은 처분 시에 이미 그 효력이 발생하거나(취소 사유의 경우), 효력이 발생하지 않았는지(무효 사유의 경우)가 확정되므로, 처분의 위법성을 후행하는 사정으로 평가하는 것은 법적 안정성을 해칠 수 있다.

(2) 항고소송의 특성

- 무효등 확인소송은 행정청의 과거의 위법한 처분 행위를 사후적으로 심사하는 항고소송의 본질을 가지므로, 처분 시에 존재했던 하자를 기준으로 판단하는 것이 타당하다. 즉, 처분 후의 법령이나 사실의 변경은 원칙적으로 고려 대상이 아니다.

IV. 결론

- 무효등 확인소송의 심리는 취소소송의 심리 원칙을 대부분 준용하나, 무효인 처분은 중대하고 명백한 하자에 중점을 둔다는 특성을 가진다. 심리는 직권심리주의와 구술심리주의를 기본 원칙으로 하며, 입증책임은 원칙적으로 위법성을 주장하는 원고에게 있으나 법원은 직권심리를 통해 실질적 공평을 기한다. 또한, 처분의 위법성 판단의 기준이 되는 시점은 소송 계속 중 발생한 사정 변경을 고려하지 않고 처분 당시로 한다.

<제9장 무효등 확인소송.제4절 무효등 확인소송의 종료>

I. 법원의 판결

- 법원의 판결은 소송 요건에 관한 판단인 소송판결과 청구의 당부에 관한 판단인 본안판결로 나뉘며, 무효확인소송에서는 사정판결이 불허된다.

1. 소송판결

(1) 정의

- 소송판결은 소송 요건이 결여되었을 때 본안 심리를 거절하는 형식적인 판결이다.

(2) 각하판결

- 무효등 확인소송의 소송 요건 중 하나라도 결여되면 법원은 각하판결을 내리며 소송은 종료된다. 예를 들어 법률상 이익이 없는 자가 제기한 경우, 처분성이 없는 행위를 대상으로 한 경우 등을 들 수 있다.

2. 본안판결

(1) 정의

- 본안판결은 소송 요건이 모두 충족되었음을 전제로 하여, 원고의 청구가 이유 있는지 여부에 대해 판단하는 실질적인 판결이다.

(2) 인용판결

- 인용판결은 원고의 무효등 확인 청구가 이유 있다고 인정될 때 법원이 내리는 판결이다. 이 판결은 처분등의 효력 부존재(무효) 또는 존재 여부를 공적으로 확정하는 형성적 효력을 가진다. 무효확인소송의 인용판결은 해당 처분등이 중대하고 명백한 하자로 인해 무효임을 선언하는 판결이다.

(3) 기각판결

- 기각판결은 원고의 무효등 확인 청구가 이유 없다고 인정될 때 법원이 내리는 판결이다. 이는 처분등에 원고가 주장하는 무효 사유가 없거나, 하자가 있으나 취소 사유에 불과하여 공정력이 유지되는 경우에 해당한다. 판례는 처분의 하자가 취소 사유에 그치는 경우에도 무효확인 청구를 기각해야 한다는 태도를 취한다.

3. 사정판결

(1) 정의

- 사정판결은 비록 처분이 위법하지만, 인용 판결을 내릴 경우 공공복리에 현저한 영향을 미칠 우려가 있다고 인정될 때 법원이 청구를 기각하는 판결을 말한다. 행정소송법 제38조 제1항은 사정판결에 관한 규정인 제28조를 준용하지 않는다.

(2) 사정판결 불허의 이유

- 무효확인소송에서 사정판결이 허용되지 않는 이유는 다음과 같다. 첫째, 무효인 처분은 처음부터 효력이 없으므로 공정력이 존재하지 않아 사정판결을 통해 그 효력을 유지시킬 법적 근거가 없다. 둘째, 무효인 처분을 공공복리라는 이유로 유효하게 유지시키는 것은 법치주의 원칙에 정면으로 위배되어 하자의 치유를 인정할 수 없기 때문이다. 따라서 무효확인소송에서는 처분에 무효 사유가 인정되면 예외 없이 인용판결을 내려야 한다.

II. 판결의 효력

- 무효등 확인소송의 판결은 확정되면 소송 당사자 및 관계인에게 구속력을 미치며, 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 판결 효력에 관한 규정들이 준용된다.

1. 취소소송규정의 준용[행소법 제38조, 제29조, 제30조]

(1) 기속력[행소법 제38조, 제30조]

- 무효등 확인소송의 인용판결이 확정되면, 그 판결의 기속력에 관한 규정인 제30조가 준용된다. 기속력이란 판결의 내용에 따라 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 동일한 사안에 대해 같은 처분 또는 재결을 반복하거나 판결의 취지에 반하는 행위를 할 수 없도록 구속하는 효력을 말한다. 즉, 무효가 확인된 처분과 동일한 내용의 처분을 다시 할 수 없다.

(2) 제3자효[행소법 제38조, 제29조]

- 무효등 확인소송의 판결은 확정되면 제3자효(대세효)에 관한 규정인 제29조가 준용된다. 이는 판결의 효력이 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 미친다는 것을 의미한다. 무효확인소송의 경우 처분의 무효가 공적으로 확정되므로, 그 처분과 이해관계가 있는 제3자에게도 그 무효의 효력이 미쳐 법률관계의 불안정성을 해소한다.

2. 간접강제 허용 여부

(1) 간접강제의 정의

- 간접강제란 행정청이 판결의 취지에 따른 재처분 의무를 이행하지 않을 때, 법원이 간접적으로 금전적 제재를 가하여 심리적 압박을 가함으로써 그 의무 이행을 강제하는 수단이다. 행정소송법 제38조 제1항은 간접강제에 관한 규정인 제34조를 준용하지 않는다.

(2) 간접강제 불허의 이유★

- 간접강제는 주로 거부처분 취소소송에서 인용판결이 확정되었을 때 그 취지에 따른 재처분 의무의 이행을 확보하기 위해 인정된다. 무효확인소송의 인용판결은 처분의 효력이 처음부터 없었음을 확인하는 것이므로, 피고 행정청에 새롭게 어떤 작위(作爲) 의무(재처분 의무)를 발생시킨다고 보기 어렵다. 따라서 간접강제 규정은 준용되지 않는다고 해석하는 것이 일반적이다. 다만, 무효인 거부처분에 대해 무효확인 판결이 내려진 경우, 판결의 실효성 확보를 위해 간접강제 허용 여부에 대한 학설의 대립이 존재한다.

III. 재심[행소법 제38조, 제31조]

- 재심은 확정된 종국판결에 중대한 하자가 있는 경우 그 판결의 취소를 구하고 사건을 다시 심리하는 비상적인 불복 방법이다.

1. 재심 규정의 준용

- 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 재심 규정인 제31조가 무효등 확인소송에 준용된다.

2. 재심 사유

- 재심 청구는 민사소송법 제451조에 규정된 재심 사유(판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 경우, 당사자를 대리한 법정대리인 또는 소송대리인의 대리권에 흠이 있는 경우 등)가 있는 경우에 한하여 인정된다.

3. 재심 기간

- 재심을 청구할 수 있는 기간은 판결이 확정되었음을 안 날부터 30일 이내, 판결 확정일로부터 1년 이내이다. 이 기간은 불변 기간으로 규정된다.

IV. 결론

- 무효등 확인소송의 종료는 주로 법원의 판결로 이루어지며, 소송 요건 불비 시에는 각하판결로, 청구 이유 인정 시에는 인용판결로 종료된다. 이 소송의 가장 큰 특징은 사정판결이 허용되지 않는다는 점이며, 인용판결의 효력으로서 기속력과 제3자효가 준용된다. 간접강제는 재처분 의무가 발생하지 않는다는 이유로 원칙적으로 준용되지 않으며, 재심 역시 취소소송의 규정이 준용되어 확정판결의 공정성을 담보하는 역할을 한다.

<제9장 무효등 확인소송.제5절 취소소송과의 관계>

I. 문제점

- 취소소송과 무효등 확인소송은 모두 행정청의 처분등의 위법성을 다투는 항고소송이라는 공통점을 가진다. 그러나 취소소송은 취소 사유(하자가 있거나 공정력 인정)를, 무효등 확인소송은 무효 사유(중대하고 명백한 하자, 공정력 불인정)를 대상으로 한다. 이 차이로 인해 다음과 같은 문제들이 발생한다. 첫째, 두 청구를 하나의 소송에서 병합할 수 있는지 여부, 둘째, 처분의 하자 정도를 잘못 판단하여 무효 사유가 있는 처분에 대해 취소소송을 제기하거나, 반대로 취소 사유가 있는 처분에 대해 무효등 확인소송을 제기했을 때 법원이 어떻게 판단해야 하는지 여부 등이 주요 쟁점이다.

II. 취소소송과 무효등 확인소송의 병합

1. 주위적·예비적 청구로만 병합 가능

- 취소소송의 제소기간은 엄격한 제한이 있는 반면, 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없다. 따라서 두 청구를 단순히 합치는 단순 병합을 허용할 경우, 제소기간 제한이 없는 무효등 확인소송을 이용하여 사실상 취소소송의 제소기간을 잠탈하는 결과가 발생할 수 있다. 이에 판례는 두 청구를 주위적 청구와 예비적 청구로만 병합하는 것을 허용한다.

2. 병합형태

(1) 무효등 확인청구를 주위적으로 제기한 경우

- 원고가 무효등 확인청구를 주위적으로 하고, 취소청구를 예비적으로 병합하는 형태이다. 이는 처분의 하자가 무효 사유에 해당한다고 강하게 주장하면서도, 법원이 이를 취소 사유로 판단할 경우에 대비하는 방식이다. 법원은 주위적 청구인 무효등 확인청구에 대해 먼저 심리하고, 이를 기각할 경우에만 예비적 청구인 취소청구를 심리한다. 이 경우 예비적 청구인 취소소송은 제소기간 요건을 충족해야만 본안 심리가 가능하다.

(2) 취소청구를 주위적으로 제기한 경우

- 원고가 취소청구를 주위적으로 하고, 무효등 확인청구를 예비적으로 병합하는 형태이다. 이는 처분의 하자가 취소 사유에 해당한다고 주장하면서도, 법원이 이를 무효 사유로 판단할 경우에 대비하는 방식이다. 법원은 주위적 청구인 취소청구를 먼저 심리하며, 주위적 청구가 기각될 때 예비적 청구인 무효등 확인청구를 심리한다.

III. 무효사유가 있는 처분에 대하여 취소소송을 제기한 경우

- 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 무효 사유에 해당함에도 불구하고, 원고가 착오로 취소소송을 제기한 경우이다.

1. 문제점

- 무효인 처분은 공정력이 없으므로 취소소송의 대상이 될 수 없다는 견해도 존재하지만, 판례는 취소소송의 대상인 처분의 개념을 넓게 해석하여 무효인 처분도 포함될 수 있는지 여부에 대해 다름이 있었다.

2. 판례의 태도

- 판례는 무효 사유가 있는 처분이라도 이를 취소소송의 대상인 처분에 포함된다고 본다. 따라서 법원은 취소소송의 형태로 제기된 소를 적법한 것으로 보아 본안 심리를 진행한다. 다만, 심리 결과 처분이 무효 사유에 해당한다고 판단될 경우, 법원은 취소 판결을 내리는 것이 아니라 무효확인 판결을 내리거나 당원 무효임을 전제로 취소 판결을 내리게 된다. 이는 무효등 확인소송의 판결이 취소소송 판결의 효력 규정을 준용하는 점, 그리고 취소소송의 제소기간 내에 소가 제기되었으므로 원고에게 최대한의 권리 구제 기회를 제공해야 한다는 소송 경제적 관점에서 비롯된 해석이다.

IV. 취소사유가 있는 처분에 대하여 무효등 확인소송을 제기한 경우

- 처분에 취소 사유에 해당하는 위법한 하자가 있음에도 불구하고, 원고가 착오로 무효등 확인소송을 제기한 경우이다.

1. 문제점

- 무효등 확인소송은 무효 사유에 해당하는 처분만을 대상으로 하므로, 법원이 심리 결과 처분의 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단했을 때, 원고의 청구 형태를 그대로 유지하여 기각해야 하는지, 아니면 청구의 변경 등을 통해 취소소송으로 구제해 주어야 하는지가 문제된다.

2. 견해의 대립

(1) 청구 기각설

- 청구 기각설은 무효등 확인소송은 중대하고 명백한 하자를 전제로 하므로, 법원이 심리 결과 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단되면, 원고의 무효 확인 청구는 이유가 없는 것으로 보아 기각 판결을 내려야 한다는 견해이다. 판례는 무효등 확인소송의 심리 결과 취소 사유에 해당하는 하자가 발견된 경우에도 청구를 기각하고, 원고에게 소를 변경하거나 별도로 취소소송을 제기할 것을 요구해야 한다고 본다. 이는 취소소송의 제소기간 제한이라는 엄격한 요건을 무효등 확인소송을 통해 잠탈하는 것을 방지하고, 두 소송의 구별 실익을 유지하려는 취지이다.

(2) 취소소송으로의 전환 허용설 (소 변경 허용)

- 소 변경 허용설은 법원이 직권으로 청구를 취소소송으로 변경할 수 있도록 하거나, 석명권을 행사하여 원고에게 소의 변경을 유도해야 한다는 견해이다. 이는 원고에게 최대한의 권리 구제를 제공해야 한다는 실질적 정의 관념과 소송 경제의 측면을 강조한다. 그러나 이 견해는 취소소송의 제소기간 요건을 무력화시킬 우려가 있다.

(3) 최근 판례

- 과거 판례가 소송 형식에 구애받지 않는 폭넓은 취소판결의 가능성을 열었다면, 최근 판례는 이를 정교화하여 취소소송의 요건을 갖춘 경우라는 제한적 범주 내에서 무효 선언적 의미의 취소판결을 인정하고 있다.

V. 결론

- 취소소송과 무효등 확인소송은 하자의 정도에 따라 구별되지만, 소송상 청구의 병합은 주위적·예비적 병합 형태로만 허용된다. 무효 사유가 있는 처분에 대한 취소소송은 판례가 이를 허용하여 인용 판결을 내릴 수 있도록 하며, 취소 사유가 있는 처분에 대한 무효등 확인소송은 취소소송의 요건을 갖춘 경우라면 무효선언적 의미의 취소판결을 인정한다.

<보충-무효사유와 취소사유의 비교>

I. 행정행위의 하자과 효력의 관계

- 행정행위가 적법하게 성립하기 위해서는 주체, 내용, 절차, 형식의 요건을 모두 갖추어야 한다. 이러한 요건 중 일부를 결여한 경우를 행정행위의 하자라고 하며, 하자의 정도에 따라 당해 행정행위는 무효가 되거나 취소가 가능한 상태가 된다. 무효와 취소의 구별은 행정법 관계의 안정성과 국민의 권리구제라는 두 가지 측면에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 이하에서는 무효사유와 취소사유의 정의, 구별 기준, 그리고 구체적인 효력상의 차이점에 대하여 논한다.

II. 무효사유와 취소사유의 개념

1. 무효사유의 정의

- 행정행위의 하자가 중대하고 명백하여 외관상 행정행위로서 존재함에도 불구하고 처음부터 아무런 효력도 발생하지 않는 경우를 의미한다. 무효인 행정행위는 누구의 주장이나 법원의 판결을 기다릴 필요 없이 당연히 효력이 없는 것으로 간주된다.

2. 취소사유의 정의

- 행정행위에 하자가 있으나 그 하자가 무효가 될 정도로 중대하고 명백하지는 않아, 권한 있는 기관(행정청 또는 법원)에 의해 취소되기 전까지는 유효한 것으로 통용되는 상태를 의미한다. 이는 행정행위의 공정력에 근거한 것으로, 취소권자가 취소권을 행사하면 처분 시로 소급하여 효력을 상실하게 된다.

III. 무효와 취소의 구별 기준

1. 중대·명백설 (다수설 및 판례)

- 행정행위의 하자가 중대하고도 명백한 경우에만 무효로 보아야 한다는 견해이다. 여기서 중대성이란 하자가 행정행위의 중요한 요건을 위반한 것을 의미하며, 명백성이란 하자의 존재가 외관상 누구나 알 수 있을 정도로 분명한 것을 의미한다.

2. 구별의 구체적 판단

- 판례는 하자가 중대하더라도 명백하지 않은 경우에는 취소사유에 불과하다고 판단한다. 이는 행정처분의 유효성을 믿은 제3자의 신뢰를 보호하고 법적 안정성을 유지하기 위함이다. 반면, 하자가 중대하고 명백하여 행정의 일관성을 희생하더라도 그 효력을 부정해야 할 객관적 사정이 있는 경우에는 무효로 파악한다.

IV. 무효와 취소의 효력상 차이점

1. 공정력과 강제력의 인정 여부

- 취소사유가 있는 행정행위는 취소되기 전까지 유효한 것으로 추정되는 공정력을 가진다. 따라서 국민은 그 효력을 부인할 수 없으며 행정청은 이를 근거로 강제집행을 할 수 있다. 반면, 무효인 행정행위는 공정력이 발생하지 않으므로 처음부터 강제력을 행사할 수 없으며, 국민은 이에 따를 의무가 없다.

2. 제소기간의 제한 여부

- 취소소송은 행정소송법상 처분등이 있음을 안 날부터 90일, 있는 날부터 1년이라는 엄격한 제소기간의 제한을 받는다. 그러나 무효등 확인소송은 그 효력이 처음부터 없는 것이므로 시간의 경과에 관계없이 언제든지 제기할 수 있어 제소기간의 제한을 받지 않는다.

3. 행정쟁송의 형태

- 취소사유인 경우에는 취소소송 또는 취소심판을 제기하여야 하나, 무효사유인 경우에는 무효등 확인소송 또는 무효등 확인심판을 제기한다. 다만, 판례는 무효사유인 경우에도 취소소송의 형식으로 다투는 것을 허용하고 있다(무효를 선언하는 의미의 취소판결).

4. 하자의 치유와 전환

- 취소할 수 있는 행정행위는 일정한 요건 하에 하자의 치유(사후적인 요건 보충 등)가 인정될 수 있으나, 무효인 행정행위는 하자의 치유가 인정되지 않는다. 다만, 무효인 행정행위가 다른 행정행위의 요건을 갖춘 경우 다른 행위로 효력을 발생시키는 무효행위의 전환은 논의될 수 있다.

5. 선결문제로서의 효력

- 민사소송이나 형사소송에서 행정행위의 효력이 선결문제가 된 경우, 취소사유인 행정행위는 법원이 스스로 효력을 부인할 수 없으므로 행정소송을 통해 취소되지 않는 한 유효한 것으로 재판의 전제를 삼아야 한다. 그러나 무효인 행정행위는 민·형사법원이 독자적으로 그 효력이 없음을 전제로 판결할 수 있다.

V. 관련 판례를 통한 검토

1. 조세채무 확정 후 법률의 위헌 결정

- 판례는 법률에 근거하여 조세 부과 처분이 내려진 후 그 근거 법률이 위헌으로 결정된 경우, 당해 처분의 하자는 중대하지만 명백하다고 할 수 없으므로 원칙적으로 취소사유에 해당한다고 본다. 법률이 위헌 결정되기 전까지는 법규의 효력이 유효한 것으로 믿는 것이 일반적이기 때문이다.

2. 권한 없는 기관의 행정처분

- 권한 없는 기관의 행한 처분은 주체에 관한 중대한 하자가 있으므로 원칙적으로 무효라는 것이 사법부의 입장이다. 다만, 권한의 위임 등이 존재하여 외관상 권한이 있는 것처럼 보이고 그 유무를 가리는 데 정밀한 조사가 필요한 경우에는 명백성 요건이 결여되어 취소사유로 분류되기도 한다.

3. 절차적 하자의 정도

- 청문 절차를 거치지 않거나 이유 제시를 누락한 것과 같은 절차적 하자는 대개 취소사유로 다루어진다. 다만, 법령에서 정한 필수적 절차를 완전히 무시하여 처분의 정당성을 본질적으로 훼손한 수준에 이르면 무효로 판단될 여지가 있다.

VI. 결론

- 무효사유와 취소사유의 구분은 법적 안정성과 구체적 타당성 사이의 조화를 도모하기 위한 법적 장치이다. 취소사유는 행정행위의 공정력을 인정하여 일단 행정의 원활한 집행을 보장하되 사후적인 교정 기회를 부여하는 것이며, 무효사유는 중대한 오류가 있는 행정권 행사에 대하여 처음부터 법적 구속력을 박탈하는 것이다. 실무적으로는 제소기간의 도과 여부나 사법심사의 범위가 달라지므로, 하자의 정도를 객관적인 기준에 따라 엄격히 판단하는 태도가 요구된다. 국민의 권리 구제 측면에서는 무효를 폭넓게 인정하는 것이 유리할 수 있으나, 행정법 관계의 조속한 확정을 위해서는 중대·명백설의 취지를 존중하며 사안별로 신중한 접근이 필요하다.

<보충-주위적 청구와 예비적 청구의 비교>

I. 소송상의 복수청구와 병합의 의미

- 민사소송이나 행정소송에서 원고는 하나의 소송절차를 통해 여러 개의 청구를 동시에 제기할 수 있다. 이를 청구의 병합이라 하며, 분쟁을 일거에 해결하여 소송경제를 도모하고 판결의 모순과 저촉을 방지하는 데 목적이 있다. 병합의 형태 중 주위적 청구와 예비적 청구는 청구 간에 순위를 두어 심판을 구하는 독특한 구조를 가진다. 이하에서는 주위적 청구와 예비적 청구의 정의, 성립 요건, 심리 방식 및 판결의 효력에 대하여 구체적으로 논한다.

II. 주위적 청구와 예비적 청구의 개념

I. 주위적 청구의 정의

- 주위적 청구란 원고가 소송을 통해 제1차적으로 심판을 구하는 청구를 의미한다. 원고가 가장 우선적으로 인용되기를 희망하는 청구로서, 병합된 청구들 중 심리의 시작점이 된다. 주위적 청구가 인용되면 원고의 목적이 달성된 것으로 보아 후순위 청구에 대한 심리는 필요하지 않게 된다.

II. 예비적 청구의 정의

- 예비적 청구란 주위적 청구가 법원에서 기각되거나 각하될 경우를 대비하여 제2차적으로 심판을 구하는 청구를 의미한다. 즉, 주위적 청구가 받아들여지지 않았을 때 비로소 심리해 달라는 조건부 청구의 성격을 가진다. 이는 원고가 주위적 청구의 승소 가능성에 확신이 없을 때, 차선책으로서의 권리구제를 도모하기 위해 제기한다.

III. 예비적 병합의 성립 요건과 허용 범위

1. 청구 간의 양립 불가능성

- 예비적 병합은 원칙적으로 주위적 청구와 예비적 청구가 서로 양립할 수 없는 관계에 있을 때 제기한다. 예를 들어 계약이 유효함을 전제로 한 이행 청구(주위적)와 계약이 무효임을 전제로 한 원상회복청구(예비적)는 동시에 인용될 수 없으므로 예비적 병합의 전형적인 대상이 된다. 다만, 최근 판례와 학설은 양립 가능한 청구라 하더라도 원고가 순위를 붙여 병합할 의사가 명확하다면 이를 허용하는 경향이 있다.

2.소송절차의 공통성

- 병합되는 여러 청구는 동일한 종류의 소송절차에 의하여 심리될 수 있어야 하며, 해당 법원에 그 청구들에 대한 관할권이 존재해야 한다. 행정소송법 제10조에 따른 관련 청구의 이송 및 병합 규정은 이러한 절차적 연계성을 보장하는 근거가 된다.

IV. 소송 절차에서의 심리 방식

1. 심리의 순서

- 법원은 원고가 붙인 순위에 구속된다. 따라서 반드시 주위적 청구를 먼저 심리하여야 하며, 주위적 청구가 인용될 수 있음에도 불구하고 이를 무시하고 예비적 청구를 먼저 인용하는 것은 허용되지 않는다. 만약 주위적 청구가 인용된다면 예비적 청구는 심리할 필요가 없는 부적정 조건이 되어 심판 대상에서 제외된다.

2. 주위적 청구 기각 시의 심리

- 법원이 주위적 청구를 심리한 결과 근거가 없다고 판단하여 기각하거나 소송요건 흠결로 각하하는 경우, 비로소 예비적 청구에 대한 심리를 시작한다. 이때 법원은 예비적 청구의 당부를 판단하여 인용 또는 기각 판결을 내리게 된다.

V. 판결의 형식과 효력

1. 전부인용 및 일부인용의 양태

- 주위적 청구가 인용되는 경우 법원은 주위적 청구에 대해서만 주문에 기재하며, 예비적 청구에 대해서는 별도의 판단을 내리지 않는다. 반면 주위적 청구가 기각되고 예비적 청구가 인용되는 경우에는 주문에 주위적 청구의 기각 사실과 예비적 청구의 인용 사실을 모두 기재하여야 한다.

2. 상소와의 관계

- 주위적 청구가 기각되고 예비적 청구가 인용된 판결에 대하여 피고가 항소한 경우, 상소의 불가분 원칙에 따라 주위적 청구 부분도 함께 상소심으로 이전된다. 항소심 법원은 다시 주위적 청구부터 심리하여야 하며, 만약 항소심에서 주위적 청구가 인용될 수 있다고 판단한다면 제1심 판결을 취소하고 주위적 청구 인용 판결을 내려야 한다.

VI. 행정쟁송에서의 특수성

1. 무효등 확인소송과 취소소송의 병합

- 행정소송에서 가장 빈번하게 나타나는 형태는 주위적으로 처분의 무효등 확인을 구하고, 예비적으로 처분의 취소를 구하는 병합이다. 하자의 정도가 중대명백하여 무효인지를 먼저 따져보고, 만약 무효가 아니라면 취소사유에 해당하는지를 판단해 달라는 취지이다. 판례는 이러한 형태의 병합을 예비적 병합의 전형으로 인정한다.

2. 제소기간 준수 여부

- 예비적으로 취소소송을 병합하는 경우, 주위적 청구인 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없으나 예비적 청구인 취소소송은 제소기간 내에 제기되어야 함이 원칙이다. 다만, 주위적 청구의 제기 시점이 취소소송의 제소기간 내였다면 병합된 예비적 청구 역시 적법한 것으로 간주된다.

VII. 관련 판례를 통한 검토

1. 심판 범위에 관한 판례

- 법원이 주위적 청구를 인용하면서 예비적 청구까지 판단한 경우, 이는 상소심에서 절차적 위법으로 지적될 수 있다. 판례는 주위적 청구가 인용되었음에도 예비적 청구를 판단하는 것은 원고의 의사에 반하며 소송 계속의 범위를 이탈한 것이라고 보고 있다.

2. 예비적 피고 추가의 문제

- 과거에는 청구의 병합뿐만 아니라 피고를 예비적으로 추가하는 것이 허용되지 않았으나, 현재 민사소송법 및 행정소송법 해석상 일정한 요건 하에 예비적 피고 추가가 인정되고 있다. 이는 누구에게 책임이 있는지 불분명한 상황에서 원고가 피고를 선택적으로 지정하여 소송을 제기할 수 있게 함으로써 권리 구제의 범위를 넓힌 것이다.

3. 판단유탈의 문제

- 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대해 판단을 누락한 경우, 이는 판단유탈에 해당하여 상소 사유가 된다. 법원은 원고가 제기한 순위에 따라 모든 청구에 대한 응답을 완료해야 할 의무가 있기 때문이다.

VIII. 결론

- 주위적 청구와 예비적 청구는 원고의 권리 구제를 극대화하기 위한 전략적 소송 형태이다. 주위적 청구는 원고가 지향하는 최우선의 법적 상태를 확정하는 도구이며, 예비적 청구는 법적 불확실성에 대비한 안전장치로서 기능한다. 이러한 병합 청구는 법원으로 하여금 사안의 실체를 다각도에서 검토하게 하여 분쟁의 일회적 해결을 가능케 한다. 실무적으로는 청구 간의 논리적 선후 관계를 명확히 설정하고 각 청구의 요건을 개별적으로 입증하는 태도가 요구된다. 특히 행정소송에서는 하자의 정도에 따른 소송 형태의 병합이 빈번하므로, 무효와 취소의 법리를 주위적·예비적 구조 내에서 조화롭게 배치하는 것이 실효적인 권리 구제의 핵심이 된다.

<제9장 무효등 확인소송.제6절 가구제>

I. 집행정지[행소법 제38조]

1. 준용 여부

- 집행정지란 처분등으로 인해 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위해 그 처분의 효력이나 집행을 잠정적으로 정지시키는 제도를 말한다. 행정소송법 제38조 제1항은 집행정지에 관한 규정인 제23조를 무효등 확인소송에 준용한다고 규정한다. 따라서 무효등 확인소송에서도 집행정지 신청이 가능하다.

2. 요건의 특수성

(1) 본안 청구의 계속 및 적법

- 집행정지 요건 중 본안 청구의 적법성은 무효확인소송의 특성상 그 확인이 용이하다는 점을 제외하고 취소소송과 동일하다.

(2) 회복하기 어려운 손해

- 처분의 집행으로 인해 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어야 한다. 무효인 처분은 처음부터 효력이 없으므로 원칙적으로 집행력도 없으나, 외형상 처분이 존재하는 것처럼 집행이 강행되어 손해가 발생할 수 있다. 이 경우 회복하기 어려운 손해의 발생이 인정되어야 한다.

(3) 공공복리에 미치는 영향이 없을 것

- 집행정지가 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없어야 한다.

(4) 무효의 명백성(판례)

- 취소소송에서는 단순히 본안 청구가 이유 있음(승소 가능성)이 소명되어야 하지만, 무효확인소송의 경우 그 처분에 무효 사유가 명백하고 쉽게 소명되어야 집행정지가 허용된다는 것이 판례의 태도이다. 이는 무효인 처분은 효력이 없으므로 원칙적으로 집행정지가 필요하지 않다는 전제에서, 예외적으로 집행정지를 허용하는 기준을 높게 설정한 것이다.

II. 가처분

1. 문제의 소재

- 가처분이란 다툼 있는 권리 관계에 대해 본안 판결이 확정되기까지 법률 관계의 현상을 임시적으로 정하는 제도를 말한다. 행정소송법은 집행정지에 관한 규정만 두고 있을 뿐, 가처분에 관한 규정은 별도로 두고 있지 않다. 따라서 무효등 확인소송에서 가처분이 허용되는지 여부가 문제된다.

2. 판례의 태도

(1) 가처분 불허의 원칙

- 판례는 행정소송법상 가처분에 관한 명문 규정이 없을 뿐만 아니라, 집행정지 규정이 행정처분의 공정력이나 집행력을 정지시키는 특별한 가구제 수단이므로, 민사소송법상의 가처분 규정이 행정소송에 준용되지 않는다고 본다. 따라서 무효등 확인소송을 포함한 항고소송에서는 가처분이 원칙적으로 허용되지 않는다는 것이 확립된 판례의 태도이다.

(2) 예외적 인정론(학설)

- 학설 중에는 집행정지로는 구제할 수 없는 침익적인 비처분 행위나 부작위에 대한 확인소송 등에서는 국민의 권리 구제 실효성 확보를 위해 가처분을 예외적으로 인정해야 한다는 견해도 있으나, 판례는 이를 부정한다.

III. 결론

- 무효등 확인소송의 가구제 수단으로 집행정지는 행정소송법 규정에 따라 준용되어 인정된다. 다만, 무효확인소송의 본질상 그 처분의 무효가 명백히 소명되어야 한다는 점을 요건으로 한다. 반면, 가처분은 행정소송법상 명문 규정이 없으며 판례가 민사소송법상의 준용을 부정하는 태도를 취하고 있어 원칙적으로 허용되지 않는다. 이러한 가구제 수단의 제한적인 인정은 무효인 처분이 갖는 효력 부존재라는 특성과 행정법 관계의 안정성 유지 필요성을 조화시키려는 것이다.

<제9장 무효등 확인소송.제7절 청구의 병합과 소의 변경>

I. 관련청구소송의 병합 및 이송[행소법 제38조, 제10조]

1. 관련청구소송의 병합

- 무효등 확인소송의 심리 및 재판에는 행정소송법 제10조가 준용되어 관련청구소송의 병합이 허용된다.

(1) 관련청구소송의 범위

- 관련청구소송이란 당해 처분 또는 재결과 관련된 손해배상, 부당이득반환, 원상회복 등의 소송이나, 당해 처분 또는 재결을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송을 말한다. 이러한 관련청구소송은 당해 무효등 확인소송이 계속 중인 법원에 함께 제기할 수 있다.

(2) 병합의 실익

- 무효확인소송에서 인용판결이 확정되면 처분의 무효가 확인되므로, 그 처분을 근거로 발생한 부당이득반환 등의 법률관계에 관한 청구를 하나의 소송에서 함께 심리하여 판결의 모순 저축을 방지하고 소송 경제를 도모하는 실익이 있다. 예를 들어 처분의 무효확인 청구와 그 무효인 처분으로 인해 납부한 금원의 부당이득반환 청구를 병합하여 제기할 수 있다.

2. 관련청구소송의 이송

- 관련청구소송이 무효등 확인소송이 계속된 법원 외의 다른 법원에 계속되어 있는 경우, 법원은 병합 심리의 필요성이 있다고 인정될 때 당사자의 신청 또는 직권에 의해 해당 사건을 무효등 확인소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있다. 이는 심리를 집중시켜 시간과 비용을 절약하는 데 기여한다.

II. 소의 변경[행소법 제37조]

- 행정소송법 제37조는 처분등에 대한 무효등 확인소송을 취소소송으로 변경하는 것을 허용하며, 반대로 취소소송을 무효등 확인소송으로 변경하는 것도 포함한다. 이는 당사자에게 최대한의 권리 구제 기회를 제공하려는 취지이다.

1. 무효등 확인소송에서 취소소송으로의 변경

- 원고가 무효등 확인소송을 제기했으나 법원 심리 과정에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단될 경우, 법원의 석명권 행사 또는 원고의 신청에 의해 취소소송으로의 변경이 허용된다. 이때 변경된 소는 당초 소를 제기한 때에 제기된 것으로 보므로, 제소기간 요건은 당초 소 제기 시를 기준으로 충족되어야 한다.

2. 취소소송에서 무효등 확인소송으로의 변경

- 취소소송을 제기했으나 하자가 무효 사유임이 명백한 경우 무효등 확인소송으로 변경하는 것이 가능하다. 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없으므로, 이 경우 제소기간 문제가 발생하지 않는다.

3. 소 변경의 요건 및 한계

- 소의 변경은 청구의 기초에 변경이 없고, 사실심 변론 종결 시까지만 가능하다. 또한, 피고를 달리하는 소의 변경은 원칙적으로 허용되지 않으나, 피고가 행정청에서 국가 또는 공공단체로 변경되는 경우 등에는 예외적으로 허용될 수 있다.

III. 결론

- 무효등 확인소송은 관련청구소송의 병합 및 이송 규정이 준용되어 손해배상 등 다양한 청구를 함께 심리할 수 있다. 또한, 행정소송법 제37조에 따라 취소소송과의 상호 간 소의 변경이 허용되어, 원고가 소송 종류를 잘못 선택했다라도 권리 구제의 기회를 상실하지 않도록 한다. 특히 소의 변경 시에는 변경된 소가 당초 소를 제기한 때에 제기된 것으로 보는 효과가 있어, 취소소송의 제소기간 요건 준수에 중요한 영향을 미친다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타 소송.제1절 부작위위법확인소송>

I. 부작위위법확인소송의 의의

1. 개념[행소법 제4조 제3호]

- 부작위위법확인소송이란 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 않은 경우(부작위)에 그 부작위가 위법함을 확인하는 소송을 말한다. 행정소송법 제4조 제3호에 규정되어 있다. 이 소송은 행정청의 응답 의무를 전제로 하며, 응답 의무가 있음에도 불구하고 아무런 응답을 하지 않는 소극적 위법 상태를 제거하는 것을 목적으로 한다.

2. 제도적 한계

- 부작위위법확인소송은 행정청에게 응답 의무를 이행하도록 강제하는 데 그 목적이 있을 뿐, 신청에 따른 특정한 처분을 하도록 강제하는 것은 아니다. 이는 법원이 행정청의 재량권 행사에 직접 개입하는 것을 자제하고, 권력분립의 원칙을 존중하기 위한 제도적 한계이다. 즉, 법원이 부작위가 위법함을 확인하는 판결을 내려도, 행정청은 인용 처분이나 거부 처분 중 어떤 응답을 할지에 대해서는 여전히 재량권을 가진다.

II. 부작위위법확인소송의 요건

- 부작위위법확인소송이 적법하려면 항고소송 일반의 요건 외에 부작위위법확인소송에 특유한 요건이 충족되어야 한다.

1. 대상적격

(1) 부작위의 성립

- 부작위가 성립하기 위해서는 당사자의 신청이 있어야 하며, 그 신청은 공법상의 신청이어야 한다. 또한, 행정청이 신청에 대하여 상당한 기간 내에 응답을 하지 않은 상태가 지속되어야 한다. 여기서 상당한 기간은 사회 통념상 행정청이 처분을 할 것으로 기대되는 합리적인 기간을 의미한다.

(2) 일정한 처분

- 부작위의 대상이 되는 행정작용은 일정한 처분이어야 한다. 즉, 그 행정작용이 행정소송법 제2조 제1항 제1호에 규정된 처분성을 가져야 한다. 처분성을 가지지 않는 행정작용을 구하는 신청에 대한 부작위는 이 소송의 대상이 될 수 없다.

(3) 법률상 의무

- 행정청에게 당사자의 신청에 대하여 처분을 하여야 할 법률상 의무가 존재해야 한다. 이는 당사자에게 신청권이 있음을 의미하며, 신청권이 없는 자의 신청에 대한 무응답은 부작위위법확인소송의 대상이 될 수 없다. 신청권은 관련 법규의 해석에 의해 인정되어야 한다.

2. 당사자적격

(1) 원고적격

- 원고적격은 행정소송법 제36조에 규정되어 있다. 부작위위법확인소송은 처분등을 신청한 자로서 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다. 이는 부작위로 인해 법률상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자에게 원고적격을 인정하는 것이다. 단순한 사실상의 이익이나 간접적인 이해관계만으로는 부족하다.

(2) 피고적격

- 피고적격은 행정소송법 제38조 제2항에 의해 제13조가 준용된다. 피고는 부작위 상태에 있는 행정청이 된다.

3. 기타 요건

(1) 행정심판전치주의

- 부작위위법확인소송에서도 행정심판전치주의가 적용되며, 이 경우 의무이행심판을 필요적으로 거쳐야 한다.

(2) 제소기간

① 행정심판을 거치지 아니한 경우

- 부작위는 계속되는 것이므로 부작위위법확인소송은 원칙상 제소기간의 제한을 받지 않는다고 보는 것이 타당하다.

② 행정심판을 거친 경우

- 판례는 행정심판을 거친 경우에는 행정소송법 제20조가 정한 제소기간 내(안 날로부터 90일, 있은 날로부터 1년)에 부작위위법확인소송의 소를 제기하여야 한다고 한다.

(3) 재판관할[행소법 제38조 제2항, 제9조]

- 부작위위법확인소송의 재판관할도 취소소송과 마찬가지로 피고인 행정청의 소재지를 관할하는 행정법원을 제1심 관할법원으로 한다.

III. 부작위위법확인소송의 심리

- 부작위위법확인소송의 심리는 행정소송법 제38조 제2항에 따라 취소소송의 심리 규정들이 준용된다.

1. 심리의 기본원칙

- 부작위위법확인소송은 직권심리주의, 구술심리주의, 공개심리주의 등 취소소송의 심리 원칙이 그대로 적용된다. 법원은 당사자가 주장하지 않은 사항에 대해서도 직권으로 심리할 수 있다.

2. 심리의 범위

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 위법한지 여부만을 심리한다.

(1) 위법성 판단 대상

- 법원은 행정청에게 응답 의무가 있음에도 응답하지 않은 부작위 자체의 위법성만을 심리한다.

(2) 본안 판단의 불가능

- 법원은 신청에 따른 응답한 처분(인용 처분)을 해야 할 것인지 여부 등 본안 사항에 대해서는 심리할 수 없다. 이는 사법부가 행정청의 재량권 행사에 직접 개입하는 것을 막는 권력분립 원칙의 존중 때문이다.

3. 입증책임

- 처분 등에 관한 입증책임 원칙이 준용되어, 원고가 부작위의 존재와 신청권의 존재 등 소송 요건에 관한 사실을 입증해야 한다. 반면, 피고인 행정청은 부작위가 적법하다는 사실(상당한 기간이 경과하지 않았거나 신청권이 없다는 등)을 입증할 책임이 있다.

4. 위법성 판단의 기준시

- 부작위위법확인소송은 행정청의 위법 상태가 계속되는 것을 다루는 소송이라는 특수성이 있다. 판례는 부작위의 위법성 판단의 기준 시점을 사실심 변론 종결 시로 본다. 이는 행정청의 응답 의무가 소송이 진행되는 중에도 계속되고, 법원이 소송 종료 시점까지의 행정청의 응답 여부 및 그 법적 상태를 포괄적으로 판단해야 하기 때문이다. 이는 처분 시를 기준으로 하는 취소소송과 구별되는 가장 큰 특징이다.

IV. 부작위위법확인소송의 종료

- 부작위위법확인소송은 법원의 판결, 소의 취하 등으로 종료되며, 판결의 효력은 취소소송 규정이 준용되지만 그 특성상 간접강제가 허용된다는 특징이 있다.

1. 법원의 판결

(1) 소송판결

- 소송 요건이 결여된 경우 법원은 각하판결을 내린다. 예를 들어 이미 거부 처분이 내려져 부작위 상태가 아닌 경우, 신청권이 없는 자가 제기한 경우 등을 들 수 있다.

(2) 인용판결

- 부작위가 위법하다고 인정될 때 법원은 인용판결을 내린다. 이 판결은 행정청에게 판결의 취지에 따른 재처분 의무를 발생시킨다.

(3) 기각판결

- 부작위가 위법하지 않다고 인정될 때 법원은 기각판결을 내린다. 예를 들어 신청권이 없거나, 상당한 기간이 경과하지 않은 경우 등을 들 수 있다.

(4) 사정판결

- 취소소송의 제28조(사정판결)에 관한 규정이 부작위위법확인소송에 준용되지 않는다는 것이 일반적인 해석이다. 부작위의 위법성을 확인하는 판결을 공공복리라는 이유로 기각할 실익이 없기 때문이다.

2. 판결의 효력

(1) 기속력[행소법 제38조 제2항, 제30조]

- 부작위위법확인소송의 인용판결이 확정되면, 취소소송의 기속력에 관한 제30조가 준용된다. 법원의 위법 확인 판결의 취지에 따라 행정청은 지체 없이 이전에 신청받은 사항에 대해 응당한 처분을 해야 할 재처분 의무를 부담한다. 즉, 단순히 이전의 부작위 상태를 반복하거나 단순한 무의미한 거부 처분만을 반복해서는 안 된다.

(2) 간접강제[행소법 제38조 제2항, 제34조]

- 부작위위법확인소송의 경우 인용판결에도 불구하고 행정청이 재처분 의무를 이행하지 않을 때, 행정소송법 제38조 제2항은 제34조(간접강제)를 준용한다. 법원은 신청에 따라 결정으로 상당한 기간을 정하고, 행정청이 그 기간 내에 처분을 하지 않으면 자연 기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명할 수 있다. 이는 판결의 실효성을 확보하기 위한 강력한 수단이다.

(3) 제3자효[행소법 제38조 제2항, 제17조, 제31조]

- 제3자효에 관한 규정은 부작위위법확인판결에 대하여도 준용된다. 판결의 효력이 제3자에게도 미치므로 제3자를 보호하기 위하여 제3자의 소송 참가제도와 제3자의 재심청구제도도 준용된다.

3. 재심[행소법 제38조 제2항, 제31조]

- 부작위위법확인소송의 확정 판결에 중대한 하자가 있는 경우, 취소소송의 제31조가 준용되어 재심을 청구할 수 있다. 재심 사유는 민사소송법 제451조의 규정을 따른다.

V. 가구제

1. 집행정지

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위를 대상으로 하므로, 처분의 효력이나 집행이 존재하지 않는다. 따라서 취소소송에서 인정되는 처분의 효력 정지를 목적으로 하는 집행정지는 성질상 인정되지 않는다.

2. 가처분

- 부작위위법확인소송은 행정청의 응답을 강제하는 소송이지만, 행정소송법상 가처분에 관한 명문 규정이 없으므로, 판례의 태도에 따라 가처분은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만, 학설은 부작위가 계속될 경우 회복하기 어려운 손해가 발생하는 예외적인 경우에 한하여 잠정적인 조치를 위해 가처분을 인정해야 한다는 주장을 제기하기도 한다.

VI. 청구의 병합과 소의 변경

1. 관련 청구소송의 병합 및 이송[행소법 제38조 제2항, 제10조]

- 부작위위법확인소송에도 취소소송의 제10조가 준용되어 관련 청구소송의 병합 및 이송이 허용된다. 관련 청구소송에는 부작위로 인한 손해에 대한 손해배상 청구 등이 포함될 수 있다.

2. 소의 변경

- 행정소송법 제37조에 따라 부작위위법확인소송을 다른 항고소송(거부처분 취소소송)으로 소의 변경이 허용된다.

(1) 부작위위법확인소송에서 거부처분 취소소송으로의 변경

- 부작위위법확인소송이 계속되는 도중에 행정청이 거부 처분을 한 경우, 원고는 부작위위법확인소송을 거부처분 취소소송으로 변경할 수 있다. 이는 행정소송법 제22조(처분 변경으로 인한 소의 변경)와 제37조에 근거를 둔다.

(2) 변경의 효과

- 소의 변경은 청구의 기초에 변경이 없고, 사실심 변론 종결 시까지만 허용되며, 변경된 소는 당초 소를 제기한 때에 제기된 것으로 본다.

VI. 결론

- 부작위위법확인소송은 행정청의 응답 의무 불이행에 대한 위법성만을 심리하는 소송으로서, 신청권과 처분성이 소송 요건의 핵심이다. 취소소송과 달리 위법성 판단의 기준 시점은 사실심 변론 종결 시로 본다. 판결의 효력과 관련하여 기속력과 간접강제가 준용되어 재처분 의무 이행의 실효성이 확보된다는 특징을 가진다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타 소송.제2절 당사자소송>

I. 당사자소송의 의의[행소법 제3조 제2호]

- 당사자소송이란 행정청의 처분등을 직접적인 대상으로 하지 않고, 공법상의 법률관계에 관하여 그 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송을 말한다. 행정소송법 제3조 제2호에 규정되어 있다. 이는 행정주체와 사인(私人) 간의 공법상 권리·의무 관계를 다투는 소송으로서, 공법상 계약이나 공법상 사실행위 등 권력 관계 외의 공법관계에서 주로 발생한다. 당사자소송은 원고와 피고가 대등한 당사자의 지위에서 소송을 진행한다는 점에서, 원고가 행정청의 처분에 대한 취소나 변경을 구하는 항고소송과 구별된다.

II. 다른 소송과의 구별

1. 민사소송과의 구별

- 당사자소송과 민사소송은 모두 대등한 당사자 간의 법률관계를 다투는 점에서 유사하다. 그러나 당사자소송은 그 다툼의 대상이 되는 법률관계가 공법상의 법률관계인 반면, 민사소송은 사법상의 법률관계를 다룬다. 예를 들어 공무원 연금 지급 청구는 당사자소송이지만, 국가를 상대로 한 일반적인 채무불이행으로 인한 손해배상 청구는 민사소송이다. 공법관계와 사법관계의 구별이 모호할 경우 당사자소송인지 민사소송인지에 대한 판단이 어려워지는 경우가 발생한다.

2. 항고소송과의 구별

- 항고소송은 행정청의 처분등을 직접적으로 대상으로 하여 취소, 무효 확인, 부작위위법 확인을 구하는 소송이다. 반면, 당사자소송은 행정청의 처분등을 직접적인 대상으로 하지 않고, 처분의 유무와 관계없이 공법상의 권리·의무를 다툰다. 항고소송은 원고와 피고가 대립적인 지위에 서는 반면, 당사자소송은 대등한 당사자로서의 지위에서 법률관계를 다툰다.

III. 당사자소송의 종류

- 당사자소송은 그 성립의 배경에 따라 실질적 당사자소송과 형식적 당사자소송으로 나뉜다.

1. 실질적 당사자소송

- 실질적 당사자소송은 공법상의 권리·의무에 관하여 그 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송으로서, 행정소송법 제3조 제2호에 규정된 본래적인 당사자소송을 말한다. 예를 들어 공법상 계약의 무효 확인 청구, 공무원의 보수 지급 청구, 공무원 지위 확인 청구 등을 들 수 있다.

2. 형식적 당사자소송

- 형식적 당사자소송은 행정청의 처분등을 직접 다투는 것은 아니지만, 처분의 효력을 전제로 하여 법률관계의 존부를 다투는 소송이다. 형식상 당사자소송의 형태를 취하지만, 실질적으로는 항고소송의 성격을 가진다. 예를 들어 토지 수용의 보상금 증감 청구소송을 들 수 있으며, 이는 재결의 효력 발생을 전제로 한다. 이는 법률의 규정에 의해 당사자소송의 형태로 제기하도록 특별히 정해진 경우에 해당한다.

IV. 당사자소송의 요건

- 당사자소송이 적법하게 제기되기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다.

1. 대상적격

- 당사자소송의 대상은 공법상의 법률관계이어야 한다. 공법상의 법률관계란 행정주체와 사인 간에 발생하는 공법적인 권리·의무 관계를 말하며, 이는 법규, 공법상 계약, 공법상 사실행위 등 다양한 원인에 의해 발생할 수 있다.

2. 당사자적격

(1) 원고적격

- 원고적격은 소송의 대상인 공법상의 법률관계에 관하여 권리 또는 의무를 주장하는 자에게 인정된다.

(2) 피고적격[행소법 제39조]

- 피고적격은 행정소송법 제39조에 규정되어 있다. 당사자소송은 국가·공공단체 그 밖의 권리주체를 피고로 한다. 즉, 처분등을 행한 행정청(기관)이 아니라 권리·의무의 주체가 되는 국가 또는 공공단체 등이 피고가 된다.

3. 기타요건

(1) 행정심판전치주의

- 취소소송에서의 예외적 행정심판전치주의는 당사자소송에 준용되지 않는다. 다만, 손실보상청구소송과 관련하여 개별법에서 이의신청 또는 재심 절차 등의 전치주의를 규정하고 있다.

(2) 제소기간

- 당사자소송에서는 취소소송의 제소기간에 관한 규정이 준용되지 않는다. 다만, 당사자소송에 관한 제소기간이 법령에 정하여져 있는 경우에는 그에 의하고, 그 기간은 불변기간으로 한다.

(3) 재판관할[행소법 제40조]

- 당사자소송은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원에 제기한다.

V. 당사자소송의 심리

1. 심리의 기본원칙[행소법 제44조 제1항, 제25조, 제26조]

- 당사자소송에서는 행정심판기록 제출명령과 직권심리주의가 적용된다.

2. 입증책임

- 입증책임은 민사소송법상 일반원칙인 법률요건분류설에 따른다.

VI. 당사자소송의 종료

1. 법원의 판결

- 당사자소송은 소송 요건을 갖추지 못하면 각하판결이, 청구가 이유 없으면 기각판결이, 청구가 이유 있으면 인용판결(이행판결, 확인판결 등)이 내려진다.

2. 판결의 효력[행소법 제44조 제1항, 제30조 제1항]

- 당사자소송의 확정판결도 불가변력·불가쟁력·기속력·기판력을 가진다. 다만, 취소판결의 제3자효, 재처분의무 및 간접강제 등은 당사자소송에서는 적용되지 아니한다.

3. 재심

- 당사자소송에서는 제3자에 의한 재심청구가 인정되지 아니한다.

4. 가집행선고

- 가집행선고란 미확정의 중국판결에 대하여, 그것이 확정된 것과 같은 집행력을 부여하는 형식적 재판을 의미한다. 당사자소송은 이행 청구를 목적으로 하는 경우가 많으므로, 민사소송법의 원칙에 따라 법원은 판결이 확정되기 전이라도 임시로 집행할 수 있도록 하는 가집행선고를 할 수 있다.

VI. 가구제

- 당사자소송의 가구제에 대해서는 행정소송법에 특별한 규정이 없다. 따라서 민사소송법의 원칙에 따라 민사집행법상의 가압류 또는 가처분이 적용된다. 예를 들어 공법상 금전 지급 청구 소송의 경우 가압류가, 지위 확인 청구 소송의 경우 가처분이 허용된다. 이는 행정청의 처분을 대상으로 하는 항고소송과 구별되는 특징이다.

VII. 청구의 병합과 소의 변경 및 이송

1. 관련 청구소송의 병합 및 이송[행소법 제44조 제2항, 제10조]

(1) 관련 청구소송의 병합

- 당사자소송의 심리 및 재판에는 행정소송법 제44조 제2항에 의해 제10조가 준용되어 관련 청구소송의 병합이 허용된다.

(2) 관련 청구소송의 범위

- 당사자소송의 관련 청구소송으로는 항고소송(공무원 지위 확인 소송에 부수된 징계 처분 취소 소송)이나, 민사소송 등 다른 유형의 소송이 포함될 수 있다.

2. 소의 변경[행소법 제42조, 제21조, 제44조, 제22조]

(1) 항고소송으로의 변경

- 행정소송법 제42조는 당사자소송을 항고소송으로 변경하는 것을 허용하며, 제21조(소의 변경)가 준용된다. 원고가 소송의 유형을 잘못 선택한 경우 권리 구제 기회를 주기 위함이다.

(2) 항고소송에서의 변경

- 항고소송을 당사자소송으로 변경하는 것 역시 제42조의 규정에 의해 허용된다.

(3) 소 변경의 효과

- 소의 변경은 청구의 기초에 변경이 없고, 사실심 변론 종결 시까지만 허용되며, 변경된 소는 당초 소를 제기한 때에 제기된 것으로 본다.

3. 소의 이송

- 관련 청구소송의 이송 규정(제10조)이 준용되므로, 관련 사건이 다른 법원에 계속된 경우 당사자소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있다. 또한, 소가 관할 법원에 잘못 제기된 경우 제17조에 따라 관할 법원으로 이송하는 것도 가능하다.

IX. 결론

- 당사자소송은 공법상의 법률관계를 대상으로 국가 등 권리주체를 피고로 하는 소송이다. 심리 및 판결 효력에 있어 제3자효 규정이 준용되지 않으며, 가구제로는 민사집행법상의 가압류·가처분이 적용된다. 또한, 항고소송과의 상호 간 소의 변경이 허용되어 국민의 실질적 권리 구제에 기여한다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타 소송.제3절 민중소송>

I. 민중소송의 의의[행소법 제3조 제3호]

- 민중소송이란 국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 하였을 때, 개인의 법률상 이익과는 관계없이 공익의 보호를 위하여 법률이 정하는 자가 제기할 수 있는 소송을 말한다. 행정소송법 제3조 제3호에 규정되어 있다. 이는 자신의 주관적 권리 구제를 목적으로 하는 항고소송이나 당사자 소송과 달리, 객관적 소송의 한 형태로서 법치 행정의 실현과 공익의 확보를 목적으로 한다.

II. 민중소송의 성질

1. 객관적 소송

- 민중소송은 소송을 제기하는 자의 개인적인 권리 또는 이익의 구제를 목적으로 하지 않고, 국가 또는 공공단체의 행위에 대한 법령 위반 여부를 심사하여 객관적인 법질서의 유지를 목적으로 하는 객관적 소송의 성질을 가진다. 따라서 민중소송의 원고적격은 일반 국민에게 광범위하게 인정되는 것이 아니라, 법률이 정한 자에게만 인정된다는 특징이 있다.

2. 법정소송주의

- 민중소송은 공익 보호를 위한 소송이므로, 그 제기를 남용할 경우 행정의 효율성이 저해될 우려가 있다. 이에 행정소송법은 민중소송은 법률이 정한 경우에 한하여 제기할 수 있다고 규정한다(법정소송주의). 즉, 개별 법률에 근거 규정이 있을 때에만 제기할 수 있다.

III. 민중소송의 종류

- 민중소송은 개별 법률의 규정에 따라 그 유형이 다양하게 나타나지만, 크게 다음 두 가지 유형으로 분류할 수 있다.

1. 선거소송 및 당선소송

- 공직선거법에 규정된 소송으로서, 선거 또는 당선의 효력 유무에 관하여 다투는 소송이다. 예를 들어 선거의 전부 또는 일부의 무효를 다투는 소송, 당선의 효력을 다투는 소송 등이 있으며, 이들은 선거의 공정성이라는 공익을 보호하기 위한 민중소송의 대표적인 예이다.

2. 지방자치법상 주민소송

- 지방자치법에 규정된 소송으로서, 지방자치단체의 장 또는 직원의 재산상 손해를 가져오는 위법한 행위에 대해 주민이 감사 청구를 거쳐 제기하는 소송이다. 이는 지방자치단체의 재정적 건전성이라는 공익을 보호하고, 지방 행정에 대한 주민의 감시권을 보장하기 위한 민중소송이다.

IV. 적용법규[행소법 제46조]

- 민중소송의 심리와 재판에 관하여 행정소송법 제46조는 다음과 같은 규정을 적용한다.

1. 보충적 적용

- 민중소송의 심리와 재판에 관하여는 해당 민중소송을 규정하고 있는 개별 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는, 행정소송법 제1장부터 제4장까지의 규정을 준용한다. 즉, 민중소송에 관한 일반법은 행정소송법이며, 개별법이 우선 적용되고 미비된 사항은 행정소송법의 규정이 보충적으로 적용된다.

2. 준용 배제되는 규정

(1) 제23조(집행정지)

- 개별 법률에 특별한 규정이 없는 한, 민중소송에는 집행정지 규정이 준용되지 않는다. 이는 공익을 위해 제기되는 민중소송에서 집행정지를 광범위하게 허용할 경우 행정의 공익적 목적 수행에 지장을 초래할 수 있기 때문이다.

(2) 제26조(직권심리)

- 직권심리 규정은 민중소송에 준용되지 않는다. 민중소송은 법률이 정한 자가 법률 위반 행위를 주장하는 객관적 소송이므로, 법원은 변론주의를 원칙으로 하여 당사자가 주장한 사실에 한정하여 심리하는 것이 타당하다고 본다.

V. 결론

- 민중소송은 법률이 정한 자만이 공익 보호를 위해 제기할 수 있는 객관적 소송으로서, 법정소송주의가 지배한다. 선거소송이나 주민소송 등이 대표적이며, 심리 및 재판에는 개별 법률의 규정이 우선 적용되고, 행정소송법의 규정이 보충적으로 준용된다. 특히 집행정지와 직권심리 규정은 원칙적으로 준용되지 않는다는 특징이 있다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타 소송.제4절 기관소송>

I. 기관소송의 의의[행소법 제3조 제4호]

- 기관소송이란 국가 또는 공공단체의 기관 상호 간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때, 이들 기관을 당사자로 하여 제기하는 소송을 말한다. 행정소송법 제3조 제4호에 규정되어 있다. 이는 행정기관들 사이의 권한 충돌을 해결함으로써 행정의 적법성을 확보하고 법치 행정의 원리를 구현하는 것을 목적으로 한다. 기관소송 역시 법률이 정한 경우에 한하여 제기할 수 있는 법정소송주의가 적용된다.

II. 기관소송의 인정필요성

- 기관소송은 행정조직 내부에 존재하는 권한 다툼을 법원의 사법적 심사를 통해 해결하여 행정의 효율성과 통일성을 확보하기 위해 필요하다. 행정기관 간의 권한 침해 행위가 발생했을 때, 이를 소송으로 해결하지 못하면 행정 집행의 혼란을 초래하고 궁극적으로 국민의 권익 침해로 이어질 수 있다. 따라서 법원의 객관적 판단을 통해 행정조직의 법적 안정성과 질서를 유지하는 것이 기관소송의 주된 필요성이다.

III. 권한쟁의심판과의 구별

- 기관소송은 기관 상호 간의 권한 다툼을 해결한다는 점에서 헌법재판소의 권한쟁의심판과 유사하나, 다음과 같은 점에서 구별된다.

1. 관할 법원 및 심판 기관

- 권한쟁의심판은 헌법재판소의 관할이며, 기관소송은 행정법원(법원)의 관할이다.

2. 다툼의 주체

- 권한쟁의심판은 국가 기관 상호 간, 국가 기관과 지방자치단체 상호 간, 지방자치단체 상호 간 등 헌법 기관이나 지방자치단체 등의 공권력 주체 간의 권한 다툼을 대상으로 한다. 반면, 기관소송은 국가 또는 공공단체 내부의 기관 상호 간의 권한 다툼을 대상으로 하며, 소송의 당사자가 된다.

3. 법적 근거

- 권한쟁의심판은 헌법과 헌법재판소법에 근거하는 반면, 기관소송은 행정소송법과 개별 법률(지방자치법 등)에 근거한다.

IV. 구체적 경우

- 기관소송은 법정소송주의에 따라 개별 법률에 명시된 경우에 한하여 제기할 수 있으며, 주로 지방자치단체와 관련하여 권한 다툼이 발생하는 경우가 많다.

1. 지방의회 재의결에 대한 지방자치단체장의 소송[지방자치법 제192조 제4항]

- 지방의회의 의결이 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 판단될 때, 지방자치단체장은 재의를 요구할 수 있다. 지방의회가 재의결을 하였으나 그 재의결이 법령에 위반된다고 판단되면, 지방자치단체장은 재의결된 날부터 20일 이내에 대법원에 소송을 제기할 수 있다. 이는 지방자치단체장과 지방의회 간의 권한 다툼을 해결하는 대표적인 기관소송이다.

2. 지방의회 재의결에 대한 주무부장관 또는 시·도지사의 소송[지방자치법 제192조 제5항·제8항]

- 지방의회의 재의결이 법령에 위반된다고 판단될 때, 주무부장관이나 시·도지사는 지방자치단체장을 거쳐 대법원에 소송을 제기할 수 있다. 이 역시 지방의회와 감독 기관 간의 권한 다툼을 해결하는 기관소송의 한 형태이다.

3. 주무부장관이나 시·도지사의 기관위임사무 이행명령에 대한 지방자치단체장의 소송[지방자치법 제189조 제6항]

- 국가사무 또는 시·도사무의 기관위임사무에 관하여 주무부장관이나 시·도지사가 지방자치단체장에게 발하는 이행명령이 위법하다고 판단될 경우, 지방자치단체장은 이행명령을 받은 날부터 15일 이내에 대법원에 소송을 제기할 수 있다.

4. 교육·학예에 관한 시·도의회 재의결에 대한 교육감의 소송[지방교육자치에 관한 법률 제28조]

- 시·도의회 의결이 교육·학예에 관한 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 판단되어 교육감이 재의를 요구하였으나 의회가 재의결한 경우, 교육감은 그 재의결된 날부터 20일 이내에 대법원에 소송을 제기할 수 있다.

V. 법적 규율

- 기관소송은 객관적 소송의 성질을 가지므로, 그 당사자자격 및 적용법규 등에 있어서 일반적인 항고소송이나 당사자소송과 다른 특별한 규율을 받는다.

1. 당사자자격

- 기관소송의 당사자자격은 행정소송법 제3조 제4호의 정의에 따라 법률에 의해 소송을 제기할 수 있는 기관에게만 인정된다. 즉, 소송을 통해 자기 기관의 권한을 주장하는 기관이 원고가 되고, 그 권한을 침해하거나 다투는 상대 기관이 피고가 된다.

2. 재판관할

- 기관소송은 그 성질상 국가적·공익적 중요성을 가지는 경우가 많으므로, 그 재판관할은 일반 행정법원이 아닌 대법원에 전속되는 경우가 많다.(지방자치법상의 소송 규정 참고) 이는 소송의 신속한 종결과 법적 안정성 확보를 위한 것이다.

3. 적용법규[행소법 제46조]

- 민중소송과 마찬가지로, 기관소송의 심리와 재판에 관하여는 해당 기관소송을 규정하고 있는 개별 법률의 특별한 규정이 없는 한, 행정소송법 제1장부터 제4장까지의 규정을 준용한다. 그러나 기관소송의 특성상 항고소송의 규정 중 제23조(집행정지)나 제26조(직권심리) 등은 준용되지 않는 것이 일반적이다. 이는 소송의 신속한 진행과 변론주의의 적용에 따른 것이다.

VI. 결론

- 기관소송은 국가 또는 공공단체 내부 기관 상호 간의 권한 다툼을 해결하는 객관적 소송으로서, 법정소송주의에 따라 개별 법률에 명시된 경우에만 제기할 수 있다. 주로 지방자치법상의 지방자치단체장과 의회 간, 또는 감독 기관 간의 소송이 주를 이루며, 그 관할은 대법원에 집중되는 경우가 많다. 심리와 재판에는 개별법이 우선 적용되고, 행정소송법의 규정이 보충적으로 준용된다.

<제11장 행정심판의 일반론.제1절 서설>

I. 행정심판의 의의

1. 개념

- 행정심판이란 행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위에 대하여 행정심판위원회가 심리·재결하는 절차를 말한다. 행정심판은 행정소송과 함께 행정 작용으로 인해 권리나 이익을 침해당한 국민을 구제하는 주요한 제도이다. 행정심판은 행정소송에 비해 신속하고 간이한 절차로 진행되며, 행정 내부적으로 분쟁을 해결한다는 특징을 가진다.

2. 성격

(1) 사법절차 유사성

- 행정심판은 행정기관에 의해 이루어지지만, 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사하고, 당사자 대립주의에 의해 심리가 진행되는 등 사법적 절차와 유사한 성격을 가진다. 이는 행정심판이 실질적으로 준사법적 기능을 수행함을 의미한다.

(2) 행정의 자체 통제

- 행정심판은 행정 내부에 설치된 행정심판위원회에 의해 이루어지므로, 행정청 스스로 자신의 행위를 자율적으로 통제하는 행정의 자체 통제 기능을 수행한다. 이는 행정의 전문성과 효율성을 고려한 제도이다.

(3) 쟁송절차

- 행정심판은 행정청의 처분등에 불복하여 그 위법성 또는 부당성을 주장하는 쟁송절차이다.

3. 존재이유

(1) 전문성과 효율성

- 행정심판은 법원에 비해 당해 행정 분야에 대한 전문성을 가진 기관이 심리하므로, 해당 분야의 특성을 고려한 적절한 결정을 내릴 수 있어 효율적이다.

(2) 신속성과 간이성

- 행정소송에 비해 신속하고 간이하게 분쟁을 해결할 수 있어 국민의 권리 구제를 용이하게 한다.

(3) 사법 부담 경감

- 행정심판을 통해 행정 내부에서 분쟁의 상당 부분을 해결함으로써, 법원의 소송 부담을 경감시키는 역할을 한다.

(4) 부당성 심사

- 법원의 행정소송은 원칙적으로 처분의 위법성만을 심사하지만, 행정심판은 부당성까지 심사할 수 있어 국민의 권리 보호 범위가 넓어진다.

II. 이의신청과의 구별

1. 이의신청의 의의

- 이의신청이란 행정청의 처분등에 대하여 그 처분청에 다시 심사를 청구하는 행위를 말한다. 행정심판처럼 별도의 독립된 기관이 아니라, 처분청 자신이 심사를 한다는 특징이 있다. 이의신청은 행정심판법에 규정된 제도가 아니라, 개별 법률에 의해 규정되는 경우가 일반적이다.

2. 법적 성격

- 이의신청은 처분청 자신에게 다시 심사를 요구하는 행위이므로, 원칙적으로는 행정 내부적인 절차에 불과하며 쟁송절차로 보기는 어렵다. 다만, 개별 법률의 규정에 따라 그 심사 과정이나 효력이 행정심판과 유사한 성격을 가질 수도 있다.

3. 구별실익

- 이의신청과 행정심판을 구별하는 실익은 다음과 같다. 첫째, 행정심판은 행정소송의 전심절차가 될 수 있지만, 이의신청은 전심절차가 될 수 없는 경우가 많다. 둘째, 이의신청은 행정심판과 달리 불복 기간의 정지가 인정되지 않는 경우가 많아, 행정심판이나 행정소송 제기 기간에 영향을 미칠 수 있다.

4. 구별기준

(1) 심사기관

- 행정심판은 처분청 외의 독립된 행정심판위원회가 심사하는 반면, 이의신청은 원칙적으로 처분청 자신이 심사한다.

(2) 법적 근거

- 행정심판은 행정심판법에 일반적 근거를 두고 개별 법률에서 특별히 규정하는 반면, 이의신청은 대부분 개별 법률에 근거를 둔다.

(3) 심사범위

- 행정심판은 위법성 및 부당성을 심사하지만, 이의신청은 처분의 당부에 대한 재심사에 한정되는 경우가 많다.

5. 행정심판인지 여부에 대한 구체적 검토

- 어떤 제도가 행정심판인지 이의신청인지 여부는 그 제도의 명칭에 관계없이 실질적인 내용과 규정된 절차를 기준으로 판단해야 한다. 즉, 그 제도가 행정심판법이 정한 행정심판위원회를 통해 독립적으로 심사가 이루어지는지, 또는 행정심판법의 적용을 받는다고 명시되어 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 개별 법률이 이의신청이라고 규정하고 있더라도, 그 성격상 행정심판의 절차를 따르도록 되어 있다면 실질적으로 행정심판으로 볼 수도 있다.

III. 결론

- 행정심판은 행정청의 위법·부당한 처분등에 대한 행정 내부의 쟁송절차로서, 행정소송에 비해 전문성, 신속성, 부당성 심사라는 장점을 통해 국민의 권리 구제에 기여한다. 이와 유사한 이의신청은 처분청 자신의 재심사 절차라는 점에서 행정심판과 구별되나, 구체적인 제도의 실질에 따라 행정심판으로 간주될 수 있으므로 그 구별 기준을 명확히 할 필요가 있다.

<제11장 행정심판의 일반론.제2절 행정심판의 종류>

I. 일반행정심판

1. 의의[행심법 제5조]

- 일반행정심판이란 행정심판법에 그 종류와 절차가 규정되어 있는 행정심판을 말한다. 이는 행정심판법 제5조에 따라 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판 세 가지로 분류된다. 일반행정심판은 행정심판에 관한 일반법으로서의 지위를 가진다.

2. 종류

(1) 취소심판[행심법 제5조 제1호]

- 행정청의 위법 또는 부당한 처분의 취소 또는 변경을 구하는 심판이다. 행정소송의 취소소송에 상응하는 심판 유형으로서, 처분의 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사할 수 있다는 특징이 있다.

(2) 무효등확인심판[행심법 제5조 제2호]

- 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부에 대한 확인을 구하는 심판이다. 행정소송의 무효등확인소송에 상응하는 심판 유형이다. 처분의 무효가 확인되는 경우 그 처분은 처음부터 효력이 없었던 것으로 본다.

(3) 의무이행심판[행심법 제5조 제3호]

- 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 구하는 심판이다. 행정소송의 부작위위법확인소송에 대응하는 심판 유형이나, 단순히 위법 확인에 그치지 않고 특정한 처분을 명하도록 구할 수 있다는 점에서 행정소송보다 더 적극적인 권리구제 수단이다.

II. 특별행정심판

1. 개념

- 특별행정심판이란 행정심판법이 아닌 개별 법률에서 특별한 사항에 대하여 규정하고 있는 행정심판을 말한다. 이는 당해 행정 분야의 특수성이나 전문성을 고려하여 일반적인 행정심판 절차를 따르기 어려울 때 인정된다. 예를 들어 조세 심판, 특허 심판 등을 들 수 있다.

2. 행정심판법의 적용

- 행정심판법 제4조는 개별 법률에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 행정심판법이 적용된다고 규정한다. 따라서 특별행정심판의 경우에도 개별법에 규정되지 않은 사항에 대해서는 행정심판법의 규정이 보충적으로 적용된다.

3. 법적 성격

- 특별행정심판은 그 심판 절차, 청구 기간, 재결의 효력 등에 있어 일반행정심판과 다를 수 있으나, 본질적으로는 행정 내부의 쟁송절차로서의 성격을 공유한다.

III. 의무이행심판의 구체적 검토

- 의무이행심판은 행정청의 거부나 부작위에 대해 국민의 적극적인 권리 구제를 목적으로 한다는 점에서 특히 중요하다.

1. 서설

- 의무이행심판은 행정청의 소극적인 자세로 인해 국민의 권익이 침해되는 상황을 구제하기 위해 도입된 제도이다. 취소심판이나 무효등확인심판만으로는 국민의 실질적인 권리 구제가 미흡할 수 있으므로, 심판을 통해 직접적인 처분을 구하는 것이다.

2. 심판청구요건

(1) 대상적격

- 대상적격은 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위이다. 이는 당사자의 신청에 대하여 행정청이 응답할 법률상 또는 조리상 의무가 있음에도 이를 이행하지 않은 경우를 의미한다. 단순한 사실행위에 대한 부작위 등은 해당되지 않는다.

(2) 청구인 적격

- 청구인 적격은 처분을 신청한 자로서 법률상 이익이 있는 자에게 인정된다.

(3) 청구 기간

- 거부처분에 대한 의무이행심판은 취소심판의 청구 기간이 적용되나, 부작위에 대한 의무이행심판은 부작위 상태가 계속되는 한 청구 기간의 제한이 없다.

3. 재결

(1) 각하재결

- 각하재결은 심판청구의 제기요건을 충족하지 않은 부적법한 심판청구에 대하여 본안에 대한 심리를 거절하는 내용의 재결을 말한다.

(2) 기각재결

① 기각재결

- 일반적인 경우의 기각재결은 본안심리의 결과, 심판청구가 이유 없다고 인정하여 그 청구를 배척하고 원처분을 지지하는 재결을 의미한다.

② 사정재결

- 사정재결은 심판청구가 행정심판위원회의 심리 결과 이유 있다 하더라도, 이를 인용하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정되어 그 청구를 기각하는 재결을 말한다.

(3) 인용재결

① 처분재결

- 기속행위의 경우에는 행정심판위원회는 재결로써 청구인의 청구내용대로 처분을 할 수 있으나, 재량행위의 경우에는 처분의 인용 여부가 처분청의 재량이므로 처분재결을 할 수 없다.

② 처분명령재결

- 기속행위의 경우에는 특정 처분을 할 것을 명하는 재결을 하고, 재량행위의 경우에는 처분청으로 하여금 다시 처분을 하도록 하는 재결정을 명하는 재결을 한다.

(4) 간접적 구속력

- 인용재결이 내려지면 피청구인인 행정청은 재결의 취지에 따라 처분을 해야 할 재처분 의무를 부담하며, 이는 행정심판법 제49조 제2항(기속력)에 따른 것이다. 행정심판법은 이 재처분 의무를 이행하지 않을 경우 간접강제를 할 수 있도록 규정하여(제50조의2), 재결의 실효성을 확보한다.

4. 가구제

- 의무이행심판의 경우 본안 재결 전까지 신청인의 권익이 침해되는 것을 막기 위해 가구제 제도가 인정된다.

(1) 집행정지

① 의의[행심법 제30조]

- 행정심판위원회는 처분등의 효력이나, 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 중대한 손해가 생기는 것을 예방할 필요가 있다고 인정할 경우에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 행정심판위원회의 심리·의결을 거쳐 예외적으로 처분등의 효력이나, 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지를 결정할 수 있다.

② 거부처분의 경우

- 집행정지는 종전의 상태를 유지시키는 소극적인 것이므로 종전의 상태를 변경시키는 적극적인 조치로 활용될 수 없다. 이에 따라 거부처분에 대하여는 원칙적으로 집행정지가 허용되지 아니한다.

③ 부작위의 경우

- 집행정지는 처분에 대한 가구제수단이므로 부작위에 대하여는 집행정지가 허용될 여지가 없다.

(2) 임시처분

① 의의[행심법 제31조]

- 임시처분이란 행정청의 처분 또는 부작위로 인하여 당사자에게 발생할 수 있는 중대한 불이익이나 급박한 위험을 막기 위하여, 당사자에게 임시지위를 부여하는 행정심판위원회의 결정을 의미한다.

② 대상

- 법문상 처분 또는 부작위를 대상으로 규정하나, 적극적 처분의 경우에는 임시처분의 대상이 되기 어렵다. 이는 행정심판법 제31조 제3항에서, 임시처분은 제30조 제2항에 따른 집행정지로서 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다고 규정하고 있기 때문이다. 따라서 임시처분의 대상은 소극적 처분인 거부처분과 부작위이다.

Ⅳ. 결론

- 행정심판은 행정심판법에 규정된 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판의 일반행정심판과 개별 법률에 규정된 특별행정심판으로 구분된다. 특히 의무이행심판은 행정청의 소극적인 행정 작용에 대해 적극적인 처분을 구하는 심판으로서, 각하·기각·인용재결이 있으며, 인용재결에는 처분재결과 처분명령재결이 있다. 재결의 실효성을 확보하기 위해 행정심판법상 간접강제와 임시처분 제도를 명시적으로 인정하고 있다는 점에서 국민의 권리 구제에 있어 중요한 역할을 수행한다.

<제11장 행정심판의 일반론.제3절 고지제도>

I. 고지제도의 의의

1. 개념

- 고지제도란 행정청이 처분을 할 때 그 처분에 대하여 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있는지 여부, 제기하는 경우 청구 또는 소송 제기 기간과 청구 또는 소송 제기 기관 등을 당사자에게 알려주어야 하는 제도를 말한다. 이는 행정심판법 제58조에 규정되어 있으며, 행정구제 제도를 국민이 쉽게 이용할 수 있도록 하기 위한 목적을 가진다.

2. 성격

- 고지제도는 국민의 행정쟁송 제기권을 실질적으로 보장하기 위한 행정 절차상의 의무이며, 행정청이 반드시 준수해야 하는 법적 의무이다. 이는 국민의 알 권리를 실현하고 쟁송 제도의 실효성을 높이기 위한 장치이다.

3. 인정의 필요성

- 행정구제 제도는 복잡하고 전문적이며, 특히, 행정심판이나 행정소송의 청구 기간은 단기로 정해져 있는 경우가 많아 국민이 이를 알지 못하면 구제받을 기회를 상실하기 쉽다. 따라서 행정청이 처분과 동시에 구제 방법을 알려주도록 의무화함으로써 국민의 권리 구제 기회를 실질적으로 보장하고 법치 행정의 원리를 구현하는 데 그 필요성이 인정된다.

II. 고지의 종류

- 고지는 행정청이 직권으로 하는 경우와 당사자의 청구에 의해 하는 경우로 나뉜다.

1. 직권에 의한 고지[행정법 제58조 제1항]

- 행정심판법 제58조 제1항은 행정청이 처분을 할 때 직권으로 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는지, 제기하는 경우 심판청구 절차, 심판청구 기간을 당사자에게 알려야 한다고 규정한다. 이는 행정청이 처분과 동시에 고지를 해야 하는 가장 일반적인 형태의 고지이다. 행정심판뿐만 아니라 행정소송에 관한 사항도 함께 고지해야 하는 것이 일반적이다.

2. 청구에 의한 고지[행정법 제58조 제2항]

- 행정심판법 제58조 제2항은 당사자가 행정청의 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지 여부 및 청구 기간과 청구 기관에 대하여 문의하는 경우, 행정청은 이에 대한 정보를 제공하여야 한다고 규정한다. 이는 당사자의 적극적인 문의에 대한 행정청의 응답 의무를 규정한 것으로, 직권 고지가 누락되거나 불충분할 경우를 대비하여 국민의 권리를 보장한다.

III. 불고지 또는 오고지의 효과

- 행정청이 고지 의무를 이행하지 않거나(불고지), 사실과 다르게 잘못 고지한 경우(오고지)에는 국민의 권리 구제에 중대한 영향을 미치므로 특별한 효과가 인정된다.

1. 취지

- 고지 의무의 불이행이나 착오는 행정청의 귀책 사유로 발생한 것이므로, 그로 인해 국민이 구제받을 기회를 상실해서는 안 된다는 신뢰 보호 및 국민 권리 구제의 원칙에서 그 효과가 도출된다.

2. 불고지의 효과

(1) 심판청구서 제출기관을 알리지 아니한 경우[행정법 제23조 제2항·제3항·제4항]

- 처분청이 고지를 하지 아니하여 청구인이 심판청구서를 처분청이나 행정심판위원회가 아닌 다른 행정기관에 제출한 경우에는 당해 행정기관은 그 심판청구서를 지체 없이 정당한 권한이 있는 피청구인에게 송부하고, 그 사실을 청구인에게 통지하여야 한다. 이때 심판청구기간을 계산할 경우에는 제1항에 따른 피청구인이나 행정심판위원회 또는 제2항에 따른 행정기관에 심판청구서가 제출되었을 때에 행정심판이 청구된 것으로 본다.

(2) 청구기간을 알리지 아니한 경우[행정법 제27조 제1항·제6항]

- 심판청구는 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내에 청구하여야 한다. 그러나 행정청이 청구기간을 고지하지 아니한 경우에는 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 청구하면 된다.

3. 오고지의 효과

(1) 심판청구서 제출기관을 잘못 알린 경우[행정법 제23조 제2항·제4항]

- 처분청이 심판청구서 제출기관을 잘못 고지하여, 청구인이 심판청구서를 처분청이나 행정심판위원회가 아닌 다른 행정기관에 제출한 경우의 효과도 위의 불고지의 경우와 같다.

(2) 청구기간을 잘못 알린 경우[행정법 제27조 제5항]

- 행정청의 심판청구기간의 착오로 인하여 소정의 기간보다 길게 된 경우에는 그 고지된 청구기간 내에 심판청구가 있으면, 그 심판청구는 적법한 기간 내에 청구된 것으로 본다.

IV. 결론

- 고지제도는 행정청이 처분 시 국민에게 쟁송 제기 방법 및 기간을 알려주어야 하는 법적 의무로서, 국민의 권리 구제 기회를 실질적으로 보장하기 위해 인정된다. 행정청이 고지 의무를 이행하지 않은 불고지의 경우 청구 기간이 연장되는 효과가 발생하며, 잘못 고지한 오고지의 경우 잘못 고지된 기간 또는 기관을 기준으로 적법성을 인정하여 국민에게 불이익이 돌아가지 않도록 보호한다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제1절 행정심판의 대상적격>

I. 의의[행심법 제3조 제1항]

- 행정심판의 대상적격이란 행정심판에 의해 심사되어야 할 적합한 대상을 의미한다. 행정심판법 제3조 제1항은 행정심판의 대상을 행정청의 처분 또는 부작위로 규정하고 있다. 즉, 처분이나 부작위가 아닌 행정작용에 대해서는 원칙적으로 행정심판을 제기할 수 없다. 행정심판의 대상적격은 행정심판을 제기하기 위한 가장 기본적인 요건이며, 이 요건을 충족하지 못하면 그 청구는 각하된다.

II. 취소심판 · 무효등확인심판의 대상적격[행심법 제5조 제1호 · 제2호]

1. 의의

- 취소심판과 무효등확인심판은 행정청의 이미 존재하는 처분을 다투는 심판이라는 공통점을 가지므로, 그 대상적격은 기본적으로 처분에 한정된다.

2. 처분[행심법 제5조 제1호 · 제2호]

(1) 개념

- 취소심판 및 무효등확인심판의 대상인 처분은 행정심판법 제2조 제1호에 따라 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다. 이는 행정소송법상의 처분 개념과 실질적으로 동일하며, 공권력의 행사로 인해 국민의 권리 · 의무에 직접적인 변동을 가져오는 행위여야 한다.

(2) 행정입법 등 제외

- 법규명령이나 행정규칙과 같은 일반적 · 추상적인 행정입법은 특정 개인의 권리 · 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 원칙적으로 처분이 아니며, 행정심판의 대상이 될 수 없다. 다만, 예외적으로 그 자체로 국민의 권리 · 의무에 직접 영향을 미치는 경우에는 처분성이 인정될 수도 있다.

(3) 부작위 제외

- 취소심판과 무효등확인심판은 이미 행해진 처분의 위법 · 부당성이나 효력 유무를 다투는 것이므로, 부작위는 이 두 심판의 대상이 될 수 없다. 부작위는 의무이행심판의 대상이 된다.

III. 의무이행심판의 대상적격[행심법 제5조 제3호]

- 의무이행심판은 행정청의 소극적인 행정작용을 대상으로 하며, 거부처분과 부작위 두 가지가 대상이 된다.

1. 거부처분

(1) 개념

- 거부처분은 당사자의 신청에 대하여 행정청이 그 신청에 따른 처분을 하지 않겠다는 의사를 외부에 표시하는 행위를 말한다. 거부처분은 행정심판법상 처분의 일종으로 분류되지만, 의무이행심판의 대상이 되기 위해서는 다음과 같은 요건을 추가로 충족해야 한다.

(2) 법률상 신청권

- 당사자에게 처분을 신청할 법률상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다. 신청권이 없는 자의 신청에 대한 거부는 적법한 거부이므로 의무이행심판의 대상이 될 수 없다.

(3) 위법 또는 부당한 거부

- 거부처분의 내용이 위법하거나 부당해야 의무이행심판의 대상이 된다.

2. 부작위

(1) 개념

- 부작위란 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말한다. 이는 행정소송법상의 부작위 개념과 동일하다.

(2) 요건

- 부작위가 의무이행심판의 대상이 되기 위해서는 다음 요건을 충족해야 한다.

① 법률상 의무

- 행정청에게 법률상 또는 조리상 신청에 따른 처분을 해야 할 응답 의무가 존재해야 한다.

② 상당한 기간 경과

- 신청을 받은 행정청이 상당한 기간이 경과했음에도 응답을 하지 않고 있는 상태여야 한다. 상당한 기간은 사회 통념상 합리적인 기간을 의미한다.

③ 신청권

- 당사자에게 신청권이 존재해야 한다.

IV. 결론

- 행정심판의 대상적격은 행정청의 처분 또는 부작위에 한정된다. 취소심판 및 무효등확인심판은 처분을 대상으로 하며, 이 처분은 행정소송의 처분 개념과 동일하다. 의무이행심판은 행정청의 거부처분 또는 부작위를 대상으로 하는데, 특히 이 경우 당사자에게 법률상 신청권이 존재하고 행정청에게 응답 의무가 있다는 점이 중요한 요건이 된다. 이 대상적격 요건의 충족 여부에 따라 행정심판 청구의 적법성이 결정된다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제2절 행정심판의 당사자자격>

I. 청구인

1. 의의[행심법 제13조 제1항]

- 청구인이란 자기의 권리 또는 이익을 침해당했다고 주장하며 행정심판을 제기하는 당사자를 말한다. 행정심판법 제13조 제1항은 청구인 자격의 일반 원칙을 규정하고 있다.

2. 청구인자격

(1) 일반적 원칙

- 청구인 자격은 행정심판을 청구할 수 있는 법률상의 자격을 의미하며, 행정심판법 제13조 제1항은 처분의 취소 또는 변경을 구할 법률상 이익이 있는 자가 청구할 수 있다고 규정한다.

(2) 제3자의 청구인 자격

- 처분의 직접 상대방이 아닌 제3자도 그 처분으로 인해 법률상 이익을 침해받은 경우에는 청구인이 될 수 있다. (경쟁 관계에 있는 사업자에 대한 허가 처분으로 인해 자신의 법률상 이익이 침해된 경우)

3. 행정심판유형별 청구인자격

(1) 취소심판[행심법 제13조 제1항]

- 취소심판은 처분의 취소 또는 변경을 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다.

(2) 무효등확인심판[행심법 제13조 제2항]

- 무효등확인심판은 처분의 효력 유무나 존재 여부에 대한 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자가 청구할 수 있고, 이때 확인을 구할 법률상 이익은 처분의 근거법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익을 말한다.

(3) 의무이행심판[행심법 제13조 제3항]

- 의무이행심판은 처분을 신청한 자로, 행정청의 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 구할 법률상 이익이 있는 자가 청구할 수 있다. 이때 청구인자격이 인정되기 위해서는 일정한 처분을 신청한 것만으로는 충분하지 않고, 근거법령 등에 근거한 신청권이 있어야 한다.

II. 피청구인

1. 의의[행심법 제17조 제1항]

- 피청구인이란 행정심판 청구를 받은 행정청을 말하며, 행정심판법 제17조 제1항은 피청구인 자격에 관한 일반 원칙을 규정한다.

(1) 피청구인 자격의 원칙

- 피청구인 자격은 처분을 한 행정청 또는 부작위 상태에 있는 행정청에게 있다. 처분을 집행하거나 보조하는 기관이 아니라, 자기 명의로 행정작용을 행한 행정청이 피청구인이 된다.

(2) 예외적 피청구인

① 권한의 위임 또는 위탁이 있는 경우

- 권한을 위임받거나 위탁받은 수입청(수탁청)이 피청구인이 된다. 이는 위임 또는 위탁받은 기관이 자기 명의로 처분을 하기 때문이다.

② 행정청이 없어진 경우

- 처분을 한 행정청이 폐지 등으로 없어진 경우에는 그 사무를 승계한 행정청이 피청구인이 된다.

③ 다른 행정청에 소속된 기관의 처분

- 법령에 의해 행정청의 권한에 속하는 사무가 다른 행정청에 소속된 기관에 위임된 경우, 그 기관이 소속된 행정청(감독청)이 피청구인이 된다.

2. 피청구인 경정[행심법 제17조 제2항·제5항]

- 피청구인 경정이란 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우, 올바른 피청구인으로 당사자를 바꾸는 절차를 말한다.

(1) 경정의 사유 및 절차[행심법 제17조 제2항]

- 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우, 행정심판위원회는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의해 결정으로써 피청구인을 경정할 수 있다.

(2) 경정의 효과[행심법 제17조 제5항]

- 피청구인이 경정되면, 새로운 피청구인에 대한 심판 청구는 당초 심판 청구 시에 제기된 것으로 본다. 이는 청구인이 피청구인을 잘못 지정했더라도 청구 기간의 도과로 인해 권리 구제 기회를 상실하는 것을 방지하기 위한 제도이다.

III. 참가인[행심법 제20조, 제21조]

- 참가인이란 행정심판 청구에는 직접적인 당사자(청구인, 피청구인)는 아니지만, 그 심판의 재결에 이해관계가 있는 제3자 또는 행정청을 말한다.

1. 제3자의 참가[행심법 제20조]

- 행정심판의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자는 행정심판위원회에 참가 신청을 하거나, 위원회의 직권에 의한 요구로 심판에 참가할 수 있다. 이는 심판 절차에서 제3자의 방어권을 보장하기 위한 제도이다.

2. 행정청의 참가[행심법 제21조]

- 행정심판의 결과에 이해관계가 있는 행정청은 위원회에 참가를 신청하거나, 위원회의 요구로 심판에 참가할 수 있다. 이는 이해관계가 있는 행정기관의 의견을 들어 심리의 공정성과 충실성을 확보하기 위한 것이다.

IV. 결론

- 행정심판의 당사자자격은 청구인과 피청구인에게 적합한 자격이 있는지를 판단하는 중요한 요건이다. 청구인은 처분의 취소 또는 변경을 구할 법률상 이익이 있는 자여야 하며, 특히 의무이행심판에서는 신청권이 요구된다. 피청구인은 원칙적으로 처분을 행하거나 부작위 상태에 있는 행정청이 되며, 예외적으로 권한의 위임 또는 위탁이 있는 경우나 행정청이 없어진 경우 등에는 특별히 정해진 기관이 피청구인이 된다. 피청구인을 잘못 지정한 경우에는 경정 제도를 통해 권리 구제를 보장하며, 참가인 제도는 재결에 이해관계가 있는 제3자나 행정청의 심판 참여를 허용한다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제3절 행정심판의 청구>

I. 행정심판청구기간

1. 의의

- 청구기간이란 행정심판을 제기할 수 있는 법정된 기간을 말하며, 행정심판법은 국민의 신속한 권리 구제와 행정작용의 조기 확정을 위해 청구기간을 제한한다. 이는 심판청구의 적법 요건에 해당하며, 청구기간을 초과한 심판청구는 각하된다. 이 기간은 법원이 직권으로 조사해야 하는 불변 기간이다. 행정심판청구기간은 취소심판청구와 거부처분에 대한 의무이행심판청구에 적용되며, 무효등확인심판청구와 부작위에 대한 의무이행심판청구에는 적용되지 아니한다.

2. 행정심판법상 행정심판청구기간

(1) 처분이 있음을 안 날부터의 기간[행심법 제27조 제1항]

- 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구하여야 한다. 여기서 안 날이란 청구인이 처분의 존재를 현실적으로 인식한 날을 의미한다.

(2) 처분이 있었던 날부터의 기간[행심법 제27조 제3항]

- 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구하여야 한다. 이는 청구인이 처분이 있음을 알았는지 여부와 관계없이 적용되는 최장 기간의 제한이다.

(3) 기간의 특례

① 정당한 사유에 의한 연장

- 청구인이 천재지변, 전쟁, 사변 등 정당한 사유로 인해 90일 또는 180일의 기간 내에 청구할 수 없었던 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 청구할 수 있다.

② 부작위에 대한 심판

- 부작위에 대한 의무이행심판은 기간의 제한이 없다. 부작위의 위법·부당 상태는 계속되고 있으므로, 법적 안정성을 해칠 우려가 없기 때문이다.

3. 특별법상 행정심판청구기간

- 행정심판법 제27조 제5항은 다른 법률에 심판청구기간에 대한 특별한 규정이 있는 경우, 그 법률에 따른다고 규정한다. 이는 특별법 우선의 원칙에 따른 것으로, 개별 법률에서 행정심판의 전문성이나 특수성을 고려하여 기간을 달리 정할 수 있음을 의미한다. 예를 들어 공무원 징계에 대한 소청 심사 청구기간은 일반적인 행정심판 청구기간과 다를 수 있다.

II. 행정심판청구의 절차 및 방식

1. 행정심판 제기절차

- 행정심판은 원칙적으로 피청구인(처분청)을 거쳐 관할 행정심판위원회에 도달하는 절차를 거친다.

(1) 청구서 제출

- 청구인은 행정심판 청구서를 피청구인 또는 행정심판위원회에 제출할 수 있다. 이는 행정심판의 제기가 용이하도록 청구 기관을 복수화한 것이다.

(2) 피청구인 경우

- 피청구인에게 청구서가 제출된 경우, 피청구인은 청구서를 받은 날부터 10일 이내에 답변서와 함께 관할 행정심판위원회에 청구서를 보내야 한다. 이 기간은 피청구인의 의무 기간일 뿐, 청구기간의 적법성 판단에는 영향을 미치지 않는다.

(3) 위원회 도달

- 청구서가 행정심판위원회에 도달하면 위원회는 심판청구가 접수된 것으로 보고 심리를 개시한다.

2. 행정심판청구 방식

(1) 서면주의

- 행정심판의 청구는 서면으로 하여야 한다(서면주의). 구술이나 전화 등에 의한 청구는 원칙적으로 인정되지 않는다.

(2) 청구서의 기재 사항

- 청구서에는 당사자의 성명 또는 명칭, 주소, 피청구인, 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위, 청구의 취지와 이유 등 법정된 사항을 필수적으로 기재하여야 한다.

(3) 온라인 청구

- 행정심판법은 정보 통신망을 이용하여 행정심판을 청구할 수 있도록 규정하여, 국민의 접근 편의성을 높이고 있다.

III. 행정심판청구의 효과[행심법 제30조 제1항·제2항]

1. 집행부정지원칙[행심법 제30조 제1항]

- 행정심판의 청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 미치지 않는다는 것이 원칙이다. 이를 집행부정지원칙이라고 한다. 이는 행정의 공정력을 유지하고 행정 목적의 실효성을 확보하기 위한 것이다.

2. 집행정지[행심법 제30조 제2항]

(1) 의의

- 집행부정지원칙에 대한 예외로서, 처분을 그대로 두면 회복하기 어려운 손해가 생길 우려가 있는 경우, 당사자의 신청 또는 행정심판위원회의 직권에 의해 처분의 효력, 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부를 정지할 수 있다. 이를 집행정지라고 한다.

(2) 요건

- ① 본안 심판청구가 계속 중일 것. ② 처분 등의 존속으로 인해 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있을 것. ③ 긴급한 필요가 있을 것. ④ 공공 복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것.

(3) 한계

- 처분의 효력 정지는 처분의 집행을 정지함으로써 그 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다.

3. 심판 계속 효과

- 행정심판이 적법하게 청구되어 계속 중인 경우, 이는 행정소송의 전심절차를 거쳤다는 효력을 가지며, 행정소송 제기 기간 계산 등에 영향을 미친다.

IV. 결론

- 행정심판의 청구는 처분이 있음을 안 날부터 90일, 있었던 날부터 180일의 청구기간을 준수해야 하며, 부작위에 대한 심판은 기간 제한이 없다. 청구는 원칙적으로 서면으로 피청구인 또는 행정심판위원회에 제출한다. 심판청구가 있더라도 처분의 효력은 정지되지 않는다는 집행부정지원칙이 원칙이

나, 회복하기 어려운 손해 등의 요건이 충족되면 집행정지 결정이 내려질 수 있다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제4절 행정심판기관>

I. 행정심판기관의 의의

- 행정심판기관은 행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위에 대한 국민의 불복 청구를 심사하고, 이에 대한 결론인 재결을 내리는 합의제 행정기관을 말한다. 종전에는 처분청의 직근 상급 행정기관이 심판 기관의 역할을 수행하였으나, 현행 행정심판법은 행정심판위원회라는 독립된 합의제 기관이 이를 담당하도록 하여 심판의 공정성을 제고하였다.

II. 행정심판기관의 법적 지위 및 성격

- 행정심판기관인 행정심판위원회는 행정기관에 소속되어 있지만, 그 기능과 운영에 있어서 독립성과 중립성을 확보하도록 규정되어 있다.

1. 합의제 행정기관

- 행정심판위원회는 복수의 위원으로 구성되어 합의를 통해 의사를 결정하는 합의제 행정기관이다. 이는 단독제 기관보다 심리의 신중성과 공정성을 확보하는 데 유리하다.

2. 준사법기관의 성격

- 행정심판위원회는 행정청의 처분에 대한 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사하고, 당사자 대립주의에 입각하여 심리 절차를 진행하므로, 사법기관과 유사한 준사법기관의 성격을 가진다.

3. 독립성과 중립성

- 행정심판위원회는 그 소속 행정기관으로부터 독립하여 심판의 사무를 수행하며, 위원들의 임기와 신분 보장 등을 통해 정치적 중립성을 유지하도록 법적으로 규율된다. 이는 심판의 객관성을 확보하는 데 중요하다.

III. 행정심판기관의 종류

- 행정심판기관인 행정심판위원회는 그 관할 영역에 따라 중앙, 시·도, 직근 상급기관 소속 위원회 등으로 분류된다.

1. 일반행정심판위원회[행심법 제6조 제1항]

- 감사원, 국가정보원장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 대통령 소속 기관의 장, 국회사무총장·법원행정처장·헌법재판소사무처장 및 중앙선거관리위원회사무총장, 국가인권위원회, 그 밖에 지위·성격의 독립성과 특수성 등이 인정되어 대통령령으로 정하는 행정청의 경우에는 그 행정청 또는 그 소속 행정청의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구에 대하여, 그 행정청에 두는 행정심판위원회에서 심리·재결한다.

2. 중앙행정심판위원회[행심법 제6조 제2항]

- 행정심판법 제6조 제1항에 따른 행정청 외의 국가행정기관의 장 또는 그 소속 행정청, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 의회, 지방자치법에 따른 지방자치단체조합 등 관계 법률에 따라 국가·지방자치단체·공공법인 등이 공동으로 설립한 행정청의 경우에는 그 행정청의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구에 대하여 국민권익위원회에 두는 중앙행정심판위원회에서 심리·재결한다.

3. 시·도행정심판위원회[행심법 제6조 제3항]

- 시·도 소속 행정청, 시·도의 관할구역에 있는 시·군·자치구의 장, 소속 행정청 또는 시·군·자치구의 의회, 시·도의 관할 구역에 있는 둘 이상의 지방자치단체·공공법인 등이 공동으로 설립한 행정청의 경우에는 그 행정청의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구에 대하여, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 소속으로 두는 행정심판위원회에서 심리·재결한다.

4. 직근 상급행정기관 소속 행정심판위원회[행심법 제6조 제4항]

- 행정심판법 제6조 제2항 제1호에도 불구하고, 대통령령으로 정하는 국가행정기관 소속 특별지방행정기관의 장의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구에 대하여 해당 행정청의 직근 상급행정기관에 두는 행정심판위원회에서 심리·재결한다.

IV. 행정심판기관의 구성 및 회의

- 행정심판위원회는 위원장과 다수의 위원으로 구성되며, 그 구성 방식과 회의 운영에 있어 중립성을 확보하기 위한 규정을 둔다.

1. 일반행정심판위원회

(1) 구성 원칙[행심법 제7조 제1항]

- 위원장은 행정심판위원회를 대표하며, 위원회는 위원장 1명을 포함하여 50명 이내의 위원으로 구성된다. 위원의 상당수는 공무원이 아닌 외부 전문가 중에서 위촉되어야 하며, 이는 심판의 객관성을 높이기 위함이다.

(2) 회의 운영[행심법 제7조 제6항]

- 회의는 위원장이 소집하며, 재적 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

2. 중앙행정심판위원회

(1) 구성의 특수성[행심법 제8조 제1항]

- 중앙행정심판위원회는 위원장 1명을 포함하여 70명 이내의 위원으로 구성된다. 상임위원을 두어 심판 사무의 전문성과 지속성을 확보하며, 위원장은 정무직으로 임명된다. 위원의 2분의 1 이상은 공무원이 아닌 사람으로 위촉되어야 한다.

(2) 소위원회[행심법 제8조 제5항·제6항·제7항]

- 중앙행정심판위원회는 사건의 효율적 심리를 위해 소위원회를 구성하여 운영할 수 있다. 소위원회는 위원회의 의결로써 위임받은 사항에 한하여 의결 권한을 행사한다.

V. 위원의 제척·기피·회피제도

- 위원회의 심판이 공정하게 이루어지도록 하기 위하여, 특정 사건과 이해관계가 있는 위원이 그 심리·의결에 참여하는 것을 배제하는 제도가 인정된다.

1. 제척[행심법 제10조 제1항]

- 제척이란 법률이 정한 특정한 사유가 있는 경우, 그 위원이 당연히 그 심판에 참여할 수 없도록 배제되는 것을 말한다. 행정심판법 제10조 제1항은 위원이거나 그 배우자가 해당 사건의 당사자가 되거나, 당사자와 친족 관계에 있는 경우 등 객관적인 이해관계가 있는 경우를 제척 사유로 규정한다.

2. 기피[행심법 제10조 제2항]

- 기피란 당사자가 위원에게 공정한 심리·의결을 기대하기 어려운 사정이 있다고 판단될 때, 그 사유를 들어 위원의 심판 참여를 배제해 줄 것을 신청하는 제도를 말한다. 행정심판법 제10조 제2항은 당사자의 기피 신청이 있을 경우 위원회가 의결로써 기피 여부를 결정하도록 한다.

3. 회피[행심법 제10조 제7항]

- 회피란 제척 또는 기피 사유에 해당하는 위원 자신이 스스로 그 심판에서 물러나는 것을 말한다. 행정심판법 제10조 제7항은 위원이 제척 또는 기피 사유에 해당한다고 판단할 경우, 스스로 심판 참여를 회피하여야 할 의무를 규정한다.

Ⅴ. 행정심판기관의 권한과 의무

1. 권한

- 행정심판기관인 위원회는 행정심판의 심리 및 재결에 필요한 광범위한 권한을 가진다.

(1) 재결 권한

- 청구된 심판에 대하여 심리하고, 인용, 기각, 각하재결을 내릴 수 있는 최종적 권한을 가진다. 특히, 의무이행심판에서는 처분재결이나 처분명령재결을 할 수 있다.

(2) 심리 권한

- 증거 조사, 사실 확인, 감정 등을 할 수 있으며, 관계 행정청에 대하여 자료 제출 및 의견 진술을 요구할 수 있다.

(3) 가구제 권한

- 본안 재결 전까지 긴급한 필요가 있을 때 집행정지 또는 임시처분을 결정할 수 있는 권한을 가진다.

2. 의무

- 행정심판기관은 공정한 심판 절차 운영을 위한 여러 의무를 부담한다.

(1) 공정한 심리 의무

- 위원회의 위원들은 공정하고 독립적인 자세로 심리에 임하여야 할 의무를 가진다.

(2) 신속한 처리 의무

- 행정심판은 청구서 접수일로부터 원칙적으로 60일 이내에 재결하여야 할 신속 처리 의무를 부담한다.

3. 권한승계

- 처분청의 권한이 다른 행정청에 승계된 경우, 심판청구는 그 권한을 승계한 행정청을 피청구인으로 하여 계속된다. 이는 심판의 실효성을 유지하기 위한 것이다.

Ⅵ. 결론

- 행정심판기관인 행정심판위원회는 행정청 소속이지만 그 기능은 독립성을 가진 합의제 준사법기관으로서, 국민권익위원회, 시·도, 직군 상급기관 소속으로 분류된다. 위원회의 심리 공정성을 확보하기 위해 제척, 기피, 회피 제도가 엄격히 적용된다. 행정심판기관은 재결, 심리, 가구제 등의 광범위한 권한을 가지며, 특히 신속하고 공정한 심리 의무를 부담함으로써 국민의 권리 구제에 핵심적인 역할을 수행한다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제5절 가구제>

I. 서설

- 가구제란 행정심판의 본안 재결이 있기 전까지 심판청구인에게 발생할 수 있는 회복하기 어려운 손해를 예방하거나 방지하기 위하여 잠정적인 구제 조치를 취하는 제도를 말한다. 행정심판법은 가구제 수단으로 처분의 효력 및 집행을 정지시키는 집행정지와 잠정적으로 신청인의 지위를 정하는 임시 처분을 규정하고 있다. 이는 국민의 권리 구제의 실효성을 확보하기 위한 중요한 제도이다.

II. 집행정지

1. 의의[행심법 제30조]

- 집행정지란 행정심판이 청구된 처분의 효력이나 그 집행, 또는 절차의 속행을 잠정적으로 정지시키는 결정을 말한다. 행정심판법 제30조에 규정되어 있다. 이는 처분의 공정력 때문에 심판청구가 있더라도 처분의 효력이 유지되는 집행부정지의 원칙에 대한 예외이다.

2. 집행부정지의 원칙

- 행정심판법 제30조 제1항은 행정심판의 청구는 처분의 효력이나 그 집행, 또는 절차의 속행에 영향을 미치지 않는다는 집행부정지의 원칙을 규정한다. 이는 행정의 공정력을 유지하고 행정 목적의 실효성을 확보하기 위함이다.

3. 요건

- 집행정지 결정은 다음과 같은 요건을 모두 충족해야 한다.

(1) 본안 심판이 계속 중일 것

- 집행정지는 본안 심판의 부수적인 절차이므로, 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판 중 하나가 적법하게 청구되어 행정심판위원회에 계속 중이어야 한다.

(2) 처분의 존속으로 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있을 것

- 회복하기 어려운 손해란 처분이 집행되거나 지속될 경우 금전 보상으로는 완전히 회복하기 어렵거나, 회복이 가능하더라도 사회 통념상 참을 수 없는 유·무형의 손해를 의미한다.

(3) 손해 예방을 위한 긴급한 필요가 있을 것

- 손해를 예방하기 위한 조치를 취할 시간적 여유가 없는 등 긴급한 필요가 인정되어야 한다.

(4) 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것

- 집행정지를 통해 얻을 수 있는 사익 보호보다 집행정지로 인해 공공복리에 미치는 중대한 영향이 더 크다고 판단되어서는 안 된다.

4. 대상[행심법 제30조 제2항]

- 집행정지의 대상은 행정심판법 제30조 제2항에 따라 다음과 같이 세 가지가 있다.

(1) 효력의 정지

- 처분 자체가 가지는 법적 효력을 정지시키는 것을 말한다. 이는 처분의 집행을 정지함으로써 그 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다.

(2) 집행의 정지

- 처분의 집행 행위(영업 정지 처분에 따른 간판 철거 명령)를 정지시키는 것이다.

(3) 절차의 속행 정지

- 연속되는 행정 절차의 다음 단계로 나아가는 것을 정지시키는 것이다.

5. 절차

- 집행정지는 당사자의 신청 또는 행정심판위원회의 직권으로 심리하여 결정으로써 행한다. 위원회는 관계 행정청의 의견을 들어야 한다.

6. 효과

- 집행정지 결정이 있으면 그 처분의 효력은 잠정적으로 정지되며, 본안 재결이 있을 때까지 지속된다. 집행정지 결정은 처분등의 효력 자체를 없애는 것이 아니라 잠시 그 작용을 멈추게 하는 것이므로, 처분의 위법성은 여전히 본안 심리에서 판단된다.

7. 취소[행심법 제30조 제4항]

- 집행정지 결정의 사유가 소멸되거나, 사정이 변경되어 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 생기는 등 집행정지를 유지할 필요가 없을 때에는, 행정심판위원회는 직권 또는 당사자의 신청에 의해 집행정지 결정을 취소할 수 있다.

III. 임시처분

1. 의의[행심법 제31조]

- 임시처분이란 행정심판법 제31조에 규정된 제도로, 거부처분이나 부작위를 대상으로 하는 의무이행심판에서 특히 중요한 가구제 수단으로서, 집행정지로는 구제받을 수 없는 경우 당사자 또는 이해관계인의 권익 보호를 위해 임시적인 지위를 정하는 처분을 말한다.

2. 요건

- 임시처분은 다음 요건을 모두 충족해야 한다. ① 처분이나 부작위를 그대로 둘 경우 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있을 것. ② 손해 예방의 긴급한 필요가 있을 것. ③ 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것. ④ 집행정지로는 목적을 달성할 수 없을 것. 이러한 임시처분은 집행정지를 할 수 없는 경우에 보충적으로만 허용된다는 보충성의 원칙이 적용된다.

3. 대상

- 임시처분의 대상은 주로 거부처분이나 부작위를 다투는 의무이행심판에 한정된다. 취소심판 등 다른 심판에서는 집행정지를 통해 대부분의 가구제 목적을 달성할 수 있기 때문이다. 임시처분은 행정청에 잠정적인 처분을 하도록 명하는 형태가 될 수 있다.

4. 절차[행심법 제31조 제2항]

- 임시처분은 당사자의 신청 또는 행정심판위원회의 직권으로 심리하여 결정으로써 행하며, 행정심판위원회는 임시처분을 할 때 직권으로 또는 당사자의 신청에 의해 관계 행정청의 의견을 들어야 한다.

5. 취소[행심법 제31조 제2항, 제30조 제4항]

- 임시처분을 한 후 그 사유가 소멸되거나, 사정이 변경되어 임시처분을 유지할 필요가 없을 때에는 행정심판법 제31조 제2항에 따라 제30조 제4항의 규정이 준용되어, 위원회는 직권 또는 당사자의 신청에 의해 임시처분 결정을 취소할 수 있다.

IV. 결론

- 행정심판의 가구제는 본안 재결 전 국민의 권익을 잠정적으로 보호하는 중요한 절차이다. 집행정지는 처분의 효력·집행·절차의 속행을 정지하는 것이며, 회복하기 어려운 손해와 긴급성을 요건으로 한다. 반면, 임시처분은 주로 의무이행심판에서 집행정지로 목적 달성이 불가능할 때 보충적으로 허용되며, 잠정적으로 신청인의 지위를 정하는 더 적극적인 구제 수단이라는 특징이 있다. 이 두 제도는 공공복리를 해치지 않는 범위 내에서 국민의 실질적인 권리 구제를 보장한다.

<제13장 행정심판의 심리·재결.제1절 행정심판의 심리>

I. 심리의 의의

- 심리란 행정심판위원회가 청구인의 주장과 피청구인의 반박을 듣고, 제출된 증거와 자료를 검토하며, 필요하다면 직권으로 사실을 조사하여 청구의 적법성과 당부를 판단하는 일련의 절차이다. 심리는 행정심판 절차의 핵심을 이루며, 구술심리와 서면심리의 방법을 통해 진행된다.

II. 심리의 종류

- 심리는 청구의 적법성을 판단하는 요건심리와 청구의 당부를 판단하는 본안심리로 나뉜다.

1. 요건심리[행심법 제43조 제1항]

- 요건심리란 행정심판이 적법하게 제기되었는지, 즉 청구 요건을 갖추었는지 여부를 심리하는 것을 말한다. 행정심판법 제43조 제1항은 청구가 부적법하면 그 심판청구를 재결로써 각하하여야 한다고 규정한다.

(1) 심리 대상

- ① **대상적격**
 - 처분 또는 부작위가 행정심판의 대상인지 여부.
- ② **당사자적격**
 - 청구인과 피청구인 적격이 있는지 여부.
- ③ **청구기간**
 - 청구기간을 도과하지 않았는지 여부.
- ④ **협의의 심판 이익**
 - 재결을 통해 권리 구제의 실익이 있는지 여부.
- ⑤ **기타**
 - 전심 절차의 준수 여부 등.

(2) 재결

- 요건을 갖추지 못한 청구는 각하재결을 한다.

2. 본안심리[행심법 제43조 제2항·제5항]

- 본안심리란 청구 요건을 갖춘 적법한 심판청구에 대하여, 청구인의 주장이 이유 있는지 여부를 심리하는 것을 말한다.

(1) 심리 대상

- 처분 또는 부작위의 위법성 및 부당성 유무를 심리한다. 위법성은 법령 위반 여부이고, 부당성은 재량권의 일탈·남용, 목적의 부적절성, 형평성 위반 등 합목적성 위반 여부이다.

(2) 재결

- 본안심리의 결과 청구가 이유 있으면 인용재결을, 이유 없으면 기각재결을 한다.

III. 심리의 범위

- 심리의 범위는 당사자의 청구 범위에 한정되며, 청구인에게 불리하게 재결할 수 없다는 원칙이 적용된다.

1. 불고불리의 원칙[행심법 제47조 제1항]

- 행정심판법 제47조 제1항은 행정심판위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위 외의 사항에 대하여 재결하지 못한다고 규정한다. 이를 불고불리의 원칙이라고 한다. 이는 청구인이 신청한 범위 내에서만 심리하고 재결해야 함을 의미한다.

2. 불이익 변경금지의 원칙[행심법 제47조 제2항]

- 행정심판법 제47조 제2항은 행정심판위원회는 청구인의 심판청구에 대하여 청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 재결을 하지 못한다고 규정한다. 이를 불이익 변경금지의 원칙이라고 한다. 예를 들어 3개월 영업 정지 처분을 다투는 심판에서 6개월 영업 정지 재결을 내릴 수 없다. 이는 청구인이 심판청구로 인해 더 큰 불이익을 받는 것을 방지하여 심판 제도의 이용을 위축시키지 않도록 하기 위함이다.

IV. 심리의 절차

1. 심리의 기본원칙

(1) 대심주의

- 행정심판법은 대심주의를 취한다. 대심주의란 심판청구인과 피청구인이 서로 대등한 입장에서 공격·방어방법을 제출하게 하고, 이때 제출된 공격·방어방법을 바탕으로 심리를 진행하는 원칙을 의미한다.

(2) 처분권주의

- 처분권주의란 심판의 개시, 심판의 대상, 심판의 종결을 당사자의 의사에 일임하는 것을 의미한다. 행정심판은 청구인의 심판청구에 의하여 개시되고, 청구인이 심판의 대상과 범위를 결정하며, 청구인이 심판청구를 취하함으로써 심판절차를 종료시킬 수 있다.

(3) 직권심리주의[행심법 제39조, 제36조 제1항]

- 행정심판위원회가 필요하다고 인정할 경우에는 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 심리할 수 있고, 사건의 심리를 위해서는 직권으로 증거조사를 할 수 있다고 규정하고 있어, 직권심리주의를 택하고 있다.

(4) 구술심리주의와 서면심리주의[행심법 제40조 제1항 전단/후단]

- 행정심판법은 서면심리주의와 구술심리주의를 함께 채택하고 있으며, 어느 방식을 취할 것인지는 행정심판위원회의 판단에 맡기고 있다. 그러나 당사자가 구술심리를 신청하였다면, 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정하는 경우 외에는 구술심리를 하도록 하고 있어, 심판청구인이 자신의 주장을 할 기회를 충분히 부여하고 있다.

2. 당사자의 절차적 권리

(1) 위원·직원에 대한 기피신청권[행심법 제10조 제3항]

- 당사자는 위원에 대하여 제척신청이나 기피신청을 할 수 있다. 제척신청이나 기피신청은 그 사유를 소명한 문서로 하여야 한다. 다만, 불가피한 경우 신청한 날로부터 3일 이내에 신청사유를 소명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

(2) 보충서면제출권[행심법 제33조 제1항]

- 당사자는 심판청구서·보정서·답변서·참가신청서 등에서 주장한 사실을 보충하고, 다른 당사자의 주장을 다시 반박하기 위하여 필요하면 행정심판위원회에 보충서면을 제출할 수 있다. 이 경우 다른 당사자의 수만큼 보충서면의 부분을 함께 제출하여야 한다.

(3) 구술심리신청권[행심법 제40조 제1항]

- 행정심판의 심리는 구술심리나 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청하였다면, 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.

(4) 물적 증거제출권[행심법 제34조 제1항]

- 당사자는 심판청구서·보정서·답변서·참가신청서·보충서면 등에 덧붙여 그 주장을 뒷받침하는 증거서류나 증거물을 제출할 수 있다.

(5) 증거조사신청권[행심법 제36조 제1항]

- 행정심판위원회는 사건의 심리를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 당사자의 신청에 의하여 증거조사를 할 수 있다고 규정하고 있다.

V. 심리의 병합과 분리

1. 병합[행심법 제37조]

- 행정심판법 제37조는 수 개의 심판청구가 관련되거나 동일한 사실 또는 법률 문제를 다루는 경우, 행정심판위원회가 직권 또는 당사자의 신청에 의해 이들을 병합하여 심리하고 재결할 수 있도록 규정한다. 이는 심리의 효율성과 판단의 통일성을 확보하기 위함이다.

2. 분리[행심법 제37조]

- 병합된 심판청구를 심리한 결과, 분리하여 심리하는 것이 더 효율적이거나 적절하다고 판단되는 경우, 행정심판위원회는 직권 또는 당사자의 신청에 의해 심리를 분리하여 진행할 수 있다.

VI. 처분사유의 추가·변경

- 처분사유의 추가·변경이란 피청구인인 행정청이 처분 당시 제시했던 사유 외에, 행정심판 과정에서 새로운 사유를 추가하거나 기존 사유를 변경하여 처분의 정당성을 입증하려는 행위를 말한다.

1. 인정 여부 및 제한

- 행정심판에서는 원칙적으로 처분 당시를 기준으로 위법·부당성을 판단한다. 따라서 처분 당시 제시하지 않았던 새로운 사실을 추가하거나 변경하는 것은 청구인의 방어권을 침해할 우려가 있어 엄격하게 제한된다. 판례는 기본적 사실 관계의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서만 추가·변경을 허용한다.

2. 심리 범위와의 관계

- 처분사유의 추가·변경은 청구의 본안심리 단계에서 피청구인의 주장을 강화하는 형태로 이루어지며, 불고불리의 원칙은 피청구인의 주장이 아닌 위원회의 재결 범위를 제한하는 원칙이므로 직접적인 관계는 없다.

VI. 결론

- 행정심판의 심리는 요건심리와 본안심리로 나뉘며, 심리의 범위는 불고불리의 원칙과 불이익 변경금지의 원칙에 의해 제한된다. 위원회는 직권심리주의에 입각하여 직권으로 사실을 조사할 수 있으며, 관련 사건은 병합하거나 분리하여 심리할 수 있다. 심리 과정에서 피청구인은 기본적 사실 관계의 동일성이 유지되는 범위 내에서만 처분사유의 추가·변경을 할 수 있다.

<제13장 행정심판의 심리·재결.제2절 행정심판의 재결>

I. 재결의 의의[행심법 제2조 제3호]

- 재결이란 행정심판위원회에서 행정심판 청구 사건에 대한 심리를 마친 후 내리는 최종적인 판단을 말한다. 행정심판법 제2조 제3호는 재결을 심판청구에 대하여 행정심판위원회가 행하는 판단이라고 정의한다. 재결은 행정청의 처분과 동일한 효력을 가지며, 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 준사법적 행위의 성격을 가진다.

II. 재결의 절차

1. 행정심판위원회의 의결

- 행정심판위원회는 심판청구에 대한 심리를 마치면 그 심판청구에 대하여 재결할 내용을 의결하고, 재결하여야 한다.

2. 재결의 기간[행심법 제45조 제1항]

- 행정심판법 제45조 제1항은 행정심판위원회는 심판청구를 받은 날부터 60일 이내에 재결하여야 한다고 규정한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장이 직권으로 30일을 연장할 수 있다. 이는 행정심판 제도의 목적인 신속한 권리 구제를 실현하기 위한 강행 규정이다.

3. 재결의 방식[행심법 제46조 제1항]

- 행정심판법 제46조 제1항은 재결은 문서로써 하여야 하며, 재결서에는 주문, 청구의 취지, 이유, 재결한 날짜 등을 기재하여야 한다고 규정한다. 이는 재결의 명확성과 공신력을 확보하기 위한 것이다.

4. 재결의 범위[행심법 제47조]

(1) 불고불리의 원칙[제1항]

- 재결은 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위 외의 사항에 대하여는 할 수 없다. 즉, 재결의 범위는 청구의 범위에 한정되어야 한다는 불고불리의 원칙이 적용된다.

(2) 불이익 변경금지의 원칙[제2항]

- 재결은 청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 내용으로 할 수 없다. 이는 불이익 변경금지의 원칙으로서, 청구인이 구제받고자 심판을 청구했다가 오히려 불이익을 입는 것을 방지하기 위함이다.

5. 재결의 송달과 효력 발생[행심법 제48조]

(1) 송달[제1항]

- 위원회는 재결서의 정본을 당사자에게 송달하여야 한다.

(2) 효력 발생 시기[제2항]

- 재결은 당사자에게 송달되었을 때 그 효력이 발생한다. 다만, 재결서가 당사자에게 도달하였더라도 송달이 되지 않은 경우에는 효력이 발생하지 않는 것으로 해석된다.

III. 재결의 종류

- 재결은 크게 청구 요건의 구비 여부에 따른 각하재결과 본안 판단에 따른 기각재결, 인용재결로 나뉜다.

1. 각하재결[행심법 제43조 제1항]

- 각하재결은 심판청구가 청구 요건을 갖추지 못하여 부적법하다고 판단될 때, 본안 심리에 들어가지 않고 그 청구를 배척하는 재결을 말한다. 행정심판법 제43조 제1항에 근거한다.

2. 기각재결

- 기각재결은 심판청구가 적법하여 본안 심리를 하였으나, 청구인의 주장이 이유가 없다고 판단될 때, 청구를 배척하는 재결을 말한다. 즉, 처분 또는 부작위가 위법하거나 부당하지 않다고 판단한 경우이다.

3. 인용재결

- 인용재결은 심판청구가 적법하고 청구인의 주장이 이유 있다고 판단될 때, 청구인의 주장을 받아들이는 재결을 말한다. 인용재결에는 취소심판, 무효확인심판, 의무이행심판에 따라 다음과 같은 세부 유형이 있다.

(1) 취소재결

- 처분의 전부 또는 일부를 취소하거나 변경하는 재결이다.

(2) 확인재결

- 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 재결이다.

(3) 의무이행재결

- 거부처분 또는 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 재결이다. 여기에는 위원회가 직접 처분을 하는 처분재결과 피청구인에게 처분을 명하는 처분명령재결이 있다.

IV. 재결의 효력

1. 서설

- 재결은 행정청의 최종적인 판단으로서 법적 효력을 가지며, 이는 불가쟁력, 불가변력, 형성력, 기속력 등의 형태로 나타난다.

2. 불가쟁력[행심법 제51조, 행소법 제19조 단서, 제20조 제1항 단서]

- 불가쟁력이란 재결에 대하여 더 이상 행정심판이나 행정소송을 제기하여 다툴 수 없게 되는 효력을 말한다. 행정심판법 제51조는 재심판 청구 금지를 규정한다. 행정소송법 제19조 단서와 제20조 제1항 단서는 재결 자체의 위법을 이유로 소송을 제기하는 경우를 제한한다. 즉, 재결이 있게 되면 당사자는 원칙적으로 재결의 내용에 대하여 행정소송을 제기할 수 있는 제소 기간을 적용받게 된다.

3. 불가변력

- 불가변력이란 재결을 한 행정심판위원회가 그 재결의 내용에 구속되어 스스로 재결을 취소하거나 변경할 수 없게 되는 효력을 말한다. 이는 재결의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위한 것이다.

4. 형성력

- 형성력이란 인용재결이 내려지는 경우, 그 재결의 내용에 따라 종전 처분 등의 법률 관계가 새롭게 형성되거나 변경되는 효력을 말한다. 예를 들어 취소재결이 있으면 처분은 당연히 취소되어 효력을 상실한다.

5. 기속력

- 기속력이란 재결의 내용이 피청구인인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하여, 재결의 취지에 따라 행동하도록 의무를 부과하는 효력을 말한다.

(1) 내용

- 기속력은 재결의 주문과 그 전제가 된 구체적인 위법·부당 판단에 미친다.

(2) 재처분 의무[행심법 제49조 제2항]

- 행정심판법 제49조 제2항은 인용재결이 있으면 피청구인인 행정청은 그 재결의 취지에 따라 다시 처분을 하여야 할 재처분 의무를 부담한다고 규정한다.

(3) 간접강제[행심법 제50조의2]

- 재처분 의무를 이행하지 않는 경우, 행정심판위원회는 당사자의 신청에 의해 간접강제를 결정할 수 있다. 이는 기속력의 실효성을 확보하기 위한 제도이다.

V. 재결의 불복

1. 재심판청구의 금지[행심법 제51조]

- 행정심판법 제51조는 재결에 대하여는 다시 행정심판을 청구할 수 없다고 규정한다. 이는 행정심판 절차의 조속한 종결을 통해 행정의 법적 안정성을 확보하기 위함이다.

2. 재결에 대한 행정소송

(1) 원칙

- 재결에 대하여 불복하는 경우, 당사자는 재결의 통지를 받은 날부터 90일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다.

(2) 재결주의와 원처분주의

- 우리나라는 원칙적으로 원처분주의를 취하여, 행정소송은 재결 자체의 위법성이 아닌 원처분의 위법성을 다투는 것을 원칙으로 한다. 다만, 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에는 예외적으로 재결을 소송의 대상으로 할 수 있다.

3. 피청구인(처분청)의 불복가능성

- 피청구인인 행정청은 재결에 대하여 기속력을 받으므로, 원칙적으로 재결에 불복하여 행정소송을 제기할 수 없다. 이는 행정의 통일성과 신뢰 보호 원칙에 따른 것이다.

VI. 결론

- 재결은 행정심판위원회가 내리는 최종적인 판단으로, 60일 이내에 문서로써 하여야 한다. 재결의 종류에는 각하, 기각, 인용재결이 있으며, 재결은 불가쟁력, 불가변력, 형성력, 기속력 등의 효력을 가진다. 특히, 기속력은 피청구인에게 재처분 의무를 부과하며, 불이행 시 간접강제의 대상이 된다. 재결에 대한 불복은 원칙적으로 재심판청구가 금지되고 행정소송으로만 다툴 수 있다.